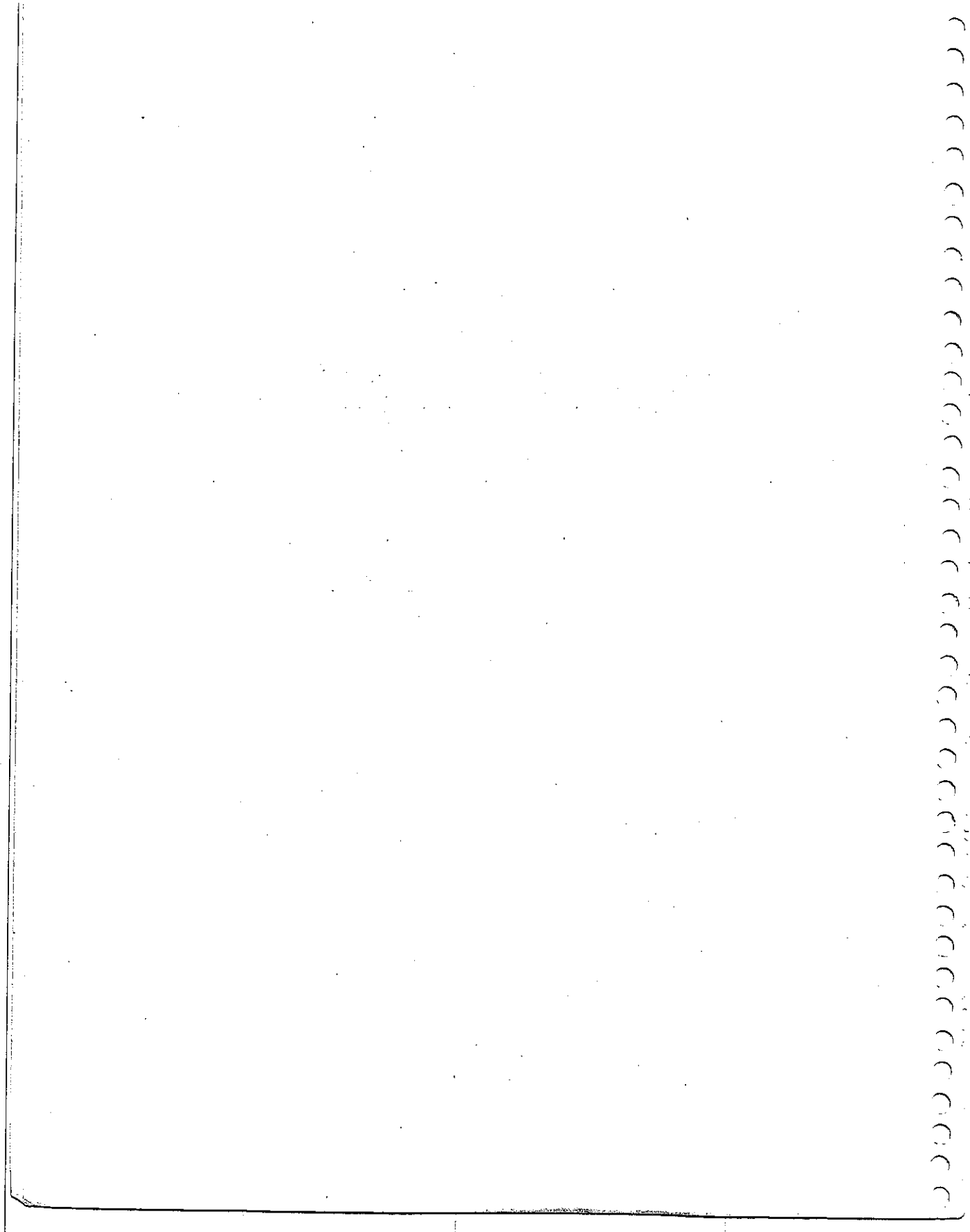


# **NOCIONES DE DERECHO**

**PARA ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS**



## PRESENTACION

Me resulta particularmente grato y agradezco especialmente al autor de este libro, Pablo Alejandro Pérez, que me haya invitado a realizar su presentación.

La obra trata, en gran parte, del temario de una de las materias más intrincadas y comprensivas propias del Derecho Civil, cual es el Derecho de las Obligaciones, especialmente en su faz atinente a la Responsabilidad. Pérez hace de la misma una síntesis tan virtuosa que denota el previo análisis exhaustivo; pero, además, se introduce en el resto de las asignaturas que completan la mayor parte del Plan de Estudios de la Ciencia Jurídica planteándolas con precisión y claridad.

Este libro, seguramente, permitirá que el joven universitario logre, a través de su lectura, un conocimiento puntual del mundo del Derecho que completará su formación y facilitará la aplicación de la Ciencia en la que se está forjando a la normativa jurídica en cuestión.

Recuerdo que Pablo fue profesor, entre los años 1999 y 2010, de la Cátedra de Derecho Civil II de la que quien escribe era Titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Pablo fue un gran colaborador, de enorme dedicación y de permanente estudio y reflexión, hombre que unía lo teórico con su experiencia práctica para la mejor comprensión de sus alumnos.

En tal sentido, no me causa ninguna sorpresa; pero sí una gran alegría, que aquel joven profesor haya sobrepasado con creces a quien fuera su titular de cátedra en aquella casa de altos estudio.

Dra. Silvia Tosti

## Acerca del autor

Pablo Alejandro Pérego es abogado (USAL), dedicado desde hace dieciocho años a la profesión liberal y la docencia. Cursó estudios de postgrado en el Programa de Actualización en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la U.B.A.. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador (1999-2011) en las asignaturas Derecho Civil Parte General, Derecho Civil II (Obligaciones) y Derecho Civil III (Contratos Civiles). También se desempeñó como profesor invitado de la Universidad de Derecho de Buenos Aires en la materia Derecho de las Obligaciones.

Actualmente se desempeña como Profesor Asociado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) de las asignaturas Derecho para Ingenieros, Derecho Público y Privado y Derecho Aduanero, institución donde se forjó e impulsó el desarrollo de la presente obra.

En la actividad privada es socio del Estudio Jurídico Pérego-Giles y Asociados, desempeñándose personalmente como asesor de numerosas empresas PYMES, de distintos sectores, en las especialidades de Derecho Laboral, Previsional e Informático.

Es Secretario de la Asociación Argentina de Informática Jurídica y miembro del Instituto de Derecho Informático del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde se encuentra matriculado así como también en el Colegio de Abogados de San Isidro. Como Secretario de la A.A.I.J. organizó diversas jornadas de Derecho Informático en la Universidad de la Policía Federal Argentina (IUPFA) y el XV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática llevado a cabo en la U.C.A. en el año 2011.

Es coautor de libros y trabajos varios sobre comentarios a fallos jurisprudenciales y ha participado como expositor invitado presentando ponencias en numerosas Jornadas y Congresos, tanto Nacionales como Internacionales.



## PALABRAS PRELIMINARES

Esta obra surge de una necesidad detectada mediante encuestas efectuadas a los alumnos en el marco de los cursos de derecho del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

La mayoría de los cursantes solicitaba un libro para estudiar, que poseyera unidad de visión, profundidad y método educativo en los distintos temas que se le proponían a lo largo de la asignatura, que, hasta ese entonces, se estudiaban con la recomendación de libros, artículos o publicaciones diversas para cada unidad. Ese material, muchas veces escrito para otro tipo de destinatario, utilizaba distintos métodos educativos, daba por conocido el lenguaje por utilizar, así como muchos puntos previos de conocimiento; otras veces, mantenía una profundidad distinta de la buscada en un curso de derecho para estudiantes de otras carreras universitarias.

Entonces, a propuesta del director del Departamento de Economía, Finanzas y Legales, doctor RifatLelic, por solicitud expresa del rectorado del ITBA, pusimos en marcha el proyecto de realizar este libro para responder a lo que se presentaba como evidente necesidad.

Escribir un libro de esta naturaleza resultó ser una tarea compleja al tener que mantener como objetivo presentar el material con un lenguaje apropiado para el entendimiento de un estudiante que no sería un futuro profesional abogado y que, en cambio, estaba acostumbrado al estudio de materias duras. Creo que hemos alcanzando el objetivo propuesto, como ya indicó quien presentó este libro, la doctora Silvia Tosti, tratando de aunar la praxis jurídica con la teoría para la comprensión del futuro profesional.

Con la alegría de la obra concluida, debo agradecer a una gran cantidad de personas. Por orden cronológico quiero agradecer a mis padres, ya que de ellos heredé las vocaciones que hicieron posible esta obra: de mi padre, la abogacía y de mi madre, la docencia. A la doctora Silvia Tosti y al doctor Manuel Osvaldo Cobas, que fueron quienes me permitieron hacer mis primeras armas en la docencia a través de sus cátedras en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, y que me transmitieron una forma amena de relacionarme con el alumnado. También debo agradecer al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, especialmente en las personas de su rector Dr. Ing. Germán Guido Lavalle, quien le precediera en el cargo Almirante Ing. Enrique Molina Pico, al secretario académico Dr. Arturo de Zan y al Dr. RifatLelic, que impulsaron el desarrollo del presente libro, especialmente este último que con su experiencia en estas cuestiones, fue guiando y apoyando la continuidad de la obra a través del tiempo. Finalmente, debo agradecer a quienes aportaron un invalorable apoyo como correctores y amigos, que me dieron el impulso final, en el momento adecuado, con su desinteresada corrección del libro y fijación de objetivos temporales, Liliana Santoro y Marcelo Mario Lançon.

Por último, y más importante, dedico este libro a mi esposa y mis cuatro hijos, quienes fueron los que realmente hicieron que esto sea posible con su cariño, apoyo, tolerancia y renuncia personal a compartir con mi persona el tiempo que debí dedicar al presente.

Pablo Alejandro Pérez.

## **PALABRAS PRELIMINARES A LA SEGUNDA EDICION**

Esta nueva edición de "Nociones de Derecho" presenta la actualización necesaria fruto de la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Fueron adecuados a la normativa vigente la totalidad de los temas abordados; siendo de especial interés los cambios introducidos en materia de responsabilidad, contratos y derecho comercial.

Es oportuno comentar que, durante el empleo de la primera edición de esta obra en las clases dictadas en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en el periodo 2014-2015, he obtenido junto a los docentes que integran las distintas cátedras, excelentes resultados. Estos fueron puestos de manifiesto al elevarse los promedios de notas a los que el alumnado accedió luego de cada curso. Evidentemente, contar con un material acorde a la profundidad que se le quiere aportar a cada tema, escrito de un mismo modo y forma de abordaje, provee al estudiante de una herramienta que le facilita la comprensión de una materia y temática a la que suele no estar acostumbrado.

El dinamismo actual de las clases, la introducción de la informática en las aulas, los cambios que se desarrollan en todas las materias incluidas el derecho, y la utilidad que, espero, se introduzca con esta nueva edición, me lleva a pensar en otras forma de ampliar la presente obra. Por eso, he publicado, junto a esta nueva edición, un sitio web, [www.nocionesdederecho.com.ar](http://www.nocionesdederecho.com.ar). Allí, se podrán realizar comentarios, advertir sobre posibles errores o modificaciones, obtener material de apoyo, etc. En definitiva, ampliar la vinculación de los profesores que utilicen este sistema con sus potenciales alumnos y entre sí.

Finalmente, quiero dedicar esta segunda edición a la memoria de mi padre, recientemente fallecido, como agradecimiento al amor, esfuerzo, enseñanza y sacrificio que realizó hasta el último momento de su vida.

Pablo Alejandro Pérego.

A mis padres.

A mi esposa e hijos.

A mis alumnos.

## ÍNDICE:

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACION .....</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>Acerca del autor .....</b>                                                                  | <b>2</b>  |
| <b>PALABRAS PRELIMINARES .....</b>                                                             | <b>3</b>  |
| <b>PALABRAS PRELIMINARES A LA SEGUNDA EDICION .....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>Adagios Latinos para reflexionar... ..</b>                                                  | <b>17</b> |
| "Facultas naturalis ejus facere livet libertas est, nisi si quid vi aut jure prohibetur" ..... | 17        |
| "Honestum lucrum illud est per quod nemo laeditur" .....                                       | 17        |
| "Ignorantia legis non excusat" .....                                                           | 17        |
| "Jura vigilantibus prossunt et subveniunt" .....                                               | 17        |
| "Juris praecepta summa haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere." ...   | 17        |
| "Jus est ars boni et aequi." .....                                                             | 17        |
| "Justitia est constants et perpetua voluntas jui suum cuque tribuendi." .....                  | 17        |
| "Melius est intacta jura servare quam vulneratae causae remedium quaerere" .....               | 17        |
| "Quae rerum natura prohibentur nulla lege confirmata sunt" .....                               | 18        |
| "Verba volant, scripta manent" .....                                                           | 18        |
| <b>Capítulo 1. Introducción para el estudio del derecho.....</b>                               | <b>19</b> |
| 1. Concepto de derecho .....                                                                   | 19        |
| 2. Norma jurídica.....                                                                         | 21        |
| 2.1 Los tratados internacionales.....                                                          | 23        |
| 3. Fuentes del derecho .....                                                                   | 23        |
| 3.1 La ley .....                                                                               | 24        |
| 3.2 La costumbre.....                                                                          | 26        |
| 3.3 La jurisprudencia .....                                                                    | 26        |
| 3.4 La doctrina .....                                                                          | 27        |
| 4. Diversas clasificaciones del derecho .....                                                  | 27        |
| 4.1 Ley natural y derecho positivo.....                                                        | 27        |
| 4.2 Derecho continental y Common Law .....                                                     | 27        |
| 4.3 Derecho objetivo y subjetivo .....                                                         | 29        |

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4 Derecho público y privado. Ramas del derecho .....                                                                  | 29        |
| 5. El derecho, el tiempo y el territorio .....                                                                          | 30        |
| <b>III</b> 6. Organización del Estado .....                                                                             | 32        |
| 6.1 División de poderes .....                                                                                           | 33        |
| 6.2 Funciones de los tres poderes .....                                                                                 | 34        |
| 6.3 Control e interdependencia de los poderes .....                                                                     | 41        |
| 6.4 Derechos y garantías constitucionales .....                                                                         | 42        |
| 7. Gobierno digital .....                                                                                               | 44        |
| 7.1 Concepto .....                                                                                                      | 44        |
| <b>Capítulo 2. Derecho e informática .....</b>                                                                          | <b>45</b> |
| 1. La informática en el ámbito del derecho .....                                                                        | 45        |
| 2. Informática jurídica decisional y de gestión .....                                                                   | 45        |
| 3. Derecho informático .....                                                                                            | 46        |
| 3.1 Transversalidad .....                                                                                               | 46        |
| 3.2 Autonomía del derecho informático .....                                                                             | 47        |
| 4. Introducción a algunas cuestiones del derecho informático .....                                                      | 48        |
| 5. Problema de la jurisdicción .....                                                                                    | 49        |
| <b>VIII</b> <b>Capítulo 3. Responsabilidad civil. Parte general .....</b>                                               | <b>52</b> |
| 1. Persona .....                                                                                                        | 52        |
| 1.1 Definición. Persona humana y jurídica .....                                                                         | 52        |
| 1.2 Capacidad .....                                                                                                     | 53        |
| 1.3. Obligaciones .....                                                                                                 | 56        |
| 2. Responsabilidad civil .....                                                                                          | 68        |
| 2.1 Incumplimiento inimputable .....                                                                                    | 72        |
| 2.2 Daño. Daños resarcibles .....                                                                                       | 73        |
| 2.3 Extensión de la responsabilidad .....                                                                               | 74        |
| 2.4 Distinción de la responsabilidad civil y la penal .....                                                             | 76        |
| <b>Capítulo 4. Responsabilidad. Parte especial .....</b>                                                                | <b>77</b> |
| 1. Responsabilidad y TIC. Tipos de responsabilidad en Internet: diversos sujetos involucrados. Su responsabilidad ..... | 77        |

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Régimen de banco de datos: Derecho a la intimidad. Hábeas data. Ley 25.326 y su decreto reglamentario 1.558/2001, Ley de Protección de Datos Personales..... | 79 |
| 2.1 Derecho a la intimidad .....                                                                                                                                | 79 |
| 3. Responsabilidades emergentes del comercio en general.....                                                                                                    | 83 |
| 3.1. <i>Ley de Defensa del Consumidor</i> .....                                                                                                                 | 83 |
| 3.2 Ley de Defensa de la Competencia.....                                                                                                                       | 87 |
| 3.3 Ley de Lealtad Comercial.....                                                                                                                               | 90 |

### **III Capítulo 5. Contratos..... 93**

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Contrato. Concepto.....                                                                         | 93  |
| 1.1 Elementos esenciales: sujetos. Capacidad .....                                                 | 94  |
| 1.2 Consentimiento y formación del contrato.....                                                   | 95  |
| 1.3 Objeto.....                                                                                    | 97  |
| 1.4 Causa.....                                                                                     | 97  |
| 1.5 Interpretación .....                                                                           | 98  |
| 1.6 Régimen legal de adhesión y las disposiciones de la ley 24.240, de defensa del consumidor..... | 99  |
| 1.7. Clasificación de los contratos .....                                                          | 100 |
| 1.8 Vicios de los contratos .....                                                                  | 102 |
| 1.9. Cláusulas contractuales especiales. Cláusulas de escape.....                                  | 103 |
| 1.10 Resolución de contratos .....                                                                 | 104 |
| 1.11 Pacto comisorio.....                                                                          | 104 |
| 2. Etapa precontractual .....                                                                      | 105 |
| 2.1 Significación .....                                                                            | 105 |
| 2.2. Responsabilidad .....                                                                         | 105 |
| 2.3 Importancia actual de la documentación de las negociaciones en la etapa precontractual .....   | 106 |
| 3. Señal o arras.....                                                                              | 107 |
| 4. Contratos típicos civiles y comerciales .....                                                   | 107 |
| 4.1. Compraventa.....                                                                              | 108 |
| 4.2 Permuta .....                                                                                  | 109 |
| 4.3 Cesión de derechos .....                                                                       | 110 |
| 4.4 Locación de cosa.....                                                                          | 111 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.5. Locación de servicios y de obra.....                                                                                                                                                                                                | 113        |
| 4.6. Naturaleza de la vinculación profesional. Distintos regímenes.....                                                                                                                                                                  | 115        |
| 4.7. Mandato.....                                                                                                                                                                                                                        | 116        |
| 4.8. Mutuo.....                                                                                                                                                                                                                          | 116        |
| 5. Comercio electrónico. Economía tradicional y la nueva economía de la sociedad de la información, ventajas, inconvenientes y desafíos.....                                                                                             | 117        |
| 5.1. Cuestión de la ley aplicable.....                                                                                                                                                                                                   | 118        |
| 5.2. Contratos cuyo objeto deba ser cumplido en la Argentina y legislación nacional.....                                                                                                                                                 | 119        |
| 5.3. Prórroga de jurisdicción.....                                                                                                                                                                                                       | 120        |
| 5.4. Antecedentes legislativos del derecho argentino.....                                                                                                                                                                                | 124        |
| 6.1. Contratos informáticos. Concepto. Clasificación. Características específicas.....                                                                                                                                                   | 125        |
| 6.2. Contratos electrónicos. Definición. Caracteres.....                                                                                                                                                                                 | 126        |
| 6.3. Formas de contratación electrónica.....                                                                                                                                                                                             | 127        |
| 6.3. Clasificación de los contratos informáticos según el objeto y el negocio jurídico.....                                                                                                                                              | 129        |
| 7. Software. Licencias. Normas aplicables. Software libre. Nuevas licencias que surgen de la internacionalidad de la Internet.....                                                                                                       | 131        |
| 8. Prueba del contrato informático. Documentos. Clasificación. Otros medios de prueba que fija el CPCCN. Firma digital. Ley 25.506 y su decreto reglamentario 2.628/2002. Documento electrónico. Time stamping o sellado del tiempo..... | 132        |
| 8.1. Documento digital o electrónico.....                                                                                                                                                                                                | 134        |
| 8.2. Time stamping o sellado del tiempo.....                                                                                                                                                                                             | 136        |
| <b>Capítulo 6. Delitos.....</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>137</b> |
| 1. Derecho penal. La responsabilidad penal.....                                                                                                                                                                                          | 137        |
| 1.1 Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas.....                                                                                                                                                                       | 138        |
| 2. Delitos informáticos. Definición.....                                                                                                                                                                                                 | 139        |
| 2.1. Delitos tipificados por la ley 11.723.....                                                                                                                                                                                          | 139        |
| 2.2. Delitos comunes cometidos a través de medios informáticos. Concepto. Delitos tipificados por nuestro Código Penal.....                                                                                                              | 142        |
| 2.3. Otros ilícitos tipificados en leyes especiales.....                                                                                                                                                                                 | 143        |
| 2.4. Figuras penales tipificadas en la nueva ley de delitos informáticos.....                                                                                                                                                            | 144        |
| 3. Nombres de dominio y protección marcaria (ciberocupación de dominios).....                                                                                                                                                            | 149        |
| <b>IV Capítulo 7. Derecho empresarial.....</b>                                                                                                                                                                                           | <b>151</b> |



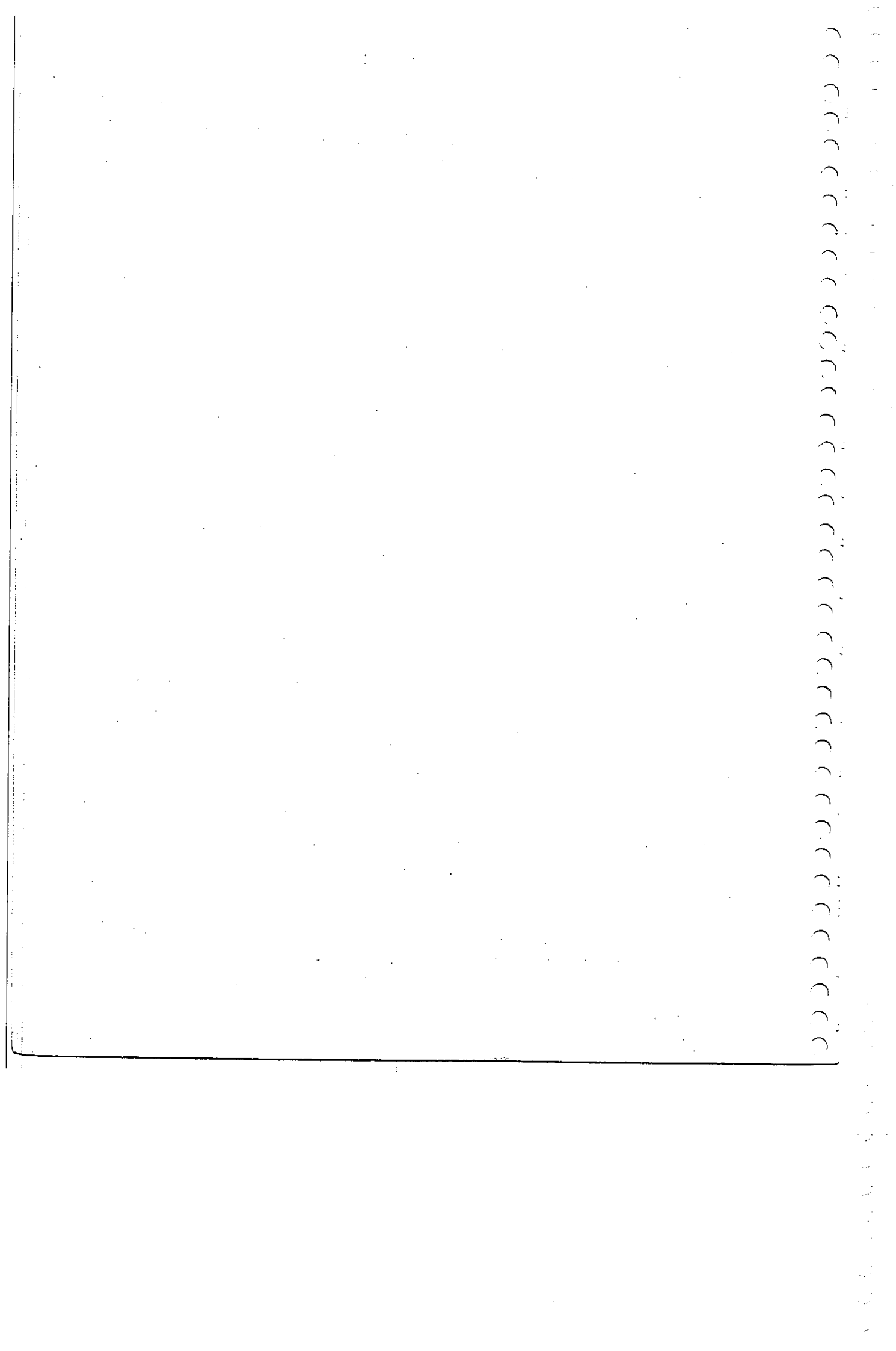
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Derecho comercial.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151 |
| 1.1. Concepto de empresa/empresario .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 153 |
| 1.2. Fondo de comercio.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153 |
| 1.3. Títulos de crédito .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154 |
| 1.4. Seguros.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157 |
| 2. Contratos comerciales modernos. Canales de venta.....                                                                                                                                                                                                                                                | 158 |
| 2.1 Leasing.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159 |
| 2.2 Licencia.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 |
| 2.3 Estimatorio o de consignación.....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159 |
| 2.4 Contrato de suministro.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160 |
| 2.5 Canales de comercialización.....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161 |
| 2.6 Contrato de distribución.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161 |
| 2.7 Contrato de agencia.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162 |
| 2.8 Contrato de concesión.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162 |
| 2.9 Franquicia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163 |
| 2.10 Corretaje.....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164 |
| 3. Sociedades: sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Diferencias y similitudes. Beneficios de cada una. Organización, dirección y control. Trámites en la Inspección General de Justicia. Unión de sociedades: fusiones y adquisiciones. Grupos de control y <i>holdings</i> . ..... | 164 |
| 4. Establecimiento de una sociedad extranjera en la Argentina .....                                                                                                                                                                                                                                     | 168 |
| 4.1 Sucursal.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168 |
| 4.2 Filial.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169 |
| 5. Bolsas y mercados de valores.....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169 |
| 6. Concursos y quiebras.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 |
| 6.1 Concurso preventivo .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 |
| 6.2 Quiebra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 |
| 7. Derecho tributario. Impuestos de la persona física y jurídica. ....                                                                                                                                                                                                                                  | 179 |
| 7.1 Impuesto a las ganancias.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179 |
| 7.2 Impuesto a la ganancia mínima presunta.....                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 |
| 7.3 Impuesto al valor agregado .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181 |
| 7.4 Impuesto a los bienes personales .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 181 |

|                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.5 Monotributo .....                                                                                                                                     | 182        |
| 7.6 Otros tributos .....                                                                                                                                  | 183        |
| 7.7 Impuestos provinciales.....                                                                                                                           | 184        |
| <b>UV Capítulo 8. Propiedad intelectual .....</b>                                                                                                         | <b>185</b> |
| 1. Derechos intelectuales .....                                                                                                                           | 185        |
| 1.1 Naturaleza jurídica .....                                                                                                                             | 185        |
| 1.2 Derechos de autor .....                                                                                                                               | 185        |
| 1.3 Marcas. Ley 22.362, de marcas y designaciones .....                                                                                                   | 187        |
| 1.4. Patentes. Ley 24.481, de patentes de invención y modelos de utilidad (t. o. decreto 260/96). La patentabilidad de los programas de computación ..... | 192        |
| 2. Nombres de dominio. Concepto. Gobierno de Internet (ICANN). Política de asignación de ND. Conflictos y soluciones. NIC.ar. Reglamentación.....         | 199        |
| <b>Capítulo 9. Derecho laboral .....</b>                                                                                                                  | <b>201</b> |
| 1. Definición de derecho laboral.....                                                                                                                     | 201        |
| 1.1 Especialidad del régimen laboral .....                                                                                                                | 203        |
| 1.2 Principios generales del derecho del trabajo.....                                                                                                     | 204        |
| 1.3 Derechos y deberes de las partes .....                                                                                                                | 205        |
| 1.4 Derechos del empleador.....                                                                                                                           | 205        |
| 1.5 Deberes del empleador.....                                                                                                                            | 206        |
| 1.6 Derechos del trabajador .....                                                                                                                         | 207        |
| 1.7 Deberes del trabajador .....                                                                                                                          | 207        |
| 2. Duración del contrato de trabajo. Modalidades de contratación. Modalidades promovidas.....                                                             | 207        |
| 2.1 Principio general: tiempo indeterminado.....                                                                                                          | 208        |
| 2.2 Modalidades.....                                                                                                                                      | 209        |
| 3. Administración de los recursos humanos .....                                                                                                           | 213        |
| 3.1 Salario. Definición .....                                                                                                                             | 213        |
| 3.2 Determinación.....                                                                                                                                    | 213        |
| 3.3 Régimen de las licencias.....                                                                                                                         | 214        |
| 3.4 Licencias especiales .....                                                                                                                            | 215        |
| 3.5 Régimen de las sanciones .....                                                                                                                        | 218        |
| 3.5 Formas de extinción del contrato o la relación laboral .....                                                                                          | 218        |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6 Contingencias especiales que extinguen la relación laboral .....        | 221        |
| 3.7 Multas .....                                                            | 223        |
| 3.8 Reglamento interno de la empresa .....                                  | 223        |
| 3.9 Uso de recursos informáticos de la empresa por empleados .....          | 223        |
| 4. Ley de Riesgos de Trabajo. Enfermedades y accidentes de trabajo .....    | 226        |
| 4.1 Procedimiento .....                                                     | 227        |
| 4.2 Planteos judiciales .....                                               | 228        |
| <b>CAPÍTULO 10. Derecho administrativo. ....</b>                            | <b>229</b> |
| 1. El Estado .....                                                          | 229        |
| 1.1 Funciones del Estado (clasificación) .....                              | 230        |
| 2. Derecho administrativo. Concepto. ....                                   | 230        |
| 2.1 Características del derecho administrativo .....                        | 231        |
| 2.2 Soberanía. Autonomía. Autarquía. Autarcía .....                         | 231        |
| 2.2.1 Órganos de la administración pública .....                            | 232        |
| 3. Principios fundamentales de la organización administrativa .....         | 233        |
| 3.1 Órganos de fiscalización administrativa .....                           | 234        |
| 4. Acto administrativo .....                                                | 236        |
| 4.1 Clasificación de los actos administrativos .....                        | 236        |
| 4.2 Elementos del acto administrativo .....                                 | 237        |
| 4.3 Caracteres del acto administrativo (artículo 12 de la ley 19.549) ..... | 238        |
| 4.4 Nulidad del acto administrativo .....                                   | 238        |
| 5. Contratos administrativos .....                                          | 240        |
| 5.1 Selección del co-contratante .....                                      | 240        |
| 5.2 Mecanismos de selección del co-contratante .....                        | 241        |
| 6. Servicio público .....                                                   | 242        |
| 6.1 Marco regulatorio .....                                                 | 243        |
| 7. Entes reguladores .....                                                  | 244        |
| 8. Procedimiento administrativo .....                                       | 244        |
| 8.1 Recursos .....                                                          | 244        |
| <b>CAPÍTULO 11: Derecho procesal .....</b>                                  | <b>247</b> |
| 1. Derecho procesal .....                                                   | 247        |

|                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 Mediación y conciliación.....                                                                                                                                           | 248        |
| 2. La prueba. Medios de prueba. Confesión. Testimonial. Pedido de informes. Instrumental. Documental. La prueba pericial. El dictamen pericial. Honorarios del perito ..... | 249        |
| 2.1 Prueba documental.....                                                                                                                                                  | 250        |
| 2.2 Confesión de partes:.....                                                                                                                                               | 251        |
| 2.3 Presunciones legales o judiciales:.....                                                                                                                                 | 252        |
| 2.4 Testigos .....                                                                                                                                                          | 252        |
| 2.5 Prueba pericial .....                                                                                                                                                   | 253        |
| 2.6 Prueba de informes .....                                                                                                                                                | 254        |
| 2.7 Admisibilidad de la prueba .....                                                                                                                                        | 255        |
| 3. El arbitraje. Procedimiento. Cláusulas arbitrales.....                                                                                                                   | 255        |
| <b>Glosario de términos jurídicos: .....</b>                                                                                                                                | <b>258</b> |
| A .....                                                                                                                                                                     | 258        |
| B.....                                                                                                                                                                      | 261        |
| C.....                                                                                                                                                                      | 262        |
| D .....                                                                                                                                                                     | 263        |
| E.....                                                                                                                                                                      | 264        |
| F.....                                                                                                                                                                      | 264        |
| G .....                                                                                                                                                                     | 264        |
| H .....                                                                                                                                                                     | 265        |
| I.....                                                                                                                                                                      | 265        |
| J.....                                                                                                                                                                      | 265        |
| L.....                                                                                                                                                                      | 265        |
| M.....                                                                                                                                                                      | 266        |
| N.....                                                                                                                                                                      | 266        |
| O .....                                                                                                                                                                     | 266        |
| P.....                                                                                                                                                                      | 267        |
| R.....                                                                                                                                                                      | 268        |
| S.....                                                                                                                                                                      | 268        |
| T.....                                                                                                                                                                      | 268        |
| U .....                                                                                                                                                                     | 268        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| V .....                  | 269        |
| <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b> | <b>270</b> |



### **Adagios Latinos para reflexionar...**

**"Facultas naturalisejusfacerelivet libertas est, nisi si quid vi aut jure prohibetur"**

La libertad es una facultad natural de obrar libremente en todo lo que no está prohibido por la ley.

**"Honestumlucrumilludest per quodnemolaeditur"**

El lucro es honesto cuando no daña a otro.

**"Ignorantialegis non excusat"**

La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.

**"Jura vigilantibusprossunt et subveniunt"**

El Derecho favorece a quien vigila sus derechos.

**"Jurispraeceptasummahaec: honeste vivere, alterum non laedere, suumcuiquetribuere."**

Estos son los principios del derecho: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo.

**"Jusestarsboni et aequi."**

El Derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo.

**"Justitiaestconstants et perpetua voluntasjuisuumcuiquetribuendi."**

Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo.

**"Melius est intacta jura servarequamvulnerataecausaeremediumquaerere"**

Mejor es conservar el derecho que, vulnerado, recuperarlo.

**"Quaererum natura prohibenturnullalegeconfirmatasunt"**

Lo que está prohibido por la naturaleza de las cosas, nula la ley que lo confirme.

**"Verba volant, scriptamaneant"**

Las palabras vuelan, los escritos quedan.



## Capítulo 1. Introducción para el estudio del derecho

### 1. Concepto de derecho

El ser humano, para entrar en relación con sus semejantes, debió crear primero un lenguaje. Luego, como resultaba que quien solía tener razón en una disputa de cualquier naturaleza era comúnmente el que ostentaba mayor poder físico, para tener una vida pacífica y en sociedad debió crear normas que regulen las conductas humanas y sus consecuencias.

Así, el primer precepto o norma jurídica que nos llega de la historia es la Ley del Talió, receptada en el Código de Hammurabi<sup>1</sup> (1792 a. C.). El resumen de dicho precepto, en palabras de uso común, es conocido con la frase "Ojo por ojo y diente por diente". Este avance jurídico fundamental suele confundirse, por la forma en que está enunciado, más con una venganza que con una norma que ordena las acciones e impone una reparación acorde con un delito cometido o un daño causado (siempre en relación con la época a la que nos remontamos). Sin embargo, dicha interpretación obedece a la errónea aplicación del precepto, más que a la corrección de éste. Entendiéndolo en un todo, y a la luz de la situación histórica en la que fue dictado, es el primer escrito jurídico donde aparece la regla de la proporcionalidad como criterio de justicia, evitando así que quien ostentaba el poder físico ejerciera represalias desproporcionadas en relación con el daño o el injusto sufrido.

A través de un ejemplo del citado código se puede apreciar la aplicación de dicho precepto. En la norma 229 se establecía que si un arquitecto realizaba una casa para otra persona, y no la hacía sólida, por lo que ésta terminaba por derrumbarse, lo cual provocaba la muerte al propietario de la casa, el arquitecto sería ejecutado. En el mismo sentido, se acentúa la aplicación de la norma cuando se señala que si quien moría era el hijo del propietario, se ejecutaría al hijo del arquitecto.<sup>2</sup>

También pueden extraerse del mismo código ejemplos de penas menores, que consistían en la reparación del daño causado devolviendo materias primas, como plata, trigo, vino, etcétera.

<sup>1</sup>Este código perduró hasta nuestros días gracias a estar tallado en una piedra de grandes dimensiones que se encuentra, actualmente, en el Museo del Louvre, en París. Elaborado por Hammurabi, sexto rey babilónico de la primera dinastía (1728-1686 a. C.), que gobernó Mesopotamia por cuarenta largos años, en el siglo XVII antes de Cristo. Es un bloque de basalto de 2,50 m de alto por 1,90 de ancho en la base, de color negro, grabado con caracteres cuneiformes acadios, que contiene 282 leyes -civiles y penales- que el dios solar de la justicia -Shamash- le entregó al rey, señor de toda Mesopotamia.

<sup>2</sup>Puede consultarse el Código de Hammurabi en cualquier edición impresa. También se encuentra disponible en abundantes páginas web.

En los casos en que no existía daño físico pero el hecho era grave, se buscaba una forma de compensación física, por ejemplo, al autor de un robo se le cortaba la mano. De esta forma, ya desde este primer antecedente se observa con claridad la importancia del derecho para lograr una vida en sociedad de manera justa y ordenada. Todo esto hay que encuadrarlo en un análisis histórico, dando por descontado que algunas de las consecuencias descriptas hoy en día resultan extremadamente punitivas.

Fruto de la evolución, comenzaba allí el desarrollo histórico del derecho, y podemos concluir definiéndolo —siguiendo al doctor Guillermo Borda— como “un conjunto de normas que regulan la conducta humana, establecidas por el Estado con carácter obligatorio y orientadas a la idea de justicia”.

Pero el derecho no es el único orden normativo. Todas las ciencias tienen postulados o normas, y pueden ser clasificadas, según su objeto de estudio, en ciencias del ser y ciencias del deber ser.

Las ciencias del ser estudian y describen la naturaleza física y humana tal cual es en la realidad. Algunos ejemplos son: la física, la botánica, la medicina, la ingeniería, etcétera. El principio de análisis básico de estas ciencias es la relación de causa y efecto. De este modo, de estas ciencias se derivarán postulados que pretenden ser de aplicación universal (necesariamente se aplicarán a toda la naturaleza o el universo).

Por otro lado, las ciencias del deber ser, como el derecho o la psicología, estudian cómo prescribir, inducir u orientar la conducta humana, y así, en la materia que nos ocupa, se intenta generar un sistema jurídico que pueda hacer predecible, en la mayor medida posible, el comportamiento humano. Entonces, se pretende lograr que los hombres se comporten de determinada manera en la sociedad; y en caso de que se produzca una violación a la norma, que el castigo sea adecuado a la falta cometida o repare el daño causado, y aleje cualquier idea de venganza por parte del agredido. De esta forma se intenta generar un marco de seguridad jurídica, garantizando la convivencia y el desarrollo de las personas en la sociedad.

Las ciencias del deber ser no respetan el principio de causalidad, basan su estudio en otro principio: el de la libertad del ser humano para elegir sus acciones o capacidad de discernimiento. Cuando este discernimiento es llevado a la práctica en una acción, ésta contiene una clara intención, y si no hubiese condicionantes graves que la eliminen, la persona efectuará ese acto con libertad (libre albedrío, optando bien o mal). Estas acciones, tomadas con discernimiento, intención y libertad, son el objeto de estudio de la religión, la moral y el derecho. Sobre este punto de los tres elementos volveremos en capítulos posteriores.

Podemos, entonces, vislumbrar claramente las diferencias importantes que existen entre unas y otras ciencia, las del ser y las del deber ser.

Hallamos una primera diferencia en que las normas del deber ser pueden cumplirse en la realidad o no, mientras que las leyes del ser lo hacen inexorablemente. Las ciencias del deber ser regulan sistemas ideales para que el hombre se comporte. Ideales, porque sólo se encuentran en perfección en el mundo de las ideas, ya que en la realidad el ser humano, habitualmente, viola las normas. Frente a estas violaciones se provocan las consecuencias que la misma norma prescribe para el caso de su incumplimiento.

En la actualidad, esta brecha es cada vez mayor, consecuencia clara de dos pérdidas muy importantes. En primer lugar, en el mundo moderno se ha perdido la práctica religiosa auténtica, que lleva al hombre a la búsqueda de la respuesta de sus interrogantes últimos (más profundos), a reconocer la realidad tal y como es, y al otro como semejante. Al buscar el amor, la felicidad, la justicia y la verdad, el hombre empieza a actuar en consecuencia, naturalmente, sin esfuerzo, respetando acabadamente las normas de convivencia.

Pero esta pérdida no es la única; también la ética se ve debilitada por una presión social que busca soluciones prácticas y por lo general rápidas, sin detenerse a contemplar el divorcio que genera, en varias ocasiones, esa practicidad con respecto al ideal que regula nuestra vida en sociedad. Es así como se genera una suerte de individualismo al que poco le importa el otro sujeto y que lleva, cada vez más, al desorden y la inseguridad (tanto física como jurídica).

La otra diferencia importante, en las leyes formuladas por las ciencias del deber ser, es que las normas del derecho pueden cambiarse, mejorarse o empeorarse. Como no pretenden describir causas y efectos físicos de la realidad, sino inducir conductas humanas, no son leyes inmutables; por ese motivo, todas las sociedades tienden a ir perfeccionando sus normas legales y morales. Ello no implica que todo cambio normativo sea mejor; en este punto hay que destacar la importancia del ideal al que debe tender la norma, como objetivo a perseguir: la idea de justicia; así, nuevamente, reaparece lo importante: la ética y la religión.

## 2. Norma jurídica

La norma jurídica es la base del estudio del derecho. Para los iuspositivistas<sup>3</sup>—como, por ejemplo, Kelsen— la norma debe describir y prescribir una conducta, y a continuación establecer las consecuencias de que esa conducta no sea cumplida (sanción). Por ejemplo: a una persona que comete un asesinato se le aplicará prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.<sup>4</sup> La norma, así, tiene valor porque fue sancionada mediante el procedimiento que la misma ley prevé, sin importar la finalidad última de la ley. Por otro lado, para los iusnaturalistas—siguiendo a Santo

<sup>3</sup>Corriente filosófica de estudio del derecho que considera que sólo importa el derecho positivo (impuesto), es decir, la norma impuesta por el poder, sin darle importancia el efecto social que ésta provoque o al ideal ético.

<sup>4</sup>Artículo 79 del Código Penal: "Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena".

Tomás-- la norma debe ser "una prescripción de la razón, en vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad".<sup>5</sup> Por supuesto que también se prevén consecuencias ante su quebrantamiento, pero en sí misma la norma debe tender al bien común. Esto es conteste con la idea de justicia.

Las normas jurídicas se ordenan según su jerarquía, y dado que hay menor cantidad de las de más jerarquía que de las de menor jerarquía, se suele visualizar el sistema jurídico de un Estado con el dibujo de una pirámide: la pirámide de normas jurídicas.

A la Constitución Nacional se la ubica en el ápice o cúspide de la pirámide.

Según Kelsen, más arriba de la constitución de un país no hay normas jurídicas, sino un hecho de fuerza que otorga legitimidad al Estado y le confiere el monopolio de la fuerza.

En el mismo nivel que la Constitución, conforme la modificación ocurrida en 1994, se encuentran también los tratados internacionales, ratificados por la ley que surge de la Carta Magna. Luego siguen las leyes (dictadas por el Poder Legislativo), los decretos (dictados por el Poder Ejecutivo), las resoluciones y otras normativas emanadas de órganos inferiores, y, finalmente, las convenciones de los particulares.

La norma jurídica tiene varios requisitos. En primer lugar debe poseer *validez*, elemento que se encuentra vinculado, en forma vertical o jerárquica, a su creación. Esto significa que la norma ha sido creada conforme lo indica el procedimiento dictado por otra norma de rango superior. Así, las leyes deben ser dictadas conforme lo prescribe la Constitución Nacional, y los decretos del Poder Ejecutivo deben limitarse a lo establecido como su función en el mismo cuerpo normativo. En el mismo sentido deben dictarse los reglamentos y ordenanzas.

Otro requisito es el de su *vigencia*, esto es, que la norma, a lo largo del tiempo, continúe siendo cumplida en forma efectiva. Hay casos en que la norma sancionada, válida, puede carecer de vigencia. Por ejemplo, la prohibición de conducir alcoholizado, de cruzar semáforos en rojo, o la obligación de llevar el cinturón de seguridad que se halla en los vehículos, existe hace años, pero, como su control no era estricto, la gente incumplía la manda. La ley cobraba importancia, únicamente, en los casos en que quien manejara causaba un accidente y, supongamos, lo hiciese alcoholizado, puesto que agravaba las consecuencias del hecho. Es decir, todo ese sistema de normas era preexistente al sistema de puntaje del registro para conducir, de sanciones pecuniarias más onerosas y de secuestro del vehículo, que es de aplicación hoy por hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pero había perdido su vigencia por la falta de control. Así, el legislador, observando que no se cumplía una norma válida y legítima, hecho que generaba un aumento de los accidentes de tránsito, creó un nuevo sistema sancionatorio para volver a otorgarle vigencia a lo ya existente.

---

<sup>5</sup>Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, 1-2, cuestión 90, artículo, 4º, Ed. BAC, tomo VI, pág. 42.

Finalmente, en la base de la pirámide ubicamos a los contratos o las convenciones privadas. Estos integran el eslabón más grande, con la salvedad que los contratos sólo tienen efecto entre las partes, sin afectar derechos de terceros. Así, el contrato será una norma para las partes a la que deberán someterse como a la ley misma.

## **2.1 Los tratados internacionales**

Párrafo aparte merecen los tratados internacionales, ya mencionados, en esta breve explicación del orden de prelación. Su inclusión en aquel obedece a una tendencia mundial. Los tratados internacionales contemplados hasta el momento en nuestra Constitución son de integración (art. 75, inc. 24) y de derechos humanos (art. 75, inc. 22).

Los 10 tratados sobre derecho humanos incluidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución son:

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
- Declaración Universal de los Derechos Humanos;
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo;
- Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes;
- Convención sobre los Derechos del Niño

Los fallos de los organismos creados a raíz de pactos de derechos humanos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, creada por el Pacto de San José de Costa Rica, no tienen imperium sobre los estados; sus sanciones son de tipo moral.

## **3. Fuentes del derecho**

Llamamos fuentes del derecho a aquello que origina la norma jurídica. No existe una única fuente del derecho sino varias y se pueden clasificar, según su importancia, en las que se detallarán a continuación.

### 3.1 La ley

La ley cuenta con dos acepciones. En sentido amplio, incluye un conjunto de normas que son tanto leyes como decretos, resoluciones, etcétera. Este conjunto constituye la fuente más importante de creación de normas jurídicas, aunque no la más abundante, por cuanto es infinitamente superior la cantidad de contratos o convenciones privadas que también generan normas jurídicas (aunque limitadas en su obligación entre las partes contrayentes). Las leyes en sentido amplio requieren, para su sanción, del procedimiento del órgano del Estado que les otorga validez, esto es, que sea competente para crearlas.

En sentido estricto, son únicamente las que se sancionan en el Congreso Nacional (hablando siempre a nivel nacional, ya que las leyes provinciales se sancionan en las legislaturas respectivas), conforme el procedimiento de sanción dispuesto en la Constitución Nacional (y, en el caso de las provincias, en las constituciones provinciales).

Así como la sanción de las leyes tiene sus diferencias entre el nivel nacional y el provincial, también existen diferencias entre los países, pues cada uno posee sus propios métodos de dictado de las leyes. En la Argentina, el sistema surge de los artículos 77 al 84 de la Constitución Nacional.

Las leyes dictadas conforme el citado procedimiento mantendrán su vigencia hasta tanto no sean derogadas en forma expresa por otra ley (que la modifique o sustituya total o parcialmente), en forma tácita (lo que podría darse por medio de los principios "Ley posterior deroga a ley anterior" y "Ley especial deroga a ley general") o por *desuetudo*, que suele definirse como "la continua inobservancia de la ley por los miembros de la sociedad y por los órganos de aplicación" que causa una referida pérdida de 'vigencia'.

#### 3.1.1 Tipos de leyes

Con relación a la función y alcance que tienen las leyes, se clasifican en imperativas o supletorias.

Son imperativas las leyes que los particulares, al hacer un contrato, no pueden dejar de lado y que los obligan independientemente de la voluntad en contrario que hubiesen pactado. Que una norma sea imperativa se fundamenta en que el legislador considera que ésta propicia el orden público, la moral y las buenas costumbres, razón por la cual no es adecuado que las partes prevean alejarse de lo que ésta dispone.

Las normas supletorias no poseen la característica de obligatoriedad antes mencionada y juegan un papel, como su nombre lo indica, que viene a subsanar la falta de regulación de derechos y obligaciones específicos, conforme el acto que han llevado a cabo las partes. Estas normas pueden ser dejadas de lado por los particulares por el principio de autonomía de la libertad; puede acordarse cualquier otro fin o consecuencia a sus actos que los que dispongan dichas leyes, sin embargo, si nada han acordado con relación a la situación regulada en dichas normas, éstas serán de aplicación al contrato o situación jurídica. Existe una gran cantidad de normas supletorias que, por ejemplo, ayudan a las partes a no tener que prever todas las circunstancias que pudiesen ocasionarse durante la vigencia de un contrato, como: ¿qué pasaría con las mejoras introducidas en un inmueble alquilado? o ¿cuál es el plazo mínimo de vigencia para un contrato de locación? Aunque las partes nada dispongan, la ley otorga una solución en caso de encontrarnos ante la situación descripta.

### 3.1.2 Códigos

Dentro de las leyes encontramos también un tipo especial llamado código: se trata de un conjunto de normas abocadas a reglar una rama específica del derecho en forma sistemática. Tanto las leyes como los códigos se diferencian, según la materia que traten, en leyes o códigos de *fondo* o *forma*. Las leyes de fondo son reservadas por la Constitución Nacional para ser dictadas por el Congreso de la Nación y tener aplicación en todo el país, dado que versan sobre derecho civil, derecho comercial, minería, derecho penal, derecho del trabajo y de la seguridad social. En cambio, las leyes de forma se refieren al procedimiento para llevar a cabo la aplicación de las leyes de fondo. Siendo que las idiosincrasias, cantidad de habitantes y extensión del territorio de cada provincia son distintos, las características de la aplicación de las leyes son reservadas. Esto significa que cada provincia dicta su código de procedimientos para cada fuero y establece autónomamente sus tribunales de primera instancia, cámaras de apelaciones y supremas cortes. Por ejemplo, en la Capital Federal encontramos juzgados nacionales en lo civil y juzgados nacionales en lo comercial; en cambio en la provincia de Buenos Aires encontramos ambas materias unidas en un solo fuero: el civil y comercial. También podemos ver diferencias en el fuero del trabajo, pues en la Capital Federal hay juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones y en la provincia de Buenos Aires, en cambio, existen tribunales del trabajo (tribunales por estar constituidos por tres jueces cada uno) de instancia única con apelación a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Es importante destacar que, con el fin de obtener la modificación de los códigos, no es necesario el dictado de uno nuevo, sino que basta con dictar una ley que modifique los artículos o, de ser el caso, los capítulos cuestionados del código. Aún así, la última reforma optó por modificar totalmente y unificar los Códigos Civil y Comercial en un solo cuerpo normativo cuyas modificaciones se han volcado en esta nueva edición del presente libro.

### 3.2 La costumbre

Basta observar la vida en sociedad para encontrar que el ser humano se mueve en determinados ambientes respetando *usos sociales* que lo llevan a actuar de determinada forma. Sin embargo, no todas las personas respetan estos usos sociales, por cuanto son mayormente facultativos. Pero cuando éstos son resaltados por la mayoría de la sociedad y se empiezan a considerar *obligatorios*, se transforman, por su repetición, en *costumbres*.

Con el fin de su aplicación como fuente del derecho, la costumbre tiene un tratamiento restrictivo. En su redacción vigente, el artículo 1° del Código Civil y Comercial de la Nación dice: "...Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho". También encontramos normas como la del artículo 2.649 y la de los artículos 1.255, 1.061, 1064 al 1.066, todas las cuales remiten a los usos del lugar para juzgar sobre la validez o invalidez del acto que tratan.

### 3.3 La jurisprudencia

Se conocen con el término *jurisprudencia* las decisiones del órgano judicial del Estado. Los distintos jueces (de primera instancia, de cámaras de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) van tratando en forma reiterada diversas situaciones que permiten interpretar el alcance de determinada norma, cuya aplicación al caso particular resulta confusa. Cuando la interpretación se vuelve generalizada y pacífica (esto significa que la mayoría de los jueces resuelven cuestiones similares en igual sentido), se dice que la jurisprudencia interpreta la norma de determinada forma; sin embargo, los precedentes judiciales no son obligatorios para los otros jueces, ya que pueden apartarse, fundadamente, de la interpretación de los jueces de rango superior. De esta forma, no resultan obligatorias las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los jueces de cámara o para el juez de primera instancia, que tienen la opción de alejarse de éstas. Para hacer eso, es requisito que se aparten en forma fundada, por dos motivos: en primer lugar, porque es razonable pensar que el superior revocará el fallo si no encuentra motivos para alejarse de lo resuelto en casos anteriores (para garantizar la seguridad jurídica); y, en segundo lugar, porque la sentencia no fundada podría ser tachada de arbitraria.

En la Argentina, sin embargo, existe un caso de obligatoriedad de los fallos precedentes: el supuesto de los fallos plenarios. Éstos son dictados por la Cámara de Apelaciones *en pleno* (con todos los jueces de todas sus salas reunidos para dictarlo) y versan sobre determinada



cuestión puntual. Una vez resuelto el fallo será de aplicación obligatoria para los jueces inferiores y la misma Cámara de Apelaciones que lo dictó, por un término de diez años. Sin perjuicio de eso, el juez en cada caso concreto puede dejar a salvo su opinión en contrario, pese a que debe respetar lo resuelto por el superior. Esta opinión, si se hace mayoritaria, puede, con el tiempo, revertir el fallo plenario con otro de igual naturaleza.

### 3.4 La doctrina

La última fuente del derecho, la doctrina, es la reunión de las opiniones de los autores expertos en derecho que se han volcado en los diversos libros y artículos sobre materia jurídica. Este tipo de fuente no tiene ninguna obligatoriedad, pero su aplicación, para todos los operadores del derecho, sin embargo, constituye una guía de interpretación. Cuanto mayor importancia y trayectoria posea el autor, mayor autoridad tendrán sus opiniones para ser tomadas en cuenta.

## 4. Diversas clasificaciones del derecho

### 4.1 Ley natural y derecho positivo

El Ley natural constituye un orden de la naturaleza, preexistente, que debería ser respetado por el sistema legal de cada país.

En cambio, el derecho positivo es el conjunto de normas impuestas (con validez y vigencia) con el fin de regular las conductas humanas. En opinión del tratadista Borda, estas normas deben también estar orientadas hacia la justicia y el bien común para ser tales.

### 4.2 Derecho continental y CommonLaw

Observando los distintos sistemas jurídicos existentes en el mundo se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran los países cuyo sistema jurídico deriva del sistema sajón, que recibe el nombre de *CommonLaw*.

Por otro lado, están los países cuyos sistemas derivan del sistema románico, que se denomina *derecho continental*.

Nuestro país posee el último sistema referido, el cual deriva del aplicado en Europa continental. Éste tiene sus raíces tanto en el derecho romano, como en el germano y el canónico. Este sistema de derecho se utiliza en la mayoría de los países europeos y en aquellos que, mediante la colonización, fueron influenciados por éstos. La característica distintiva, en comparación con el otro gran sistema jurídico existente, el *CommonLaw*, es que la principal fuente del derecho es la ley.

Nuestro sistema, entonces, se sustenta en las normas dictadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Éstas serán interpretadas, en caso de conflicto, por el Poder Judicial, y en el caso concreto de que fueran llevadas a su competencia mediante el pedido de los habitantes. Estos pedidos se efectúan mediante las conocidas *demandas*. La norma jurídica, salvo excepciones, tiene carácter general, por lo que puede ocasionar una controversia, y en caso de que esto ocurra, deberá ser solucionada por el sistema judicial.

Así, la labor jurisprudencial se verá limitada al ámbito de la *interpretación* de la normativa vigente; puede llegar a ser tachada de inconstitucional, pero, para el caso en concreto que nos ocupa, no pierde, por ello, la ley su vigencia.

Por su parte el sistema anglosajón deriva del derecho aplicado en la Inglaterra medieval. Así, teniendo este origen, existiendo en aquel entonces falta de unidad jurídica (ley confusa, difusa y mayormente desconocida) y habiendo diversidad de poderes, se priorizó y basó el derecho en las decisiones de los tribunales en mayor medida, en los precedentes de ellos mismos y los de otros tribunales superiores.

Este derecho tuvo su expansión al tiempo de la colonización británica. Actualmente es de aplicación en Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos (aunque no en todos los estados miembros), Australia, Nueva Zelanda, Canadá (con la excepción de Quebec), Hong Kong, India, Malasia, Singapur y Sudáfrica.

Se destaca de este derecho que, para los casos posteriores, la *ratio decidendi*<sup>6</sup> de los precedentes jurisprudenciales obliga a los tribunales inferiores a fallar de la misma manera o similar. De esta forma, se torna de vital importancia, en este sistema, el análisis detallado de los precedentes para lograr inferir la norma. Por lo tanto, el estudio del derecho termina sustentándose en casos modelos que se comparan con la situación en estudio para ver si es similar o no. Esto no implica que no existan normas y que éstas no marquen un orden social, sino que la interpretación judicial cobra una vital importancia en la generación del derecho, mucho más dinámica y potente, como fuente del mismo, que en el derecho continental.

---

<sup>6</sup>Razón o análisis utilizado para resolver un conflicto.

En cambio, en el sistema continental, cada juez puede resolver el caso que se le presenta de la forma que considere más conveniente o justa, e incluso puede apartarse de la jurisprudencia mayoritaria (aunque sea seguida por jueces que se encuentran por encima de él y que, eventualmente, deberán entender en una revisión de sus decisiones). Esto siempre y cuando pueda producir un fallo ajustado a derecho y con fundamentos que justifiquen ese apartarse de los precedentes del superior (de lo contrario, lo más probable es que su sentencia sea dejada sin efecto por la alzada). La única excepción que, dentro del sistema continental, existe para este principio general está constituida por los llamados *fallos plenarios*, que fueron comentados más arriba.

#### 4.3 Derecho objetivo y subjetivo

En cuanto a la clasificación que tiene por objeto a la persona, podemos encontrar el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo resulta ser el conjunto de normas jurídicas establecidas para regir las relaciones de los hombres en sociedad. Por su parte, el derecho subjetivo es el poder o la facultad que tiene el sujeto particular de exigir algo o de realizar determinado acto.

#### 4.4 Derecho público y privado. Ramas del derecho

El derecho en conjunto forma una unidad. El estudio de las divisiones o ramas del derecho sirve, en primer lugar, para fines académicos y, en segundo lugar, para establecer una prelación y aplicación de las distintas normas en caso de conflicto entre ellas, priorizando su especialidad.

Una primera clasificación que se remonta al derecho romano es la de *derecho público* y *privado*. El derecho público versa sobre las relaciones entre el Estado y los particulares. En cambio, el derecho privado se refiere a las relaciones entre los particulares. Siguiendo esta clasificación, encontramos, dentro del derecho público, el derecho constitucional. En éste se encuentran todas las normas referidas a la organización del Estado, la división de poderes, las relaciones del Estado y de sus habitantes y los derechos y garantías de las personas.

También dentro del derecho público encontramos el derecho administrativo, que regula en particular la relación de la administración pública con los individuos, para el caso concreto.

El derecho penal es el que establece las medidas que sirven para garantizar la vida en sociedad y fija las penas aplicables para el caso de la violación de aquéllas. Es también necesaria la existencia del derecho procesal, porque se encarga de organizar la administración de la justicia,

por medio de los códigos de procedimiento, cuyo dictado, como hemos visto, es facultad de las provincias.

Finalmente, también encontramos el derecho internacional público, que permite regular la relación de los Estados entre sí. Éste sirve, asimismo, para todo lo referente a la sanción de los tratados internacionales y su jerarquía, conforme el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Por el lado del derecho privado encontramos, en primer lugar, el derecho civil. Este derecho regula las relaciones de las personas físicas y jurídicas entre sí cuando el tratamiento de estas relaciones por su especificidad no caiga dentro de la órbita del derecho comercial u otro derecho especial, como se verá más adelante.

El derecho comercial, por su parte, regula las relaciones que surjan del ejercicio del comercio, siendo aplicable a los comerciantes y a quienes negocien con ellos.

El derecho laboral, dentro de las más importantes ramas del derecho privado, rige las relaciones entre empleadores y empleados con un claro papel tutelar del trabajador.

Finalmente, podemos destacar el derecho internacional privado, que regula cuestiones de las personas físicas residentes en distintos países. Éste es de vital importancia a la hora de reglar todo lo relacionado con el comercio electrónico y las consecuencias de las TIC's<sup>7</sup> y su injerencia en el derecho.

## **5. El derecho, el tiempo y el territorio**

El derecho obedece a ciertos principios que deben ser respetados por quien resulte encargado de la sanción de la norma. Los principios más comunes, que se relacionan con el tiempo y el territorio, son los siguientes:

### **5.1. Principio de irretroactividad.**

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, este principio establece que las leyes no tendrán efecto sobre hechos o actos que hubieran acontecido antes de su entrada en vigencia. Así, el artículo 7° del Código Civil y Comercial nos enseña que "A partir de su entrada en vigencia,

---

<sup>7</sup> Tecnologías de la información y comunicaciones.

las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo."

## 5.2. Prescripción.

Otro principio elemental, con relación al tiempo, es el de la prescripción de los derechos. El Código Civil y Comercial establece que la prescripción es "una forma de adquirir o perder derechos por el mero paso del tiempo". Es conocida la prescripción adquisitiva, por ejemplo, porque permite a una persona que tiene la posesión de un inmueble, de buena fe y por más de veinte años, adquirir su propiedad (debe destacarse que esta persona no ha comprado el inmueble en cuestión; sino que simplemente lo ha ocupado por el tiempo indicado). En cambio, la prescripción liberatoria permite al deudor, frente a la falta de ejercicio de la acción por parte de su acreedor, por un lapso fijado por la ley según la naturaleza del acto de que se trate, rechazar la acción de éste por medio de una defensa procesal llamada *excepción de prescripción*. Este sistema de la prescripción tiene el objeto de dar seguridad jurídica y eliminar la incertidumbre de posibles derechos o reclamos que pudieran ser ejercidos en forma perpetua si este límite no existiese.

## 5.3. Territorialidad del derecho.

Este principio indica que las normas emanadas de los organismos argentinos son de aplicación únicamente en nuestro país. Esto se deduce en razón de que cada Estado es soberano y, por ende, puede dictar sus propias normas y aplicarlas dentro de su territorio, pero no fuera de él. Cuando se pretende aplicar normas extranjeras, o viceversa, nos remitimos a tratados internacionales, en caso de ser derecho internacional público, o a normas del derecho internacional privado, cuando su aplicación sea entre personas de distintos países. Por ejemplo, el derecho argentino reconoce a las sociedades extranjeras en nuestro país siempre y cuando éstas sean constituidas conforme a las leyes de dicho país y adapten su presencia a los lineamientos que indica la ley de sociedades. Así, existe internacionalmente multitud de tratados en que los países, por cuestiones de utilidad, reconocen la validez recíproca de normas, actos jurídicos y distintas documentaciones emanadas de cada uno.

Deben comprenderse la importancia y la dificultad del aspecto de la transnacionalidad del derecho, en especial en cuestiones de comercio electrónico o delitos informáticos. Basta imaginar un delito cometido por medios informáticos en un país donde dicha acción no constituye delito,

pero que en el lugar donde se encuentra la víctima sí lo es. El conflicto de normas surge de forma evidente y su aplicación es extremadamente difícil. Sin entrar en un terreno delictual, un contrato puede ser suscripto por personas localizadas en diferentes países a través de Internet, tener sus efectos en un tercer país y haberse suscripto mediante un servidor alojado en un cuarto país. ¿Cuál será la norma de fondo y de forma aplicable a la solución del conflicto? Existen distintas soluciones, aunque no definitivas, que serán abordadas más adelante en la presente obra.

## 6. Organización del Estado

La República Argentina es un Estado federal constituido por veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Conforme lo establece nuestra Carta Magna, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.

Es *representativa* porque gobiernan los representantes del pueblo y no sus habitantes en forma directa. Por esto, el texto del artículo 22 de la Constitución Nacional dice: "*El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución...*".

Por *representación* se entiende que las autoridades son elegidas en elecciones que son universales, obligatorias e igualitarias. Las decisiones de gobierno que tomen las autoridades elegidas, serán en nombre de toda la sociedad.

Es *republicana* porque los representantes serán elegidos a través del sufragio popular. La forma federal de gobierno surge de los orígenes de la unidad nacional, la que proviene de la voluntad de los estados provinciales, que decidieron y crearon una unidad superior a ellos, delegando algunas de sus potestades a un gobierno central y reservando para sí mismos aquellos poderes que no estuvieran expresamente delegados al gobierno federal.

Este régimen resultó ser una democracia presidencialista. Para que se respeten, dentro de esta forma de gobierno, las garantías y derechos individuales constitucionalmente receptados, fue necesario limitar el poder único soberano del Estado. Para ello se adoptó un sistema que se comenzó a utilizar a partir de las revoluciones francesa y norteamericana, el de la división en tres poderes (más específicamente en funciones): el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos tres poderes poseen sus funciones específicas y al mismo tiempo ejercen una suerte de contralor entre ellos.

La Constitución Nacional es un cuerpo normativo que se encuentra dividido en dos partes. La primera parte se compone de dos capítulos. En el capítulo primero encontramos las

declaraciones, derechos y garantías (artículos 1° al 35), y en el capítulo segundo los nuevos derechos y garantías (artículos 36 al 43). Luego sigue la segunda parte, que está conformada de dos títulos. El primero trata del gobierno federal y el segundo, de las facultades reservadas a las provincias.

### 6.1 División de poderes

El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación (artículo 87 de la Constitución Nacional). Este cargo sólo puede ser ejercido por un ciudadano argentino nativo o por opción; la duración en su cargo es por el término de cuatro años y existe la posibilidad de ser reelegido por un solo período consecutivo.

La elección se realiza a través del voto popular directo, con posibilidad de doble vuelta en caso de que no se obtenga en la primera vuelta más del 45 % de los votos afirmativos o, en su defecto, un 40 % de los votos con una superioridad del 10 % de ellos respecto del candidato que sigue.

El vicepresidente de la nación acompaña al presidente y es elegido por el mismo período y con las mismas modalidades. Ejerce el cargo de presidente del Senado pero sin voto, salvo en caso de empate.

El presidente de la Nación tiene a su cargo varias jefaturas. Es jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país (artículo 99, inciso 1).

El vicepresidente tiene por función reemplazar al presidente en los casos de ausencia, muerte, renuncia o destitución. Si ambos cayeran en dichas causales, es el Congreso de la Nación el que determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que hayan cesado las causas o un nuevo presidente sea elegido. Esta norma constitucional tiene su reglamentación en la Ley de Acefalía (20.972). El antecedente más próximo de la utilización de este mecanismo lo hemos vivido en nuestro país a finales de 2001 y principios de 2002. El Congreso, reunido en asamblea (todos sus miembros juntos), debió elegir, entre senadores nacionales, diputados nacionales o gobernadores provinciales, a una persona para que desempeñara la función de presidente hasta finalizar el período del ex presidente Fernando de la Rúa.

El Poder Legislativo se encuentra a cargo del Congreso de la Nación. Éste se compone de dos cámaras, la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores (de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La Cámara de Senadores se encuentra integrada por tres senadores por provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires. Estos senadores duran en su cargo seis años, son elegidos en forma directa por el voto de la población y renuevan su composición por tercios, cada dos años. Las tres bancas de cada provincia corresponden dos al partido político con la mayoría de los votos y la restante al partido político que siga en cantidad de votos. Los requisitos para ser senador son: tener por lo menos treinta años de edad, seis años de ciudadanía de la Nación, ser natural de la provincia en la que es elegido o tener dos años de residencia inmediata en ella.

La Cámara de Diputados cuenta en la actualidad con 257 miembros que también son elegidos en forma directa, pero con una duración de cuatro años de mandato, y se renuevan por mitades cada dos años. Tanto los diputados como los senadores son reelegibles, sin límite de veces. Los requisitos para ser diputado son: haber cumplido los veinticinco años de edad, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, ser natural de la provincia en la que es elegido o tener dos años de residencia inmediata.

El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. La Corte Suprema está compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de la Nación, con el acuerdo del Senado de la Nación. Los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema son: ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las cualidades requeridas para ser senador.

## **6.2 Funciones de los tres poderes**

### **6.2.1 Poder Ejecutivo**

El presidente tiene, entre otras, las siguientes atribuciones (conforme el artículo 99 de la Constitución Nacional):

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu, con excepciones reglamentarias.
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución Nacional, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros. El jefe de Gabinete de Ministros,



personalmente y dentro de los diez días, someterá la medida a consideración de una comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación.

4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado de la Nación por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores sobre la base de una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.

6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.

7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de Gabinete de Ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por la Constitución Nacional.

8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación; reunidas a tal efecto las dos cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución Nacional, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.

10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de Gabinete de Ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras; recibe sus ministros y admite sus cónsules.

12. Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.

13. Provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado de la Nación, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí sólo en el campo de batalla.
14. Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso de la Nación.
16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado de la Nación. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso de la Nación está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.
17. Puede pedir al jefe de Gabinete de Ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos.
18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso de la Nación. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.
19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura.
20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso de la Nación, teniendo el deber de convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

### **6.2.2 Poder Legislativo**

El Congreso de la Nación tiene las siguientes atribuciones, según el artículo 75 de la Constitución Nacional:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las

contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, se efectuará en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como cámara de origen al Senado de la Nación y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso de la Nación cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara.
4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.
5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.
7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, sobre la base del programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.
12. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y el de las provincias entre sí.
14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.
15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación; fijar los de las provincias, crear otras nuevas; y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.
16. Proveer a la seguridad de las fronteras.
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país; al adelanto y bienestar de todas las provincias; y al progreso de la ilustración; dictando planes de instrucción general y universitaria; y promoviendo la industria; la inmigración; la construcción de ferrocarriles y canales navegables; la colonización de tierras de propiedad nacional; la introducción y establecimiento de nuevas industrias; la importación de capitales extranjeros; y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano; al progreso económico con justicia social; a la productividad de la economía nacional; a la generación de empleo; a la formación profesional de los trabajadores; a la defensa del valor de la moneda; a la investigación; y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación; y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado de la Nación será cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural; la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico; y los espacios culturales y audiovisuales.

20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; crear y suprimir empleos y fijar sus atribuciones; dar pensiones; decretar honores; y conceder amnistías generales.

21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la república; y declarar el caso de proceder a nueva elección.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso de la Nación, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. En el caso de los tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada cámara, declarará la conveniencia de la aprobación de un tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara.
25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas.
27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.
28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
29. Declarar en estado de sitio en uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la república. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución Nacional al gobierno de la Nación Argentina.

### 6.2.3 Poder Judicial

El Poder Judicial tiene las atribuciones que los artículos 116 a 119 de la Constitución Nacional disponen, es decir, el conocimiento y decisión de todas las causas que tengan que ver con:

- Cuestiones de jerarquía constitucional y de conflicto de las leyes de la Nación.
- Tratados con naciones extranjeras.
- Cuestiones que incluyan a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros.
- Cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima.
- Asuntos en que la Nación sea parte.
- Conflictos entre dos o más provincias.
- Conflictos entre una provincia y los vecinos de la otra.
- Conflictos entre vecinos de diferentes provincias.
- Conflictos entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero.

La Corte Suprema interviene por vía de apelaciones, según las reglas y excepciones que prescriban las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, con excepción de lo que incumba a cuestiones con embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que una provincia fuera parte, donde intervendrá con competencia originaria y exclusiva.

### 6.3 Control e interdependencia de los poderes

Se indicó anteriormente que la división de poderes, establecida por la Constitución Nacional, busca limitar abusos por parte del Estado. De esta forma, dispone balancear los tres poderes, dividiendo las funciones del, en definitiva, único poder. Cada uno de los “poderes” tiene una función principal, lo que no impide que, en casos excepcionales, todos asuman potestades diferentes y concurrentes.

El Poder Ejecutivo, en casos de necesidad y urgencia, legisla (decretos de necesidad y urgencia). También, entre sus facultades está la de conmutar o perdonar las penas, es decir, juzgar, que es facultad propia del Poder Judicial.

El Poder Legislativo, cuando trata la ley de ministerios, o cuando aprueba o modifica el presupuesto nacional, incide en la administración del país; o, cuando dispone el juicio político, “usa” una facultad del Poder Judicial.

Finalmente, el Poder Judicial en algunas ocasiones puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. De esa forma, para el caso concreto, está legislando. Y, si la declaración de inconstitucionalidad pesa sobre una resolución administrativa, está indirectamente administrando.

#### 6.4 Derechos y garantías constitucionales

En la primera parte de la Constitución Nacional encontramos, a partir del artículo 14, los derechos y garantías individuales. Todos estos derechos no son absolutos, puesto que se encuentran limitados, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. En nuestro país toda persona tiene derecho a "...trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender" (artículo 14 de la Constitución Nacional).

Por su parte el artículo 14 bis, que incluye los derechos de segunda generación, establece las generalidades del derecho del trabajo y las garantías de los beneficios de la seguridad social.<sup>8</sup>

Queda establecido en el artículo 16 que todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Dispone también que los impuestos y las cargas públicas serán distribuidos en forma igualitaria.

El derecho a la propiedad se encuentra reconocido en el artículo 17, en el cual queda establecida la inviolabilidad del mismo, encontrando únicamente el límite en la expropiación por causa de utilidad pública, que tiene como requisitos la sanción de una ley y la indemnización al particular expropiado.

---

<sup>8</sup>Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.



En la órbita del derecho penal, el artículo 18 dispone que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. También prohíbe el juzgamiento por comisiones especiales o jueces distintos de los existentes antes del hecho de la causa. Establece la prohibición de arresto sin orden escrita de autoridad competente y el principio de que nadie se encuentra obligado a declarar contra sí mismo. Regula, además, otras cuestiones del derecho penal.

El artículo 19 dispone que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral públicas, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este principio es también receptado y explicado más adelante, al tratar el tema de la libertad contractual.

Los derechos detallados anteriormente se completan con el resto de los que surgen en el articulado de la Constitución Nacional, y todos se encuentran sujetos a lo que dispone el artículo 28 del cuerpo normativo, que reza: "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".

Debe también estarse a lo que indica el artículo 33, cuyo texto dice: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".

El capítulo segundo del primer libro de la Constitución Nacional dispone los nuevos derechos y garantías.

Aquí se consagran:

- La permanente vigencia de la Constitución Nacional (artículo 36).
- La garantía de acceso a los derechos políticos (artículo 37).
- El sostenimiento de los partidos políticos (artículo 38).
- El derecho de la población para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados (artículo 39).
- La reglamentación de la consulta popular (artículo 40).
- El derecho al ambiente sano. El daño ambiental y la obligación de reparar dicho daño. La utilización racional de los recursos y la prohibición del ingreso de residuos peligrosos (artículo 41).
- La protección del derecho al consumidor, que luego encuentra su reglamentación en la Ley de Defensa del Consumidor (artículo 42).
- La acción de amparo, de hábeas data y de hábeas corpus (artículo 43).

## **7. Gobierno digital**

### **7.1 Concepto**

Se entiende actualmente por gobierno digital la utilización en la mayor medida posible de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en el funcionamiento del gobierno, sus dependencias y su relación con los ciudadanos. De esta forma, se busca, mediante la utilización de la tecnología, lograr hacer más transparente la gestión pública y agilizar la tradicional tramitación burocrática, para poder elevar la calidad de los servicios gubernamentales.

Actualmente existen muchas iniciativas a nivel nacional e internacional. La mayoría de los países se encuentran abocados a:

Lograr la integración del sector público, mediante la utilización de los servicios de redes e integración de las bases de datos, lo que genera mayor control y corrección de la información manejada.

El diseño de nuevos procedimientos que agilicen la gestión pública, digitalizando la mayor cantidad de documentos posibles, los que tradicionalmente se presentaban en formato de papel. Esto permite acelerar la gestión de los expedientes administrativos, ya que se encuentran disponibles en forma inmediata y simultánea para varios operadores, no demorándose tiempo en su traslado físico.

Mayor rapidez y seguridad de la gestión de los servicios para permitir a la población un acceso rápido, no limitado al horario de gestión personalizada de la administración.

Utilización de portales que permitan la participación ciudadana, tanto en la gestión como en la opinión, en determinados temas, para que se puedan plantear problemas, necesidades y dificultades por solucionar.

Promoción de políticas de publicidad e información de la sociedad sobre derechos y procedimientos para que se pueda acceder a ellos a través de todos los sistemas.

En nuestro país, todos estos sistemas, en mayor o menor medida, encuentran recepción en organismos oficiales como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), diversos portales de gobiernos nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias, donde se pueden gestionar turnos, averiguar información sobre diversos trámites, efectuar reclamos, sugerencias, etcétera.

## Capítulo 2. Derecho e informática

### 1. La informática en el ámbito del derecho

Siguiendo a la Real Academia Española podemos definir la informática como un “conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores”. También se puede definir la informática como “una ciencia cuyo objeto de estudio es el conocimiento de la información”. Con tales fines se utilizan la computación y las TIC como instrumento operativo y de gestión. Utilizando la teoría de los sistemas y aplicándola sobre distintos tipos de organizaciones, se la intenta perfeccionar en lo que se refiere a la eficacia en el tratamiento de la información, su generación y circulación.

Cuando la ciencia de la informática desarrolla su saber dentro de sistemas destinados a la operatoria jurídica (como puede ser la administración de un juzgado o de un estudio jurídico) o simplemente produce efectos con consecuencias jurídicas, nos adentramos de lleno en ámbitos del derecho informático.

### 2. Informática jurídica decisional y de gestión

Considerando la introducción anterior deberíamos tratar la distinción entre dos términos similares, pero que se refieren a circunstancias distintas.

En principio, encontramos la informática jurídica, pero precisamos especificar dos términos más: la informática decisional y la informática de gestión. En sí, estos dos términos no hacen más que referirse a diferentes aplicaciones que resultan de la informática para su utilización por los operadores del derecho. Así, todo lo referente a la gestión de despachos o dependencias judiciales será informática jurídica de gestión.

En cambio, la informática jurídica decisional nos acerca más a la obtención de resoluciones a conflictos legales mediante el uso de la inteligencia artificial (cualquiera sea el método aplicado), de modo que la tecnología permita resolver la cuestión, o al menos acercar a las partes a un entendimiento, pero excediendo el mero hecho de ser una plataforma que permita el encuentro de éstas.

### 3. Derecho informático

Podemos definir el derecho informático como un "conjunto de normas y principios que tienen por objeto reglar, definir, interpretar y estudiar los aspectos en que la tecnología informática se relaciona con las distintas instituciones jurídicas".<sup>9</sup> También podemos tomar como definición la siguiente: "La disciplina que estudia el fenómeno de la información, y la elaboración, transmisión y utilización de la información, principalmente, aunque no necesariamente, con la ayuda de ordenadores y sistemas de telecomunicación como instrumentos".<sup>10</sup> De estas definiciones surgen claramente las diferencias en los dos términos acuñados más arriba.

A partir de estas definiciones se pueden inferir las diferencias entre el derecho informático y la informática jurídica. Para expresarlo en forma simple, se podría decir que un término alude a la regulación del derecho de las tecnologías, y el otro, a la puesta de dichas tecnologías al servicio de los operadores del derecho.

Las actividades relacionadas con el tratamiento electrónico de información al que se refiere el autor citado en los párrafos anteriores, se caracterizan por poseer diversos caracteres que no se encuentran presentes en otros hechos que igualmente generan consecuencias jurídicas. El hecho informático comparte con el derecho caracteres que dificultan su regulación. Así, tendrá "globalidad y transnacionalidad": ambos conceptos se refieren a la facilidad que tienen los hechos informáticos de atravesar las fronteras territoriales de cualquier país. Esta característica genera un concepto normativo y, consecuentemente, una inseguridad jurídica en el derecho informático, sobre la que se debe trabajar para superarla. Específicamente, el problema de la jurisdicción que generan estas características de globalidad y transnacionalidad, es tratado en el último punto del presente capítulo.

#### 3.1 Transversalidad

El hecho informático impone una diferenciación en su estudio, por cuanto, debido a su naturaleza especial, escapa de la tradicional especialización vertical del saber normalmente utilizado en cualquier ciencia, e incluso de la clasificación o división horizontal entre los distintos saberes. El hecho informático aúna y atraviesa "transversalmente" distintas disciplinas incluidas en el derecho, lo que dificulta enormemente su estudio desde el punto de vista legal y, en consecuencia, su regulación legislativa.

<sup>9</sup> Luz, Clara Bibiana, *Manual de derecho informático*, Ed. Nova Tesis.

<sup>10</sup> Altmark, Daniel Ricardo, *Informática y derecho*, vol. 1, Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 6.

### 3.2 Autonomía del derecho informático

El derecho informático, para ser considerado una rama autónoma del derecho, debe poseer, en primer lugar, autonomía científica, es decir que debe contar con principios que no pertenezcan a otras ramas del derecho. Esto no implica que todo el ordenamiento en su conjunto no pueda ser aplicado al hecho informático, sino que, para considerar autónoma a una rama del derecho, es necesario que existan aquéllos.

En segundo lugar, requiere de una autonomía legislativa, que se vería plasmada en la existencia de leyes y códigos propios. En nuestro país no existen códigos de derecho informático (ni los puede haber por no estar contemplado en la Constitución Nacional). En cambio, existen cada vez más leyes que tratan distintos aspectos de éste, como la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Firma Digital, la Ley de Delitos Informáticos, la Ley de Derechos de Autor, entre otras. Es de destacar que la legislación específica, en la mayoría de los casos y en el momento actual, resulta escasa e insuficiente, debiendo recurrirse a aplicaciones analógicas de la norma general. Esto no significa que los conflictos queden sin resolver; pero exige un papel de la Justicia que muchas veces roza el rol legislativo para zanjar los reclamos que le son llevados a su entendimiento.

A la fecha no existen códigos o reglas aplicables directamente a Internet más allá de la regulación de la ICANN<sup>11</sup> y de los distintos NIC,<sup>12</sup> por lo que se utilizan normalmente las normas ya existentes y las nuevas especializadas, pero esto dependerá del grado de desarrollo legislativo de cada país. Sí existen, en cambio, regulaciones sobre comercio electrónico a nivel internacional, firma digital, resolución *online* de conflictos (ODR), etcétera.

También se requiere autonomía didáctica o académica para poder hablar de autonomía del derecho informático. Esto implica la existencia de cátedras y asignaturas propias dentro del estudio universitario. Lentamente se van desarrollando, primero como carreras de especialización de posgrado, cursos de actualización del derecho informático; existen también hoy en día algunas materias autónomas de grado en distintas universidades del país; pero es normal aún tratar temas generales agregando las consecuencias que el hecho informático pudiera tener, pero insertándolo dentro de las asignaturas que ya existen.

Por último, se requeriría también la autonomía judicial, lo que implicaría la existencia de tribunales especializados. Es claramente éste el aspecto más controvertido y, en opinión del autor, más descuidado a la fecha, por cuanto la especialización que requiere el hecho informático, que

---

<sup>11</sup> Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([www.icann.org](http://www.icann.org)).

<sup>12</sup> En el caso argentino se puede visitar [www.nic.ar](http://www.nic.ar) (Network Information Center Argentina).

puede caer en la jurisdicción de tribunales tanto civiles, como comerciales, laborales u otros, genera interpretaciones diversas y muchas veces poco felices en la solución de conflictos que tengan aristas dentro del terreno del derecho informático. Si bien es cierto que el juzgador cuenta con "auxiliares", que son los peritos informáticos, éstos suelen aportar pruebas técnicas, pero no criterios jurídicos especializados en la materia, por lo que su apoyo resulta también limitado e insuficiente en este aspecto.

#### **4. Introducción a algunas cuestiones del derecho informático**

La irrupción de la informática en el ámbito del derecho genera conflictos en sus distintas ramas. Podemos simplemente, observando los diarios y la información disponible, tener un primer acercamiento a los nuevos delitos que surgen por el uso de las tecnologías en forma ilegal. Estos delitos pueden ser conflictos de propiedad intelectual y protección de derechos de autor, que comúnmente la gente no considera delitos, pero lo son, por ejemplo: el intercambio de programas, música, películas, videos en general, que poseen protección de los derechos autor, puede caer en los tipos penales que se encuentran normados en la Ley de Propiedad Intelectual (derechos de autor).

Existe también la mala utilización de la tecnología con fines netamente delictivos, por ejemplo, sustitución de identidad, hurto informático (que la ley legisla como estafa informática), delito de daños a sistemas informáticos, violación de correspondencia al violar el e-mail de terceros (problemática que también nos introduce en el mundo del derecho del trabajo), y muchos otros delitos que se tratarán en detalle más adelante en la presente obra.

Escapándose del ámbito delictivo, en las relaciones entre las personas surge todo un nuevo mundo contractual en el que las tecnologías tienen cada vez mayor injerencia. Existe desde hace ya varios años la contratación electrónica automatizada a nivel empresario: mediante la utilización de un contrato marco y de un sistema informático desarrollado específicamente para la tarea a realizar se comercializan bienes prácticamente sin intervención del ser humano. Sin tener que buscar ese nivel de especificidad, las compraventas a través del medio informático son moneda corriente en los sitios de subastas electrónicas.

Párrafo aparte merece la problemática que surge cuando se conjuga la compra-venta de bienes informáticos con sistemas donde quien brinda la solución informática la provee en cuanto al software y al hardware. Allí aparece contractualmente una inversión de la tradicional "parte fuerte" en el contrato, que no necesariamente será quien cuente con más cantidad de dinero, sino quien tenga el conocimiento del producto que se está vendiendo. Por esta razón, doctrinariamente se considera que existe una obligación de "consejo" y de "advertencia" (puede recibir diversos nombres y se profundizará más adelante en la presente obra).

Podemos mencionar también las responsabilidades emergentes del uso de las bases de datos, fenómeno que si bien existía aun antes de la irrupción de la informática en el ámbito del derecho, el auge en informática documental ha permitido su crecimiento exponencial, lo que puede llegar a permitir que se produzcan grandes perjuicios por el mal uso de estos datos y la relación de los existentes en las distintas bases de datos. Así, fue surgiendo toda la normativa de protección de datos personales, y se creó a nivel estatal la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,<sup>13</sup> dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la cual se encarga de controlar la adecuación de las bases de datos destinadas a brindar informes según los estándares de seguridad requeridos por la ley.<sup>14</sup>

Finalmente, uno de los problemas principales que enfrenta el derecho informático es el de la identificación del sujeto que actúa a través de dicho sistema. Tanto para el ámbito delictual como para el ámbito obligacional contractual, el problema queda aún sin solución, ya que la mayoría de los delitos informáticos terminan con su rastro de origen en un cibercafé, un ciberlocutorio o la IP de algún acceso público a la red de redes. Por su parte, en las cuestiones contractuales, si bien tienen un primer enfoque de solución en la utilización de la firma digital y de los sistemas de identificación biométrico o de comunicación de protocolo seguro (https), son aún muchos los problemas que pueden generarse, tanto por la jurisdicción y ley aplicable (las contrataciones fácilmente pueden ser internacionales y tener distintas leyes, tanto de fondo como de forma, y entrar en conflicto unas con otras), como por cuestiones temporales o de robo de claves o abuso de firmas delegadas.

Resulta entonces muy amplia la injerencia del hecho informático en el derecho, por lo que el trabajo por realizar, tanto académica como profesionalmente, es clave; su estudio merece ser profundizado y esta obra pretende constituir un punto de inicio.

## 5. Problema de la jurisdicción

Otra de las consecuencias de la particularidad del hecho informático, que se destaca por su importancia y dificultad en la solución de conflictos, es la característica de transnacionalidad. Es de por sí complicado su estudio y regulación a nivel nacional por lo novedosos y ágiles que son los hechos informáticos, por lo que mucho más difícil es su regulación internacional.

---

<sup>13</sup> <http://www.jus.gov.ar/datos-personales.aspx>.

<sup>14</sup> Tiene a su cargo el Registro de las Bases de Datos, instrumento organizado con el fin de conocer y controlar las bases de datos. Asesora y asiste a los titulares de datos personales, y recibe las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos.

En el capítulo anterior hemos introducido el concepto de derecho internacional público y privado, el cual contiene normas para la regulación de la jurisdicción y ley aplicables a los distintos conflictos que pudieran darse en los ámbitos de injerencia de éstos. Sin embargo, cuando se producen hechos en el ciberespacio la primera dificultad por zanjar resulta la existencia —o no— de un lugar llamado "ciberespacio". De existir éste estaría fuera de la jurisdicción de país alguno, pero lo cierto es que, hablando informáticamente, los hechos se realizan físicamente en un determinado país, tienen sus consecuencias físicamente en otro determinado país, y muy probablemente sean procesados, informáticamente hablando, en un servidor que se encuentre en un tercer país, o un cuarto o quinto.

Es importante considerar que, pese a ser un ideal ampliamente desarrollado y un atractivo llamativo, la idea de la "existencia de una realidad virtual" o de "un lugar extraterritorial fuera del alcance de las reglas jurídicas" no es más que pura fantasía. Sostener eso es un vago intento de evadirse de toda normativa y, por ende, de cualquier posibilidad de convivencia social, en pro de una supuesta "libertad" que "debiera reinar en la red de redes". Por eso, es una prioridad, con una mirada realista, posibilitar la solución jurídica de los problemas que se planteen, determinar el problema de la jurisdicción y la ley aplicable al hecho informático que se suscite mediante la utilización de Internet, y con tintes de internacionalidad. Mientras la solución no sea adoptada en forma consensuada por los distintos países, ésta pasará por criterios tales como las posibilidades económicas de quien efectúe una eventual demanda, la importancia en cuanto volumen de la presencia de determinado país en Internet, o simplemente el juez que entienda previamente en la causa. Así, aparecen iniciativas legales como las leyes SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act), en las que el gobierno de los Estados Unidos se auto otorgó un poder de censura previa administrativa de páginas que pudieran violar derechos de autor. En tal sentido quien escribe no pone en duda los derechos de autor, que deben ser respetados como cualquier otro derecho patrimonial; sino que el procedimiento se muestra, a primera vista, como violatorio de otros derechos personales y con grandes posibilidades de terminar en la referida censura previa de contenidos. Aunque a la fecha de redacción del presente capítulo es un poco temprano para adelantar con precisión las consecuencias de esto, el tiempo y su aplicación indicarán la verdadera finalidad de su sanción.

Mientras no exista una solución legislativa a los problemas indicados es fundamental observar o tener en cuenta algunos recaudos en cuestiones internacionales:

- 1) En la órbita contractual se tornan de vital importancia las convenciones o cláusulas que contengan claramente la prórroga de jurisdicción o el sometimiento voluntario de las partes a determinada jurisdicción y ley aplicable. También son de especial importancia las cláusulas de sometimiento a solución de controversias por medios de arbitraje. En este aspecto van tomando cada vez mayor importancia las soluciones de controversias mediante el sistema ODR (Online Dispute Resolution), que viene a constituirse en una suerte de mediación virtual que ya ha contribuido a resolver innumerables conflictos. Existen numerosos sitios donde se puede acceder a estos sistemas, que poseen una mecánica muy particular y práctica de solución de conflictos.



Éste constituye también uno de los sistemas más usados en las compras a través de sitios de subastas en línea.

2) En la esfera delictual debe dejar de darse especial consideración a la territorialidad que posee como característica el derecho penal. Ésta es una de las grandes ventajas de las que han abusado los ciberdelincuentes que cometen delitos en países carentes de regulación penal específica y, de ser posible, que no cuentan con convenios de extradición con los países donde el delito será cometido. De esta forma, la impunidad es total por dos cuestiones: en primer lugar, al no contar con convenios de extradición, los jueces penales del lugar donde se comete un delito no pueden solicitar la captura y remisión del delincuente para ser juzgado; y en segundo lugar, como principio penal, si el delito cometido en un determinado país no es tal en el país donde se lleva a cabo físicamente, los delincuentes tampoco serán apresados. Como éstos conocen los convenios internacionales que regulan las cuestiones que pueden caer dentro del ámbito delictual y cuáles son los países signatarios, escogen el lugar más adecuado para quedar impunes frente a un eventual proceso.

Finalmente, existe la dificultad de compatibilizar sistemas jurídicos distintos, que pueden ser de origen continental o de *Common Law*.

En conclusión, esto no requiere que uno registre o "pierda su anonimato" en lo que realiza a través de la red, porque es cierto que esto puede generar una avalancha incontrolable de publicidad dirigida específicamente a la persona, lo que no sólo puede llegar a considerarse una violación a la intimidad, sino que seguramente será un método para eliminar la libertad de opción del ser humano por no poder escapar a la constante presión orientada precisamente a sus gustos propios. Pero, por otro lado, debe haber mayores elementos de control para acceder a sitios potencialmente peligrosos "jurídicamente hablando". Realmente el anonimato en una operación de compraventa *online* no puede existir. Lo que debe existir son graves sanciones si, por ejemplo, un sitio de subastas "pierde" o es "violado" en la seguridad del historial de compras de un usuario. O mejor aún, prohibir la existencia de dicho historial. Esto es sólo un ejemplo de posibles soluciones que merecen un trabajo dedicado y profundo para encontrar el modo que más se adapte a estos tiempos virtuales.

### **Capítulo 3. Responsabilidad civil. Parte general<sup>15</sup>**

#### **1. Persona.**

##### **1.1 Definición. Persona humana y jurídica**

Todo el derecho, todo el universo de hechos y actos que como consecuencia tengan efectos jurídicos, mantiene como centro a la persona. Inevitablemente el ser humano, al tener que relacionarse en su vida, desarrollará una red de vinculaciones con sus semejantes, y en su desarrollo generará, modificará o extinguirá los derechos que posee. Es por esta razón que corresponde analizar en primera instancia a qué o quiénes se considera en nuestro país personas.

Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación distingue entre dos tipos de personas: Persona Humana y Persona Jurídica. Ambos tendrán capacidad de actuar, obligarse y contratar, conforme la ley les otorgue dicha capacidad.

La persona humana no se define en el nuevo código, en cambio, a la persona jurídica se la indica como "...todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación." (artículo 141 del Código Civil y Comercial).

Según el artículo 19 y 20 del mismo cuerpo normativo, la persona humana comienza su existencia desde su concepción la cual consiste en "el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo". Desde aquel momento el ser humano "goza de aptitud para ser titular de derechos..." (art. 22 C.C.C.) los que quedarán irrevocablemente adquiridos si naciera con vida, sin importar el tiempo que viviese. Por el contrario, si nace sin vida, se considera que la persona nunca existió (Artículos 20 y 21 del Código Civil y Comercial).

Por su parte, las personas jurídicas son las que disponen los artículos 145, 146 y 148 del Código Civil y Comercial y las demás leyes regulatorias de la materia, como la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley de Cooperativas, etcétera.

Según el Código Civil y Comercial, las personas jurídicas pueden ser:

<sup>15</sup> La adecuación inicial a la normativa del nuevo código fue realizada por la Srta. Florencia Diana. La corrección final es de coautoría con el Dr. Lic. Javier A. Larroudé.

a) Las de carácter público: el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. Además considera de carácter público a los Estados extranjeros, organizaciones que el derecho internacional Público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona constituida en el extranjero, y la Iglesia Católica.

b) Las de carácter privado: las sociedades, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en disposiciones del Código o en otras leyes.

Finalmente, corresponde destacar que las personas humana, tanto en el origen como en su término, y en cuanto a su capacidad, tienen un tratamiento jurídico diferente de un país a otro. Lo mismo ocurre con las personas jurídicas.

## 1.2 Capacidad<sup>16</sup>

Durante su existencia, las personas humanas y jurídicas realizarán actos para los que la ley les exige ciertas facultades y les impone algunos límites. De la propia definición de persona surge la *capacidad*, que implica que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. A esta capacidad se la denomina *capacidad de derecho*, para contraponerla a la capacidad de *ejercicio*, que es tener facultad para *actuar*, es decir, para ejercer por sí mismo los derechos (contraer nuevos, modificar o extinguir los existentes). Por ejemplo, supongamos que hay un niño de ocho años al cual un tío rico le dona un departamento; como consecuencia de eso, el niño será, sin dudas, dueño de ese departamento (capacidad de derecho); pero no podrá por sí mismo alquilarlo mientras sea menor de edad. Para poder alquilarlo o, jurídicamente hablando, realizar un contrato de locación, debe suplir o subsanar su incapacidad de *ejercicio* a través de la participación de un tutor, que lo representará para poder hacer dicho *acto de administración* (alquilar la propiedad). En este caso son tutores naturales sus padres.

En principio y salvo algunas excepciones puntuales, la *capacidad de derecho* es la norma para las personas físicas y la incapacidad, la excepción.

---

15. Artículo 22. "Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hecho, simples actos, o actos jurídicos determinados".

Artículo 23. "Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en Sentencia Judicial".

En cuanto a la capacidad de ejercicio, se destaca lo normado en los artículos 24, 26, 100 y 101 del Código Civil y Comercial.

Los que tienen incapacidad absoluta de ejercicio y no pueden contratar por sí mismos son:

- 1°. Las personas por nacer.
- 2°. Los menores que no han cumplido los 18 años. El Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años, otorgando a estos ciertos derechos que no se detallaran por exceder los límites de la presente obra.
- 3°. La persona declarada incapaz por sentencia judicial.

Finalmente, como fue ejemplificado en párrafos anteriores, los incapaces de ejercicio pueden adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley.

Dichos representantes son:

- 1°. De las personas por nacer, sus padres.
- 2°. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres o el tutor que se les designe.
- 3°. De las personas con capacidad restringida, el curador que se les nombre.

Es importante conocer la capacidad que posee la contraparte en una contratación, por los efectos negativos que puede tener contratar con alguien incapaz. Así, estos efectos del contrato (sanción de nulidad) caerán siempre sobre la parte *capaz* y nunca sobre el incapaz, y pueden producirse graves consecuencias económicas según el objeto sobre el que recaiga el contrato, que deberá soportar quien posea capacidad al momento de contratar.

Para las personas jurídicas<sup>17</sup>, en cambio, la capacidad de derecho estará limitada solamente a realizar actos que estén contemplados en su objeto social, que se encuentra individualizado en su acta constitutiva. Las sociedades son administradas por uno de sus órganos, que estará compuesto por socios o no. Este órgano se denomina *de administración*. La sociedad

---

<sup>17</sup> Artículo 141 del Código Civil y Comercial: "Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación".

ejercerá sus actos sí o sí mediante la intervención de representantes con facultades suficientes que surgen de este órgano de administración.<sup>18</sup> Este tema se profundizará en los próximos capítulos.

### 1.2.1 Patrimonio

Desde su nacimiento toda persona posee un patrimonio. Éste se encuentra constituido por un conjunto de bienes (artículo 16 del C.C.C.: "Bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre").<sup>19</sup>

A esto, siguiendo a la doctrina, deben agregarse las *deudas* que gravan el patrimonio, ya que, en definitiva, al contratar a uno le interesa la solvencia real de la contraparte y no la aparente que surge del solo análisis de los *bienes y derechos* que ostente como titular.

Tanto las personas de existencia física como las de existencia ideal poseen un patrimonio. Así, las sociedades, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros, y ninguno de sus miembros (ni todos ellos) está obligado a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiese obligado como fiador, mancomunado con ella, surja de un imperativo legal o sea dictado por sentencia judicial.

Entonces, existiendo esta diferenciación de patrimonios, la sociedad poseerá un patrimonio y los socios, otro totalmente distinto. Los socios poseen derechos respecto de la sociedad pero no son dueños en forma directa de su patrimonio. El Código Civil y Comercial en su art. 143 indica: "Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial".

### 1.2.2 Derecho subjetivo y objetivo

---

<sup>18</sup> Artículo 160 del Código Civil y Comercial: "Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión".

<sup>19</sup> Artículo 15 del Código Civil y Comercial: "Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código". El artículo 154 indica: "Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables."

Dentro del derecho patrimonial podemos distinguir el *derecho de las cosas* y el *derecho de las obligaciones*.

El derecho de las cosas (derecho objetivo) trata las relaciones jurídicas en las que una facultad es ejercida en forma directa sobre la cosa; en cambio, el derecho de las obligaciones trata de relaciones jurídicas entre sujetos que comercian con bienes o derechos y/o se causan daños entre sí (derecho subjetivo).

### 1.3. Obligaciones

En este afán de relación que se indicó al comienzo del capítulo, las personas generan vínculos jurídicos entre sí, es decir, se generan obligaciones. Nuestro Código Civil y Comercial da una definición de obligación en el art. 724 que reza "La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés". Las prestaciones que constituyen "...el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor."

Las obligaciones son de tres clases de *dar*, *hacer* o *no hacer*. Las obligaciones de dar implican la entrega de una cosa material, las de hacer requieren la ejecución de un acto u obra, y las de no hacer exigen la abstención de realizar determinado acto o conjuntos de actos.

Las obligaciones tienen una causa que les da origen. Así el artículo 726 del Código Civil y Comercial indica: "No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico".

Resumiendo lo visto en el presente capítulo e intentando darle una orientación práctica podemos indicar que cuando uno contrata y como consecuencia genera obligaciones debe tener en cuenta todo lo contemplado hasta este momento, esto es:

1) Con quién contrata (sujetos, capacidad). ¿Es una persona hábil para efectuar el negocio jurídico pretendido? ¿Qué patrimonio tiene el que se obliga para responder ante eventuales incumplimientos?

2) ¿Qué se contrata? (¿Cuál es la prestación *objeto* de las obligaciones asumidas?) ¿Es legal? ¿Es posible? ¿La persona puede contratar sobre ese tipo de objeto?

3) ¿Qué hecho idóneo la genera? (Causa.)

Estos tres elementos que surgen del primer análisis no por casualidad son los elementos que se reconocen como *esenciales* de la obligación, por lo que, de faltar alguno de ellos, ésta sería inexistente. Estos tres elementos son los sujetos, el objeto y la causa.

La obligación, si es analizada, consta de dos partes principales: la *deuda* (*ese deber de cumplir que impulsa a pagar*) y la *garantía*.

La garantía es, en principio, el patrimonio del sujeto deudor.<sup>20</sup> Así, al tener en cuenta este patrimonio, un sujeto puede sentirse inseguro de contratar a determinada persona, pese a ser aparentemente conveniente, por cuanto el patrimonio con el que cuenta se muestra *insuficiente* para *responder* ante un eventual incumplimiento. ¿Qué tipo de solución se le encuentra al problema? Existe, por ejemplo, la posibilidad de *ampliar la garantía* mediante la obligación de otro sujeto como *fiador*; la constitución de una prenda o una hipoteca sobre algún bien del deudor (derechos reales de garantía), de un seguro de caución; o cualquier otra solución tendiente a dar seguridad al cumplimiento de la obligación o del contrato. De esta forma, se amplía la garantía de la obligación asegurándose su cumplimiento.

En cuanto al objeto de la obligación es una prestación de dar, hacer o no hacer. Debemos aclarar que no todas las cosas o hechos pueden ser objeto de las obligaciones y de los contratos. Deben ser "la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extra-patrimonial del acreedor. (art. 725 CCyCN)

### **1.3.1 Obligaciones solidarias y simplemente mancomunadas**

La relación que surge de la obligación (relación obligacional) no se enlaza necesariamente entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor puramente. Puede existir pluralidad en una parte, en la otra o en ambas. Además, esta pluralidad puede estar en el origen de la

---

<sup>20</sup>El patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Éste es un principio cuyo alcance significa que, en principio, todos los bienes del patrimonio del deudor responden por las deudas que él tenga. Así, en teoría, si el deudor incumple con su obligación, los acreedores podrán ejecutar sus bienes y cobrarse del producido de éstos. El Código Civil y Comercial consagra expresamente este principio del juego armónico de los artículos 730, inciso c), permite al acreedor obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes; y el artículo 743 que indica "Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia".

obligación o ser sobreviniente (es decir, ampliar la cantidad de sujetos luego del nacimiento de la obligación).

Cuando existe pluralidad de sujetos decimos que nos encontramos frente a una obligación *mancomunada*. Ésta puede ser: a) simplemente mancomunada o b) mancomunada solidariamente (artículo 825 y 827 del C.C.C.).

### **1.3.2 Simplemente mancomunada (artículos 825 y 826)**

En esta obligación cada deudor debe pagar su cuota-parte de la deuda y cada acreedor tiene derecho a reclamar sólo su cuota-parte del crédito. En la práctica esto funciona como si fueran distintas obligaciones que conviven en el mismo contrato o en el mismo soporte material.

### **1.3.3 Mancomunada solidariamente (artículos 827a 849)**

En estas obligaciones cada deudor debe pagar en forma íntegra la deuda o cualquiera de los acreedores está facultado para exigir y percibir íntegro el crédito (según sea solidaridad activa o pasiva).<sup>21</sup>

La elección del tipo de mancomunación puede deberse a una conveniencia de la relación (cuestión comercial, de facilidad de pago, etcétera) y tener origen en el contrato, pero también puede existir la mancomunación con origen legal.

### **1.3.4 Clasificación de las obligaciones**

Las obligaciones se clasifican según diversos criterios. Principalmente encontramos:

A) Una primera clasificación general se da según la naturaleza del vínculo que une a las partes. Así, las obligaciones podrían ser *civiles*, porque el derecho les confiere acción para exigir

---

<sup>21</sup> Hablamos de solidaridad activa cuando ésta se da del lado de los acreedores y pasiva cuando la solidaridad está del lado de los deudores.



su cumplimiento en juicio; o *naturales*, porque, sin ser ejecutables, lo dado en pago en razón de ellas no es repetible<sup>22</sup>.

B) Según el tiempo en que deba cumplirse la prestación objeto de la obligación se puede clasificar en *ejecución inmediata* o en *ejecución diferida en el tiempo*. También puede clasificarse en *ejecución única*, cuando el cumplimiento se realice una sola vez; y en *ejecución permanente*, cuando una ejecución pueda ser continuada en el tiempo (la ejecución es permanente, sin finalizar); o en *ejecución periódica*, o en *trato sucesivo*, donde el cumplimiento se va dando en forma escalonada, por lo general con vencimientos mensuales.

C) También podemos clasificar a las obligaciones según su modalidad, es decir, que se encuentran sujetas a alguna condición, plazo o cargo. Sujetar una obligación a una condición implica que la existencia de ésta dependerá de un hecho futuro e incierto (no se sabe si ocurrirá o no). En cambio, sujetarla a un plazo es supeditarla al acaecimiento de un hecho futuro y cierto (el hecho ocurrirá indefectiblemente, aunque exista incertidumbre en la fecha exacta en que ello pasará, por ejemplo, sujetar el cumplimiento de una obligación al día en que se muera alguien o a la próxima vez que llueva). Finalmente el cargo es una obligación accesorio y excepcional que se le impone al adquirente de un derecho.

D) Según la prestación que sea debida en las obligaciones podemos clasificarlas en positivas o negativas (según se deba a un obrar o una omisión de obrar), y según su naturaleza en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.

E) En cuanto al sujeto, las obligaciones pueden ser de sujetos simples o plurales. Las obligaciones con pluralidad de sujetos se llaman *mancomunadas*. En el caso en que se pacte o la ley disponga que cualquiera de los acreedores o de los deudores pueda exigir o deba cumplir con la totalidad de la deuda, dicha obligación será *mancomunada solidaria*.

F) Existe también una clasificación con relación a la interdependencia de varias obligaciones: las que tienen independencia de las demás se llaman *principales*; contrariamente, las que dependen de otra como razón de su existencia se llaman *accesorias* (artículo 856 del Código Civil y Comercial).

G) Finalmente, encontramos una clasificación que, por su importancia para los ingenieros y cualquier otro profesional, veremos en un párrafo aparte; tiene que ver con la índole del contenido. De este modo, las obligaciones se clasificarán en *de medios* o *de resultado*.

---

<sup>22</sup>Este concepto siguiendo el espíritu del art. 2538 del nuevo código ya que fue expresamente derogada la mención a las obligaciones naturales; aunque dicho artículo las mantiene vigente indicado que "El pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible."

### **1.3.5 Obligaciones de medios y de resultado**

Son obligaciones de medios aquellas en las que el deudor promete ejercer su actividad, la cual normalmente tiene como consecuencia determinado resultado, que es lo que desea obtener el acreedor, aunque el deudor no garantiza lograrlo.

En las obligaciones de resultado, en cambio, lo que el deudor promete es un objetivo, una consecuencia, un resultado o una obra determinada.

Por ejemplo, si tomamos un contrato de compra-venta, el vendedor se compromete a entregar la cosa y el comprador a entregar el precio pactado. Así, las obligaciones son de resultado. En cambio, si lo que se contrata es la actividad profesional, por ejemplo, un abogado frente a un litigio, éste no puede garantizar un resultado, pero sí que utilizará todos los medios legales para intentar obtener un resultado favorable a los intereses de su cliente.

“Es diferente la producción de un resultado de su eficacia: puede ocurrir que un deudor se comprometa a realizar una obra sin garantizar su eficacia, de modo que cumpla la obligación produciendo algún resultado, aunque éste sea deficiente: por ejemplo, si se obliga únicamente a realizar una excavación para extraer petróleo, cumple cuando el líquido comienza a surgir, aunque fluya en cantidad escasa.”<sup>23</sup>

### **1.3.6 Obligaciones del ingeniero**

El ingeniero, como profesional, puede realizar todas las tareas para las que la universidad lo preparó, que usualmente se encuentran reguladas por las normas correspondientes a determinado colegio profesional.

Así, por ejemplo, el ingeniero industrial debe matricularse en el CPII (Consejo Profesional de Ingeniería Industrial); en cambio, el ingeniero en electrónica o en informática debe matricularse y registrarse por las normas del COPITEC (Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación).

Si bien el registro y la matriculación del ingeniero constituyen un requisito mínimo y esencial para desarrollar la profesión, no es menos cierto que las obligaciones del ingeniero van a surgir con los diferentes contratos que acuerde en su vida profesional.

Estas contrataciones se registrarán por las normas generales del Código Civil y Comercial, en cuanto a lo atinente a la responsabilidad profesional, y en particular deberán atenderse a las

<sup>23</sup>Alterini, ob. cit., pág. 499.

normativas especiales que rijan cada materia, según la especialización del ingeniero y los parámetros específicos de su especialidad y saber. Toda especialización profesional tiene un *estado del arte* que indica los avances que deben respetarse en la forma de realizar las obras o los proyectos, y que los profesionales deben conocer y respetar. Ello exige una permanente actualización profesional que empieza en cuanto se obtiene el título habilitante y continúa durante toda la vida profesional.

El art. 1.768 establece los lineamientos de la responsabilidad profesional liberal disponiendo "La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1.757."

También es importante destacar que las responsabilidades siempre van más allá del propio contrato y se extienden a daños que en virtud de éste puedan sufrir terceros, ya sea por aplicación directa de la responsabilidad o por la aplicación de normas de protección al consumidor.

En un plano más amplio, existe también la responsabilidad por daño a los intereses difusos de los ciudadanos, como el daño ambiental que puede ocasionarse en el ejercicio de la profesión, al realizar alguna obra contaminante.

Visto el amplio abanico de responsabilidades, y para evitar caer en el miedo que a lo largo de los cursos varios alumnos manifestaron al conocer esta perspectiva de su futuro profesional, es ampliamente recomendable la contratación de seguros que cubran la posible responsabilidad civil y que mantengan su indemnidad frente a posibles errores, negligencias o imprudencias en que pudiera incurrir en el ejercicio de su profesión y de las que, en definitiva, nadie está exento.

### **1.3.7 Efectos de las obligaciones**

Los efectos de las obligaciones son las consecuencias que éstas poseen y se proyectan sobre el acreedor y deudor.

#### **1.3.7.1 Efectos principales**

Con relación al acreedor, la ley da una serie de dispositivos legales para satisfacer su interés. Con relación al deudor tiene efectos que se corresponden con su deber y derecho de

cumplir, como, por ejemplo, rechazar una acción de cobro de una obligación o contrato ya cumplido.

En cuanto a los efectos normales, éstos surgen del artículo 730, incisos a) y b) y 731, del Código Civil y Comercial. El primer inciso otorga al acreedor los medios legales para procurar la prestación debida. El segundo consiste en la facultad de hacer procurar por otro, a costa del deudor, el cumplimiento de la obligación.

Finalmente, encontramos en el artículo 730, inciso c) el *efecto anormal* de las obligaciones: habilitar al acreedor para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios sufridos por causa de su incumplimiento. Debemos destacar que las obligaciones nacen para ser cumplidas y que la indemnización de daños y perjuicios es un remedio extraordinario, razón por la cual se la denomina *efecto anormal*.

#### 1.3.7.2 Efectos auxiliares

Por su parte, los efectos auxiliares de las obligaciones buscan mantener el patrimonio del deudor sin alteraciones que lo tornen insuficiente para cubrir las consecuencias del incumplimiento.

Pueden clasificarse en dos tipos:

a) Medidas cautelares o precautorias, que pueden ser solicitadas por el acreedor en un proceso judicial, o incluso antes, y tienen por objeto garantizar que la sentencia a cumplirse pueda tornarse efectiva.

b) Acciones de integración y deslinde del patrimonio, que intentan restaurar un conjunto de bienes cuya solvencia fue reducida por actos simulados (acción de simulación) o fraudulentos (acción revocatoria), o por la inacción del acreedor (acción subrogatoria y directa); y la acción de deslinde, que busca que no se confundan dos patrimonios distintos en perjuicio de los acreedores o de uno de ellos.

#### 1.3.8 Extinción

Las obligaciones tienen una duración. Se entiende que tienen un origen o una fuente, y también un final. Existen muchos medios de extinción de las obligaciones. El Código Civil y Comercial establece de forma enunciativa (puede haber más que los allí nombrados) diversos medios de extinción, a saber:

- Por el pago (artículo 865 y ss.).
- Por la novación (artículos 933 a 941).
- Por la compensación (artículos 921 a 930).
- Por la transacción (artículos 1641 a 1648).
- Por la confusión (artículos 931 y 932).
- Por la renuncia de los derechos del acreedor (artículos 944 a 949).
- Por la remisión de la deuda (artículos 950 a 954).
- Por la imposibilidad del pago (artículos 955 y 956).
- Por dación en pago (artículo 942)

Es importante el tratamiento del tema de la extinción de las obligaciones, pues, junto con la resolución y rescisión del contrato, forma la vía de escape o finalización de la relación contractual/obligacional con la otra parte. Esto es un elemento esencial en la vida profesional de cualquier persona.

#### 1.3.8.1 Pago

El primer medio de extinción es el pago: "...es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación" (artículo 865 del C.C.C.). El cual implica un acto jurídico unilateral tendiente a extinguir situaciones o relaciones jurídicas.<sup>24</sup>

Los legitimados activamente para pagar son: el deudor, sus representantes, sus herederos (en caso de fallecimiento) y los terceros interesados.

En caso de que exista solidaridad pasiva en la obligación que se pretende cancelar, cualquiera de los deudores puede solventar la deuda; nace luego una acción de repetición entre los codeudores en las proporciones en que se habían obligado originariamente.

Quien paga debe tener capacidad de hecho para dicho acto. En los casos de pago por un tercero interesado, éste debe ser una persona que no siendo el deudor sufra un perjuicio jurídicamente protegible en caso de incumplimiento. El pago lo puede realizar cualquiera de los sujetos mencionados, aun en contra de la voluntad del acreedor (artículo 881 del C.C.C.), salvo que éste tenga un interés legítimo en que la obligación sea cumplida por el propio deudor.

---

<sup>24</sup> Artículo 259 del Código Civil y Comercial: "El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas".

Realizado el pago, satisfecho "el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera" (artículo 880 C.C.C.).

El tercero no interesado puede pagar, pero no puede obligar al acreedor a recibir su pago por carecer de *iussolvendi*, es decir que se requiere la conformidad del acreedor para que dicho pago sea efectivo. En caso de pago hecho por un tercero, el deudor queda desobligado de la deuda original, pero se abren distintos supuestos, ya que el deudor continúa obligado hacia quien realizó el pago (*solvens*). Estos supuestos son los normados por los artículos 881 y 882 del C.C.C.

Quien recibe el pago (*accipiens*) debe ser: el acreedor, sus herederos y los representantes. Dichos sujetos deben tener capacidad de hecho con relación a la administración de sus bienes.

El objeto del pago debe ser idéntico a lo que el deudor se obligó. Así, el artículo 868 del Código Civil y Comercial indica: "El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor". Lo mismo ocurre con las obligaciones de hacer, tácitamente incluido en el mismo artículo del cuerpo legal.

El pago también debe ser íntegro, salvo que la obligación permita que sea parcial; en caso contrario el acreedor puede rechazar el pago parcial (artículo 869 del C.C.C.).

Finalmente, el pago debe realizarse en las circunstancias de tiempo y lugar pactadas.

Para acreditar que el pago fue efectuado el deudor necesita contar con el recibo otorgado por el acreedor, en el que deben constar:

- a) La firma del acreedor o persona autorizada a percibir el pago.
- b) La imputación del pago efectuado a la deuda particular.
- c) Las cláusulas o recibos especiales por los cuales se cancele parte o la totalidad de la deuda.
- d) Fecha y lugar de efectuado.

#### **1.3.8.1.1 Recibo de capital**

"Se presume, excepto prueba en contrario que: a) Si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado..." (Artículo 899 del Código Civil y Comercial).

Ha de tenerse en cuenta que "el pago puede ser probado por cualquier medio" (Artículo 895 C.C.C.) excepto que se determine lo contrario.

### 1.3.8.1.2 Pago por consignación

El deudor tiene la obligación de cancelar la deuda pagando en tiempo y forma indicados precedentemente. Pero también tiene el derecho de obtener su liberación de la deuda realizando un pago por consignación.

La consignación procede en tres supuestos enunciados en el artículo 904 del C.C.C:

- a) Que el acreedor fue constituido en mora.<sup>25</sup>
- b) Que existe incertidumbre sobre la persona del acreedor.
- c) Que el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable.

Esto no agota las posibilidades de proceder a un pago por consignación, dado que "...el pago con intervención judicial también es posible en otros supuestos, como cuando existe controversia acerca del crédito entre deudor y acreedor, o cuando el domicilio del acreedor es incierto o de acceso riesgoso, etcétera".<sup>26</sup>

### 1.3.8.2 Por la novación

Dalmacio Vélez Sarsfield define, en el Código Civil, que la novación "es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla" (artículo 933). Para que este medio funcione se requiere un *animus novandi*. Los elementos esenciales de una obligación son: los sujetos, el objeto y la causa. En la novación, la causa de la nueva obligación es la extinción de la anterior. Así, la novación podrá ser subjetiva u objetiva, según lo que cambie (uno u otro de los restantes elementos).

Los efectos de la novación son extinguir "...la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva; en tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación sólo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio" (artículo 940 del C.C.C.). Los accesorios de la obligación se extinguen salvo reserva. En el supuesto de que las garantías sean brindadas por un tercero, es requisito que éste vuelva a prestar su consentimiento; en caso contrario quedaría desobligado con la extinción de la obligación primigenia.

---

<sup>25</sup> "Retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber".

<sup>26</sup> Alterini, ob. cit., pág. 384. Teniendo en cuenta que esta edición trata el régimen del Código Civil derogado.

Dados los efectos cancelatorios de la novación, es necesario que surja en forma expresa e indubitada del documento que se redacte. Así indica el codificador: "La voluntad de novar es requisito esencial de la novación. En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción" (artículo 934 del Código Civil y Comercial).

#### 1.3.8.3 Por la compensación

El artículo 921 del Código Civil y Comercial enseña: "La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables".

La compensación exige la existencia de dos sujetos que revisten las calidades de acreedor y deudor recíprocamente de prestaciones de dar. Asimismo, implica la existencia de dos obligaciones cuyos objetos sean fungibles recíprocamente. No son compensables cosas que, aunque fungibles, no sean de la misma naturaleza, por ejemplo, no puedo compensar una deuda de una tonelada de maíz con una tonelada de trigo, aunque el valor comercial de ambas sea idéntico (artículo 923 del C.C.C.).

Finalmente, la compensación exige que ambas deudas sean líquidas y de plazo vencido o exigibles. Con liquidez nos referimos a que la deuda esté determinada en su monto o en su consistencia; y con exigibilidad indicamos que el acreedor debe tener posibilidad inmediata de ejecutar la deuda (es decir que ésta no esté supeditada a un plazo, al cumplimiento de alguna condición o que no sea natural).

#### 1.3.8.4 Por la transacción

La transacción es un contrato, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, con el objetivo de evitar un litigio, o ponerle fin al mismo.

Para que ocurra esto se deben dar dos supuestos: en primer lugar, que las partes se hagan concesiones recíprocas, es decir que cada uno sacrifique en alguna medida sus pretensiones o sus derechos; y, en segundo lugar, que las partes tengan voluntad de extinguir las obligaciones litigiosas.



Es un acto jurídico bilateral por el cual las partes extinguen las mencionadas obligaciones litigiosas en el momento en que se crea una nueva obligación fruto del acuerdo transaccional.

#### **1.3.8.5 Por la confusión**

El Código Civil y Comercial, en su artículo 931, prevé: "La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio".

La obligación queda extinguida total o parcialmente "en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión" (Artículo 932 C.C.C.).

#### **1.3.8.6 Por la renuncia de los derechos del acreedor**

Se da la renuncia cuando el acreedor abdica de algún derecho subjetivo que tiene en su interés particular. Para ello se exige la capacidad de dar y recibir gratuitamente o de contratar, según resulte renuncia onerosa o gratuita.

#### **1.3.8.7 Por la remisión de la deuda**

La remisión de la deuda es para muchos doctrinarios una especie de renuncia a los derechos del acreedor. Esta remisión se da cuando el acreedor se considera pagado ficticiamente, entregando el título que acredita la obligación que pudiera haber exigido. De esta forma, eliminando el título de la deuda, se tornaría imposible el cobro por parte del acreedor.

#### **1.3.8.8 Por la imposibilidad del pago**

El artículo 955 del Código Civil y Comercial dispone: "La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad...".

En cambio, "...si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados".

De la redacción del citado artículo se infiere la íntima relación que tiene la imposibilidad de pago con el caso fortuito o la fuerza mayor. Esto exige la existencia de la buena fe por parte del deudor y no encontrarse en mora. Como es de aplicación lo indicado del caso fortuito, tampoco debe existir la asunción de éste o la obligación legal que imputa al deudor las responsabilidades derivadas de aquél.

#### 1.3.8.9 Dación en Pago

Consiste en la extinción de la obligación por medio de la aceptación voluntaria por parte del acreedor el pago de una prestación diversa a la adeudada (Artículo 942 C.C.C.).

### 2. Responsabilidad civil.

Hablar de obligaciones y contratos implicaba, hasta la sanción del nuevo código, tratar el tema de la *responsabilidad* con la pregunta única de ¿Quién debe *responder*?. Se responde a un cuestionamiento previo: ¿quién debe cumplir la obligación preexistente contractual o indemnizar su incumplimiento? ¿O quién indemnizará a un determinado sujeto por los daños que sufrió?. Actualmente, el nuevo Código agrega dos funciones más a la responsabilidad civil, la preventiva y la punitiva.

Así queda establecido un sistema mediante el cual se reconocen tres funciones: preventiva, punitiva y resarcitoria.

#### 1º. Función preventiva

En el artículo 1.710 del C.C.C. consagra el "deber de prevención del daño", el objetivo es evitar que se produzca un daño o en caso de que haya uno, "disminuir su magnitud o no agravarlo".

Se consagra el deber de prevención para toda persona con los siguientes alcances: "toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) Evitar causar un daño no justificado; b) Adoptar buena fe (...); c) No agravar el daño, si ya se produjo" (Art.1.710 C.C.C.)."

Por otro lado, quien interponga la acción judicial, debe acreditar interés razonable en la prevención del derecho que se considera amenazado. Para poder iniciarla deben cumplirse determinados presupuestos:

- a) Autoría: “puede consistir en un hecho o una omisión de quien tiene a su cargo un deber de prevención del daño”.<sup>27</sup>
- b) Antijuridicidad: violación al deber de prevención
- c) Causalidad: la amenaza de que se provoque un daño debe poder ser previsible.

## 2°. Función Punitiva

La función punitiva implica sanciones pecuniarias (es decir, valuadas en dinero), para los casos que se provoque un daño.

Con respecto a la función punitiva, el cuerpo legal en su artículo 1.714 le otorga facultad al juez para que en caso de que “la aplicación de las condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva”, este debe “computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto”.

Se deja en mano del juez la valuación económica de las indemnizaciones por los daños provocados.

## 3°. Función Resarcitoria

El Código regula la denominada función resarcitoria, la cual consiste en la reparación del daño generado por la violación del deber de “no dañar” o el incumplimiento de una obligación.

Al igual que la función preventiva, la resarcitoria tiene sus presupuestos:

a) Antijuridicidad: Significa que la acción u omisión dañosa es contraria a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen excepciones:

- Ejercicio regular de un derecho
- Legítima defensa propia o de terceros la cual provoca daños a un tercero que no fue el agresor ilegítimo.<sup>28</sup>
- Caso fortuito o fuerza mayor.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Código Civil y Comercial. Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN. Eduardo, A. Zannoni- Marina, Mariani de Vidal, Jorge O. Zunino; Fernando E. Shina; Gloria S. Ramos.- Ed. Astrea, Abril 2015, pag. 461.-

<sup>28</sup> La legítima defensa es válida cuando se utiliza frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no debe haber sido provocada. En caso de que provoque daños a un tercero que no es el agresor ilegítimo, este tiene derecho a obtener reparación plena (Artículo 1.718 inc. b) C.C.C.)

<sup>29</sup> En estos casos se provoca un daño menor, inevitable, para evitar un daño mayor. Sin embargo, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida que el juez considere equitativo, es decir, que no necesariamente va a obtener una reparación plena del daño provocado (Artículo 1.718 inc. c) C.C.C.)

- Asunción de riesgos, de quien se expone a una situación de peligro para salvar la persona o bienes de otro.<sup>30</sup>
- Consentimiento libre e informado del damnificado, el cual libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles (salvo que se determine que fue una cláusula abusiva).

b) Factor de Atribución: A diferencia de la función preventiva, la función resarcitoria tiene como presupuesto al denominado factor de atribución. Implica dos tipos de imputación al provocador del daño: *Objetiva* y *Subjetiva*.

En la imputación *objetiva*, la única forma de eximirse de la responsabilidad es cortando el nexo causal; es decir, demostrando la existencia de alguna de las excepciones del punto anterior. Por ejemplo, si el deudor se compromete con una obligación de resultado (es decir, que promete cumplir con un objetivo, por ejemplo cirugía estética) y este cumple no importa la intención, importa que el resultado prometido no se cumplió.

En cambio, para eximirse de la imputación *subjetiva*, estos son la *culpa* y el *dolo*. En estos casos debe probarse la falta de culpa.

La *culpa* según el artículo 1.724 del Código Civil y Comercial: “consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión.”

La definición de *dolo* se encuentra inmiscuida en el mismo artículo determinando que se “configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos”.

Como queda expuesto, la diferencia entre los factores de atribución subjetivos es la *intención de generar el daño*. Si bien en ambos casos corresponde la reparación, este factor es el que puede generar una variación considerable en la cuantía de la indemnización. Es decir, la extensión de la responsabilidad.

c) Previsibilidad contractual: Otro factor a tener en cuenta dentro de la valoración de la conducta es que “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno

<sup>30</sup>Artículo 1.719 C.C.C.: “La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal.

Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro, o por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la medida del enriquecimiento por él obtenido”.

conocimiento de las cosas mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y condiciones particulares de las partes.

Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o facultad intelectual de una persona determinada a no ser en los contratos que se suponen la confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente" (artículo 1.725 C.C.C.).

Ha de tenerse en cuenta que es aplicable sólo a los contratos, con el objetivo de que las partes al momento de la negociación y fijación del precio estén al tanto de los riesgos que asumen. Las excepciones a la regla son la existencia de dolo por parte del deudor, o bien que el contrato sea de *consumo*. (Ver capítulo 4 punto 3.1).

d) Relación de causalidad: Busca analizar la causa eficiente del daño. De esta forma se podrá determinar quién es el autor material del hecho. También sirve para fijar la relación de los daños con el hecho que lo haya causado, para poder imputar al autor. Para lograr eso se realiza un análisis del tipo causa-efecto, descartando los hechos que son meramente posteriores en el tiempo, pero que no guardan relación con el daño. Así se posibilita determinar la existencia de condiciones que permiten o agravan las consecuencias dañosas del hecho antijurídico, llamadas concausas. Estas concausas imputables al sujeto pasivo del daño pueden responsabilizarlo por parte de éste y disminuir la sanción de reparación para con el sujeto activo del hecho dañoso. Por ejemplo, encaso de un accidente de tránsito, si la persona embestida no lleva cinturón de seguridad (lo que constituye su obligación) y, en consecuencia, los eventos dañosos se agravan, puede verse reducida en gran parte la indemnización a percibir en virtud de su inacción y su culpa concurrente.

Ha de tenerse en cuenta, que el fundamento de la reparación consiste, nuevamente, en que la persona debe ser responsable (responder) por los hechos propios que generen daño; o los hechos de terceros por los que se deba responder (por ejemplo, dependientes o hijos) y los daños causados por las cosas riesgosas o viciosas de las que la persona se sirve (por ejemplo, el automóvil). Esta responsabilidad intenta dejar indemne al perjudicado o *volver las cosas al estado anterior al evento dañoso*. Esto no siempre es posible, motivo por el cual muchos daños irreparables se terminan compensando en dinero.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Artículo 1.740 del Código Civil y Comercial: "Consiste en la restitución de a situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en

### 2.1 Incumplimiento inimputable

Cuando el incumplimiento derive de lo que se denomina un *caso fortuito* o una *fuerza mayor* se elimina la imputabilidad del deudor, por lo que no se deberá responder o se lo hará parcialmente, según el hecho acaecido. Nuestro código, en su artículo 1.730, indica: "Caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado".

Para que se configure el caso fortuito es necesario que éste posea las siguientes características:

a) Imprevisibilidad: Al momento de ocurrir el evento dañoso o al momento de efectuar la contratación, el hecho es imprevisible, ya que no existen razones para suponer su acaecimiento.

b) Sea irresistible o inevitable: Se refiere a que reviste la circunstancia de ser inevitable o de una fuerza tal que sea irresistible. Por ejemplo, los *tsunamis* en Asia son un claro ejemplo de un caso fortuito que, aunque previsible, es inevitable por su fuerza.

c) Que no surja o dependa del accionar del deudor.

La imposibilidad de cumplimiento es tanto física como jurídica, ya que podrían ser las circunstancias de derecho las que lo impidieran.

También se puede clasificar la imposibilidad sobreviniente del caso fortuito en *absoluta* o *relativa* y *total* o *parcial*.

Es absoluta, cuando cualquier persona, no sólo el deudor, se vería imposibilitada de cumplir.

Es relativa cuando la imposibilidad resulta de una particularidad que afecta personalmente al deudor.

Es total, cuando el cumplimiento es imposible.

Es parcial cuando aún se puede cumplir parte de la obligación.

En cuanto al tiempo, puede ser definitivo o temporario; esto último habilitaría al deudor a cumplir luego de cesadas las causas que generan la imposibilidad.

Los efectos del caso fortuito son liberar al deudor de la responsabilidad por incumplimiento. Así, el artículo 1.730 del mismo cuerpo normativo dice: "...El caso fortuito o de fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario..."

Esto tiene cuatro excepciones:

- a) Cuando el deudor asumió las consecuencias de un eventual caso fortuito en el contrato, mediante lo que se denomina pacto de garantía o cláusula de responsabilidad.
- b) Cuando el caso fortuito fue provocado por el mismo deudor.
- c) Cuando el caso fortuito sea posterior a la constitución en mora<sup>32</sup> del deudor.
- d) Cuando la misma ley no reconoce la facultad del deudor para invocar el caso fortuito como eximente de responsabilidad.

## 2.2 Daño. Daños resarcibles

El daño es el cuarto elemento que integra la función resarcitorio. El Código Civil y Comercial en su artículo 1.737 define la existencia de *daño*: "cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.

La *indemnización* a abonar en virtud de una sentencia dictada en un juicio no es la reparación del daño causado; sino la sustitución del mismo por una suma de dinero equivalente. Existen indemnizaciones *tarifadas* como, si nos refiriéramos a la indemnización por despido laboral, o ésta surge del análisis de las probanzas acompañadas en el expediente.

Este daño, como ya hemos visto, puede provenir del incumplimiento contractual o de la violación de la obligación general de no dañar.

Esta indemnización posee tres caracteres:

---

<sup>32</sup>Para que el incumplimiento imputable al deudor dé origen a la obligación de indemnizar, el deudor debe estar constituido en mora. Esto es un estado en que el incumplimiento se torna jurídicamente relevante. En los supuestos del código se requiere interpellar al deudor al pago para constituirlo en mora; esto debe realizarse por medio privado fehaciente o en forma judicial. Así, el instituto se vuelve operante. El texto del artículo 886 del Código Civil y Comercial es el siguiente: "La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el art.867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo". La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones sujetas a plazo tácito, y sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho (artículo 887 C.C.C.).

- En primer lugar, es patrimonial y consistirá en dar una suma de dinero, en entregar una cosa o hacer una reparación en especie.
- En segundo lugar, es subsidiaria en el ámbito *contractual*, por cuanto siempre puede el acreedor exigir el cumplimiento contractual en lugar de solicitar la indemnización por equivalente.
- Finalmente, es resarcitoria porque buscar la reparación no es punitorio, dado que no tiene por efecto sancionar el incumplimiento.

La cuantía de la indemnización va a tener directa vinculación con el daño causado, por lo que es importante entender su definición. Daño es cualquier menoscabo sufrido por la persona en sí misma o en sus derechos. Por supuesto que no todo daño va a ser indemnizable, puesto que el daño ocurrido no es igual al daño jurídico.

Se deben cumplir determinados requisitos para que el daño sea indemnizable, a saber:

- a) Daño cierto: el daño debe ser probable en forma objetiva en su existencia. El daño hipotético incierto o de mera conjetura no puede, en principio, ser indemnizado.
- b) Daño actual o futuro: el daño debe ser cierto, pero puede no ser actual y solamente ser futuro; no obstante ocurrirá sin lugar a dudas. No importa el tiempo que deba esperarse, pues la consecuencia lógica del hecho dañoso lo generará necesariamente. Sin perjuicio de esta aseveración, jurisprudencialmente se ha receptado la indemnización de la pérdida de chance. Esta indemnización no podrá ser equivalente al fruto posible perdido, sino al porcentaje que ocurre de la pérdida.
- c) Daño subsistente: el daño debe subsistir al momento de dictar sentencia. Esto es, que el propio tiempo no lo haya subsanado. Sin perjuicio de ello, el daño subsiste hasta que no lo repare quien es responsable de haberlo causado. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de tránsito y repara su vehículo averiado, el daño es subsistente en el dinero invertido para la reparación, hasta que quien causó el accidente lo abone. Lo mismo ocurre si quien abonó el arreglo es el seguro, lo que le da derecho a reclamar lo invertido a quien causó el daño.
- d) Daño propio (perjuicio directo): el daño lo debe haber sufrido personalmente quien solicita la reparación. Esto no implica que no se aplique a los efectos de la demanda lo visto en cuanto a la representación de las personas.

### 2.3 Extensión de la responsabilidad.

El daño debe ser probado en su existencia (incumbe a quien lo reclama). Si bien también se debe (o es conveniente) probar su cuantía para facilitar la labor judicial, los códigos procesales



de la Nación y las distintas provincias, por lo general, indican que la sentencia debe fijar el importe de los créditos por los daños y perjuicios reclamados y comprobados, pese a que no se demuestre la cuantía de éstos.

Para la evaluación del daño existen distintos métodos que es bueno conocer para un mejor manejo de las contingencias legales que en un futuro le pudieran ocurrir al ingeniero en su vida, tanto personal como profesional.

Así, el daño podrá ser valuado:

a) Legal o por la ley: cuando las indemnizaciones son tarifadas, como las ya citadas del derecho laboral.

b) Convencionalmente: por el método de la transacción, que ya hemos visto en el punto de extinción de las obligaciones tratado más arriba. Este método es de vital importancia a los fines de lograr valorar el daño.

c) Judicialmente: es precisamente el método que implica el dictado de la sentencia definitiva frente al conflicto.

d) Arbitralmente: los códigos procesales contemplan siempre la posibilidad de someter las controversias al proceso arbitral. Esto puede ser de gran utilidad en casos muy especiales o controvertidos que requieran un conocimiento técnico para su entendimiento: someterlos al área de un juez que ignore la materia (técnica, no legal), para cuya sentencia se basará en un dictamen pericial de un profesional del saber técnico que corresponda (pero que no necesariamente será un especialista en el tema puntual a tratar), puede dar resultados imprecisos para ambas partes. Frente a estos supuestos puede ser bueno y útil someter el diferendo a un proceso arbitral de un especialista, cuya conclusión será mediante un *laudo* que podrá ejecutarse por vía judicial como una sentencia.

### **2.3.1 La reparación no patrimonial**

Hemos visto que lo que se busca como principio general es la reparación plena (económicamente hablando) del daño causado (Artículo 1.740 C.C.C.), sin embargo, en este punto debemos tener en cuenta que el Código Civil y Comercial prevé además, la indemnización por las consecuencias no patrimoniales las cuales le corresponde al damnificado directo el reclamo de la indemnización. A este se suman los ascendientes, descendientes y el cónyuge en caso de que del hecho resulte la muerte o sufra de una gran discapacidad el primero (Artículo 1.741 C.C.C.).

### **2.3.2 Atenuación de la responsabilidad**

Seguidamente, el artículo 1.742 prescribe: "El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable".

El juez tiene la facultad de ordenar una indemnización que sea adecuada a las posibilidades de cumplimiento que tenga el deudor, ya que de lo contrario, si el monto de la indemnización es muy alto y este no puede cumplirlo, podría considerarse un menoscabo irrazonable al autor del hecho en los casos de haber sido con culpa. No están incluidos los casos de dolo por parte del responsable.

### **2.3.3 Dispensa anticipada de la responsabilidad.**

Dispone el art. 1.743 que "Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder."

Nuevamente existe la posibilidad de acotar el margen de la responsabilidad personal con las excepciones que indica el citado artículo. Esto permite que ante negociaciones contractuales donde el objeto sea complicado de cumplir puedan pactarse formas de limitar la responsabilidad y, en definitiva, lograr contratar sobre este tipo de objetos dificultosos.

### **2.4 Distinción de la responsabilidad civil y la penal**

Cabe diferenciar la responsabilidad civil de la penal, precisamente por su aspecto de finalidad. La responsabilidad penal busca reprender el hecho delictivo y no guarda proporción entre el daño causado y la cuantía. No existe una equivalencia entre el daño inferido al autor y la infracción medida en términos económicos.

Así, los elementos de la responsabilidad penal serán la tipicidad del acto, la antijuridicidad y la culpabilidad, dejando de lado el daño causado. Más aún, en el derecho penal existen los tipos penales que son sancionados como delitos (acciones de *peligro*), sin que sea necesaria la consecución de un daño real.

## Capítulo 4. Responsabilidad. Parte especial

### 1. Responsabilidad y TIC. Tipos de responsabilidad en Internet: diversos sujetos involucrados. Su responsabilidad

La intromisión de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, y más específicamente la Internet actual o la web 2.0, hace surgir diversas vinculaciones y grados de responsabilidad antes daños ocasionados con la informática. Debe notarse que es común la frase *libertad de expresión*, que pretende universalizarse para la red de redes, pero no puede olvidarse que el efecto viral de cualquier elemento subido a la web hace que los daños a una persona sean ilimitados e incalculables.

No es lo mismo publicar una difamación en un diario y otorgar en el mismo medio, luego, un derecho a réplica, que subir una foto inoportuna a la Internet, de donde, es muy probable, jamás pueda ser eliminada.

En primer lugar, entonces, corresponde analizar quiénes son los sujetos que pueden llegar a tener legitimación activa o pasiva en la Internet (demandar o ser demandados por su accionar). Así, encontramos a los usuarios, los buscadores de contenidos, los proveedores de contenido, los proveedores de alojamiento y los ISP o proveedores de acceso.

Cada sujeto de los mencionados tiene o puede tener una responsabilidad diferente frente a diversos daños ocasionados en el mismo hecho.

No es éste el lugar para realizar una disquisición sobre si es oportuno, posible o deseable regular o controlar la Internet, aplicar tecnologías de filtrado, de autenticación o identificación. Existen numerosos proyectos legislativos y leyes aprobadas internacionalmente, como las conocidas leyes del gobierno de los Estados Unidos de América, Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect IP Act (PIPA), que han merecido gran cantidad de análisis, repudios y aplausos, siendo fácilmente hallables en la web. Nos limitaremos a esbozar las diversas teorías de responsabilidad que surgen de los actores indicados, en forma somera.

Desde el punto de vista legislativo, la Argentina cuenta con dos leyes que tratan la regulación de la Internet: la ley 26.032, que busca incluir la búsqueda y difusión de información en la red en la garantía constitucional de libertad de expresión, y la ley 25.690, que obliga a los ISP a ofrecer a sus usuarios programas para filtrar contenido no deseado de la web.

En virtud de estas leyes, los buscadores y proveedores de contenidos tienen su actividad garantizada por la Constitución. En efecto, la mayoría de los fallos de la CNCiv.y Com. Federal contra Google Inc. y Yahoo de Argentina S.R.L. destacan que por la citada ley la actividad es lícita. En tal sentido, quien alega un perjuicio debe probar el contenido dañoso y luego el perjuicio.

Algunos autores consideran la actividad en la Internet como riesgosa; otros estiman que es un accionar personal. Como consecuencia de posicionarse en un criterio u otro, las soluciones jurídicas varían enormemente. Asimismo, en algunas situaciones los criterios pueden ser mixtos.

De manera que, si se produce un daño por un contenido publicado en la web, las responsabilidades varían. Las soluciones propuestas por la doctrina y la jurisprudencia son:

a) Si se identifica al autor del contenido, la responsabilidad es personal por el artículo 1716 y 1.724 del Código Civil y Comercial.

b) Si el autor es anónimo, surgen preguntas sobre la responsabilidad de los ISP. En un primer momento, con las antiguas BBS, los ISP eran al mismo tiempo proveedores de contenidos; pero en la actualidad se los considera meros intermediarios que proveen acceso. Caso contrario, sería como responsabilizar al puestero de diarios por lo que fuera publicado en ellos.

c) Si los ISP realizan o mantienen sitios bajo la administración, al igual que el proveedor *dehosting*, pueden ser considerados con las responsabilidades de un editor. Así lo entiende el fallo conocido como "Jujuy Digital", en el que se condenó al titular de la página web por los contenidos publicados en virtud de la responsabilidad objetiva y con la equiparación con el editor mencionada. Ello en virtud de no haber actuado pertinentemente, evitando la difusión del contenido dañoso alojado en el sitio, en omisión de las mismas políticas de uso que se habían establecido. Así, podemos ver que se los condena por la omisión (culpa) y el riesgo inherente del sitio (responsabilidad objetiva), es decir, una solución con criterio mixto.

d) Finalmente la responsabilidad de los buscadores, tema de actualidad, se ha basado en los pocos precedentes jurisprudenciales de nuestro país en afectaciones del honor con medidas cautelares, solicitando el cese de la publicación de determinados resultados en las búsquedas.

De esta manera, si consideramos que la actividad del buscador responde con una responsabilidad objetiva, bastaría con iniciar la demanda por la afectación sufrida en los derechos. Si, en cambio, consideramos el criterio de una responsabilidad subjetiva, debería intimarse previamente al buscador a eliminar el contenido debidamente identificado, antes de reclamar judicialmente su supresión.

A la misma solución se llega frente a las redes sociales y *blogs* con contenidos inadecuados que causen un perjuicio.

## **2. Régimen de banco de datos: Derecho a la intimidad. Hábeas data. Ley 25.326 y su decreto reglamentario 1.558/2001, Ley de Protección de Datos Personales.**

Cuando se pretende estudiar el régimen de los bancos de datos debe hacerse referencia al derecho constitucional de hábeas data. Este instituto y la regulación de los bancos de datos guardan, como punto común, el derecho a la privacidad y la intimidad.

Para poder conocer qué datos personales tiene un banco de datos público o privado, especialmente para conocer la exactitud y actualización de aquéllos, la reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho constitucional de hábeas data.

Hasta la sanción de la ley 25.326, de protección de datos personales y hábeas data,<sup>33</sup> el 4 de octubre de 2000, que fue promulgada el 30 del mismo mes, no existían más que fallos aislados estableciendo un criterio de protección, como permitir el conocimiento de los datos registrados ante una afectación de la esfera íntima de la persona, datos sensibles, datos laborales, políticos, religiosos o de salud, entre otros, en consonancia con la manda constitucional.

### **2.1 Derecho a la intimidad**

Definir el derecho a la intimidad no resulta sencillo. Para el derecho argentino es menester observar la jurisprudencia de la CSJN, que en autos "Estado Nacional - Dirección General Impositiva (DGI) c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal", de fecha 13/2/1996,<sup>34</sup> indicó que la protección que otorga el derecho a la intimidad se da sobre "un ámbito

<sup>33</sup>El artículo 1º de la ley 25.326 dice: "La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

"Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

"En ningún caso se podrán afectar las bases de datos ni las fuentes de información periodísticas".

<sup>34</sup> Puede ser consultado en el repertorio, *La Ley*, 1996-B, 35.

de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad".

La potencialidad de la aplicación de este concepto, en virtud del avance de las tecnologías, obligó, con la sanción de la ley, a tratar de regular la creciente cantidad de información que se encuentra, por ejemplo, en bancos profesionales legales, contables y de salud, en hospitales, empleos, etcétera.

Esta potencialidad, detectada por los constituyentes de 1994, hizo que se plasmara la protección legal, en el mencionado artículo 43 de la Constitución Nacional,<sup>35</sup> como derecho de "tercera generación".

La ley 25.326, en el texto de su artículo primero, receptó esta situación y pretendió plasmar una mecánica protectoria que fue sufriendo diversas modificaciones y agregados.

Existe, a nivel internacional, gran cantidad de Constituciones que receptan este derecho, así como también normas y directrices al respecto de la protección de datos personales, que exceden los límites de la presente obra. Mientras el obrar del profesional se limite al accionar dentro del ámbito argentino, basta con la mención aquí realizada y el estudio de la legislación de

---

<sup>35</sup>El texto del artículo 43 dice: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

"Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

"Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio".

nuestro país; pero, vista la posible transnacionalidad de las conductas informáticas, se deberá contemplar el estudio de la reglamentación en los posibles países donde se registre o mantenga una base de datos.

Específicamente la ley argentina prevé que los datos deben ser obtenidos de forma lícita, ser de calidad, obtenidos con consentimiento e información de la persona, ser actuales y posibilitar el acceso, rectificación y supresión de éstos en caso de que sean necesarios.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Los textos de los artículos 4°, 5° y 6° de la ley 25.326 dicen:

“Artículo 4°. Calidad de los datos.

“1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.

“2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.

“3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

“4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.

“5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.

“6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.

“7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.”

“Artículo 5°. Consentimiento.

“1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

“El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 6° de la presente ley.

“2. No será necesario el consentimiento cuando:

“a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;

“b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal;

“c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;

La ley incluye a los bancos de datos públicos y privados. Con respecto a los privados, en un primer momento se discutió a qué tipo de banco de datos se refería, ya que, con la tecnología, cualquier teléfono celular personal podría caer en la categoría de banco de datos. La solución la reguló el artículo 1º del decreto 1.558, de 2001, cuyo texto dice: "A los efectos de esta reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes, aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito".

Finalmente, la ley trata sobre la prohibición de recopilar datos de carácter sensible, salvo que medien razones de interés general autorizadas. Esto dispuso el artículo 7º, cuyo texto indica: "*Categoría de datos.* 1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por

---

"d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;

"e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la ley 21.526."

"Artículo 6º. Información.

"Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:

"a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios;

"b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;

"c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;

"d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;

"e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos."



parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”.

Con relación a las bases de datos de instituciones médicas, señalamos que se rigen por el secreto profesional (artículo 8° de la ley 25.326); la ley regula todo lo relativo al derecho de acceso del titular de la información, la prohibición o límites a la cesión de las bases de datos, y lo relativo a la seguridad física y de software.

### **3. Responsabilidades emergentes del comercio en general**

#### **3.1. Ley de Defensa del Consumidor**

La ley 24.240, sancionada en el año 1993, dio origen legal a la defensa del consumidor. Con la reforma constitucional de 1994, estos derechos adquirieron protección en nuestra Carta Magna. Finalmente, las modificaciones establecidas por la ley 26.361 actualizaron la normativa de la ley originaria.

La ley en estudio observa las relaciones jurídicas entre la cadena de producción y el consumidor, suponiendo que este último se encuentra en desventaja frente a aquélla. Así, entendiendo que en una relación de consumo la libertad de negociación se encuentra limitada, se establecen presunciones en favor del consumidor.

El objeto de la ley se establece claramente en su artículo 1°: “...la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.

”Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”.

La contraparte en la relación de consumo,<sup>37</sup> para la ley, se llama *proveedor*. El artículo 2° del mismo cuerpo normativo indica que proveedor es “la persona física o jurídica de naturaleza

<sup>37</sup> Artículo 3° de la Ley de Defensa del Consumidor: “*Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia.* Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la ley

pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.

"No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. (Artículo sustituido por artículo 2° de la ley 26.361, B.O. 7/4/2008)".

Con el objetivo de la protección del consumidor en mente, y luego de definir a las partes y su vinculación, la Ley de Defensa del Consumidor se introduce en la reglamentación de las situaciones más comunes y los elementos contractuales que habitualmente se encuentran en una relación de consumo.

Así, regula sobre:

Información al consumidor y protección de su salud (artículos 4° al 6°): la prioridad resulta ser la información clara y verídica, proporcionada en forma gratuita al consumidor.

Asimismo, es el primer eslabón en la seguridad del consumidor, estableciendo la obligación de que las cosas vendidas no presenten riesgos para éste, y en caso de presentarlos, garantizar las normas de seguridad para minimizar las posibilidades de riesgo.

Condiciones de la oferta y venta (artículos 7° al 10): regulan las condiciones de la oferta, los elementos que ésta debe contener y las posibilidades de revocarla. Evita, asimismo, la diferenciación de clientes nacionales y extranjeros, abogando por el trato digno e igualitario de la clientela. Finalmente, se establecen los contenidos mínimos del documento de venta y la debida aclaración, en caso de que se comercialicen productos re manufacturados.

Cosas muebles no consumibles (régimen de garantías de los artículos 11 al 18): se establece el régimen de garantías para venta de cosas muebles no consumibles. Así, la ley establece un plazo mínimo de garantía de seis meses para productos nuevos y tres para productos usados. Establece también que "en caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller

---

25.156 de defensa de la competencia y la ley 22.802 de lealtad comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica. (Artículo sustituido por artículo 3° de la ley 26.361, B.O. 7/4/2008)".

habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y estarán a su cargo los gastos de flete y seguros, y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución", muy por el contrario de lo que algunos comerciantes vendedores indican al entregar el producto.

Dicha garantía está solidariamente impuesta a los fabricantes, importadores y vendedores, tanto para servicio técnico como para provisión y existencia de repuestos.

También establece los elementos que deben tener el documento de la garantía y la constancia de reparación, si la hubiese. Esto con el fin de fijar las consecuencias sobre una reparación defectuosa<sup>38</sup> y la prolongación de los plazos de garantía, en caso de reparaciones y reemplazos.<sup>39</sup>

La prestación de servicios (artículos 19 al 24): se establece que la prestación de servicios debe ser en todo como se pactó en el contrato. En caso de que éstos sean de mantenimiento, deben usarse elementos acordes al producto y la reparación a efectuar, de calidad y nuevos, salvo pacto en contrario. Se fijan los elementos que deben constar en todo presupuesto y la obligación de informar al consumidor cualquier costo o trabajo no incluido en éste, previamente a su realización. Finalmente se establece el régimen de garantías sobre el trabajo efectuado.

Usuarios de servicios públicos domiciliarios (artículos 25 al 31): se regula todo lo relativo a la prestación de servicios y vinculación entre las empresas y el usuario. Se obliga a entregar o poner a disposición copia del contrato que los vincula, llevar un registro de reclamos, mantener reciprocidad de trato (por ejemplo, para que en los reintegros se aplique el mismo interés que para la mora), garantizar la seguridad de las instalaciones, la corrección en el instrumental de medición de consumo, la consecuencia por la interrupción del servicio y las posibles diferencias en la facturación de consumo.

Venta domiciliaria, por correspondencia y otras (artículos 32 al 35): ésta incluye toda venta efectuada fuera del local del vendedor y por cualquier medio, incluso los medios

---

<sup>38</sup> Artículo 17: "*Reparación no satisfactoria*. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede: a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa; b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; c) Obtener una quita proporcional del precio. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder".

<sup>39</sup> Artículo 16: "*Prolongación del plazo de garantía*. El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal".

telemáticos. Este tipo de venta tiene una garantía de devolución del producto por diez días desde su recepción, sin cargos ni gastos para el consumidor. También prohíbe las ventas de productos o servicios no solicitados por el consumidor por las que deba emitir su negativa, en caso de no desearlo, para que no se le carguen costos.

Las operaciones de venta de crédito (artículo 36): se regula todo lo relativo a la venta por crédito, estableciendo los parámetros claros de costos totales, tasas de interés, sistema de amortización, gastos extras, periodicidad del pago. Todo esto debe ser establecido en forma clara para el consumidor bajo pena de nulidad. Finalmente, se prevén las consecuencias de ventas donde el crédito lo otorga un tercero.

Los términos abusivos y cláusulas ineficaces (artículos 37 al 39): estos tres artículos proveen parte de la esencia de la protección de la ley; prohíben toda cláusula abusiva, restrictiva o que implique una dificultad probatoria para el deudor; invierten las presunciones, siendo éstas siempre a favor del consumidor, y regulan los contratos de adhesión.<sup>40</sup>

Responsabilidad por daños (artículos 40 y 40 bis): el artículo 40 de la ley establece cómo funciona la responsabilidad por daños: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.

---

<sup>40</sup> Artículo 37. "Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

"a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;

"b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;

"c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

"La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.

"En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario."

Artículo 38. "Contrato de adhesión. Contratos en formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido."

"La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena".

Asimismo, el artículo 40 bis de la ley establece la posibilidad de indemnizar el daño directo sufrido por el consumidor en sede administrativa del organismo de defensa del consumidor, sin perjuicio de los mayores daños que puedan ser reclamados en sede judicial.

Autoridad de aplicación, procedimiento y sanciones (artículos 41 al 51): se establece como autoridad de aplicación a "la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción [...]". La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones". Luego se establecen sus atribuciones y funciones con relación a la ley, fijándose el procedimiento administrativo para zanjar las cuestiones llevadas a su conocimiento, así como las sanciones para proveedores incumplidores de la LDC.

De las acciones (artículos 52 al 54): la LDC establece que los procedimientos referentes a cuestiones con alcance en esta ley deberán tramitar por el procedimiento más abreviado que exista en la jurisdicción de que se trate. También existen la posibilidad de acciones colectivas y la fijación de la única multa civil existente en la legislación, que se denomina daño punitivo, yendo más allá de los daños causados, como un castigo ejemplar al proveedor incumplidor.

De las asociaciones de consumidores (artículos 55 al 58): fija la ley el procedimiento para la existencia de asociaciones de consumidores, su legitimación, autorización para funcionar y los reclamos que pueden interponer.

Arbitraje (artículo 59): la LDC, en consonancia con los ordenamientos internacionales más modernos, propicia la organización de tribunales arbitrales para las cuestiones que regula.

Disposiciones finales (artículo 60 al final): trata sobre la educación del consumidor y los aportes estatales para el financiamiento de las estructuras creadas por la presente ley. Establecen el orden público de esta ley y su vigencia para todo el ámbito nacional.

### 3.2 Ley de Defensa de la Competencia

Enseña el doctor Juan M. Farina que la Ley de Defensa de la Competencia "tiene por finalidad la protección de la libre concurrencia (y evitar la actividad monopólica u oligopólica), que es la base fundamental de la economía de mercado que caracteriza a nuestro régimen económico. El destinatario final de la tutela que brinda la ley es, en definitiva, el consumidor. Veremos a continuación las partes más destacables de la ley 22.262:

la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;

"d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa".

La fusión o adquisición cuyo objeto o efecto pudiere ser restringir o distorsionar la competencia se encuentran prohibidas por esta ley (artículo 7°).

En los actos indicados en el artículo 6°, cuyo volumen real de operación, determinado por el procedimiento que indica el artículo 8°, supere los doscientos millones de pesos (\$200.000.000), se deberá realizar un procedimiento previo ante el Tribunal de Defensa de la Competencia bajo pena de nulidad y aplicación de las sanciones de la ley, que resultan extremadamente onerosas.

El procedimiento indicado por la ley puede arrojar tres resultados posibles:

- "a) Autorizar la operación;
- "b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo tribunal establezca;
- "c) Denegar la autorización" (artículo 13).

Las resoluciones del tribunal podrán ser recurridas ante la Justicia.

### 3.3 Ley de Lealtad Comercial

Seguimos nuevamente al doctor Farina: "Conforme a lo expresado en su exposición de motivos, esta ley se propone los siguientes objetivos: 1) reunir en un solo cuerpo los temas contemplados en las leyes 17.016, 17.088 y 19.982; 2) regular jurídicamente la publicidad de servicios; 3) establecer normas procesales para el juzgamiento de las infracciones a la ley, y 4) delegar en las autoridades locales el control, vigilancia y juzgamiento de las eventuales infracciones".<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Farina, Juan M., ob. cit.

Esta ley reúne en un solo cuerpo las normas vigentes referidas a la identificación de mercaderías y a la publicidad de bienes muebles, inmuebles, servicios y también alas autoridades de aplicación. Asimismo, prevé las infracciones, sanciones y recursos.

Junto con la Ley de Defensa del Consumidor forma un conjunto de protección, ya que evita el posible fraude por confusión o falta de información en los productos.

Así lo ha entendido abundante jurisprudencia, que dice, por ejemplo: "Las normas de defensa de la competencia (ley 22.262) y de lealtad comercial (22.802) se integran en el sistema de protección jurídica del consumidor (ver artículo 3° de la ley 24.240), aunque a menudo no tutelan en forma directa e inmediata los intereses de los consumidores sino sólo por vía refleja como objeto de coordinación para la salvaguarda de los derechos del empresario. En relación concreta a la ley 22.802, de lealtad comercial, la misma establece estas bases en su exposición de motivos, puesto que mediante la inserción de normas referentes a identificación de mercaderías y a la publicidad de bienes y servicios se pretende también proteger al consumidor (CN Fed. Cont. Adm., Wassington SACIFI c. Secretaría de Comercio e Inversión. Albremática 106964)".<sup>43</sup>

De este modo, regula todo lo referente a la identificación de mercaderías, contenidos de envases, medidas, envoltorios, denominación de origen y origen según su manufactura.

También establece el procedimiento de fraccionado de mercadería y que "queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas y envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de producción" (artículo 5°).

En su artículo 9° establece la prohibición de realizar propaganda que pueda inducir a engaño o confusión sobre las características de los productos ofrecidos.

En su artículo 10 prohíbe:

"a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la intervención del azar;

"b) Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada en todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio;

"c) Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios de acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del producto vendido, cuando el valor entregado supere el corriente de los objetos rescatados o el que éstos tengan para quien los recupere".

<sup>43</sup> Código de Comercio y normas complementarias, directores: Ghersi y Weingarten, Editorial Nova Tesis.

Finalmente, dedica sus artículos 11 a 31 para establecer a la Secretaría de Comercio como órgano de aplicación, sus facultades, el procedimiento de la ley y las posibles sanciones por su violación.

El artículo 9° bis, como nota destacable, hoy en día sigue vigente y establece: "En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor."

"En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm (artículo sustituido por el artículo 1° de la ley 26.179, BO, 20/12/2006)". Conviene destacar la fecha de la reforma y los montos en cuestión, que hoy dejarían a la norma en desuso.



## Capítulo 5. Contratos<sup>44</sup>

### 1. Contrato. Concepto

El contrato es el instrumento jurídico más importante que el ser humano utiliza para entretener sus diversas relaciones; constituye una de las fuentes de las obligaciones que hemos visto en capítulos anteriores. Así, desde el inicio del día el hombre vive contratando o cumpliendo contratos de los más variados tipos. Desde el inicio de la jornada las personas utilizan servicios que pagan mensualmente. Por ejemplo, como consecuencia del cumplimiento del contrato por parte de las compañías de luz, gas y agua, un individuo puede iniciar la jornada tomando un baño caliente, prendiendo luces, viendo la televisión; finalmente descenderá por el ascensor de su departamento para dirigirse a su trabajo (contrato de derecho laboral, que se verá más adelante en la presente obra) por un medio de transporte público (contrato de transporte) y, en su empleo, comprará a nombre de la razón social empleadora bienes (compraventa) o producirá y comercializará productos o servicios (contratos comerciales), etcétera.

Estas relaciones contractuales se entretienen cuando las partes que poseen un bien o brindan un servicio se ponen de acuerdo en los costos y la forma de proporcionarlo, tal como expresa el artículo 957 del Código Civil y Comercial: "Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales".

El contrato resulta ser, en su género, un acto jurídico (ver el artículo 259 del Código Civil y Comercial). Como acto jurídico posee las particularidades de ser *bilateral*, por requerir el consentimiento de dos o más personas; de ser un acto entre vivos y de poseer naturaleza patrimonial (por cuanto el objeto de los contratos debe ser susceptible de valoración económica, aunque este no sea patrimonial, conforme al artículo 1.003 del C.C.C.).

Esta herramienta reviste en sí misma una importancia económica fundamental en el desarrollo social. Así, para su mayor entendimiento se debe empezar por analizar los elementos esenciales que hacen a la condición de existencia de los contratos.

---

<sup>44</sup> La adecuación inicial a la normativa del nuevo código fue realizada por la Srta. Florencia Diana. La corrección final por el autor.

### 1.1 Elementos esenciales: sujetos. Capacidad

El contrato como acuerdo de voluntades es un *acto jurídico* tendiente a crear, modificar o extinguir derechos. Los actos jurídicos los pueden realizar tanto las personas humanas como las jurídicas que posean *capacidad* para el tipo de acto que intenten hacer. Debe recordarse que la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular o *gozar* de los derechos; en cambio, la capacidad de hecho es la aptitud de *ejercer* esos derechos por sí mismo.

El ordenamiento argentino tiene como regla la capacidad de las personas físicas, por lo que el Código Civil y Comercial se limita a indicar los supuestos de incapacidad que son excepción a ese principio general. Siempre hay aptitud para contratar, salvo donde se encuentre limitada por un supuesto de incapacidad determinado.

Como normas específicas de contratos, los artículos 1.000 a 1.002, 1.023, 1.025 y 1.026 del Código Civil y Comercial son los que regulan la capacidad para contratar. Reza el artículo 1.001: "No pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona."<sup>45</sup>

Según el artículo 1.002 tienen *inhabilidad especial* para contratar en interés propio:

"a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados;

b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido;

c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido;

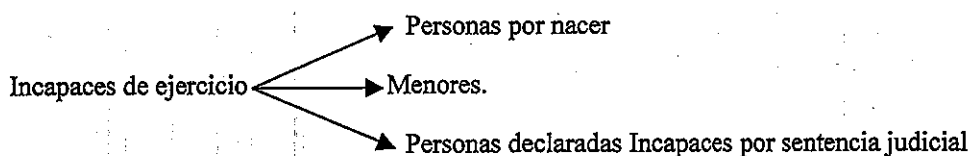
d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.

Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo"

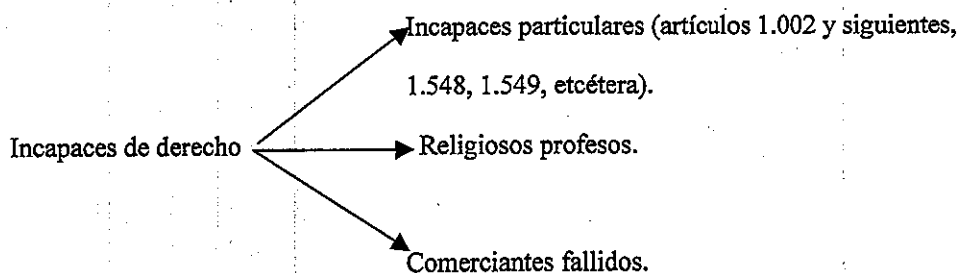
---

<sup>45</sup> "Interpósita Persona": Según la real academia española es aquella persona que, aparentando obrar por cuenta propia, interviene en un acto jurídico por encargo y en provecho de otro

Por otro lado, son *incapaces* de ejercicio para contratar, según los artículos del Código Civil y Comercial son:



En cuanto a los incapaces de derecho para contratar, serían los que surgen del siguiente cuadro:



## 1.2 Consentimiento y formación del contrato

Dispone el artículo 971 del Código Civil y Comercial que el consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra. Agrega el artículo 979 que "toda declaración o acto del destinatario que revela la conformidad con la oferta constituye aceptación". Puede ser expreso o tácito: es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, o por signos inequívocos. El consentimiento tácito resultará de hechos, o de actos que lo presupongan, o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que la ley exige una manifestación expresa de la voluntad; o que las partes hubiesen estipulado que sus convenciones no fuesen obligatorias, sino después de llenarse algunas formalidades".

También debemos atenernos a que "El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes." (artículo 979 del C.C.C.).

De esta forma quedan plasmadas la mecánica en que se desarrolla la formación del contrato (mediante el método oferta-aceptación) y la forma de manifestar el consentimiento. Aún así, el procedimiento de formación del contrato tiene características propias, las que desarrollamos a continuación:

a) Oferta: es una propuesta que una de las partes le dirige a otra para que celebren un contrato. Para que la oferta sea válida y efectiva debe bastar con la simple aceptación para perfeccionar el contrato.

En cuanto a la duración, la oferta puede ser revocada si la comunicación de la retractación "es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta" (artículo 975 del Código Civil y Comercial). La oferta puede quedar sin efecto por muerte del oferente o incapacidad (artículo 976 del Código Civil y Comercial).

b) Aceptación: la aceptación perfecciona el contrato. Para que este efecto se produzca es necesario que ésta sea "lisa y llana" (que no se modifique o sea condicionada en nada) y en tiempo oportuno. Cualquier modificación que contenga la oferta la transformará en una "contrapropuesta" que deberá, a su vez, ser aceptada por el oferente originario.

### **1.2.1 Modalidades especiales**

Párrafo aparte merecen las nuevas tecnologías y su injerencia en la formación de contratos. Ya desde la irrupción del teléfono y el fax empezaron los problemas en cuanto a la formación del contrato respecto del tiempo y lugar. Así, los contratos celebrados vía telefónica se consideraban hechos entre presentes (por lo que la aceptación y la oferta debían ser seguidas en el tiempo); pero en cuanto al lugar de celebración se consideraban entre ausentes. De esta forma, el contrato se regulaba conforme a las normas del lugar más favorable a la validez del acto. En cambio, los contratos vía fax son considerados entre ausentes tanto en cuanto al momento como al lugar de su celebración.

En el actual Código Civil y Comercial fueron reguladas diversas modalidades de contratación las cuales serán tratadas en mayor profundidad más adelante en la presente obra.

Finalmente, en cuanto al momento en que se debe reputar concluido el contrato, el artículo 980 toma la expedición de la aceptación. Como excepción, el artículo 981 aclara que el oferente puede retractar la aceptación antes de que tome conocimiento de ésta; en caso de fallecimiento o incapacidad del oferente, sobreviniente a la oferta y anterior al conocimiento de la aceptación, queda la oferta sin efecto.

### 1.3 Objeto

Los contratos son fuente de las obligaciones. Las obligaciones tienen por objeto una prestación. Esta prestación puede estar constituida por la entrega de un objeto material, la realización de un acto o su abstención. El objeto por entregar o el hecho por realizar es el objeto de los contratos.

El objeto va a estar limitado por las disposiciones de los artículos 1.003 al 1.010 y lo dispuesto en el artículo 279 del Código Civil y Comercial (objeto de los actos jurídicos), el cual resulta de aplicación por lo indicado en el artículo 1.003 del mismo cuerpo normativo. El Código entonces, determina que no pueden constituir objeto de los contratos: "... los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean." (Artículo 1.004 del Código Civil y Comercial).

A su vez, debemos tener en cuenta que el objeto debe poseer ciertas características: debe ser determinado desde el origen o determinable antes del vencimiento de la obligación (para poder reclamar el cumplimiento la persona debe saber cuál es el objeto puntual sobre el cual hacer la petición); también debe ser posible (y existente, por cuanto la inexistencia del objeto hace a su imposibilidad), lícito, y conforme con la moral y las buenas costumbres.

Finalmente, existen supuestos especiales en los que se puede contratar sobre cosas futuras (artículo 1.007 del Código Civil y Comercial), sobre cosas litigiosas o sujetas a gravámenes o embargo (artículo 1.009 del C.C.C.N), y sobre cosas ajenas (artículo 1.008).

### 1.4 Causa

El último de los elementos esenciales<sup>46</sup> del contrato es la causa. El término *causa*, jurídicamente hablando, contiene dos posibles acepciones y, como consecuencia de eso, se ha generado una larga y aún no solucionada discusión sobre el alcance del término.

En primer lugar, la teoría clásica considera la causa como el antecedente que da origen a la obligación. Por ende, para esta doctrina la obligación tendría su causa en la ley, en el contrato, en los hechos lícitos, etcétera. De esta manera, estamos en presencia de la denominada *causa fuente* (artículo 726 del Código Civil y Comercial).

---

<sup>46</sup> Llamados *esenciales* puesto que, de faltar alguno de los cuatro elementos: capacidad, consentimiento, objeto y causa, no existiría contrato.

En segundo lugar, nos encontramos con la *causa fin*, que resultaría la *finalidad* que las partes se han propuesto al contratar. Este último punto es el que ha dado lugar a teorías denominadas *anticausalistas*, que pregonan la inexistencia de la causa. Aún así, el código las regula en los artículos 727 y 282, por lo que mantener, como antes de la reforma, que el legislador pretendió regular algo inexistente nos llevaría a pretender modificar la letra de la ley en lugar de procurar comprender el alcance de ésta.

Así, podemos comprender, como enseña el maestro Borda: "...causa es el fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al contratar, es la razón directa y concreta de la celebración del acto, y precisamente por ello resalta para la contraparte, que no puede ignorarla. En los contratos onerosos, la causa para cada uno de los contratantes será la contraprestación del otro, integrada por todos los elementos que han sido determinantes del consentimiento. En los actos gratuitos, la causa será el propósito de beneficiar a un amigo o pariente, a alguien con quien se mantiene una deuda de gratitud, o simplemente a un extraño; o bien el deseo de crear una institución benéfica o de ayudar a las existentes".<sup>47</sup>

Esta causa no debe confundirse con los *motivos* que pudiese tener el contratante, ya que al derecho no le importan los motivos internos de la persona o sus pensamientos. De este modo, si alguien vende su propiedad, la causa para el derecho será obtener el dinero que se entregue por ésta, sin importar lo que el vendedor pretenda realizar con la plata resultante de la venta. Ahora bien, las partes pueden hacer que los *motivos* entren dentro de la categoría de *causa* indicando expresamente el porqué último por el que se realiza la venta; así, los motivos integrarían la causa y podría resolverse la inexistencia de contrato por falta de causa en caso de frustrarse dichos motivos.

### 1.5 Interpretación

La interpretación de los contratos es el acto de entender la voluntad de las partes mediante el análisis de la declaración que han efectuado al momento de contratar. Esto ocurre cuando las partes, posteriormente a la celebración del contrato, no se ponen de acuerdo en el alcance que cada una pretende dar a alguna cláusula contractual, o para el caso de que haya alguna circunstancia, durante la vida del contrato, que no hubiese estado contemplada en él y que tampoco surja de las disposiciones que la ley muchas veces, en forma imperativa o supletoria, dispone para el tipo de contrato celebrado.

Los principios que deben utilizarse para interpretar los contratos son:

---

<sup>47</sup>Borda, Guillermo A., *Manual de contratos*, Editorial Perrot, decimoctava edición actualizada, pág. 77.

a) La buena fe, usos y costumbres: dice el artículo 961 del Código Civil y Comercial que “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”. A la hora de interpretar el contrato, y en caso de controversia, el juez debería preguntarse qué alcance le daría una persona honrada a la cláusula en disputa si al redactarla hubiese obrado con cuidado y previsión. Para el sistema sajón esta regla se une con la interpretación directa gramatical y ordinaria, razón por la cual generalmente se observa, en los contratos en lengua inglesa, un glosario de definiciones que evitan casi cualquier posibilidad de malinterpretar el alcance de las palabras. En nuestro país debe estarse a la interpretación que las partes quisieron darles a los términos, por cuanto pueden haberlos utilizado de forma distinta y ambas estar de acuerdo. Son también importantes, para determinar e interpretar las cláusulas, los usos y costumbres sociales. El contrato es una unidad, y sus cláusulas deben ser interpretadas en el conjunto de éste y no en forma aislada.

b) Las condiciones existentes al momento de la contratación: éstas son las circunstancias reinantes en el momento de la declaración de voluntad. Así, no sería lo mismo una declaración hecha en tono de broma entre amigos, que una declaración hecha seriamente ante clientes, por lo que una y otra tendrían distintos efectos jurídicos.

c) La conducta de las partes: este principio ha sido receptado por la jurisprudencia en gran cantidad de ocasiones y surge de la propia realidad, por cuanto las partes que obran de buena fe adoptan conductas concordantes con lo que verosímelmente han querido manifestar al momento de contratar.

d) El contrato celebrado y su finalidad: todo aquel que contrata lo hace con una finalidad. Muchas veces esta finalidad va a surgir de la naturaleza del contrato celebrado y sirve para revelar el alcance de éste.

#### **1.6 Régimen legal de adhesión y las disposiciones de la ley 24.240, de defensa del consumidor**

Además de los contratos civiles ya mencionados, el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 984 a 989) y la ley 24.240 regulan los denominados contratos por adhesión. Requiere una especial interpretación por escapar a la mecánica de creación contractual tradicional, también denominado contrato *prestablecido*. Este tipo de contrato suele ser de uso común y es utilizado en una gran cantidad de contrataciones, como por ejemplo contratos de transporte, de servicios, de préstamos prendarios, de cláusulas de utilización de servicios de Internet, etcétera. La particularidad de estos contratos radica en la imposibilidad de discutir las cláusulas que la parte más débil tiene en la contratación, debiendo limitarse a aceptar el contrato

o no. Así, cuando una cláusula de estos contratos esté redactada en forma oculta u oscura y cuya interpretación sea dudosa, deberá estarse a la nulidad de la cláusula en cuestión. Esto tiene una particular interpretación cuando se refiere a contratos de consumo, en los que intervienen los lineamientos de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, en forma especial.

El artículo 37 del título IX de la mencionada ley, "De los términos abusivos y cláusulas ineficaces", regula la interpretación de los contratos de consumo con particulares limitaciones que no se aplican al resto de las contrataciones civiles. El texto indica: "Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario".

Para el supuesto de los contratos de adhesión específicamente, es el artículo 38 el que indica su tratamiento. Así, el régimen dispone: "La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido". Y el artículo 39 agrega: "Cuando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación".

### 1.7. Clasificación de los contratos

La clasificación de los contratos sirve para determinar las diferencias y similitudes de distintos contratos conforme a su naturaleza. De esta forma, a igual naturaleza tendremos iguales o similares consecuencias jurídicas. Los contratos se pueden clasificar según distintos criterios:

a) Según las partes que resulten obligadas existirán contratos unilaterales o bilaterales (artículo 966 del Código Civil y Comercial). Serán unilaterales cuando una sola parte resulte obligada (por ejemplo en las donaciones) y bilaterales, cuando existan en el contrato



obligaciones recíprocas (compraventa, locación, cesión, etcétera). Las consecuencias de uno u otro tipo están dadas por la exigencia del doble ejemplar, la existencia de la excepción de incumplimiento (artículo 1.031 del Código Civil y Comercial)<sup>48</sup> y el pacto comisorio (artículo 1.083 Código Civil y Comercial).<sup>49</sup>

b) Según existan obligaciones recíprocas o no serán onerosos o gratuitos. Son onerosos cuando la promesa de una prestación versa sobre el interés de obtener otra cosa a cambio. En los gratuitos sólo una parte se obliga desde el punto de vista económico, lo que no implica que pudieren existir obligaciones a su cargo sin quitar el carácter de gratuito, ya que no es lo que se tuvo en mira al contratar como *contraprestación*. Las consecuencias de esta clasificación radican en la mayor protección que tienen los contratos onerosos (acciones de reducción, revocatoria, reivindicación y garantía de evicción, lesión enorme, acción de colación), pues las cláusulas dudosas en estos contratos deben interpretarse de forma tal de devolver el equilibrio económico al contrato.

c) En los contratos onerosos las prestaciones pueden ser equivalentes, por esa razón se dice que las partes cambian cosas de idéntico valor. En ese caso, serán contratos conmutativos. Si, en cambio, la prestación a cargo de una de las partes o de todas ellas, depende en su onerosidad de un acontecimiento futuro e incierto, es un contrato aleatorio (artículo 968 del Código Civil y Comercial). Contratos típicos aleatorios son la renta vitalicia (donde una parte da una suma de dinero a cambio de que la otra parte le pague una mensualidad durante toda su vida; el negocio está limitado por la duración de la vida del beneficiario, pero no puede determinarse de antemano) o la venta de cosa futura, en la que no se sabe con precisión si existirá o, de hacerlo, qué cantidad contiene, como, por ejemplo, la venta de cosecha que aún no se ha realizado. Lo importante es que los contratos aleatorios no tienen protección alguna frente a grandes desequilibrios económicos; es lo que las partes aceptaron al contratar. Así no sería posible plantear la teoría de la imprevisión o la lesión.

d) El artículo 1.892 del Código Civil y Comercial indica que existen contratos reales cuando el contrato queda perfeccionado al entregar la cosa que constituye su objeto. Los contratos reales son el depósito, el comodato, el mutuo y la renta vitalicia. El resto de los contratos se perfecciona con el mero consentimiento prestado por las partes, sin importar si el contrato es formal o no.

<sup>48</sup> Artículo 1031.- "Suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación."

<sup>49</sup> Artículo 1083.- Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor sólo puede resolver integralmente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial.

e) Cuando el contrato no depende de formalidad alguna para su realización estamos en presencia de contratos *no formales*. Basta el acuerdo de voluntades para que el contrato quede perfeccionado. En cambio, cuando la validez del contrato depende de la observancia de la ley en cuanto a la forma que allí se establece, nos encontramos ante contratos *formales*. Éstos pueden ser con formalidad *ad probationem* (para su prueba), o formalidad solemne para constituirlos o *ad solemnitatem* (Artículo 969 C.C.C.N.).

El artículo 1.020 consiente flexibilidad en los medios probatorios de los contratos en los casos que sea imposible obtener prueba del cumplimiento de las formalidades requeridas. Expresamente deja asentado el uso de la prueba testimonial y prescribe el denominado principio de prueba instrumental, el cual sugiere que es válido cualquier instrumento que haga verosímil la existencia del contrato.

f) Si los contratos se encuentra regulados en el Código Civil y Comercial o en una ley especial se llamarán nominados. En su defecto, se llamarán innominados o *atípicos*. Esto no resta valor, sino que, para el caso de los nominados, permite la aplicación de las normas del Código Civil y Comercial o la ley especial, donde el legislador ya ha previsto una gran cantidad de situaciones y ha regulado también sus consecuencias con normas imperativas o supletorias, según sea el caso. De ser un contrato innominado, según el art. 970 CCC los mismos "están regidos, en el siguiente orden, por: a) la voluntad de las partes; b) las normas generales sobre contratos y obligaciones; c) los usos y prácticas del lugar de celebración; d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad."

g) Finalmente, según sea el momento de cumplimiento del contrato éste podrá ser inmediato, diferido o periódico. En nuestro país, para los contratos de cumplimiento diferido, y en mayor medida para los periódicos, existe toda la normativa de la teoría de la imprevisión, por cuanto en contratos que duren por años suelen cambiar enormemente las condiciones contractuales originarias reinantes en la Argentina.

### 1.8 Vicios de los contratos

Los contratos como actos jurídicos hacen suyo lo dispuesto para los vicios de éstos, ya sean por error, violencia, fraude, dolo, simulación o estado de necesidad.

Para el caso concreto de los contratos, los vicios habilitan a la parte que los sufre a pedir la nulidad del contrato. De esta forma, el artículo 387 del Código Civil y Comercial dice que la nulidad absoluta puede alegarse por cualquier interesado, exceptuando por la parte que invoque la

propia torpeza para lograr provecho. Ahora bien, el derecho para alegar la nulidad cesa cuando, habiendo tomado conocimiento de los vicios, y habiendo cesado éstos, el contrato se confirme, ya sea expresa o tácitamente (artículo 388 del Código Civil y Comercial).

### **1.8.1 Vicio de lesión**

Se configura cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación (confrontar artículo 332 del Código Civil y Comercial). Para que este supuesto se dé se deben configurar las dos condiciones que impone la ley: a) el aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia, y b) la desproporción notable. Sobre este punto en particular se debe concluir que, como principio general, la desproporción debe subsistir al momento de la demanda. De esta forma, quien resulta damnificado puede reclamarle reajuste del contrato en términos equitativos o la nulidad del mismo (artículo 332 *in fine*).

## **1.9. Cláusulas contractuales especiales. Cláusulas de escape**

Los contratos, como las obligaciones, nacen para extinguirse naturalmente mediante el pago, que significa el cumplimiento de lo debido. Ahora bien, no siempre en la vida contractual estos acuerdos de voluntades se cumplen. Cuando una parte incumple puede que a la otra ya no le sirvan las obligaciones cumplidas en forma tardía o defectuosa; o también suele ocurrir que una parte exija el cumplimiento a la otra sin que haya hecho su parte. También, las partes pueden ponerse de acuerdo en extinguir el contrato. Para ello se contemplan los siguientes institutos:

### **1.9.1 Rescisión bilateral**

Con el acuerdo de voluntades se puede crear un contrato y también se lo puede extinguir. De esta manera, si las partes involucradas acuerdan en poner fin a su vinculación contractual y dejan sin efecto el contrato, se produce un *distraeto*. En esta rescisión las partes pueden pactar volver las cosas al estado anterior a la contratación o dejar subsistentes los efectos que se hayan producido, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden afectarse derechos de terceros que se hayan adquirido en consecuencia de la habida contratación (art. 1.076 C.C.C.).

### **1.9.2 Rescisión unilateral**

Si bien la rescisión implica un acuerdo de voluntades, existe también la rescisión unilateral. En ésta una sola de las partes resuelve terminar el contrato. La ley, en algunos casos,

otorga esta facultad, como, por ejemplo, en el derecho laboral, en la locación de obra, cuando el dueño puede desistir por su propia voluntad (artículo 1.261 del Código Civil y Comercial); el mandato que puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes en cualquier momento, etcétera.

El efecto de la rescisión unilateral siempre deja subsistente lo ya ocurrido en virtud de la vinculación existente.

### 1.10 Resolución de contratos

Al contrario de la rescisión, no existe, en la resolución, un nuevo acuerdo de voluntades, sino que un hecho sobreviniente, imputable a una parte o a ninguna, genera la extinción del contrato.

Esto puede ocurrir de pleno derecho (por ejemplo, cuando se cumple una condición resolutoria),<sup>50</sup> o puede ser necesario que una parte manifieste su voluntad de resolver el contrato (por ejemplo, cuando se pacta un arrepentimiento, o ante un incumplimiento de la contraparte).

Dentro de este instituto se encuentran el pacto comisorio, la teoría de la imprevisión y la seña (instituto que ya hemos visto en las páginas anteriores).

El efecto de la resolución es volver las cosas al estado anterior a la contratación. Los efectos son similares a los de la nulidad; sin embargo, surgen de un hecho posterior a la contratación y no contemporáneo.

### 1.11 Pacto comisorio

Enseña el maestro Borda que "se llama pacto comisorio la cláusula que permite a los contratantes reclamar la resolución del contrato cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones a su cargo".<sup>51</sup>

Existen dos tipos de pactos comisorios: el que está establecido en el contrato, o expreso, y aquel del cual nada dice el contrato, pero que por su naturaleza bilateral y onerosa se considera inserto. Este último caso es el del pacto comisorio tácito.

---

<sup>50</sup>Hecho futuro e incierto del que depende la resolución de un derecho adquirido, de tal manera que, no cumplida la condición, o siendo cierto que no se cumplirá, el derecho subordinado a ella queda irrevocablemente adquirido como si nunca hubiese existido condición alguna (artículo 343 y ss. del Código Civil).

<sup>51</sup>Borda, Guillermo, ob. cit., pág. 131.

El artículo 1.083 del Código Civil y Comercial dispone: "Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor sólo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial".

Para resolver un contrato por incumplimiento, éste debe ser esencial atendiendo las finalidades del contrato. Según el artículo 1.084 se considera que es esencial cuando:

- a) el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato;
- b) el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor;
- c) el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar;
- d) el incumplimiento es intencional;
- e) el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor.

## **2. Etapa precontractual**

### **2.1 Significación**

Es normal que las tratativas precontractuales lleven un plazo más o menos extenso durante el cual se determina el alcance de las obligaciones de cada parte, según la complejidad del negocio que se está desarrollando. Esta negociación puede suponer que las partes incurran en gastos o en trabajos y gestiones destinados al futuro contrato. Aún así, según el art. 990 del CCC las partes son libres de abandonarlas en cualquier momento.

### **2.2. Responsabilidad**

Las partes realizan los gastos de las tentativas en interés propio, asumiendo el riesgo de que la otra parte no acepte contratar; pero puede darse el caso de que las tratativas estén ya en un nivel de avance que la parte que incurre en el gasto lo haga con la firme y legítima esperanza de contratar, ya que es claro que el negocio será perfeccionado; en este supuesto, si la otra parte interrumpe las negociaciones en forma intempestiva e injustificada, puede dar lugar a lo que doctrinariamente se denomina *culpa precontractual*.

Si bien hemos explicado que por la libertad contractual nadie se encuentra obligado a contratar con otra persona, estando realmente avanzada la negociación y actuando de buena fe, y habiendo incurrido una parte en gastos preparatorios del contrato, la idea de justicia se ve violada si se permite que la otra parte rompa, sin responsabilidad alguna, las negociaciones. Esta *culpa*, que se le imputará a la parte que actuó en forma injustificada, debe ser probada, por lo que la responsabilidad se basa en un abuso del derecho que puede dar lugar a que se indemnice por los gastos, pero no por la ganancia que la otra parte tendría en el negocio. Así lo dispone el art. 991 donde dice "Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato."

### **2.3 Importancia actual de la documentación de las negociaciones en la etapa precontractual**

Surge con palmaria importancia la documentación de las negociaciones en la etapa precontractual, por cuanto, al no contarse con contrato alguno, deberá demostrarse el origen de los actos preparatorios que resultaron dañosos y que era lógico que debían ser realizados para poder cumplir el futuro contrato, conforme estaba en vías de ser pactado.

Para documentar las negociaciones es útil cualquier medio de prueba, aunque debe tenerse en cuenta el valor probatorio de lo que cada uno pretenderá utilizar en un eventual pleito. Gracias a las nuevas tecnologías suele contarse con gran cantidad de documentación, habitualmente constituida por pedidos o intercambios vía e-mail o comunicaciones electrónicas, cuya autenticidad deberá probarse, lo que en algunos casos suele ser una tarea muy difícil.

#### **2.3.1 Contratos preliminares**

Ante la incertidumbre que genera la etapa precontractual, pero no siendo obligatorio, el Código Civil y Comercial regula los denominados contratos preliminares o preparatorios. Estos consisten en contratos previos al principal, con la finalidad de generar un mayor compromiso y seguridad jurídica entre las partes. En definitiva, un medio probatorio irrecusable de la vinculación entre los interesados.

Deben contener "el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro y definitivo". Poseen vigencia de plazo máximo de un año, renovable, si las partes a su vencimiento así lo convinieran.

Los contratos preparatorios son:

- a) La promesa de contratar (Art. 995 C.C.C.)
- b) Contrato de opción (Art. 996 C.C.C.)
- c) Pacto de preferencia (Art 997 a 999 C.C.C.)

### 2.3.2 Deber de confidencialidad

En toda esta etapa previa contractual existe un deber de confidencialidad. Este encuentra actualmente recepción expresa en el nuevo código donde el art. 992 dispone que "Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento."

### 3. Señal o arras

En vista de las dificultades que pueden darse en la etapa precontractual, es frecuente que, a los fines de tener que evitar demostrar los daños y estar *cubiertos* ante una eventual retractación de la parte contratante, se exija con la oferta una garantía de su seriedad. Esa garantía se denomina *señal* o *arras* y se encuentra legislada en el artículo 1.059 y 1.060 del Código Civil y Comercial, que permite dar como señal cualquier cosa, aunque lo más usual es que se entregue una suma de dinero.

El régimen legal de la señal establece un doble uso: en primer lugar, constituye la garantía del acto y, en consecuencia, si es una suma de dinero, será un anticipo del pago del precio; y, en segundo lugar, otorga a las partes la facultad de arrepentirse, perdiendo una de ellas la señal y teniendo que devolver el doble de lo percibido la otra; pero solo para el supuesto de que expresamente así lo convengan las partes.

### 4. Contratos típicos civiles y comerciales

Los contratos *nominados* o *típicos* son los que se encuentran previstos en el código. Dada la importancia que han tenido a través del tiempo para el comercio, merecen especial tratamiento. En cambio, los contratos que no responden a nomenclatura alguna, y que se desarrollan también dentro de la libertad contractual de las partes, son de libre creación de éstas y se conocen como *innominados* o *atípicos*.

#### 4.1. Compraventa

Según el artículo 1.123 del Código Civil y Comercial: "Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, y la otra a pagar un precio en dinero".

Este contrato es el principal de los negocios jurídicos y el que tiene mayor importancia en las relaciones jurídico-comerciales de los individuos.

Los caracteres de este contrato, conforme la clasificación vista anteriormente, son:

- a) Bilateral, por cuanto existen obligaciones para ambas partes;
- b) Consensual, porque no requiere la entrega de la cosa para surtir efectos, bastando el mero consentimiento u obligación de entrega de ésta;
- c) Formal, a los fines del registro de la transferencia del dominio en caso de los bienes inmuebles, y no formal, ya que surte efectos de compraventa por instrumento privado;
- d) Oneroso, por cuanto de la propia definición surge que requiere como contraprestación la entrega de dinero;
- e) Conmutativo, por cuanto la suma entregada debe guardar relación de equivalencia con el valor de mercado de la cosa. En caso de no respetarse y ser abusivo, podría dar lugar al vicio de lesión. Puede ser un contrato aleatorio si se contrata a sabiendas de que la cosa puede llegar a no existir o ser menor que lo esperado, siendo ese acontecimiento conocido y tenido en cuenta especialmente para contratar.

La capacidad requerida para la celebración del contrato de compraventa es la de disposición de bienes (artículo 22 y subsiguientes del Código Civil y Comercial). Especialmente existen incapacidades de derecho para la celebración de este contrato, como ser: a) Los esposos entre sí (artículo 1.002 del Código Civil y Comercial); b) Los padres, tutores y curadores de los menores que se encuentran bajo su guarda (artículo 1.002 del Código Civil y Comercial); c) Los albaceas; d) Los mandatarios sobre los bienes objeto del mandato; e) Los demás sujetos individualizados en el artículo 1.002 del Código Civil y Comercial.

En cuanto a la forma y prueba del contrato, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1.017 del Código Civil y Comercial para la compraventa de inmuebles, los contratos de compraventa poseen libertad de formas por ser contratos consensuales no formales, por lo que puede demostrarse su existencia por cualquier medio de prueba, siendo siempre indispensable que la prueba no sea limitada únicamente a declaraciones de testigos, salvo que tuviese el contrato principio de ejecución (confrontar artículo 1.020 del Código Civil y Comercial).

El objeto de la compraventa debe recaer sobre una cosa mueble o inmueble, ya que el principio es que "pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos" (artículos 1.003 a 1.011 C.C.C.).



El precio en la compraventa debe reunir los siguientes requisitos:

- a) Debe ser en dinero;
- b) Debe ser serio (en caso contrario caería bajo un supuesto de vicio de lesión (artículo 332 del C.C.C.), y
- c) Debe ser determinado o pasible de determinación (artículo 1.133 del Código Civil y Comercial).

El contrato de compraventa lleva en su naturaleza las garantías de *evicción* y *vicios ocultos*. Como ya se ha visto, la garantía de evicción es la que regulan los artículos 1.033 y subsiguientes, que consideran: "Están obligados al saneamiento: a) El transmitente de bienes a título oneroso; b) Quien ha dividido bienes de otros c) sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso", y explican que la evicción se da cuando "...a) toda turbación de derecho, total o parcial, que recae sobre el bien, por causa anterior o contemporánea a la adquisición; b) los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el adquirente; c) las turbaciones de hecho causadas por el transmitente."

Por su parte, los vicios ocultos ocurren cuando los defectos existen al tiempo de su adquisición, pero se revelan luego, siendo tan importantes que el adquirente no habría comprado la cosa o habría dado un precio menor por ella.<sup>52</sup> Ésta es también una garantía propia de los contratos onerosos, y se encuentra legislada en los artículos 1.051 y subsiguientes del Código Civil y Comercial.

#### 4.2 Permuta

Se constituye contrato de permuta cuando se realiza el trueque o cambio de una cosa por otra. El contrato es consensual, por lo que admite la promesa de trueque (artículo 1.172 Código Civil y Comercial). Por imperio del artículo 1.175 las disposiciones aplicables a la compraventa lo son a la permuta, razón que obedece a que aquella no es más que un trueque por dinero. Las naturalezas de ambos contratos son idénticas.

---

<sup>52</sup>ARTICULO 1051.- "Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a:

- a) los defectos no comprendidos en las exclusiones del artículo 1053;
- b) los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor."

### 4.3 Cesión de derechos

Dispone el artículo 1.614 del Código Civil y Comercial: "Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien, o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este Capítulo.". Este contrato abarca tanto la cesión de créditos como de derechos no crediticios (artículos 1.616 y 1.617).

Las *cosas* se *venden*, en cambio los *derechos* se *ceden*, razón por la cual, visto que la cesión aparenta ser una *compraventa de derechos*, el artículo 1.614 del Código Civil y Comercial dispone que se aplican las reglas de la compraventa en tanto no se opongan a las disposiciones específicas de las normas de la cesión. El mismo artículo dispone que en caso de que la cesión sea gratuita se juzgará por las reglas de la donación.

Los caracteres del contrato son: a) Consensual; b) Formal (porque exige la forma escrita bajo pena de nulidad, según artículo 1.618 del Código Civil y Comercial, salvo los títulos al portador, en los que basta con su entrega, conforme el mismo artículo); se puede ceder por documento privado, salvo que sean derechos litigiosos, derechos hereditarios o de actos que fueran realizados con formalidad de escritura pública, por lo que debe respetarse dicha forma bajo pena de nulidad; c) Pueden ser onerosos o gratuitos.

El carácter general de la cesión sobre cualquier derecho tiene como excepción los siguientes supuestos: a) Que las partes dispusieran la incesibilidad de los derechos (artículo 1.616 del Código Civil y Comercial); b) Que sean derechos inherentes a la persona (derecho al nombre, al estado, capacidad, domicilio, derecho de familia, etcétera; ver artículo 1.617 del Código Civil y Comercial); c) Las jubilaciones y pensiones; d) Los derechos de uso y habitación; e) El derecho a alimentos futuros; f) Las indemnizaciones por accidente de trabajo y otros créditos con origen en la relación laboral; G) la cesión de deudas sin mediar la autorización previa del acreedor (sin embargo, es posible la cesión del fondo de comercio, cuyo tratamiento se verá en forma especial más adelante).

La cesión se perfecciona con el mero consentimiento entre las partes, aun sin mediar la entrega del título, el cual es exigido por la ley a los efectos de dar seguridad jurídica. En cambio, el deudor *cedido* se libera de su obligación pagando al cesionario si no fue notificado de la cesión, razón por la cual la ley exige la entrega del título a los fines de garantizar que el cedente no comerciará con su derecho más de una vez, burlando derechos de terceros y, eventualmente, del deudor cedido. Si éste fuera el caso (no es de extrañar que se den cesiones de una misma factura varias veces), el deudor deberá pagar al cesionario que primero notifique de la cesión de crédito habida (artículo 1.620 del Código Civil y Comercial). A los fines de la notificación la ley

no requiere forma alguna; pero para darle efecto contra terceros la notificación debe ser por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables (artículo 1.620 del C.C.C.). Si la notificación la realizaran varios cesionarios el mismo día, se pagará en partes iguales a cada uno en atención a que en el Código Civil y Comercial los plazos se cuentan por día y no por horas (artículo 1.626).

#### 4.4 Locación de cosa

Existe locación de cosa cuando una persona, llamada locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa a otra, llamada locatario, por un determinado tiempo, obligándose este último a pagar, a cambio, un precio en dinero.

Las locaciones de cosa, de obra y de servicio en el Código Civil y Comercial son tratadas en conjunto en el artículo 1.187, que dice: "Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa."

La locación es otro de los contratos de mayor importancia en los negocios, por cuanto éstos se desarrollan siempre a través de cosas y servicios locados. Así, debemos prestar atención a los caracteres de este contrato, los cuales son: a) Bilateral; b) Oneroso y conmutativo; c) Consensual; d) De tracto sucesivo (su cumplimiento se desarrolla a través de un período más o menos prolongado).

La capacidad que la ley exige para este tipo de contratos es la de administración de bienes; por ello, a diferencia de la compraventa, los menores emancipados, los inhabilitados, los administradores de bienes ajenos, y los padres y tutores, con algunos límites, pueden arrendar bienes.

En cuanto a la incapacidad de ejercicio, el artículo 1.002 del Código Civil y Comercial dispone inhabilidades especiales para contratar por interés propio, siendo una regla general que incluye la locación.

El objeto de la locación puede ser cualquier cosa inmueble o mueble no fungible<sup>53</sup> existente al momento de contratar, salvo que expresamente se pacte la locación de cosa

<sup>53</sup>Las cosas fungibles no se pueden alquilar, pues una cosa fungible es igual a otra, por lo que se cumpliría devolviendo cosa distinta de la entregada de igual naturaleza, estando así frente aun contrato de consumo y no a una locación. Si bien la diferencia parece sutil, no lo es en el caso de que la cosa se destruya por caso fortuito, en atención a que las cosas perecen para su dueño, pero siendo fungible el género nunca muere, bastando con devolver otra cosa de igual característica.

futura; así el contrato queda condicionado a que la cosa exista realmente. Así el art 1.192 dispone que "Toda cosa presente o futura, cuya tenencia esté en el comercio, puede ser objeto del contrato de locación, si es determinable, aunque sea sólo en su especie. Se comprenden en el contrato, a falta de previsión en contrario, los productos y los frutos ordinarios".

El plazo del contrato tiene un máximo de veinte años para destino habitacional y cincuenta para otros destino (artículo 1.507 del Código Civil); asimismo se prevé un mínimo de dos años si se carece de plazo expreso y determinado con excepción de los destinos previstos en el art. 1.199 de mismos cuerpo normativo.

Como contrato de ejecución con tracto sucesivo, las obligaciones que pesan sobre el locador son distintas de los contratos vistos hasta ahora. Así, deberá el locador:

- a) Entregar la cosa (artículo 1.200);
- b) Mantener al locatario en su uso y goce (artículos 1.201), y
- c) Conservarla en buen estado mientras dure el contrato (artículo 1.201). Deberá también abonar las mejoras introducidas por el locatario que tuvieren por objeto hacer posible el uso de la cosa para el que fuera destinado, y finalmente abonar los impuestos y cargas que pesen sobre la cosa (aunque esto último convencionalmente se traslada muchas veces al locatario).

Por su parte, el locatario debe:

- a) Usar la cosa conforme al destino para el que fue locada;
- b) Conservarla en buen estado;
- c) Pagar los cánones locativos, y
- d) Restituir la cosa al término de la locación.

Finalmente, como todo derecho, puede cederse o sublocarse, salvo que expresamente se encuentre prohibida o limitada dicha facultad en forma convencional en el contrato.

El contrato finaliza por varias razones, y la principal es por el vencimiento del plazo acordado; también puede finalizar por: a) Pérdida de la cosa locada; b) Imposibilidad por caso fortuito de utilizar la cosa para su fin; c) Por vicios redhibitorios; d) Por incumplimiento de las partes. También puede extinguirse el contrato por: a) Acuerdo de parte; b) Confusión; c) Cumplimiento de la condición resolutoria. En cambio, no concluye la locación por muerte del locador, por venta de la cosa arrendada, por necesidad del locador de uso personal de la cosa o por imposibilidad del locatario de seguir usándola.

#### 4.5. Locación de servicios y de obra

De los artículos 1.251 y ss del Código Civil y Comercial surge la regulación de los contratos de *locación de servicios* y de *locación de obra*. Dice el artículo 1.251 del Código Civil y Comercial: "Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución".

La locación de obra es una obligación de resultado concreto, distinguiéndolo así de la locación de servicios, en la que se trata de un trabajo en dirección a un resultado, pero que se independiza de la obtención de él. La locación de obra es "el contrato por el cual una de las partes, denominada locador de obra (empresario, constructor, contratista, y en su caso, profesional liberal, autor, artista, etc.), se compromete a alcanzar un resultado, material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico, sin subordinación jurídica, y la otra parte, denominada locatario de obra (dueño, propietario, comitente, patrocinado, paciente, cliente, etc.), se obliga a pagar un precio determinado o determinable en dinero. El objeto de ambos contratos puede consistir en una actividad o un resultado, tanto material como inmaterial, incluyendo todos los casos en que se retribuye con un precio cierto en dinero el esfuerzo, la actividad o el trabajo ajeno, cualquiera que sea su clase o naturaleza".<sup>54</sup> Así lo dispone expresamente el art. 1.252 de nuevo Código Civil y Comercial.

Este contrato se caracteriza por ser bilateral, consensual, conmutativo, oneroso y no formal.

EL nuevo Código Civil y Comercial expresamente contempla los distintos tipos de contratación que eran usados generalmente en esta modalidad contractual y surgían de la ley de obras públicas. Los distintos sistemas son:

- Por unidad de medida: en este caso, el precio se fija por la medida o por unidades técnicas, por ejemplo, kilómetros de camino o metros de pared construidos;
- Coste y costas: el precio se fija teniendo en cuenta lo que la obra costaría de mantenerse los precios de materiales y salarios vigentes en el momento de la contratación, pero se

<sup>54</sup> Quiroga, Eduardo Molina, *Prueba en la locación de servicios de obra. Honorarios profesionales y presunción de onerosidad*, Biblioteca Digital de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (puede consultarse en <http://www.aaba.org.ar/bi070002.htm>).

reconoce al contratista el derecho de reajustar el precio de acuerdo con la variación de aquéllos;

- Por ajuste alcanzado o "retribución global": se da cuando las partes, desde el comienzo, fijan un precio fijo e invariable, y cualquier modificación que haya en el precio de los materiales o en la mano de obra no altera el precio fijado. Si no se pacta ninguna forma se presume esta modalidad de ajuste alzado con provisión de materiales por el contratista.
- Por cualquier otro sistema que se acuerde. Todos con o sin provisión de materiales.

Recomendamos la atenta lectura de los artículos 1.262 a 1.277 del Código Civil y Comercial que disponen las normas específicas para la contratación de obras.

#### **4.5.1 Subcontratación en la locación de la obra**

El dueño de la obra o locatario puede celebrar o suscribir contratos separados con distintas empresas dentro de la misma obra. También es posible que la obra se haya encargado a una empresa y ésta subcontrate por su cuenta a los distintos gremios necesarios para terminarla. En definitiva, la responsabilidad última recae en la empresa principal.

#### **4.5.2 Obligaciones del locador de obra, contratista o prestador.**

Dispone el art 1.256 del CCC que el contratista o prestador de servicios está obligado a:

- a. "ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;
- b. informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;
- c. proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;
- d. usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;
- e. ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole. "

En caso de incumplimiento en tiempo y forma, el locatario puede optar por: dejar de pagar el precio; resolver el contrato; accionar por daños y perjuicios, o hacer ejecutar el contrato por un tercero o repararlo por un tercero.

La responsabilidad por ruina total o parcial se extiende, por vicio de construcción, vicio del suelo o mala calidad de materiales, haya o no el constructor provisto los materiales.

Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá producirse la ruina dentro de los diez años de recibida la obra, y el plazo de prescripción de la acción será de un año, contado a partir del tiempo en que se haya producido.

El artículo 1.272 del Código Civil y Comercial establece que, recibida la obra, el empresario quedará libre por los vicios aparentes..

Con relación a los vicios ocultos, es decir, los que no han podido ser advertidos en el momento de la entrega, el dueño tendrá la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1.054 y concordantes

#### **4.5.3 Obligaciones del locatario**

- Obligación de cooperación, por ejemplo, entregar los materiales a tiempo;
- Pagar el precio;
- Recibir la obra.

#### **4.6 Naturaleza de la vinculación profesional. Distintos regímenes**

La naturaleza de la vinculación profesional puede entenderse de forma que "...nos encontramos frente a una relación multiforme, que puede dar lugar a contratos de locación de servicios, o de locación de obra, o de mandato, según los casos, correspondiendo estudiar el contenido concreto de la relación jurídica, sin pretender unificar la calificación de todas las variedades de relaciones que nacen del ejercicio de las profesiones liberales. Cuando la actividad del profesional se desarrolla como función de colaboración permanente, con vínculo continuativo y con subordinación al empleador, aun cuando no haya dependencia técnica por la condición de profesional universitario, la relación ha sido caracterizada como contrato de trabajo. En el caso de los ingenieros, arquitectos y agrimensores, que es el supuesto del fallo en comentario, lo común es que la relación entre estos profesionales y sus clientes constituya una locación de obra (intelectual), cuando se promete un resultado: confección de un plano, dirección técnica, división de un inmueble para su urbanización, proyecto, mensura, etcétera. También puede presentarse como locación de servicios, cuando se conviene un asesoramiento en forma permanente, o por un tiempo determinado, a cambio de una retribución periódica, sin que ello

constituya un contrato de trabajo, que también puede presentarse cuando haya subordinación jurídica. El ejercicio independiente, autónomo de la profesión es considerado como propio de la locación de obra, aun cuando como hemos visto, es una característica también de la locación de servicios, por oposición al contrato de trabajo. Esta opinión no es compartida mayoritariamente por la jurisprudencia, que utiliza a menudo el criterio basado en la existencia o no de subordinación para distinguir la locación de servicios de la locación de obra, teniendo en cuenta que tanto la dirección técnica de una obra, como la confección de planos y proyectos pueden desarrollarse bajo ambos regímenes contractuales”.<sup>55</sup>

#### 4.7 Mandato

En el derecho civil el contrato de mandato tiene lugar cuando una parte otorga a otra el poder, que ésta acepta, para representarla con el fin de ejecutar uno o varios actos jurídicos en su nombre y por su cuenta (artículo 1.319 del Código Civil y Comercial). Este contrato puede ser oneroso o gratuito; pero se presume oneroso. Puede ser conferido expresamente o tácitamente si una parte sabe que otra está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo.

El mandato puede otorgar representación o no. En caso de otorgarla se actúa a nombre y por cuenta del mandante; pero indica el art. 1.321 del Código Civil y Comercial que “si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero, e igualmente el tercero en las acciones que pueda ejercer el mandatario contra el mandante.”

Deben distinguirse tres términos que serán encontrados en la vida profesional usados común y erróneamente como sinónimos, estos son “mandato”, “poder” y “representación”. Claramente de lo indicado resulta ser que el mandato es el contrato por el cual se vinculan el mandante y el mandatario. El poder es el documento de donde surge este contrato y su efecto que es, por lo general, la representación.

#### 4.8 Mutuo

El mutuo es aquel contrato en virtud del cual una parte entrega a la otra una determinada cantidad de cosas fungibles en propiedad, devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad (artículos 1.525 y ss. del Código Civil y Comercial). El mutuo es oneroso salvo que sea pactado lo contrario (art. 1.527 CCC).

---

<sup>55</sup>Quiroga, Eduardo Molina, ob. cit.



## 5. Comercio electrónico. Economía tradicional y la nueva economía de la sociedad de la información, ventajas, inconvenientes y desafíos

Podemos definir el comercio electrónico como un conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos (esto incluye el procesamiento y la transmisión de datos de todo tipo destinados a la comercialización).

El comercio electrónico incluye todo el abanico de operaciones que se realizan por las vías comerciales tradicionales, a las que se suman las operaciones propias del medio, que se realizan *online*.

En un sentido amplio, podemos incluir dentro de comercio electrónico a toda transacción realizada por medios electrónicos, ya sean fax, telefonía, EDI<sup>56</sup> o la Internet.

El comercio electrónico plantea diferencias, ventajas, dificultades y desafíos aún no solucionados. Las principales diferencias podemos encontrarlas en la observación de la evolución del comercio.

El comercio tradicional era llevado a cabo por comerciantes individuales, sociedades comerciales y entidades de derecho público y, finalmente, el último eslabón de la cadena era la comercialización al consumidor final en las ferias y mercados.

La evolución de la electrónica y la informática hicieron que se dé un giro en las transacciones y, basándose en sistemas cerrados, a los cuales se sometían por un contrato marco previo, algunas personas comerciaban confiando en dicho sistema. A este sistema se lo denominó EDI (Electronic Data Interchange). Es un sistema que une, por ejemplo, a entidades financieras o empresas de producción, tanto locales como de distintos lugares del mundo, que le confían sus operaciones; esta clase de sistemas encuentra su seguridad jurídica en acuerdos marco suscritos de forma tradicional.

Finalmente, la red de redes permitió el comercio electrónico actual, logrando abrir el mercado, local e internacional, a la participación de todo tipo de personas, incluso, en muchos casos, menores de edad, aunque para la ley de diversos países éstos suelen ser incapaces de comerciar.

---

<sup>56</sup>Electronic Data Interchange (EDI) es un intercambio de documentos comerciales entre computadoras de proveedores habituales, los cuales se encuentran en un formato estandarizado previamente definido. Las ventajas del sistema son la reducción de costos y errores humanos y el aumento de la velocidad, lo que redundaría en un mejoramiento de las relaciones comerciales. Los sistemas EDI son automáticos, por lo que los pedidos que realiza un destinatario se introducen en el sistema informático del proveedor sin necesidad de intervención del hombre. Para lograr esto existen varios estándares EDI, entre ellos, ANSI, Edifact, Tradacoms y XML, los cuales tienen diferentes versiones, por ejemplo, ANSI 5010 o Edifact versión D12, Release A. Esta estandarización debe ser previamente definida al negociar la utilización de este sistema, por lo cual se hace necesario un convenio marco entre las partes.

Esta nueva forma de comercio posee ventajas propias del medio involucrado: rapidez, reducción de costos, pluralismo, amplitud del mercado, etcétera. También posee desventajas: dificultad de identificación de las partes, ausencia de registración en papel, dificultad probatoria, problemas con la ley y la jurisdicción aplicable; en definitiva, inseguridad jurídica y desempleo dentro de algunas ramas tradicionales de comercio.

Se intenta resolver algunos de estos problemas con normas o reglamentaciones, como la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de Uncitral, que en su artículo 5° indica: "No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos". En igual sentido, la Ley de Firma Digital argentina, en su artículo 6°, considera documento digital a "...la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura".

### 5.1 Cuestión de la ley aplicable

La negociación comercial tradicional se lleva a cabo dentro de un ámbito determinado que establece, en principio, la ley y jurisdicción aplicables. Los domicilios de las personas involucradas también intervienen en dicho establecimiento.

Con el advenimiento del comercio electrónico, las partes que se ponen en contacto suelen estar en distintas provincias o incluso diferentes países, lo que implica diversos ordenamientos jurídicos en juego. Si el comercio electrónico se lleva a cabo dentro de la República Argentina no existe problema alguno; en cambio, si se efectúa a nivel internacional, las pautas de los códigos civil y comercial y procesal argentinos debemos estar a los artículos que expresamente tratan la materia.

Si la contratación es internacional, entonces, ¿cómo poder determinar qué ley se va a aplicar a una contratación electrónica? ¿Y quién será el juez ante una controversia? Ésta es una de las problemáticas que plantea este tipo de operaciones.

Factores tales como la localización de los proveedores de servicios, del contratante, del servidor donde se realiza la transacción, del lugar de entrega o cumplimiento (si éste no es *online*) y también las distintas legislaciones impositivas hacen que sea complejo determinar el lugar de celebración y ejecución de los acuerdos.

Para solucionar este interrogante, el derecho internacional privado toma en cuenta lo que se llama el *hecho jurídico relevante*, que permite determinar, en principio, la jurisdicción competente.

También existe en el ámbito internacional la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI o Uncitral, por sus siglas en inglés, como es mayormente conocida), que dictó la guía de incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, cuyo objeto es precisamente lograr unificar las legislaciones internacionales en este aspecto.

Los diversos artículos de la ley modelo tratan desde el ámbito de aplicación (a todo tipo de información usada en contexto de actividades comerciales, en forma de mensaje de datos, artículo 1) hasta glosarios de términos, reglas de interpretación, equivalencia funcional de los mensajes de datos con los mensajes en soportes tradicionales, proceso de oferta y aceptación y determinación de los domicilios o lugares de emisión y recepción de los mensajes para determinar la ley y jurisdicción aplicables.

Así, en este aspecto, siguiendo una reciente obra publicada por los doctores Altmark y Molina Quiroga, podemos decir: "Consideramos importante el contenido del ap.4., en la medida en que define o establece claros lineamientos para la definición del lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, estableciendo dos presunciones que permiten aportar a la definición, en los contratos telemáticos de las cuestiones vinculadas a la ley aplicable y el juez competente.

"Las presunciones mencionadas establecen, por un lado, que un mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento, mientras que se considerará recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo".<sup>57</sup>

Asimismo, en el ámbito europeo encontramos otras normas sobre comercio electrónico:

—La recomendación de la Comisión Relativa a los Aspectos Jurídicos del Intercambio Electrónico de Datos, del 19 de octubre de 1994.

—La directiva 20/31/CE sobre comercio electrónico en el ámbito interno.

## 5.2 Contratos cuyo objeto deba ser cumplido en la Argentina y legislación nacional.

Los artículos 2.650 al 2.653 del nuevo Código Civil y Comercial establecen un sistema para este tipo de situaciones.

Jurisdicción aplicable, no existiendo acuerdo entre partes, será:

---

<sup>57</sup>Altmark, Daniel Ricardo y Molina Quiroga, Eduardo, *Tratado de derecho informático*, tomo II, La Ley, 2012.

- a. "los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Si existen varios demandados, los jueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos;
- b. los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales; o los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado, siempre que ésta haya participado en la negociación o celebración del contrato. " (art. 2.650 C.C.C.)

Sin embargo, los contratos en cuanto a "su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones" (art. 2.651 C.C.C.) se por el derecho elegido por las partes con los límites impuestos en el mismo artículo.

Finalmente, en defecto de elección del derecho aplicable por las partes se estará a "las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Si no está designado, o no resultare de la naturaleza de la relación, se entiende que lugar de cumplimiento es el del domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de celebración. La perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la oferta aceptada". (art. 2652 C.C.C.)

Distinta solución se llega en caso de ser un contrato de consumo donde las disposiciones especiales de los art. 2.654 y 2.655 disponen la facultad al consumidor para elegir el fuero donde demandar (jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato). El derecho aplicase será el del domicilio del consumidor y como excepción el lugar de cumplimiento o de celebración, en ese orden.

Finalmente, en caso de ausencia de determinación del derecho aplicable por las partes, excepcionalmente, el juez a pedido de parte puede establecer "del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos" conforme el art. 2.653 C.C.C.

### 5.3 Prórroga de jurisdicción

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como los restantes códigos de procedimiento provinciales, prevé la prórroga de la jurisdicción en sus primeros artículos. Esto guarda consonancia con las actuales disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial. Así, el artículo 1º del CPCCN reza: "La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el artículo 12,

inciso 4, de la ley 48, exceptúese la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aun a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley".

Por su parte, el artículo 2° indica: "La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria".

Como regla general, el código observa las pretensiones de la demanda. El artículo 5° indica: "La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este código y en otras leyes, será juez competente:

"1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor.

"La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.

"2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

"3) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

"El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

- "4) En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
- "5) En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.
- "6) En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviere especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.
- "7) En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla.
- "8) En las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor. Si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiere celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.
- "En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el artículo 152 bis del Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción.
- "9) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.
- "10) En la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión.
- "11) En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social.
- "12) En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven, salvo en el proceso sucesorio o disposición en contrario.

"13) Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el del lugar de la unidad funcional de que se trate. (Artículo sustituido por artículo 2° de la ley 25.488 BO 22/11/2001.)"

Nótese que ni el Código de Procedimientos ni el Código Civil y Comercial prevén la posibilidad de demandar en el *forumactoris* (lugar del domicilio del actor), impidiendo, en algunos casos, el real acceso a la Justicia por la parte débil, salvo supuestos de consumo.

Esta complejidad de la situación torna útil recurrir a la solución arbitral en contratos internacionales. Así, se puede establecer la posibilidad de recurrir a un árbitro en caso de conflicto y determinar la legislación y procedimiento a utilizar. Esto conlleva grandes ventajas, como ser: la rapidez, la especialización, la eficacia del laudo y la reducción de sobrecarga de los tribunales ordinarios. La solución al conflicto, al que se denomina *laudo*, puede luego ser ejecutada en los tribunales ordinarios competentes.

Este tema se analiza más a fondo en el capítulo dedicado al derecho procesal.

Finalmente, para los supuestos de pretender hacer valer en nuestro país sentencias recaídas en otros tribunales extranjeros, debe estarse a lo que disponen los artículos 517 a 519 bis del CPCCN, que contemplan también lo relativo a los efectos de los laudos dictados por tribunales arbitrales extranjeros.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Artículos 517 a 519 bis del CPCCN: "Capítulo II - Sentencias de tribunales extranjeros. Laudos de tribunales arbitrales extranjeros. Conversión en título ejecutorio. Artículo 517. Las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan.

Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:

- 1) Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero.
- 2) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa.
- 3) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.
- 4) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino.
- 5) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un (1) tribunal argentino.

También debe considerarse la regulación de este aspecto en el ámbito del Mercosur; así, se destacan las siguientes resoluciones:

—Resolución 21/04 del Grupo Mercado Común referente a la defensa del consumidor en este tipo de contrataciones.

—Resolución Mercosur 34/06 de directrices para la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo de firmas electrónicas avanzadas en el ámbito del Mercosur.

—Resolución Mercosur 37/08 de reconocimiento de la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la firma electrónica avanzada en el ámbito del Mercosur.

#### 5.4 Antecedentes legislativos del derecho argentino

Existen algunos antecedentes en nuestro país que no han llegado a ser ley ni a tener estado parlamentario. Podemos mencionar:

---

Competencia. Recaudos. Sustanciación. Artículo 518. La ejecución de la sentencia dictada por un (1) tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.

Para el trámite del exequátur se aplicarán las normas de los incidentes.

Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos.

Eficacia de sentencia extranjera. Artículo 519. Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 517.

Laudos de tribunales arbitrales extranjeros. Artículo 519 bis. Los laudos pronunciados por tribunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores, siempre que:

- 1) Se cumplieren los recaudos del artículo 517, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdicción hubiese sido admisible en los términos del artículo 1°.
- 2) Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el artículo 737.



—Proyecto de ley de e-commerce (ingreso 24/10/2006, exp. 3.812/06 presentado por el senador Capitanich).

—Anteproyecto de ley de comercio electrónico de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este anteproyecto prevé reconocimientos y situaciones en consonancia con las referidas leyes, en especial con la Ley Modelo de la Uncitral. En lo relativo a la solución de conflictos, boga por recurrir en primera instancia al arbitraje, aunque sin llegar a privar al usuario de su derecho constitucional de acceso a la justicia.

—Los anteproyectos de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial.

### **6.1 Contratos informáticos. Concepto. Clasificación. Características específicas**

Los contratos informáticos son acuerdos cuyo objeto es propiamente un bien<sup>59</sup> o servicio informático. Al igual que los contratos electrónicos, los contratos informáticos dependen en su totalidad de la informática para existir.

#### ***Clasificación***

#### ***Tipos de contratación según forma de ejecución***

Según que el acuerdo y ejecución se produzcan en la red o por medios tradicionales:

1) *Indirecta*: adquisición de bienes tangibles que luego se envían físicamente según tradicionales canales de distribución.

2) *Directa*: pedido, pago, envío de bienes intangibles o tangibles (incluso servicios) se produce *online*.

#### ***Principales transacciones***

<sup>59</sup>Bien informático: hardware o software.

Compra o locación de bienes: tangibles e intangibles.

Locación de servicios: bancarios, tarjetas de crédito, asesoramiento profesional.

Suministro de información en línea: acceso a bases de datos, empresas, bibliotecas, etcétera.

Publicidad en la Internet (avisos en sitios, Google AdWords, spam, entre otros).

Juego: apuestas, juegos en línea.

Subastas electrónicas.

Aprovisionamiento electrónico.

Abarcan todo tipo de relaciones jurídicas:

a) Consumidor-consumidor.

b) Consumidor-empresa (ley aplicable: 24.240, de defensa del consumidor, y decreto reglamentario 1.798/94).

c) Empresa-empresa.

## 6.2. Contratos electrónicos. Definición. Caracteres

Se denomina *contratación electrónica* la que se efectúa a través de la utilización de elementos electrónicos. La voluntad y la formación del contrato se transmiten por dichos medios y debe emplearse el conocimiento técnico para su interpretación. Este tipo de contrato, a diferencia de los informáticos, tiene la característica de estar determinado por el medio de contratación y no por el objeto en el cual recae ésta. Cualquier contrato, salvo los *formales absolutos* que resulten incompatibles con el medio electrónico, puede llegar a ser contrato electrónico.

Como en todo contrato, tiene vigencia el principio de autonomía de la voluntad. Este principio se ve limitado por la característica que tienen muchos de estos contratos, de ser de adhesión o *click-wrap*, como la mayoría de los términos y condiciones de sitios o de licencias de programas en que la posibilidad de uso radica en la aceptación del ciento por ciento de las cláusulas contractuales. La interpretación de estos contratos se verá limitada por la legislación y

jurisdicción aplicables. En caso de que ambas partes sean argentinas, puede darse la situación ya referida de la regulación por la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, en cuanto a la interpretación de estos contratos, por la simultaneidad de comunicación entre las dos personas ubicadas territorialmente en lugares distintos, en algunos aspectos se los entiende, para la formación del consentimiento, como contratos entre presentes, y en otras ocasiones, se los entiende como contratos entre ausentes.

### 6.3 Formas de contratación electrónica

a) *Etapas de nacimiento*: el contrato nace de forma electrónica, pero su cumplimiento se realiza de forma material tradicional.

b) *Etapas de cumplimiento*: el contrato puede nacer y cumplirse en gran medida o en parte por medios electrónicos (contratación de un seguro, afiliación a un servicio y pago de cuotas o primas con tarjeta de crédito por la Internet); pero el resto de las prestaciones se realizan en forma habitual (acarreo de un vehículo, reparación, descuentos en algún servicio, etcétera).

c) *Totalmente electrónicos*: tanto la formación como la totalidad de las prestaciones se cumplen por medios electrónicos.

*Contratos celebrados por la Internet*: conforme lo estudiado, se les aplicarán todas las normas referentes a contratos civiles y comerciales. En cuanto a las formas, sigue rigiendo el principio de libertad de éstas (artículo 974 del Código Civil y Comercial).

Este tipo de contratación tiene como dificultades la identificación de las partes, la prueba del contrato y la cuestión de la ley y jurisdicción aplicables ya estudiadas.

#### Partes contratantes

La identificación de las partes reviste otra de las dificultades mayores a la hora de la contratación electrónica, ya que las legislaciones internacionales no son idénticas o incluso son inexistentes a este respecto.

Existen diversos sistemas de identificación de partes. Debe hacerse notar que sólo puede hablarse de capacidad para contratar una vez que es identificado el sujeto.

### Sistemas de identificación

- a) Tarjeta magnética.
- b) Clave magnética.
- c) Número de código.
- d) Palabra de orden.
- e) Reconocimiento del timbre de la voz.
- f) Impresión digital.
- g) Reconocimiento y memorización de la firma del usuario.
- h) Firma digital.

### Capacidad y consentimiento

El problema de la capacidad, luego de la identificación de las partes, reviste la misma magnitud que en cualquier comercio nacional o internacional tradicional, con la excepción de que la Internet posibilita realmente que cualquier persona comercie con cualquier otra en distintas locaciones del mundo.

Así, hay que atenerse a los tres sistemas de determinación de la capacidad:

- a) Según el domicilio de la persona o su nacionalidad.
- b) Según el lugar en que el bien objeto de la contratación se encuentre.
- c) Según el lugar de celebración del contrato.

Por otro lado, la formación *online* de este tipo de contrato presenta particularidades que hacen dificultosa la aplicación del tradicional mecanismo de oferta y aceptación visto anteriormente, considerando mayormente que los contratos son celebrados entre ausentes, pese a que puede ser inmediata la declaración de voluntad. Es así que resultan útiles y difundidos los contratos de adhesión arriba referidos. Por ello, la etapa precontractual, en este tipo de contrato,

reviste mayor importancia que las otras ya explicadas por las vías tradicionales, siendo esencial la documentación, en la mayor medida posible, por cualquier medio idóneo.

La legislación internacional ya mencionada prevé pautas que, a priori, dan un principio de orientación en la solución del tema.

### **6.3 Clasificación de los contratos informáticos según el objeto y el negocio jurídico**

*Según la materia del acto pueden corresponder a:*

*a) Equipamiento:* unidades centrales de procesamiento, periféricos para la entrada y salida de datos, el almacenamiento de estos datos, equipos para comunicaciones, etcétera.

*b) Software:* software de base (sistema operativo para que funcione el hardware y puedan circular los demás programas) y aplicativo (utilidades para trabajar).

*c) Servicios:* de análisis y diseño de sistemas a medida, programación, adecuación de locales e instalación, capacitación, mantenimiento (de equipos, de software), etcétera.

*Según el negocio jurídico que se celebre:*

*a) El contrato de venta:* del equipo informático o de programas.

*b) El contrato de leasing:* se funda en relaciones jurídicas establecidas entre el proveedor de material informático, la sociedad financiera o de *leasing* y el comerciante o industrial usuario.

*c) El contrato de locación:* de equipo informático o de programas.

*d) El contrato de mantenimiento.*

*e) El contrato de prestaciones intelectuales:* comprende los estudios previos, el pliego de condiciones, la formación de personal, el contrato llave en mano.

*f) El contrato de prestación de servicios.*

### Características particulares del contrato informático

Este tipo de contrato invierte, en alguna medida, la ecuación tradicional en la que quien ostenta mayor poder económico está en una posición dominante en el contrato. Así, los diferentes niveles de conocimientos técnicos entre las partes generan una desigualdad que puede viciar el consentimiento y acarrear la nulidad del contrato.

La doctrina, en salvaguarda de esta desigualdad, ha elaborado los conceptos de deber de información y consejo. Siguiendo en esta parte a los doctores Altmark y Molina Quiroga, podemos decir: "El deber de información que pesa sobre el usuario, encuentra su límite en la obligación de asesoramiento y consejo que corresponde al proveedor que asume en esta etapa precontractual un papel protagónico, ya que en la zona del mercado donde se distribuyen bienes y servicios de tecnología avanzada, el conocimiento técnico, el saber, es causa de desequilibrio en el negocio de cambio. [...] En los contratos informáticos, en caso de duda deben interpretarse en contra del proveedor del servicio, quien debe utilizar terminología clara, para no confundir al adquirente, ya que recae sobre aquél una obligación de información y consejo".<sup>60</sup>

La modalidad habitual en que se celebra este tipo de contrato es el uso de contratos de adhesión o predispuestos, por lo que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor deviene, en muchos casos, aplicable.

### Ejecución y características

La ejecución de este tipo de contratos tiene diversas etapas y características especiales; así, deberán producirse:

—Entrega física de equipos: entrega material de los equipos.

—Instalación y puesta en marcha: si nada se ha dicho se supone que es una obligación tácita del proveedor.

---

<sup>60</sup>Altmark, Daniel Ricardo, y Molina Quiroga, Eduardo, ob. cit., donde hay jurisprudencia de la SCJ de Mendoza, sala I del 5/2/1990, en los autos "Sistex S.A. c/ Oliva S.A., Valerio", que puede consultarse en *La Ley*, 1991-A, 404.

—Test de aceptación: verificación para comprobar que se superen exigencias preestablecidas.

—Aceptación o recepción provisoria: superado el paso anterior, se acepta y surge la obligación de pagar el precio.

—Garantías específicas.

—Compatibilidad: adaptabilidad del equipo y los programa entre sí.

—Escalabilidad: posibilidad del sistema de migrar a diseños superiores o arquitecturas distintas.

—Modularidad: aptitud para funcionar por módulos independientes, autonomía.

—Capacitación del usuario, asistencia técnica, mantenimiento preventivo y funcional.

## **7. Software. Licencias. Normas aplicables. Software libre. Nuevas licencias que surgen de la internacionalidad de la Internet**

Para hablar de *compraventa de software* o de *licencias* debemos empezar por definir el software como un “conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora” (cita del *Diccionario de la Real Academia Española* online).<sup>61</sup>

Asimismo, debemos hablar de *código fuente y objeto*; el primero es el conjunto de instrucciones del programa, y el segundo, el programa compilado propiamente dicho.

Como se verá en el capítulo relativo a la propiedad intelectual, la protección jurídica del software, según su naturaleza, recae en los derechos de autor. Es así como lo cree la doctrina internacional mayoritaria,<sup>62</sup> pese a que en los Estados Unidos los esfuerzos radicarón en centrarla como derecho de patentes.

De este modo, entendiendo que los softwares son creaciones intelectuales que tienen protección por derechos de autor, son libremente comercializables, como cualquier otro derecho intelectual, lo que permite al autor contratar en la forma que mejor considere las licencias de su creación.

<sup>61</sup> Puede consultarse en <http://www.rae.es>.

<sup>62</sup> Ver los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la ADPIC, celebrados en el marco de la Ronda Uruguay del GATT.

Comercialmente hablando, cuando se negocia y otorga una licencia de uso de un software propietario, lo que se otorga, por lo general, es el código objeto, por lo que el adquirente se verá obligado a usar el software tal y como se lo entregaron, sin posibilidad de cambio. Distinta es la solución cuando se realiza un desarrollo a medida, en el que la propiedad del desarrollo es de quien lo encarga y debe contemplarse la entrega del código fuente.

Por su parte, y como contrapartida de esta comercialización del software, existe el software libre (*free software*) y de código abierto (*open source*), que no implica que éste sea gratuito; sin embargo, sí implica que el usuario podrá hacerle mejoras, estudiarlo, modificarlo, actualizarlo y adaptarlo, ya que cuenta con su código fuente.

Este tipo de licencia también permite la posibilidad de distribuir el software o redistribuirlo, de forma onerosa o gratuita, siempre que se respeten los principios de libertades y restricciones con los que fue otorgada la licencia.

De esta forma, en contraposición con los derechos de autor o *copyright*, surge el *copyleft*, que le impide, a quien modifique un programa de software libre, imponer condiciones a los demás.

Este *copyleft* se basa en la adopción del sistema de licencia pública general (LPG o PGL en inglés, Public General License), que permite, con diversas variables, adaptar la licencia a los objetivos buscados por el autor, permitiendo la libre distribución y mejora del software, sin desconocer los derechos de autor del creador que, precisamente, le impiden a quien realice dichas mejoras cobrar por aquéllas o cambiar las condiciones legales originarias.

## **8. Prueba del contrato informático. Documentos. Clasificación. Otros medios de prueba que fija el CPCCN. Firma digital. Ley 25.506 y su decreto reglamentario 2.628/2002. Documento electrónico. Time stamping o sellado del tiempo**

Los contratos informáticos se prueban, como el resto del universo contractual, por cualquier medio, salvo los que requieran una forma solemne establecida por la ley que se ha mencionado anteriormente en la presente obra.

Para el análisis de los medios probatorios nos remitimos a lo visto sobre los distintos tipos de documentos en capítulos anteriores, y al capítulo de derecho procesal, dejando, únicamente, el estudio del documento electrónico y la firma digital para este acápite.

Para lograr un instrumento que posea la dinámica del hecho informático era necesario el estudio de los avances tecnológicos para llegar a un sistema que otorgara seguridad, al tiempo



que celeridad, y que permitiera identificar a la persona emisora de una declaración de voluntad con un cierto grado de certeza.

Las técnicas de autenticación existentes nos hablan de "criptografía simétrica, la biometría y la criptografía asimétrica o criptografía de clave pública...".<sup>63</sup>

De estos métodos, dos de ellos nos permiten ocultar los mensajes con sistemas de encriptación, que hacen que sólo sean, en teoría, descifrables para el receptor.

El sistema de criptografía simétrica, utilizado originariamente en conflictos bélicos desde la antigüedad,<sup>64</sup> consiste en el conocimiento del método y clave de encriptación por el emisor y el receptor. Si bien es un método muy seguro, sólo sirve cuando la contratación es entre partes habituales. Resultaría muy difícil ponerse de acuerdo en cada compra *online* con un vendedor desconocido en un método de encriptación para la negociación; de cualquier forma, este sistema es muy usado, por ejemplo, cuando alguien inserta un PIN en un cajero automático.

Por esta dificultad mencionada, surge el sistema de criptografía asimétrico. Éste responde a la utilización de un par de claves (una pública y una privada) que genera el usuario con un sistema diseñado a tal efecto, cuyas claves secretas se mantienen en absoluto y confidencial conocimiento del suscriptor.

Para que este sistema sea confiable y útil, es necesaria la intervención de organizaciones que certifiquen que las claves públicas (accesibles para todos, por lo general publicadas en la Internet) son auténticas y responden a una persona determinada. Para que dichas entidades puedan funcionar deben ser autorizadas por el Estado, esto es, para que el sistema goce de legitimidad, al igual que en el caso de la ley de firma digital en la Argentina.

Éste es el sistema que se utiliza en las firmas digitales o firmas electrónicas avanzadas (según la terminología del Mercosur y de la ley modelo de la Uncitral).

Finalmente, se presentan los medios biométricos de identificación personal como elementos para acreditar la autenticidad en sistemas de seguridad informática. Éstos, en realidad, sirven como complemento de los otros sistemas y brindan mayor seguridad que el uso, por ejemplo, de un PIN personal.

---

<sup>63</sup>Altmark, Daniel Ricardo, y Molina Quiroga, Eduardo, ob. cit.

<sup>64</sup> Se dice de que las primeras civilizaciones ya contaban con métodos de cifrado para su utilización en conflictos bélicos. Así se tienen datos del uso de la *escitala*, que no era más que un cilindro de un diámetro determinado donde se enrollaba una tira de papel. Allí se escribía el mensaje, en forma horizontal, el cual, una vez desenrollado, resultaba ininteligible hasta no ser nuevamente enrollado, en un cilindro de similares características. De esta forma, aun atrapando al mensajero, si no se sabía el método, el mensaje quedaba oculto para el enemigo.

### 8.1. Documento digital o electrónico

Hemos mencionado que, como contrapartida del documento tradicional escrito en soporte papel, se encuentra el documento digital, que consiste en hechos de la realidad o declaraciones de voluntad que se hallan registrados en un soporte, el cual, para poder ser interpretado por el hombre, requiere de la intervención de una computadora.

Para que el documento electrónico tenga validez, como documento privado, tiene que ser susceptible de comprobación o ser reconocido en juicio por la contraparte.

Comprobar que el documento refleja la declaración de voluntad implica que el mismo es auténtico, inalterado y que fue emitido por quien lo sostiene.

Mediante la creación de una firma electrónica que utilice un sistema de criptografía asimétrica o de clave pública, como, por ejemplo, el Digital Signature Algorithm (el cual se basa en la utilización de dos números primos que sean lo más grande posible), nos garantizaríamos los extremos de seguridad indicados.

La firma digital es un procedimiento que, por medio de una función matemática de *hash*,<sup>65</sup> genera una huella digital (o resumen) del documento a suscribir. A dicha huella se la cifra con la clave privada del suscriptor, lo que da por resultado la firma digital. El receptor, para verificar la autenticidad e inalterabilidad del documento, realiza el proceso inverso. Así, debe calcular el *hash* del documento recibido y, a su resultado, aplicarle la clave pública del emisor, y como resultado se obtiene, del programa de computación que realiza la comprobación, un informe sobre la autenticidad del documento y el certificado utilizado.

En virtud de la utilización de los números primos y de la función algorítmica, la relación entre las claves públicas y privadas, si bien existente, no es directa, por lo que lograr calcular una clave a partir de la otra y una firma digital conlleva un tiempo y costo considerables. Es por esto que, manteniendo actualizada la clave con la frecuencia que indica el certificado, se logra un grado de seguridad muy alto.

---

<sup>65</sup> Una función *hash* es una función matemática que tiene por objeto efectuar un resumen del documento a firmar. Así, realiza una compresión de éste en un bloque, de un largo predeterminado, que se manifiesta carente de sentido o vinculación directa con el documento originario, y se torna ilegible. El resultado de la función resulta irreversible, por lo que no se puede deducir el documento originario desde el *hash*.

Finalmente, para dar más transparencia y funcionalidad masiva al sistema, las entidades certificantes emiten, precisamente, certificados que consisten en documentos digitales que dan fe de que ambas claves, públicas y privadas, son de titularidad de la persona certificada.

Una vez firmado digitalmente, el documento electrónico tiene todos los requisitos y valor que un documento privado,<sup>66</sup> existiendo en la ley presunciones de autoría en contra del titular de la firma utilizada. Esta presunción es *iuris tantum*, por lo que admite la prueba del error, falsedad, violación o inexistencia.<sup>67</sup>

El requisito de escritura se ve satisfecho con un documento electrónico firmado digitalmente (artículo 3º), pero se encuentra prohibida su aplicación (artículo 4º):

• “a) A las disposiciones por causa de muerte.

”b) A los actos jurídicos del derecho de familia.

c”) A los actos personalísimos en general.

”d) A los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.”

Si la firma o método utilizado no surge de una entidad certificada habilitada por el Estado para funcionar, el resultado será una firma electrónica. Un documento firmado electrónicamente (sin firma digital) no tiene presunciones y corre por cuenta de quien lo alega el probar su verosimilitud. En todo caso, podrá ser utilizado como principio de prueba por escrito, dado que se

---

<sup>66</sup> Artículo 9º de la Ley de Firma Digital, que exige como requisito de validez: “Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos: a) Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; b) Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente; c) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado”.

<sup>67</sup> Artículo 7º: “Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma”.

Artículo 8º: “Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma”.

puede interpretar que el documento satisface el requerimiento de escritura, pero la firma electrónica no satisface el requerimiento de la firma (artículo 5° de la Ley de Firma Digital).

### **8.2. Time stamping o sellado del tiempo**

La firma digital identifica al creador del documento, da fe del contenido inalterable del mensaje, pero éste adolece aún de fecha cierta.

Para dotar a una firma digital de la fecha cierta indicada, o al menos de mayor certeza con respecto a ella, de forma tal que pueda afirmarse que a partir de determinado momento en el tiempo el documento digital firmado ya existía, surge el sistema de sellado del tiempo.<sup>68</sup>

Se trata de un procedimiento *online* que, con la utilización nuevamente del sistema de firma digital, otorga certeza de la existencia del documento y lo registra. Así como el sistema de firma digital requiere de la existencia de entidades certificantes para su existencia, el sellado del tiempo requiere también una autoridad de sellado del tiempo. Este organismo es una parte, tercero desinteresado en la operatoria originaria, que por su presencia comercial otorga confianza y certifica la existencia del documento en cuestión a partir de un cierto día y hora determinados.

Para que el sellado del tiempo funcione, debe seguirse una mecánica preestablecida. Primero, el usuario debe generar el hash del documento deseado y remitirlo a la autoridad de sellado del tiempo. Luego, dicha autoridad generará el sello del tiempo, con este hash y su firma propia, introduciendo el día y la hora desde una fuente confiable, y guardará copia de lo actuado en sus registros. Luego, remite el sello del tiempo al cliente para que lo agregue a su documento.

Mediante la comprobación de la autenticidad del sello y del documento se logra un alto grado de certeza sobre la fecha de creación. Aun así, de surgir dudas, mediante los medios probatorios tradicionales, se podrá requerir un informe del sellado a la autoridad que lo realizó, ya sea durante el juicio o en la oportunidad en que resulte necesario.

---

<sup>68</sup>A los efectos del sellado del tiempo se utiliza un protocolo, el Internet X.509 Public Key Infrastructure, Time-Stamp Protocol (TSP), que puede consultarse en <http://tools.ietf.org/html/rfc3161>.

## Capítulo 6. Delitos

### 1. Derecho penal. La responsabilidad penal

El artículo 19 de la Constitución Nacional, en su parte pertinente, prescribe que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados...”. El Estado tiene un gran poder represivo que se encuentra limitado por los lineamientos del citado artículo. Así, la intervención del Estado en hechos que ofendan el orden y la moral pública, o que perjudiquen a terceros, ocurre luego de producirse el hecho.

Por su parte, el artículo 18 de la Constitución Nacional indica: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Se deduce de lo indicado que las características del derecho penal son:

- Ser una rama del derecho público (aunque existan delitos que para su represión requieran de la acción privada, en principio no deja de ser derecho público).
- Ser un derecho que regula actos extremos que han escapado al ámbito de privacidad, según indica el artículo 19 de la Constitución Nacional.
- Ser un derecho de carácter sancionatorio. Requiere la existencia de una norma previa (artículo 18 de la Constitución Nacional) que prescriba la acción punible y la consecuencia represiva de dicha acción, existente en forma previa al hecho de la causa.
- Perseguir la tranquilidad y la paz social mediante la protección de los distintos bienes jurídicos tutelados.

Estas características nos muestran las diferencias del derecho penal con el derecho civil estudiado en capítulos anteriores. Hablando específicamente de éstas con relación a la responsabilidad, y dejando de lado toda la órbita contractual del derecho civil, encontramos lo

siguiente: para que un hecho caiga dentro de la órbita de la responsabilidad penal se requiere, conforme a sus caracteres, que posea cuatro elementos, de los cuales dos se encuentran en consonancia con la responsabilidad civil.

Es necesario que exista:

- Un acto humano, y como todo acto debe ser voluntario.
- Tipicidad: que el acto caiga dentro de algunas de las acciones que los tipos (normas) penales prescriben, las que deben ser anteriores al hecho del proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional).
- Antijuridicidad: al igual que con la responsabilidad civil, no debe existir otra norma, dentro del ordenamiento jurídico, que esté autorizando el acto.
- Culpabilidad: al igual que en derecho civil, dentro de la órbita extracontractual de las obligaciones, es requisito imputar el acto mediante el dolo o la culpa, no existiendo en este caso responsabilidad objetiva.

Cuando un hecho genera responsabilidad penal es altamente probable que también haya generado un daño resarcible dentro de la órbita civil. Dándose este supuesto, el Código Civil prescribe que, si existe un proceso penal que versa sobre los mismos hechos que un proceso civil, no puede resolverse este último sin antes existir sentencia en aquél (artículo 1.775 del Código Civil y Comercial).

Tampoco se podrá, luego de la condena del acusado en el juicio penal, contestar la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado (artículo 1.776 del Código Civil y Comercial). La misma solución será en sentido contrario de existir absolución (artículo 1.777 del Código Civil y Comercial).

Por último, se destaca la finalidad represiva del derecho penal en disonancia con la finalidad de reparación que persigue el Código Civil y Comercial. Así enseña el artículo 1.716 de ese cuerpo normativo: "La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código". Se destaca que el resarcimiento de los daños consiste en intentar reformar las cosas al estado anterior al hecho dañoso. Si esto fuera imposible, la indemnización se fijará en dinero. Esta última opción también la tiene el damnificado desde el mismo momento del inicio de la demanda (artículo 1.740 del Código Civil y Comercial).

### **1.1 Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas**

El derecho penal requiere que exista un acto humano que sea juzgado y penado. De esta forma, se deduce que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal sino que son sus

administradores y eventualmente sus empleados quienes serán responsables penalmente por el hecho que caerá dentro de esta órbita del derecho. Esto no implica que por hechos que sean delitos penales no exista responsabilidad de la persona jurídica, cuyo administrador o dependiente hubiese realizado el acto punible, es decir, la persona jurídica será solidariamente responsable, con el autor del delito, de las consecuencias en cuanto a la reparación del daño causado en la órbita civil; esa persona jurídica sólo puede ser llevada a juicio penal para pedir la indemnización por daños y perjuicios en dicho fuero.

## **2. Delitos informáticos. Definición**

Con el desarrollo del hecho informático y su transnacionalidad, gracias al exponencial crecimiento de Internet, encontramos dos cuestiones nuevas de estudio dentro de la órbita penal. En orden cronológico, primero surgieron los delitos comunes realizados por medios informáticos; y luego aparecieron delitos cuya tipicidad es propia del hecho informático y sus características.

Hablando de delitos informáticos, se han esbozado diferentes definiciones, tomando la mayoría de ellas la utilización de la tecnología como eje fundamental para diferenciar si un delito es tradicional o informático. De esta forma, podríamos definir el delito informático como *aquel para el que fueron necesarios y fundamentales el conocimiento y la utilización de las herramientas informáticas o telemáticas*; así como lo fueron también para su investigación o persecución. Algunos autores incluyen también dentro de la definición el supuesto de que se violen los derechos del titular del elemento informático, sea hardware o software.

La nota característica de los delitos informáticos es que suelen ser de difícil represión; esto es así por la especialidad y el conocimiento técnico que deben tenerse, tanto para cometerlos como para investigarlos. La persecución de estos delitos suele terminar en callejones sin salida, como, por ejemplo, una señal abierta de wi-fi, un cibercafé o un locutorio con acceso a Internet.

Además de esta primaria dificultad, la transnacionalidad del hecho informático genera que, muchas veces, se hallen en juego legislaciones de países donde a los delitos les falta la nota de tipicidad. Falta consenso internacional en la represión y persecución de los delitos informáticos. Finalmente, la virtualidad de las conductas, la evolución tecnológica rápida y la territorialidad del derecho penal hacen que estos delitos sean de difícil condena.

### **2.1. Delitos tipificados por la ley 11.723**

La ley 11.723, modificada por la 25.036, protege el software como creación intelectual; resultan de aplicación sus sanciones penales para el caso de la violación de la licencia de un

producto. El alcance del término software puede extraerse de la ley 25.922, donde se lo define como "la expresión organizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones, almacenadas en medio magnético, óptico, eléctrico, discos, chips, circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que una computadora o cualquier máquina con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, disponiendo o no de datos, directa o indirectamente" (artículo 5°).

En un primer momento, con respecto a la protección legal de la Ley de Propiedad Intelectual, se generaron dudas a la hora de establecer si los delitos que surgen de los artículos 71 y 72 de dicho cuerpo normativo eran de aplicación a los softwares. Este debate llegó a su fin con la aplicación de la ley en sentido positivo, con el fallo de la Corte Suprema en la causa "Autodesk".

Los artículos 71 y 72 regulan los delitos de defraudación, falsificación, copia ilícita, plagio, reproducción de copias no autorizadas por encargo de terceros, almacenamiento de ejemplares falsificados y copias no autorizadas e importación de ejemplares falsificados o copias no autorizadas.

### **2.1.1 Delito de falsificación**

La falsificación se encuentra normada en el artículo 72, inciso b): "El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto...". Quien realiza una duplicación de cualquier tipo intelectual, incluidos los logos, aplicando la marca e imitando envases, manuales, impresiones y cualquier otra característica que posea el original, comete el delito de falsificación. Para que se dé éste debe claramente intentar venderse el producto falsificado como original.

### **2.1.2. Copiado ilícito de obras o programas**

El artículo 72, inciso a), de la Ley de Propiedad Intelectual, regula varios delitos o acciones típicas en un mismo artículo. Así, tenemos: "El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabiente...". La figura trata tanto la simple reproducción (copiado de software) como la reproducción para su venta.

En cuanto al copiado, no es requisito que se tengan fines comerciales, y cae dentro de lo que comúnmente se conoce como *piratería individual*, que, por lo general, no se considera en



forma particular una conducta ilegal, lo que no implica que sea lícita. Es de destacar que si uno utiliza una computadora ajena en la cual los programas han sido instalados en violación de la ley y de las licencias, no comete delito, por cuanto el uso no se encuentra tipificado.

Para el supuesto de programas que se distribuyen en forma gratuita (freeware) a través de la red, no se comete delito por su copiado. Tampoco se comete delito en el caso de los programas tipo shareware, que exigen un pago luego de cierto tiempo, por cuanto, por lo general, su difusión es autorizada por el propio autor; en el supuesto de no abonarse la suma requerida a posteriori del vencimiento del plazo, implicaría únicamente una violación contractual de las cláusulas que se han aceptado para la instalación del programa, pero esto no cae dentro de la figura en análisis. Distinto es el supuesto, incluso en lo particular, de compra e instalación (copiado a la propia máquina y posesión del disco de instalación) de programas de dudoso origen, circunstancia que normalmente se detecta por el uso de números de serie genéricos o extraños, por ejemplo, una seguidilla de números uno. En este caso sí se está cometiendo el delito ya mencionado.

En cuanto al copiado ilícito con fines comerciales, se diferencia del analizado delito de falsificación en que no se simula el producto original, sino que es claramente una copia ilegal. Este último supuesto se puede dar generalmente en locales que venden computadoras nuevas con sistemas operativos ya instalados, pero no de fábrica, y diversos programas más, todos sin las debidas licencias comerciales. Si bien la compra del programa ilegal no es directamente delito, en caso de que éste sea comprado con consentimiento, el comprador podría hacerse partícipe del delito en estudio.

### **2.1.3. Copiado ilícito por exceso de autorización**

Existe también el delito que se configura por la edición o reproducción de mayor número de ejemplares que el que se encuentra autorizado a una persona. Este delito suele darse en empresas donde se requieren los productos originales pero se procede a la instalación de múltiples copias no autorizadas o de mayor cantidad de copias que las autorizadas comercialmente. La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 9º, autoriza a realizar una copia de salvaguarda de los originales.

### **2.1.4 Plagio**

El delito de plagio, por su parte, se da en el supuesto de que alguien "...edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de ésta o alterando dolosamente su texto". El plagio, como delito penal, consiste en la publicación dolosa de una obra ajena como propia. En el supuesto de que no existiera dolo en la intención sería simplemente

plagio civil, nos encontraríamos frente a un ilícito que generaría la obligación de reparar el daño causado (artículo 72, inciso c), de la Ley de Propiedad Intelectual).

### ***2.1.5 Reproducción de copias no autorizadas por encargo***

Este delito, normado en el artículo 72 bis, inciso c), de la Ley de Propiedad Intelectual, se configura por la reproducción de copias no autorizadas por encargo de terceros sin derecho a eso y mediante el pago de un precio. De no existir esta retribución económica se caería en los delitos mencionados anteriormente.

### ***2.1.6. Almacenamiento de ejemplares falsificados o copias no autorizadas***

El inciso d) del mismo artículo mencionado en el párrafo anterior pena al que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo. En este tipo de pena no existe la prueba de la finalidad de distribución o venta, bastan el simple almacenamiento o la exhibición de las copias para que se configure el delito. Queda a cargo del imputado demostrar la licitud de los ejemplares que se reputan falsificados.

El que con el mismo fin facilita la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes comete también delito (inciso b) del mismo artículo). Nuevamente, el fin debe ser el lucro y la finalidad que con la que el usuario las copias es esa. En este delito, tanto locador como locatarios son partícipes.

### ***2.1.7. Importación de ejemplares falsificados o copias no autorizadas***

Finalmente, el inciso e) del artículo en análisis tipifica como delito la importación de copias ilegales destinadas a la distribución al público. Es de destacar que la norma sólo habla de importación de copias y, vista la previsión expresa sobre la aplicación de analogía con interpretación excesiva en derecho penal, no queda contemplada dentro del tipo la exportación de copias ilegales.

## **2.2. Delitos comunes cometidos a través de medios informáticos. Concepto. Delitos tipificados por nuestro Código Penal**

Fue explicado más arriba que los delitos comunes pueden ser cometidos por medios informáticos. Así, se da el caso de delitos comunes en los que la inserción de la tecnología facilita o directamente faculta la comisión de éstos. Por ejemplo, son fácilmente identificables delitos contra el honor, como ser las calumnias e injurias contempladas en los artículos 109, 110 y 113 del Código Penal.

En el supuesto de que haya alguien que impute un delito que dé lugar a la acción pública en forma falsa (calumnia), tendrá una pena de prisión de uno a tres años.

En cambio, el que deshonrar o desacreditar a otro, será reprimido con multa o con prisión de un mes a dos años.

Finalmente, el que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de dichas falsedades. La norma al referir "por cualquier medio" incluye todas las opciones por lo que este delito puede cometerse a través de una página web, un correo electrónico o cualquier otro medio disponible en Internet.

### **2.3. Otros ilícitos tipificados en leyes especiales.**

#### **2.3.1 Alteración dolosa de registros del fisco nacional (ley 24.769)**

El artículo 12 de la Ley Penal Tributaria dice que tendrá pena con prisión de dos a seis años el que "...de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales informáticos del fisco nacional, relativos a las obligaciones tributarias o recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado". Este delito constituye uno de los llamados "de peligro", por cuanto no requiere la producción concreta del daño: basta la modificación dolosa del registro.

El bien jurídico protegido recae en las finanzas públicas nacionales y en lo relativo a los recursos de la seguridad social; se protege la intangibilidad de los registros o soportes informáticos del fisco nacional.

#### **2.3.2 Violación del secreto de las informaciones de personas físicas o jurídicas almacenadas en medios informáticos (ley 24.766)**

Durante el fin de la década del noventa se sucedieron las primeras normas que tenían en cuenta los ilícitos cometidos con la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). La primera norma fue la ley 24.766/97, de confidencialidad sobre

información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. Esta norma introduce la protección del secreto sobre las informaciones de personas físicas o jurídicas almacenadas en medios informáticos (bases de datos). La pena recae en la acción típica de usar la información confidencial en forma injustificada o divulgar/revelar el secreto con la sanción correspondiente al delito de violación de secretos (contenida en el artículo 156 del Código Penal, es decir, multa de \$ 1.500 a \$ 90.000 e inhabilitación especial de seis meses a tres años).

El ámbito de aplicación de la protección del derecho lo define el artículo 2° de la ley: "La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares". La protección recae sobre la información contenida en bases de datos privadas (para los registros públicos existe la normativa mencionada), y establece protección a la información secreta, confidencial, de la empresa y personas físicas.

## **2.4. Figuras penales tipificadas en la nueva ley de delitos informáticos**

### **2.4.1 Defraudación, robo de identidad.**

El fenómeno del robo de identidad se ha ido expandiendo junto al crecimiento de la tecnología digital. Estos avances en la operatoria delictiva debieron seguirse de una regulación eficiente. La primera problemática que se enfrentó se lo hizo mediante la sanción de la ley 25.930, que incorporó, como inciso 15 del artículo 173 del Código Penal, lo siguiente: "El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciese por medio de una operación automática".

Con esta redacción se busca garantizar la seguridad de operaciones con tarjetas de crédito o débito, protegiendo a los usuarios y empresas emisoras o bancos vinculados.

Como nos encontramos frente a una defraudación, el ilícito no se configura, no queda perfeccionado, hasta que se utiliza el medio elegido, ya que se requiere el perjuicio de toda defraudación. La mera tenencia de tarjetas mellizas, por ejemplo, no se ve alcanzada por esta normativa.

Esta figura dejó incólumes otros problemas, como la realización de transferencias no autorizadas para apoderarse de dinero electrónico y otras formas automatizadas sin que mediere la

utilización de tarjetas o de sus datos, y la falsificación, alteración, supresión o eliminación de datos o programas informáticos. Como sólo una parte de los delitos de phishing quedaba cubierta (cuando los estafadores obtienen datos de cuentas bancarias, claves de acceso al servicio de home banking o contraseñas), era necesario ampliar el tipo penal a otras formas de defraudación; esto motivó la sanción del inciso 16 del artículo 173 del Código Penal, por la Ley de Delitos Informáticos.

En el análisis de la norma, un gran problema constituía la redacción originaria del artículo 172 del Código Penal, que tipifica el delito de defraudación. Allí se indica que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad disimulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.

En el texto legal se observa que la acción típica era defraudar a otro. Este “otro” nunca podría haber sido un sistema informático, por lo que era difícil hacer entrar la violación de sistemas informáticos, por ejemplo bancarios, en el delito de estafa; quedaba el autor del ilícito libre de acción hasta que intentara sustraer el dinero por alguno de los medios tradicionales o efectuar una transferencia a un tercero, momento en que se apoderaría de la cosa ajena cometiendo un delito de hurto, que tiene una pena máxima de dos años, contra los seis que se tipifican en la estafa.

Esta problemática quedó solucionada con la incorporación del mencionado inciso 16 al artículo 173 del Código Penal, que quedó redactado de la siguiente manera: “El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos”.

Si bien la solución dogmática no aparece como adecuada por la inexistencia de otro como sujeto engañado, la norma proyecta la seguridad informática como voluntad del individuo, considerando estafa a la manipulación de los sistemas de seguridad. Esta solución fue buscada con fines de agravar la sanción para este tipo de ilícitos.

#### ***2.4.2 Violación de secretos y correspondencia***

La ley de reformas al Código Penal introduce también nuevas formas de cometer delitos de violación de secretos y correspondencia. Los antecedentes jurisprudenciales y otras legislaciones a nivel internacional llevaron a tipificar la violación del correo electrónico y de cualquier otro tipo de comunicación electrónica que antes de la sanción quedaba sin protección. De esta forma, el artículo 153 del Código Penal quedó redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un

despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

"En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.

"La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

"Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena".

"Artículo 155: Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos (\$ 1.500) a pesos cien mil (\$ 100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

"Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público."

El término *indebidamente* en el segundo párrafo del artículo 153 refuerza la consideración de ser un delito doloso, eliminando el temor de cometer este delito en forma culposa que tenían algunos empresarios del sector informático si sus sistemas de administración de correo desviasen un e-mail por contener un virus o porque algún filtro lo clasifica como spam. Discusión aparte se genera ante el acceso por parte del empleador laboral al e-mail institucional que utiliza su dependiente para constatar conductas concurrentes o contrarias al débito laboral de su empleado. Sobre este tema ya hemos insistido en varias oportunidades y congresos de derecho informático.

Fue en el Primer Congreso Iberoamericano de Investigadores y Docentes de Derecho Informático (CIIDI), desarrollado en abril de 2012 en Mar del Plata, que se dijo lo siguiente: "Mucho se ha discutido sobre el tema de la privacidad del e-mail corporativo en virtud de la palabra *indebidamente*, por lo que, conforme gran parte de la doctrina y jurisprudencia que a continuación se cita, lo *indebido* cae frente a la obligación del trabajador y a las reglamentaciones internas de la empresa que aclaren sobre ese respecto, previendo formas de control, dentro de la ley laboral".

Desde el punto de vista laboral, siguiendo lo expuesto y los avances introducidos en materia penal, puede destacarse lo siguiente:

“Mediante el mal uso del e-mail laboral (que puede formarse comúnmente con `sunombre@laempresadondetrabaja.com.ar`), puede verse afectada la imagen del empleador, toda vez que la comunicación va seguida del nombre de la empresa. Sería, por ejemplo, el caso de que se imprimieran bromas, difamaciones y/o pornografía en hojas membretadas de la empresa y luego se remitieran a compañeros o personas ajenas a la misma. Y es que uno no puede saber si dicho elemento termina en la papelería de reciclaje del *contacto* o si, en cambio, es *reenviado* de modo indiscriminado a otras personas, afectando sin límites la imagen referida.

“No solamente puede afectarse la imagen empresarial; sino que el mal uso de la tecnología en tales distracciones suele alterar el orden y normal desenvolvimiento de los trabajadores, llegando a generar en ocasiones susceptibilidades entre los mismos o situaciones de acoso por envíos indebidos de correos electrónicos entre los propios compañeros de trabajo”.

#### **2.4.3 Ingreso no autorizado a un sistema informático**

Este delito, creado por la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), fue incorporado como artículo 157 bis al Código Penal y reformado por la ley 26.388, cuyo texto, en su redacción actual, es: “Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que: 1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley. 3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno (1) a cuatro (4) años”.

También resulta penado el mero acceso a cualquier sistema o dato informático que se encuentre restringido (quedan excluidas las redes abiertas y los sistemas sin seguridad). Así, el artículo 153 bis dice: “Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros”.

#### **2.4.4. Inserción de datos falsos en archivo de datos personales**

La reforma de la mencionada ley agregó el delito de inserción de datos falsos en archivos de datos personales en el artículo indicado en el párrafo anterior. Éste reprime con prisión de un mes a dos años al que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos

personales. Es un delito doloso por cuanto requiere que el autor inserte los datos *a sabiendas*, aunque no sea él mismo quien físicamente realice la inserción de dichos datos. La pena es aún más grave, de seis meses a tres años, para el que sabiendo que existe información falsa contenida en el archivo de datos personales la proporcionare a un tercero. Si se deriva perjuicio para alguna persona la escala penal se ve aumentada en un 50 %. Finalmente, prescribe la norma que si el que realiza los actos es un funcionario público llevará, como accesoria a la pena de prisión, la de inhabilitación por el desempeño de los cargos públicos por el doble del término de la condena.

#### **2.4.5 La cuestión del delito de daño por medio del borrado o destrucción de programas o virus**

El artículo 183 del Código Penal en su redacción originaria reprimía con prisión de 15 días a un año a quien “destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.

Era por demás evidente la necesaria modificación de la norma para la inclusión de los daños cometidos por medio de borrado, destrucción de programas por causa de virus o cualquier otro sistema dañino. Históricamente la definición de cosa ha sufrido modificaciones que la propia tecnología obligó a aceptar. Hasta no hace mucho tiempo el hurto de energía eléctrica no era considerado delito por cuanto estaba en discusión si la energía realmente es una cosa. En igual sentido los bites de información podrían no ser considerados cosas, y en tal sentido no son susceptibles, penalmente hablando, de delito de daño o hurto.

La reciente reforma ha solucionado el problema de recepción típica a través de sus artículos 10 y 11, que incorporan un segundo párrafo al artículo 183 y sustituyen el artículo 184, respectivamente:

“Artículo 183(segundo párrafo): En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños”.

“Artículo 184: La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: [...]

”5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos.



"6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público".

Los términos *destruir* o *inutilizar* refieren a la situación en que se han borrado los datos o programas definitivamente, sin posibilidad de recuperación. La existencia de un back-up no cambia el resultado, puesto que el daño ya está realizado y su utilización implica la reparación de dicho daño.

Los verbos típicos utilizados (*vender, distribuir, hacer circular o introducir un virus*) son meramente de *peligro*; aunque en definitiva no se utilice el virus, el delito ya es punible.

#### **2.4.6 Delitos mediante redes P2P y su relación con los derechos de autor**

Resulta casi de conocimiento público que el usuario final, por lo general, no considera delito la violación de los derechos intelectuales que resultan de la descarga ilegal tanto de programas como de música o videos y películas. Sin perjuicio de eso, hemos estudiado claramente que constituye delito la copia ilegal de dichos productos, razón por la cual son vastas e intensas las negociaciones y los intentos de la industria discográfica y cinematográfica por regular este tipo de descargas, que en definitiva son producto de una modificación cultural.

Se inició este capítulo con la explicación de cómo el derecho penal termina constituyendo un límite al poder represivo del Estado o de los Estados; sin embargo, eso sería aplicable cuando los actos privados no afecten a terceros. Culturalmente hoy en día se considera que la música o las películas no poseen ningún tipo de derecho, tal vez por diversas causas económicas o de exceso de consumismo; pero esto, analizado desde el punto de vista del derecho, es una clara violación de la ley de propiedad intelectual. La dificultad radica, en última instancia, en una toma de conciencia, por cuanto, en rigor de verdad, es absolutamente imposible que los Estados persigan y castiguen con prisión este tipo de delitos, que por su masividad involucran a gran parte de la población. Es por esto que las soluciones se vislumbran más por el lado de un cambio comercial y cultural de consumo que por el lado de la represión, sin dejar de intentar, en casos claramente abusivos o de descargas con fines comerciales para venta de copias ilegales, la persecución del autor en el caso concreto.

### **3. Nombres de dominio y protección marcaria (ciberocupación de dominios)**

A los fines de interconectar las computadoras en Internet se utiliza un protocolo de comunicación común que se denomina Transfer Control Protocol /Internet Protocol (TCP/IP), que consiste en asignarle a cada una un número identificatorio que hace las veces de un domicilio

o ubicación en la red. Este conjunto de números es de difícil memorización, por lo que se los vincula con una serie de letras con sentido que resultan más fácil de recordar, llamadas *nombre de dominio*. Esto favorece tanto la presentación de contenidos en la red como su búsqueda. Por ejemplo, es mucho más sencillo recordar el ingreso al diario *Clarín* escribiendo *www.clarin.com.ar* que haciendo lo propio mediante números. Usted podría acceder al diario *Clarín* (al momento de la escritura de este libro) tipiando 200.42.136.212; pero claramente no es un método comercialmente aceptable por su poca practicidad.

Esta practicidad mnemotécnica de los nombres de dominio los emparenta con las marcas de servicios o productos, ya que pueden ser idénticos. Ambos son signos que guardan la misma lógica de creación, lo que puede originar conflictos que serán tratados en el capítulo referido a derechos intelectuales.

Ya hace años que la posibilidad de vender productos por Internet y hacer conocida una marca por dicho medio constituye un intangible comercial de gran valor. Esto permite captar clientela a lo largo del mundo de forma directa y económica. Si el negocio es ciento por ciento online este nombre se transforma en aún más necesario.

Esta situación confiere importancia a la regulación de los nombres de dominios y de las actitudes ilícitas con relación a éstos; sin embargo, pese a que también pueden constituir conductas disvaliosas, no han tenido recepción legislativa, por ejemplo el registro impropio de nombres de dominio (conocido como ciberocupación) o el spam (correo basura o publicidad no solicitada).

## Capítulo 7. Derecho empresarial<sup>69</sup>

### 1. Derecho comercial.

Es el maestro Isaac Halperin quien nos enseña que “el derecho comercial no es el resultado de una concepción dogmática del derecho privado, esto es, no se erige en rama de éste en razón de su propia naturaleza o método de investigación; sino que es el fruto de ciertas circunstancias históricas y económicas que producen su aparición como rama separada por insuficiencia del derecho común, desbordado por las necesidades del comercio, por falta de instituciones adecuadas para la regulación de su actividad”.<sup>70</sup>

La evolución que refiere el prestigioso autor hace que recaiga dentro de la consideración del derecho comercial todo supuesto de hecho al que la ley califica de mercantil. En cambio, si nos atenemos a una definición económica del comercio éste sería toda aquella actividad de mediación entre la oferta y la demanda, hecha con el propósito de lucro y destinada a realizar, promover y facilitar el cambio de bienes elaborados o no. En esta especialización también entraría la elaboración de dichos productos.

Es por lo indicado que profundizar sobre el alcance de la expresión *acto de comercio* nos introduce en el conocimiento de la materia mercantil. Originariamente este derecho era un derecho profesional surgido de usos y costumbres entre comerciantes que intercambiaban sus productos en las ferias y mercados. Con el tiempo, la introducción en el intercambio de personas ajenas a esta profesión obligó a empezar a referirse más al acto de comerciar que a la persona que lo ejerce.

En este orden de ideas, y con la evolución, la noción legal de comercio logró incluso exceder el concepto económico de éste, abarcando prácticamente todos los supuestos industriales, salvo la actividad agropecuaria, las industrias extractivas y la comercialización por operaciones inmobiliarias. También hay que agregar, como comerciales, los actos que en razón de su forma revisten carácter de comercio, como cheques, pagarés, letras de cambio, debentures y contratos que por su naturaleza o por la necesidad empresarial poseen carácter comercial (seguros,

<sup>69</sup> La adecuación inicial a la normativa del nuevo código fue realizada por la Srta. Florencia Diana. La corrección final es de coautoría con el Dr. Gustavo Oscar Blazquez.

<sup>70</sup> Halperin, Isaac, *Curso de derecho comercial*, volumen I, Editorial Depalma.

comisiones, depósitos, etcétera). Finalmente, también revisten carácter comercial los actos de las sociedades constituidas según la ley 19.550 de sociedades.

Actualmente con la reforma introducida por el nuevo Código Civil y Comercial aparentaría que la especialidad Comercial fue absorbida por el derecho Civil que vuelve a constituir un todo legal sin divisiones. La desaparición de toda referencia al "acto de comercio", al "comerciante" y a lo "comercial" en el nuevo Código y en la ley 26.994 parecieran justificar lo indicado.

Sin embargo, si analizamos el art. 320 del C.C.C. que dice: "Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de sus libros, como es establece en esta misma Sección...", resulta que de dicha norma surgen las siguientes consideraciones:

- A. -El término "comerciante" fue reemplazado por el de "empresario".
- B. -El término "acto de comercio" fue reemplazado por la "actividad económica organizada".
- C. -El derecho comercial ahora gira sobre el término económico de "la empresa", sin la cual no hay sociedad (art. 1º Ley general de sociedades

Ello, sumado al hecho que permanecen en vigencia las leyes comerciales que modificaban al código de comercio<sup>71</sup> hacen merecedor de un tratamiento separado de la materia comercial como se venía trabajando hasta el momento.

---

<sup>71</sup> Mantienen su vigencia, entre otras, las siguientes leyes comerciales: leyes 928 y 9463 (Warrants), 9644 (Prenda agraria), 11.867 (Transferencia de Fondos de Comercio), 17.418 (Seguros), 20.091 (Entidades de Seguros), 20.094 (Navegación, habiéndosele incorporado algunos artículos del libro Tercero del Código de Comercio derogado), Dec. ley 5965/63 (Letra de cambio y pagaré); 20.266 y 25.028 (Martilleros y Corredores, parcialmente), 20.337 (cooperativas), 20.705 (Sociedades del Estado), 21.526 (Entidades financieras), 21.768 (Registros Públicos), 22.315 (IGJ), 22.316 (Registro Público de Comercio de la Capital Federal), 22.362 (Marcas), 23.576 (Obligaciones negociables), 24.240 y modificaciones (Consumidor), 24.441 (Financiamiento, parcialmente), 24.481 (Patentes), 24.452 (Cheques), 24.522 (Concursos y Quiebras), 24.587 (Nominatividad), 24.766 (Confidencialidad), 25.065 (Tarjetas de crédito), 25.156 (Defensa de la competencia) y 26.831 (Mercado de capitales); Dec. 897/95 (Prenda con registro) y Dec. 142.277/1943 (Sociedades de Capitalización y Ahorro).

### 1.1. Concepto de empresa/empresario

“La característica actual es la de producción industrial en masa y de la comercialización por la contratación en masa, conforme a contratos tipo y de adhesión, modalidad impuesta por el gran número de negocios, para los cuales se dejan de lado las consideraciones o peculiaridades del caso aislado para someter a la generalidad a normas comunes para esa comercialización, con el añadido de la tendencia a la uniformidad de las cláusulas generales de los contratos tipo en la especie de tráfico a través de ciertas regulaciones sindicales de patronos. Esta producción y comercialización en masa requiere la organización de empresa. Por empresa se entiende, aceptando provisionalmente el concepto derivado del Código Civil italiano de 1942, artículo 2.082, actividad económica organizada (de bienes y servicios) para la producción o el cambio de bienes o de servicios.”<sup>72</sup>

La empresa es un conjunto de bienes de distinta naturaleza que sirve de sostén para la actividad del empresario; es instrumental, pero por su importancia se sobrepone a la persona del empresario.

### 1.2. Fondo de comercio

Hay autores que llegan a identificar los conceptos de empresa y fondo de comercio. Tal asimilación es errónea, aunque siguiendo el criterio objetivo podría darse la confusión con alguna facilidad. El fondo de comercio es un concepto de difícil aprehensión, habida cuenta de que no se conforma con un patrimonio separado, ni con uno de afectación. Así, pueden entenderse ambas nociones viendo la empresa como el concepto dinámico y el fondo de comercio como el concepto estático.

En el régimen de transferencia de fondo de comercio (ley 11.867) se entiende éste como un conjunto de fuerzas productivas, derechos y cosas que, tanto interior como exteriormente, se presentan como un organismo, con perfecta unidad para los fines a los que tiende, que no son otros que la obtención de beneficios en el orden comercial e industrial.

- Los elementos estáticos son incorpóreos (nombre, enseña, local, concesiones, inventos, uso exclusivo de marcas) y corpóreos (instalaciones, maquinarias, mercadería, etcétera).
- El elemento dinámico o funcional (más que elemento, cualidad del fondo) está constituido por su capacidad como organismo fructífero (crédito, clientela). Este elemento funcional que económicamente se objetiva en las ganancias que produce el fondo con relación al

---

<sup>72</sup>Halperín, Isacc, ob. cit.

capital o el giro, es el que la doctrina italiana denomina *avviamento*, que nosotros conocemos con el nombre de *valorllave*.

### 1.2.1 Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la ley de fondo de comercio lo da su artículo 2º: "Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, sea que se trate de enajenación directa y privada o en público remate, sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva, y uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso de que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realiza el acto".

Si en la transferencia se enajena el fondo de comercio o simplemente elementos aislados constituye una cuestión de hecho. La jurisprudencia requiere —en general— la transferencia del giro del negocio y de la clientela.

### 1.3 Títulos de crédito

Dentro de la mecánica del giro comercial se muestran insuficientes las formas de pago tradicionales de las obligaciones civiles que fueron analizadas en los capítulos precedentes. La dinámica comercial, por su agilidad, requiere instrumentos de cancelación de obligaciones que posean esa característica.

Vienen en auxilio de esta situación los títulos de crédito, los cuales son *el documento necesario para el derecho literal y autónomo expresado*. Son obligaciones incausadas que conforman un negocio unilateral, porque se encuentra exteriorizada la voluntad de una sola parte (deudora), expresada en el título. A la otra parte (acreedora) no le corresponde ninguna obligación a cambio, sino el derecho que le confiere el documento, bajo cargas que debe realizar, siempre en su propio interés y según lo legalmente establecido para cada especie de título. En realidad, el título de crédito proviene de algún origen determinado, sólo que a los efectos de facilitar su utilización como herramienta comercial de pago y crédito la ley lo dota de la posibilidad (única en el derecho) de que exista como *obligación incausada*.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Debe recordarse que la obligación debe contar con sus tres elementos esenciales: sujeto, objeto y causa. Los títulos de crédito se erigen como única excepción al precepto.

Los títulos de crédito existentes en la Argentina son: cheques comunes y de pago diferido, pagarés, facturas de crédito, cartas de porte terrestre, cartas de porte aéreo, conocimiento de embarques, documentos de transporte multimodal, certificados de depósito, acciones de sociedades anónimas y en comandita, bonos, obligaciones negociables, títulos de deuda, certificados de participación accionaria, etcétera. Centraremos el estudio en alguno de ellos y comenzaremos por el medio de pago de uso más común, el cheque.

### 1.3.1 Cheque

El cheque es una orden de pago mediante la cual una persona que tiene cuenta corriente en un banco ordena a éste pagarle una cierta cantidad de dinero a un tercero.

Existen por ley varios tipos de cheque, los que se pueden clasificar en:

- *Cheque común:* es una orden de pago a la vista, es decir, pagadera el día de su presentación y hasta 30 días después de la fecha de emisión.
- *Cheque de pago diferido:* es una orden de pago librada para una fecha en el futuro. Posee dos fechas, la primera es de libramiento y la segunda, de pago. Entre éstas puede mediar un plazo mayor a 365 días. El pago se realiza desde la segunda de ellas y por un plazo de 30 días.

*Transmisión:* los cheques se pueden transmitir y el modo en que se haga depende del tipo de cheque, mediante entrega, endoso (no más de dos) o cesión de créditos. Los endosantes asumen responsabilidad sobre el efectivo cobro del cheque en línea descendente en la cadena de endosos hasta el depositante.

Los cheques también pueden clasificarse en:

- *Cheque cruzado:* es un cheque al cual se le trazan dos líneas rectas paralelas y en diagonal en el frente. Al hacer esto el cheque no se puede cobrar en efectivo y sólo es posible depositarlo en una cuenta.
- *Cheque al portador:* así se denomina el cheque que no tiene especificado un beneficiario y puede ser cobrado por cualquiera que lo tenga en su poder. Recibir un cheque al portador (es decir, sin la orden o nombre de quien puede cobrarlo), si bien tiene la utilidad de poder transmitirlo sin la limitación de los endosos, no cuenta con la garantía

de que pueda ser ejecutado, en caso de falta de fondos o algún otro problema con el caratular, a quien lo endosara. En definitiva, no existe problema en recibir un cheque al portador de quien lo libra contra su cuenta; pero recibir un cheque de terceros sin que quien lo transmite lo endose tiene sus riesgos.

- **Cheque no a la orden:** es un cheque que sólo puede cobrar el beneficiario al cual fue hecho el cheque.
- **Cheque certificado:** el banco certifica que el cheque tiene fondos y hace la reserva de éstos hasta que sea cobrado. Es una garantía de que el cheque tiene fondos por el plazo especificado.
- **Cheque de caja:** es un cheque expedido por una institución de crédito para ser pagado en sus propias sucursales.
- **Cheque de viajero:** es el cheque expedido por una institución bancaria para ser pagado en alguna de sus sucursales dentro del país o en el exterior.
- **Cheque para acreditar en cuenta:** cuando un cheque tiene escrita la leyenda "para acreditar en cuenta", no podrá ser cobrado en efectivo y tendrá que ser depositado en la cuenta. A diferencia del cruzado suele indicarse el banco donde deberá depositarse el mismo.
- **Cheque en blanco:** el único requisito de validez del cheque que debe ser completado sí o sí por el librador es la firma. Un cheque que esté firmado con el resto de sus campos en blanco es válido y podrá ser completado por quien lo posea para su cobro. Si bien se utiliza en circunstancias de absoluta confianza y conveniencia no deja de ser una herramienta muy peligrosa.

### 1.3.2. Obligaciones negociables

Existen otras formas de financiación en las sociedades llamadas *obligaciones negociables*. Estas herramientas son títulos de deuda privada que incorporan un derecho crediticio que posee su titular respecto de la sociedad emisora.

El inversor al adquirir este título se constituye como acreedor de la sociedad con derecho a que se le restituya el capital más los intereses convenidos en un período de tiempo determinado. Las obligaciones negociables son una forma de incrementar el patrimonio social, sin estar atado a los instrumentos y tasa bancarias comunes. Asimismo es una forma de obtener recursos económicos que no constituye una pérdida de poder político, tal sería el caso de que si lo que se emitieran fueran acciones.

Las obligaciones negociables pueden ser emitidas en forma individual o a través de un programa global. Este último consiste en un procedimiento de autorización por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que permite al emisor —bajo determinadas condiciones generales—



solicitar una autorización marco por un monto determinado y por un plazo máximo de 5 años, para posteriormente hacer emisiones en una o más series en el momento en que lo desee dentro del lapso quinquenal.

Por ejemplo, en el momento de escribir este libro la recientemente expropiada YPF autorizó la emisión de un programa de obligaciones negociables por \$ 3.500 millones (u\$s 760 millones) para buscar financiamiento. Con ese objeto la gestión de Miguel Galuccio utilizó una autorización de la CNV que había obtenido la administración anterior (llevada adelante por la empresa Repsol y la familia Eskenazi). En junio de 2008 YPF había sido autorizada para emitir hasta u\$s 1.000 millones en obligaciones negociables. Emitió únicamente u\$s 100 millones de ese programa y postergó el resto. Para hacer más tentadora la adquisición de las nuevas obligaciones negociables, un mes atrás la empresa recompró la operación negociable que vencía en 2028. El 79 % de los acreedores se avino a cobrar antes, mientras que un 21 % no aceptó ese canje que pagó, por anticipado, el mismo valor con que fueron emitidas las obligaciones. Esto se utilizó como señal para los mercados, en un intento de mantener la "reputación" de la empresa y para diferenciar la próxima emisión de las hechas anteriormente. Todo esto constituye un claro ejemplo de financiación utilizando este tipo de herramienta comercial.

#### 1.4. Seguros

El seguro es un contrato que se establece con una empresa aseguradora. Dicho contrato, denominado *póliza*, contiene la obligación de la compañía aseguradora de mantener indemne al tomador del seguro si lo contrata para sí mismo o al asegurado si sufre algún daño en su persona (enfermedades o accidentes e incluso la muerte) o en algunos de sus bienes (automóvil, empresa, taller o casa) por cualquier motivo (robo, incendio, terremoto); el asegurado (o quien se haya designado como beneficiario) recibirá la cantidad de dinero acordada en la póliza. A este pago de dinero se lo conoce como *indemnización*.

##### 1.4.1. Prima

La contraprestación que recibe la compañía de seguros se llama *prima*. El pago de la prima es el requisito para la cobertura, al punto de que la falta de pago produce la inmediata falta de aseguramiento. Este pago suele ser de periodicidad mensual y surge del costo anual dividido en doce pagos.

La mayoría de las pólizas son genéricas y puede únicamente discutirse o acordarse una mayor o menor cobertura de imprevistos, lo que va a incidir en el costo de la prima. A mayor seguridad, mayor costo. Es importante analizar los alcances de la cobertura en las condiciones tanto generales como particulares.

La contratación de seguro puede hacerse tanto en forma directa como a través de agentes de seguros, productores de seguros o asesores de seguros. Éstos pueden ser personas físicas o bien asumir formas de personas jurídicas. Se dedican a acercar a quienes necesitan asegurar su vida o sus bienes a alguna empresa de seguros que puede brindarles las coberturas requeridas. Su misión no es simplemente la venta, sino que también brindan asesoramiento técnico a los asegurados y, además, cumplen funciones complementarias del contrato de seguro, como, por ejemplo, el cobro de primas, la recepción de siniestros, etcétera; son auxiliares de comercio. En la práctica el productor suele cotizar diversos seguros y proporcionar el más adecuado para la necesidad y los costos que el requirente está dispuesto a pagar por las coberturas; esto es más sencillo y práctico que pedir cotización en todas las compañías. Asimismo, la renovación automática de los seguros y la contratación a través del productor suelen facilitar todos los trámites, incluso en caso de siniestro.

Es importante tener en cuenta que por ley la denuncia del siniestro debe hacerse dentro de las 72 horas de ocurrido. El artículo 46 de la Ley de Seguros obliga al asegurado a comunicar al asegurador el acaecimiento de un siniestro dentro de los tres días de conocerlo. El artículo 47, por su parte, pena al asegurado con la pérdida del derecho de ser indemnizado en caso de retardo o mora en su obligación de denuncia prevista en el primer párrafo del artículo 46.

## 2. Contratos comerciales modernos. Canales de venta

La vida comercial exige una serie de contratos especiales que no son los vistos hasta ahora. Así, la empresa utilizará distintas figuras contractuales para su abastecimiento y distribución de mercaderías.

“Los bienes y servicios que se vuelcan al mercado tienen como destinatarios finales a los consumidores. Incluso los elementos de uso y maquinarias que utilizan las empresas son adquiridos para aplicarlos a la producción o intercambio de esos bienes y servicios. Uno de los problemas de la empresa productora, en una economía de mercado en permanente expansión, se refiere a la necesidad de llegar con sus productos o servicios al público, de modo eficiente, uniforme, ágil, con el menor riesgo y costo posibles, para lo cual debe competir en los grandes centros comerciales y en otros medios de venta directa, como consecuencia de la generalización de la venta en masa y de la publicidad masiva. De esto deriva, necesariamente, un incremento de los gastos de explotación y el aumento de la complejidad comercial, debido a la dispersión de la clientela, lo cual determina la necesidad de contar con adecuados canales de comercialización que permitan superar estas dificultades.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Farina, Juan M., *Contratos comerciales modernos*, Ed. Astrea, 2ª edición actualizada y ampliada, 1999.

## 2.1 Leasing

En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio (Artículo 1.227 C.C.C.N)

El artículo 1.228 del Código Civil y Comercial de la Nación prescribe que el objeto del contrato pueden ser: cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes, o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga facultad de dar en leasing. Existe como requisito que se pacte un precio, tanto del canon locativo como de la venta, aunque este último no esté determinado en el origen y sea determinable únicamente en el momento de realizar la opción de compra.

Es un contrato muy útil, por ejemplo, para obtener cantidades de cosas al costo de una sola, logrando una financiación de forma indirecta. Para dar un ejemplo, la inversión para dotar a una empresa de una flota de camiones es muy grande, por lo tanto es mucho más realizable a través de la contratación de un *leasing*, ya que el pago se desdobra en cuotas y, una vez obtenida la ganancia con la explotación de los vehículos, se cumple el plazo de la opción de compra.

## 2.2 Licencia

El contrato de licencia permite, al licenciante titular de una patente, de una marca, de un diseño o de un derecho intelectual, comercializarlo, autorizando a un tercero (licenciario) a su explotación por un precio en dinero llamado *regalía* o *canon*.

Es muy común que el contrato de franquicia incluya la utilización de derechos que podrían ser regulados por un contrato de licencia. Existen ambos contratos en atención a que no siempre la franquicia se muestra como el ideal a utilizar. Si lo que nos interesa es la reproducción de un objeto registrado bajo una patente, al que se le aplicará luego la marca propia del licenciario, el contrato a utilizar en la licencia no tiene nada que ver con el negocio de la franquicia.

Es de uso común en este tipo de contratación la limitación por unidades, por tiempo o por zona de comercialización.

## 2.3 Estimatorio o de consignación

A los fines de poder dotar un comercio de mercadería, no siempre es necesario adquirirla con anterioridad a su venta. Existe la posibilidad de realizar un contrato estimatorio en el que una

parte entrega una o varias cosas muebles a la otra, obligándose ésta a pagar el precio dentro de cierto plazo, salvo que restituya las cosas antes del vencimiento del término establecido.

La utilidad de este contrato radica en la posibilidad de abastecer el negocio sin la adquisición en firme de las mercaderías y ahorrando las sucesivas compraventas, pudiendo simplificarse por períodos. Las mercaderías recibidas por esta vía, si bien no son adquiridas en propiedad, llevan la autorización de su venta y posibilidad de lucro; únicamente deben abonarse las que se hayan comercializado en el período indicado en el contrato.

Si bien puede utilizarse en cualquier tipo de comercio, este contrato es típico de las librerías y puestos de diarios y revistas.

Se destacan como elementos de este contrato que la mercadería debe tener un valor fijado por el *consignante* (quien entrega la mercadería) y que debe existir un plazo establecido para su retorno por parte del *consignatario*, en el supuesto de no haber sido comercializada al vencimiento del término establecido.

El régimen de este contrato surge de los artículos 1.335 al 1.334 del Código Civil y Comercial.

## 2.4 Contrato de suministro

Cuando la relación comercial exige permanente provisión de mercaderías es conveniente suscribir un contrato de suministro. Con relación a la forma de cumplimiento de las obligaciones vista en el pago, existe la posibilidad de que dicho cumplimiento se ejecute en forma periódica (repitiéndose cada cierto tiempo en forma continuada).

Así, el Código Civil y Comercial de la Nación define que hay contrato de suministro cuando "el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministro a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas" (artículo 1.176)

El Código Civil y Comercial estipula un plazo máximo de veinte años, si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboración, o sin él, y de diez años en los demás casos. Computándose desde la primera entrega ordinaria (art. 1.177).

Los elementos de este contrato están determinados por las cosas definidas en su calidad y cantidad. Si la cantidad no se estipuló, se entiende pactada en función de la necesidad normal del comprador (art. 1.178 C.C.C.N.). Esto genera consecuencias ante la falta de suministro, ya que quien proporciona las cosas debe ser previsor y tener las cantidades necesarias para hacer frente a su obligación, siempre y cuando no se dé la circunstancia de que haya un pedido mucho mayor que la necesidad normal del comprador. Es bueno establecer las cláusulas necesarias para prever

las cantidades habituales y las consecuencias de los incumplimientos de suministro, visto que la obligación asumida por la persona que suministra, y por la cual el suministrado contrató, no consiste sólo en la entrega de los bienes objeto del suministro, sino también en la seguridad ofrecida de suministrarlos en tiempo y forma, según las necesidades del suministrado.

## 2.5 Canales de comercialización

Para poder comercializar su mercadería la empresa debe contar con una eficiente distribución. Así surge el problema de determinar cómo llevarla a cabo. "El vocablo *distribución* suele emplearse en el mundo de los contratos comerciales en dos sentidos: a) amplio, de carácter genérico, comprensivo de las diversas formas jurídicas mediante las cuales una persona o empresa coloca en el mercado bienes o servicios que genera otra empresa (agencia, concesión, etcétera), y b) estricto (o restringido) referido a un modo particular de vinculación entre la empresa productora y el sujeto que coloca los productos en el mercado (contrato de distribución). Para evitar confusiones consideramos útil emplear la expresión *canales de comercialización por terceros* (en vez de *distribución* en sentido genérico) para referirnos a todo contrato entre una empresa productora (o mayorista) y otra empresa (o persona física no ligada por un contrato laboral), que implica una relación estable, a menudo exclusiva, e importa el compromiso de colaborar para que determinados bienes o servicios se vendan en el mercado nacional o internacional, directamente al público consumidor o bien a otras empresas. [...] Se consideran formas principales de comercialización a través de terceros en el derecho mercantil argentino moderno la agencia, la concesión, la distribución en sentido estricto y el *franchising*."<sup>75</sup>

## 2.6 Contrato de distribución

Para efectuar la comercialización de mercaderías es esencial contar con la colaboración de otras empresas o personal con el fin de facilitar la llegada de los productos a los distintos clientes en la zona en que se elija comerciar. Para ello se recurre al contrato de distribución.

Una de las cláusulas comunes de este contrato es la de *exclusividad* (distribución exclusiva y excluyente para una región o país y producto). En virtud de esta cláusula y siendo que ésta fija la posibilidad de comerciar el producto en determinado lugar, a la mejor o peor venta que efectúe el distribuidor, este contrato suele pactarse por períodos anuales, renovables por idéntico plazo.

A los fines de que el distribuidor pueda obtener ganancias de los productos comercializados se pacta un descuento en su adquisición. Tampoco es extraño pactar mayores descuentos según el volumen de la operatoria.

<sup>75</sup>Farina, Juan M., ob. cit.

Por el lado de la protección de la empresa productora se suele garantizar la no competencia por parte del distribuidor, al que se le prohíbe vender productos de otras empresas, una suerte de prohibición de competencia.

## 2.7 Contrato de agencia

“Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada proponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución.

El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al proponente.

El contrato debe instrumentarse por escrito” (art.1.479 C.C.C.N).

El siguiente artículo prescribe que “el agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica, o respecto del grupo de personas, expresamente determinados en el contrato.”

La representación puede pactarse o no, por lo que hay que estar a la letra de cada contrato.

El agente tiene independencia y autonomía en la gestión (se auto administra y determina) con la que desarrolla su actividad. Ésta se encuentra limitada por las normas del Código Civil y Comercial, y las cláusulas contractuales que lo vinculan con la proponente.

El agente goza de estabilidad en su relación con la principal, al punto de haber derecho a indemnización por rescisión injustificada del contrato antes del vencimiento del plazo.

También goza el agente de una remuneración que se efectiviza mediante el pago de una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, o concluidos por el agente, si fuere el caso, conforme a los usos y prácticas del lugar de actuación del mismo; aplicable en los casos que no hubiese pacto expreso (art. 1.486).

Frente a los terceros es meramente un intermediario, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren caberle por aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.

## 2.8 Contrato de concesión

El contrato de concesión es similar al de agencia, pero con diferencias suficientes como para evitar la confusión. Si bien es frecuente identificar a ambos contratos, en el de concesión la

exclusividad de la zona es una excepción. En cuanto a la forma de desarrollar la actividad, el concesionario está mucho más ligado y sujeto a las disposiciones y órdenes del otorgante del contrato. El concedente dicta las normas del contrato y se establece una suerte de reglamento de la actividad.

El Código define: "Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido"(artículo 1.502 C.C.C.)

El concesionario adquiere en firme la mercancía de la casa representada, corriendo con todos los riesgos del transporte, el cobro y el saneamiento de la entrega al cliente.

El concesionario no es mandatario ni representante de la concedente y no promete resultado de la promoción y venta de productos y servicios. Sin embargo, suelen tener un cupo mínimo de ventas para mantener altos niveles de descuento en el momento de adquirir la mercadería.

## 2.9 Franquicia

No siempre un negocio exitoso surge de una idea brillante y original. Basta, a veces, repetir una idea y utilizar el camino ya recorrido por alguien antes. Surgen, entonces, las franquicias como posibilidad de repetir un negocio sobre la base de un modelo exitoso ya probado en su rentabilidad.

Este tipo de contrato consiste en una relación de cooperación permanente en la cual una de las partes (franquiciante u otorgante), titular de un conjunto de bienes y derechos, como el nombre comercial, marca o signos distintivos, diseños industriales y *knowhow* del negocio, otorga a la otra (franquiciado o tomador) el derecho de vender, distribuir y/o explotar comercialmente, asumiendo el riesgo, con limitación de un lugar o no, uno o varios productos y/o servicios, utilizando para ello la marca y la forma de realizar el negocio indicado. Así, el hecho de identificar el producto con una marca ya reconocida, con la imagen comercial y con los métodos del *knowhow* le garantiza al franquiciado un éxito comercial o, al menos, una clientela ya habitual.

Este contrato está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 1.512 y siguientes. El cuerpo normativo precisa: "Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la

prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado.”

El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.

El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado.

Es normal, también, que en un contrato de franquicia se pacte un control por parte del otorgante a los efectos de que el producto y/o servicio se realice o entregue con la misma calidad que la marca suele reflejar o garantizar. Es por esto común establecer una reglamentación de la actividad, con el objeto de proteger la marca, calidad y cualidad del producto y de su mercado, lo que suele delimitarse no sólo en el contrato mismo, sino también en anexos como los manuales operativos o de servicios.

### 2.10 Corretaje

A diferencia de los contratos de concesión y agencia, en el de corretaje se da una relación entre “una persona, denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes”.(art. 1.345 CCC)

### 3. Sociedades: sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Diferencias y similitudes. Beneficios de cada una. Organización, dirección y control. Trámites en la Inspección General de Justicia. Unión de sociedades: fusiones y adquisiciones. Grupos de control y *holdings*.

En la Argentina, las sociedades pueden estar conformadas, según lo estipula el artículo 1º de la Ley General de Sociedades n.º 19.550, por la organización de una o más personas que realicen aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. También exige la ley que se constituya de acuerdo con uno de los tipos (modos) previstos en la misma. Cada uno de estos tipos sociales tiene características distintas que los diferencian entre sí, con diversos aspectos que deben respetarse en cada caso. De esta manera, para que una sociedad sea



tal, el o los socios se obligarán a realizar aportes (dinero o bienes), participarán de las ganancias y soportarán las pérdidas.

Las formas jurídicas asociativas se generan ante la necesidad de los socios de unir sus voluntades y esfuerzos para organizarse colectivamente teniendo en mente la realización de un objeto común a desarrollar a través de la organización corporativa que se creará. Existen distintas formas jurídicas asociativas, que pueden clasificarse en civiles, comerciales y solidarias o mutualistas. Cabe destacar que en el caso de la sociedad unipersonal, el único tipo social que puede utilizarse es el de Sociedad Anónima, no pudiendo ser constituida por una sociedad unipersonal.

La existencia de la persona jurídica, como se ha visto en capítulos anteriores, produce la separación patrimonial entre el patrimonio de la persona jurídica y los patrimonios de los individuos que la forman. Las formas jurídicas asociativas se originan en el acuerdo de voluntades, es decir, en contratos societarios como requisitos de su inscripción (con excepción de la sociedad de hecho, pero precisamente ésta no tiene separación patrimonial).

De esta manera, surge la tradicional pregunta frente a un emprendimiento que un futuro profesional planea ejecutar: ¿cuál es el mejor tipo societario? La respuesta variará dependiendo de diferentes aspectos: cuántos socios tendrá la sociedad, cuál es el negocio que se va a realizar (algunos negocios por ley deben ser hechos por sociedades anónimas exclusivamente), de cuánto capital se dispone, qué riesgos económicos se asumirán, cuál es la dinámica del negocio o la necesidad de tomar decisiones y ejecutarlas rápidamente, gastos de constitución y mantenimiento, etcétera. Igualmente, se debe tener en cuenta que en algunos casos se puede mutar el tipo de sociedad constituida.

Los tipos sociales más comunes y utilizados son la sociedad de hecho (SH), la sociedad de responsabilidad limitada (SRL), la sociedad anónima (SA) y, ahora, la sociedad unipersonal. La sociedad de hecho se caracteriza por no tener instrumento constitutivo; éste no se firma por no ser necesario un contrato para formar una SH. Los socios pueden pactar libremente la forma de organizarse, pero por esta informalidad existe mayor responsabilidad frente a terceros. Se entiende que cualquiera de los socios es responsable en la misma proporción que los demás por el accionar de la sociedad y que cualquier socio representa, por su calidad de tal, y obliga a la sociedad con sus actos. La solidaridad de los socios por las obligaciones societarias es total, pues deben responder con todo su patrimonio.

Puede inscribirse este tipo societario ante la AFIP; es útil e ideal para emprendimientos pequeños que involucran bajo riesgo, altos niveles de facturación (ya que abona impuestos como cualquier sociedad legalmente constituida) e inversión de una suma moderada de dinero por parte de los socios. Es especialmente útil para justificar el trabajo de los socios dentro de un mismo local, que de lo contrario debería estar habilitado a nombre de uno solo de ellos, con el

inconveniente de tener que justificar bajo qué régimen jurídico presta tareas, en caso de, por ejemplo, una inspección de policía del trabajo del Ministerio de Trabajo.

La sociedad de responsabilidad limitada se constituye a través de un contrato social en el que se detallan todas sus características, de acuerdo con las pautas que da la Ley de Sociedades y las particularidades que quieren los socios. Los elementos básicos de estos contratos son: el nombre, la duración (hasta 99 años), el objeto (actividad), el capital social (dinero integrado por los socios en el momento de formar la sociedad), quiénes estarán a cargo de la administración, qué día del año cierra su ejercicio económico, formas de dejar de tener participación en la sociedad, ya sea por voluntad individual, fallecimiento o bien si los socios deciden dar por finalizada la sociedad. El capital social se divide en cuotas parte, y cada socio con su aporte adquiere determinada cantidad de ellas. El número de cuotas que cada socio posee es determinante a la hora de tomar decisiones y también fija el grado de responsabilidad patrimonial de cada socio.

Las decisiones se toman en las reuniones de socios, que deben quedar documentadas en un libro llamado *libro de actas*. Las resoluciones allí dispuestas van a ser ejecutadas por los gerentes, que pueden ser algunos de los socios o algún tercero ajeno a la sociedad designado en el contrato.

La SRL es recomendable cuando se trata de *pocos socios* en un proyecto en el cual suele no haber un aporte de capital muy grande y se quiere salvaguardar el patrimonio personal de cada socio, pues la sociedad responde según el aporte comprometido por cada socio y el efectuado.

La sociedad anónima se constituye a través de un contrato social que se denomina *estatuto*; al igual que en la SRL, en él están plasmados todos sus rasgos.

El capital social se divide en acciones. De éstas pueden existir diferentes tipos o clases que representan mayor o menor cantidad de votos en el momento de tomar decisiones y derechos distintos. Cada accionista tiene responsabilidad limitada por la cantidad de acciones que posee y por las características de éstas.

Existen tres órganos en las sociedades anónimas, y cada uno de ellos tiene distintas funciones. El órgano de gobierno es la *asamblea de accionistas*, en la que se decide y establece el rumbo de la sociedad.

Para concretar las decisiones de la asamblea y lograr la realización del objeto social existe un órgano de administración, el *directorio*. Los miembros del directorio permanecen en sus cargos durante tres ejercicios como máximo y entre ellos se elige al presidente, quien es el representante legal de la sociedad.

El *consejo de vigilancia* es el tercer órgano y está encargado de fiscalizar la gestión del directorio, entre otras cosas.

La SA es un tipo social que admite gran cantidad de socios y negocios complejos y es, además, el único tipo que admite el modelo de sociedad unipersonal. Es por eso que debe cumplir mayores requisitos que el resto de los tipos societarios y resulta más onerosa su constitución.

Tanto la SRL como la SA tienen como requisito previo a su existencia y funcionamiento la inscripción en el Registro Público de Comercio, que en la Capital Federal depende de la Inspección General de Justicia y en la provincia de Buenos Aires de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; en el resto de las provincias ese registro depende de diferentes organismos.

Los efectos de la inscripción son: dotar de existencia a la sociedad y de las capacidades comentadas en capítulos anteriores. Así, para los terceros, la sociedad nace desde la aprobación de su inscripción. A su vez, dicha inscripción sirve para que el Estado controle si se cumplen los recaudos de la Ley de Sociedades.

Los tipos societarios, al comienzo de su actividad empresarial, deben inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- (delegación correspondiente a su domicilio). Si corresponde también deben inscribirse en el organismo impositivo provincial, según su domicilio comercial.

Luego, deben inscribirse en la municipalidad correspondiente al domicilio donde se realizará el giro comercial.

Finalmente, las personas físicas y jurídicas que realizan actividad tributan a través del impuesto al valor agregado (IVA), que se calcula sobre la base del resultado obtenido por la diferencia del IVA compra e IVA venta, descontadas las eventuales retenciones. En otro orden, tributan el impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos relacionados con la actividad, ingresos, gastos y situación patrimonial personal y de la empresa.

Las personas pueden inscribirse en el monotributo cuando son pequeños contribuyentes. Según la actividad y el lugar del domicilio, también tributan el impuesto a los ingresos brutos, en relación con la facturación que tengan.

En definitiva, uno de los factores que pueden definir la elección de una forma jurídica puede residir en motivos impositivos.

También debe considerarse que el empresario individual asume por él mismo íntegramente el riesgo del emprendimiento y que su responsabilidad es ilimitada (del mismo modo que las sociedades de hecho).

La normativa propia del empresario individual es la del Código Civil y Comercial de la Nación y la del Registro Público de Comercio.

También existen otros factores menos evidentes que pueden llevar a optar por realizar un emprendimiento en forma personal o por elegir una figura societaria u otra, como las necesidades de inversión y las posibilidades de financiación.

Cuando la inversión inicial o a breve plazo es muy importante se torna necesaria la participación de un grupo de personas para enfrentarla; esto obliga a optar por formar una sociedad.

Si la inversión proviene del financiamiento externo, a través de, por ejemplo, entidades de crédito u otras instituciones financieras, hay que hacer notar que no suelen concederse créditos a empresas cuyo capital social sea elevado (de ahí las dificultades de financiación de algunas empresas individuales, de sociedades cooperativas y de sociedades de responsabilidad limitada de capital social mínimo) o que presenten avales o garantías personales solidarias, como se ha visto anteriormente.

#### **4. Establecimiento de una sociedad extranjera en la Argentina**

Las sociedades extranjeras pueden operar en la Argentina a través de la inscripción de una sucursal o filial en el Registro Público de Comercio.

Las filiales se crean mediante la constitución de una sociedad comercial. Los tipos más comunes, nuevamente, son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Tanto la sucursal como la filial están sujetas a un mismo régimen fiscal.

##### **4.1 Sucursal**

La Ley General de Sociedades considera sucursal a una descentralización de la casa matriz de una compañía. La sucursal es regida por las leyes del país de origen de su casa matriz y por consiguiente está autorizada a realizar todos los actos que le estén permitidos a aquélla. Como resultado de esta relación la casa matriz resulta responsable indirecta de las operaciones realizadas por la sucursal.

La sucursal no está obligada a tener un capital propio, aunque tampoco limitada para poseerlo. Es requisito que lleve su contabilidad separada de la casa matriz y que presente sus estados contables anualmente ante el Registro Público de Comercio de la jurisdicción donde se encuentra radicada. (en Capital Federal la Inspección General de Justicia).

Al ser una descentralización de la casa matriz, tener una sucursal es sencillo desde el punto de vista administrativo, toda vez que no deben llevarse a cabo reuniones de socios,

accionistas o directorio, así como tampoco es necesario llevar un registro de actas. Sin embargo, sí debe inscribirse tanto en la IGJ (e informar anualmente los cambios de su representante, si los hubiese, así como cumplir los requisitos documentales para obtener su autorización para funcionar; estos documentos deberán ser presentados debidamente certificados y legalizados por autoridad consular y con apostillado de La Haya) como en AFIP-DGI (impuestos) y la ANSES a los fines de lo referente a los empleados.

#### **4.2 Filial**

A diferencia de la sucursal, la filial es una entidad separada e independiente de la casa matriz. Es, en principio, una persona distinta de la originaria, por lo que tiene sus propios deberes y obligaciones, su capital social y su propia administración y dirección.

Es la filial la responsable ante terceros por sus obligaciones, a las que responde con sus propios activos. Aunque la casa matriz no es responsable por los actos de la filial, ha existido jurisprudencia que elimina esta división y acerca a la responsabilidad de la sucursal.

Para poder constituir una filial el trámite es similar al que debe realizarse para una sucursal. De hecho la sociedad extranjera debe previamente registrarse en la Argentina en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades, al solo efecto de participar como accionista o socio en una sociedad local.

### **5. Bolsas y mercados de valores**

La Bolsa de Comercio no es más (ni menos) que un mercado. En los mercados se negocian distintos productos, siendo el lugar donde se ponen en contacto compradores y vendedores. Así, la Bolsa es también un lugar de encuentro entre compradores y vendedores de activos financieros, las empresas, el Estado y los inversionistas.

Las empresas que necesiten dinero para obtener su financiación de forma que no sea la de solicitar un crédito bancario, pueden alcanzarlo acudiendo a la Bolsa y vendiendo activos financieros (acciones, bonos, obligaciones negociables).

Así, el mercado bursátil es un tipo particular de mercado, el cual está vinculado con las operaciones o transacciones que se realizan en las diferentes bolsas alrededor del mundo. En este mercado, según la bolsa de que se trate, se realizan intercambios de productos o activos de naturaleza similar, por ejemplo, las operaciones que se realizan con títulos valores como acciones, bonos o títulos de deuda pública, entre otros, se efectúan en la bolsa de valores.

Según la reglamentación de cada bolsa variarán los requisitos para que en el mercado bursátil intervengan y realicen las operaciones de intercambios distintas personas físicas o jurídicas (nacionales o extranjeras).

La gran ventaja que ofrece un mercado bursátil, además de otras, es que genera la posibilidad de que exista un mercado secundario donde se pueden intercambiar títulos valores, activos o productos que han sido emitidos por empresas o el Estado y que ya hayan sido adquiridos anteriormente por algún inversionista.

La intercomunicación de las bolsas de las distintas ciudades del mundo genera la aparición de mercados bursátiles, tanto a nivel nacional como internacional.

El desempeño, la evolución y la tendencia del mercado bursátil se miden a través de índices que reflejan los movimientos de variación en la oferta y demanda o la influencia de factores externos sobre los precios de los diferentes productos, activos o títulos.

## 6. Concursos y quiebras

Los procedimientos previstos en la Ley de Concursos y Quiebras sirven para cuando un deudor<sup>76</sup> se encuentra imposibilitado de enfrentar sus obligaciones normalmente, atento al *estado de cesación depagos*, derivado del hecho de que su patrimonio es insolvente. Esta ley prevé dos procesos universales en que se involucrarán la totalidad del patrimonio del deudor y la presencia de sus acreedores: el proceso concursal o preventivo y el proceso de quiebra o liquidatorio.

El régimen de concurso preventivo que instituye la ley 24.522 propicia que el deudor continúe al frente de la administración de sus bienes y le otorga la oportunidad de concluir con sus acreedores un acuerdo que, por ventajas que prevé la misma ley, le permite revertir la situación de crisis que derivó en dicho proceso.

En cambio, la *quiebra directa voluntaria*, solicitada por el propio deudor, y la *quiebra directa involuntaria*, solicitada por un acreedor, no le permiten a aquél seguir con la administración de sus bienes, por lo que se produce el cese en su actividad comercial.

---

<sup>76</sup> Pueden caer en concurso o quiebra: 1) Las personas físicas. 2) Las personas de existencia ideal de carácter privado. 3) Las sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. 4) El patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de los sucesores. 5) Los deudores domiciliados en el extranjero, respecto de bienes situados en el país. No son susceptibles de ser declarados en concurso aquellos excluidos expresamente por leyes especiales, por ejemplo, las AFJP.

En este supuesto se liquidarán los bienes del deudor para abonar a los acreedores, en la medida en que alcancen y a prorrata (si no alcanzaren para abonar a todos la totalidad de la deuda), el producido de los bienes. De este modo, se abonará respetándose las categorías y privilegios de los que cada acreedor sea titular.

También puede llegarse a la quiebra por fracaso del concurso preventivo presentado por el deudor.

Es requisito o presupuesto para la apertura del concurso preventivo el estado de *cesación de pagos*,<sup>77</sup> por cualquier causa que fuere.<sup>78</sup> Este proceso se sustanciará por ante la justicia ordinaria en lo comercial de la jurisdicción del domicilio del deudor, sin importar el origen o lugar de pago de sus deudas, y arrastrará todos los juicios que tenga radicados en su contra de cualquier jurisdicción del país.

## 6.1 Concurso preventivo

El concurso preventivo es el *proces* mediante el cual un deudor, hallándose en estado de cesación de pagos, procura arribar a un acuerdo con sus acreedores, en pie de igualdad, que le permita enfrentar y superar la crisis que atraviesa. La aprobación y la homologación judicial de este acuerdo implican la novación de las deudas. La oportunidad para presentar el concurso debe ser siempre anterior a la declaración de la quiebra del deudor.

### 6.1.1 Requisitos formales de la petición del concurso

El artículo 11 del cuerpo normativo en análisis dispone: "Son requisitos formales de la petición de concurso preventivo:

---

<sup>77</sup> Artículo 79: "Hechos reveladores. Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros: 1) Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor. 2) Mora en el cumplimiento de una obligación. 3) Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones. 4) Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. 5) Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago. 6) Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores. 7) Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos".

<sup>78</sup> Artículo 1º de la Ley de Concursos y Quiebras: "Cesación de pagos. El estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69" (los artículos 66 y 69 prevén el caso de concursos de agrupamientos de empresas).

"1) Para los deudores matriculados y las personas de existencia ideal regularmente constituidas, acreditar la inscripción en los registros respectivos. Las últimas acompañarán, además, el instrumento constitutivo y sus modificaciones y constancia de las inscripciones pertinentes.

"Para las demás personas de existencia ideal, acompañar, en su caso, los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, aun cuando no estuvieran inscriptos.

"2) Explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado.

"3) Acompañar un estado detallado y valorado del activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación, estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado de situación patrimonial debe ser acompañado de dictamen suscripto por contador público nacional.

"4) Acompañar copia de los balances u otros estados contables exigidos al deudor por las disposiciones legales que rijan su actividad, o bien los previstos en sus estatutos o realizados voluntariamente por el concursado, correspondientes a los tres últimos ejercicios. En su caso, se deben agregar las memorias y los informes del órgano fiscalizador.

"5) Acompañar nómina de acreedores, con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados o responsables y privilegios. Asimismo, debe acompañar un legajo por cada acreedor, en el cual conste copia de la documentación sustentatoria de la deuda denunciada, con dictamen de contador público sobre la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o documentación existente y la inexistencia de otros acreedores en registros o documentación existente. Debe agregar el detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación.

"6) Enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado, en cada caso, y ponerlos a disposición del juez, junto con la documentación respectiva.

"7) Denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar, en su caso, que no se encuentra dentro del período de inhibición que establece el artículo 59, o el desistimiento del concurso si lo hubiere habido.

"8) Acompañar nómina de empleados, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de la seguridad social certificada por contador público." (Inciso incorporado por artículo 1° de la ley 26.684 del Boletín Oficial del 30/6/2011.)

"El escrito y la documentación agregada deben acompañarse con dos (2) copias firmadas.



"Cuando se invoque causal debida y válidamente fundada, el juez debe conceder un plazo improrrogable de diez días, a partir de la fecha de la presentación, para que el interesado dé cumplimiento total a las disposiciones del presente artículo."

Frente a la presentación de este pedido el juez deberá pronunciarse dentro del término de cinco días. Puede rechazar el pedido por las siguientes causales:

- 1) No ser sujeto susceptible.
- 2) No haber dado cumplimiento a los requisitos formales indicados (artículo 11).
- 3) Encontrarse dentro del período de un año como inhibido, según el artículo 59.
- 4) No ser juez competente.

#### **6.1.2 Efectos principales de la apertura del concurso**

1) El concursado conserva la administración de su patrimonio, pero se encuentra bajo la supervisión del síndico del concurso.

2) Tiene prohibido realizar actos a título gratuito o que de alguna forma alteren la situación de los acreedores.

3) Debe solicitar al juez autorización para realizar sobre bienes registrables actos de disposición o locación de fondos de comercio, constitución de prenda, etcétera. También debe autorizarse todo lo que exceda la administración ordinaria del giro comercial.

4) Produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a la presentación del concurso que no esté garantizado con prenda o hipoteca.

5) No puede viajar al exterior sin previa comunicación al juez del concurso.

Desde el punto de vista de las tramitaciones judiciales que afectan o tienen por parte al presentante, deben radicarse ante el juez del concurso todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado. Quedan excluidos los procesos de expropiación y los de relaciones de familia. También se suspenden las ejecuciones de garantías reales hasta tanto se haya presentado el pedido de verificación y se prohíbe deducir nuevas acciones de carácter patrimonial por causa o título anterior a la presentación. También se mantienen las medidas precautorias trabadas, salvo cuando recaigan sobre bienes necesarios para continuar con el giro ordinario. Los juicios laborales deben verificar sus créditos, a excepción de los accidentes de trabajo.

La existencia del proceso concursal debe notificarse a los eventuales acreedores mediante la publicación de edictos durante cinco días en el diario de publicaciones legales de jurisdicción

del juzgado y en otro diario de amplia circulación que el juez designe. Por su parte, el síndico enviará a cada acreedor denunciado carta certificada haciéndole conocer la apertura del concurso, con indicación de su nombre, domicilio, horario de atención, la designación del juzgado y demás aspectos que estime de interés.

En virtud del proceso abierto, y para la debida formulación del pasivo concursal, todos los acreedores por causa o título de fecha anterior a la presentación deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos. En dicho pedido deben indicar monto, causa y privilegios; acompañar los títulos que documenten la deuda; fijar domicilio legal y pagar un arancel que sumará al referido crédito por cada solicitud que presente.

Los pedidos de verificación y las deudas denunciadas por el deudor, una vez vencido el plazo para formular observaciones, serán volcados por el síndico en un informe individual sobre cada solicitud que será presentado al juzgado. El juez dictará resolución declarando verificado el crédito y, de corresponder, el privilegio.

El síndico también deberá presentar un informe general donde constarán todos los activos, los pasivos, la fecha de cesación de pagos y un informe sobre la agrupación y clasificación que efectúe el deudor sobre sus acreedores. Luego de esto el juez dictará una resolución fijando definitivamente las categorías y los acreedores comprendidos en ellas que tiene el concursado.

Los acreedores pueden ser agrupados como quirografarios, quirografarios laborales y privilegiados.

Luego de la determinación el deudor tendrá un plazo de 30 a 60 días para presentar propuestas para cada categoría de acreedores, las cuales pueden diferir entre sí. De no presentarse propuesta se declara la quiebra. Las características del acuerdo al que se arribe se describen en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras:

“Las propuestas pueden consistir en quita, espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, en la que éstos tengan calidad de socios; reorganización de la sociedad deudora; administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores; emisión de obligaciones negociables o debentures; emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de garantías sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras sociedades; capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un programa de propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categoría, y en relación con el total de los acreedores a los cuales se les formulará propuesta. Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría, pudiendo diferir entre ellas. El deudor puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categoría, entre las que podrán optar los acreedores comprendidos en ellas”.

Para la aprobación del acuerdo la ley requiere un doble régimen de mayorías:

- De acreedores computables: *mayoría absoluta*.
- De capital: 2/3 partes del capital computable dentro de cada categoría. No serán computables como acreedores.

De no obtener las conformidades a su propuesta, será declarado en quiebra, salvo los supuestos especiales que admiten la apertura del procedimiento de salvataje (*cramdown*)<sup>79</sup> previsto en el artículo 48. El acuerdo preventivo que se presente por escrito ante el juzgado con las firmas certificadas será aprobado si dentro del plazo otorgado (período de exclusividad) obtiene la conformidad de los acreedores requeridos.

Luego de presentado el acuerdo, no mediando impugnaciones que sean procedentes, el juez lo homologará. De impugnarse válidamente deberá declararse la quiebra, observando el procedimiento previsto en el artículo 48. La homologación del acuerdo importará la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. El incumplimiento total o parcial del acuerdo dará lugar a que se declare la quiebra.

## 6.2 Quiebra

Existen diversas clases de proceso de quiebra. Éstas son:

- Indirecta: por fracaso del concurso preventivo, de acuerdo con las posibilidades vistas más arriba.
- Directa involuntaria: a petición de un acreedor.
- Directa voluntaria: a petición del propio deudor.

Según el artículo 83, si la quiebra es pedida por un acreedor, debe probar sumariamente su crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos y que el deudor es pasible de estar en quiebra por el artículo 2° de la ley. También debe probar, si su crédito tiene privilegio especial, que los bienes afectados no son suficientes para cubrirlo.

---

<sup>79</sup> *Cramdown*: es un procedimiento de salvataje de empresa limitado a sociedades por acciones, SRL, cooperativas y sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sean parte, con excepción de las compañías aseguradoras, mutuales, AFJP y las demás excluidas por leyes especiales, como las entidades financieras. Este proceso pospone la declaración de quiebra del deudor, vencido el período de exclusividad. Permite que terceros o acreedores obtengan un acuerdo preventivo al asumir los pasivos de la empresa mediante su compra.

Si la quiebra es pedida por el deudor, este pedido prevalece sobre el pedido de los acreedores, cualquiera sea su estado, mientras no haya sido declarada.

Debe cumplir con los requisitos que indica el artículo 86, que remite al artículo 11, incisos 2, 3, 4 y 5, y, en su caso, los previstos en los incisos 1, 6 y 7 del mismo artículo, sin que su omisión obste a la declaración de quiebra.

La fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos por el pedido de quiebra se retrotrae a dos años. Así, los actos realizados por el deudor durante esos dos años, considerados como período de sospecha, que consistan en actos a título gratuito, pago anticipado de deudas, cuyo vencimiento, según lo pactado, debía producirse con posterioridad a la quiebra, constitución de hipoteca o prenda, o cualquier otra preferencia, respecto de obligaciones no vencidas, que originariamente no la tenían, y actos celebrados con el fallido con conocimiento del estado de cesación de pagos, resultan inoponibles a los acreedores.

### **6.2.1 Efectos de la quiebra**

La declaración de quiebra tiene varios efectos; los principales, con relación a las obligaciones del fallido, son los siguientes:

- 1) Todos los acreedores quedan sometidos al proceso y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados.
- 2) Todos los acreedores deben verificar sus créditos.
- 3) Los acreedores hipotecarios o prendarios quedan fuera del proceso y pueden reclamar en cualquier tiempo el pago de sus obligaciones mediante la venta de la cosa sobre la que recae el privilegio.
- 4) Las obligaciones que contaban con plazo para su pago se consideran vencidas de pleno derecho en la fecha de la sentencia de quiebra. Para abonarlas se deberán descontar los intereses legales por el lapso en que se anticipa su pago.
- 5) Se suspende el curso de intereses de todo tipo, con las excepciones que tienen los créditos garantizados con garantías reales y con limitaciones.
- 6) El juzgado en que tramita la quiebra atrae todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido en las que se reclamen derechos patrimoniales.
- 7) El deudor es desapoderado de los bienes y de su administración.
- 8) El síndico debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, pudiendo otorgar recibos.
- 9) Se procede a la venta inmediata de los bienes perecederos.
- 10) Desde la fecha de quiebra, el deudor queda inhabilitado en forma automática y cesa al año de la fecha de sentencia de quiebra o de la fecha de cesación de pagos, que el juez podrá adelantar o extender según las circunstancias. Si mediare condena penal, durará el tiempo

impuesto por el juez que entiende en la causa. En el caso de quiebra de personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas que hubieren integrado sus órganos de administración desde la fecha de cesación de pagos. La inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo conversión o conclusión de la quiebra. El inhabilitado no puede ejercer el comercio, ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones.

Los artículos 189 y 190 disponen:

“Artículo 189. *Continuación inmediata.* El síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez, si aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del establecimiento. El síndico debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de las veinticuatro (24) horas. El juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación, con reserva de lo expuesto en los párrafos siguientes. Para el caso que la solicitud a que refiere el segundo párrafo del presente, sea una cooperativa en formación, la misma deberá regularizar su situación en un plazo de cuarenta (40) días, plazo que podría extenderse si existiesen razones acreditadas de origen ajeno a su esfera de responsabilidad que impidan tal cometido”.

“Artículo 190. *Trámite común para todos los procesos.* En toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir del pedido formal, un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para que en plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales. El informe del síndico debe expedirse concretamente sobre los siguientes aspectos:

"1) La posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento;

"2) La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha;

"3) La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad;

"4) El plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado;

"5) Los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse;

"6) En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación;

"7) Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación;

"8) Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.

"En caso de disidencias o duda respecto de la continuación de la explotación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico, para que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.

"El juez, a los efectos del presente artículo y en el marco de las facultades del artículo 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la explotación en marcha."

Definida por el juez la continuación de la explotación, el síndico o el coadministrador se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación. En caso contrario se procede a la Liquidación de los bienes.

Para poder efectuar esto último todos los acreedores por causa o título anterior a la declaración de quiebra deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos de forma similar a la producida en el concurso preventivo. De igual modo que en el concurso, el síndico realizará un informe individual y general sobre los acreedores y el estado de la quiebra.

Luego de aprobada la última enajenación de bienes el síndico deberá presentar un informe final que contenga:

- 1) Rendición de cuentas de las operaciones efectuadas, acompañando los comprobantes.
- 2) Resultado de la realización de los bienes, con detalle del producido de cada uno.

- 3) Enumeración de los bienes que no se pudieron enajenar, de los créditos no cobrados y de los pendientes de demanda judicial.
- 4) Proyecto final de distribución, con arreglo a la verificación y graduación de los créditos.

Presentado el informe, el juez regulará sus honorarios, y procederá a publicar edictos haciendo conocer la presentación del informe y la regulación de los honorarios.

Luego la quiebra será concluida por:

- a) Avenimiento: el deudor puede solicitarla con el consentimiento de todos los acreedores verificados.
- b) Pago total: la clausura de la quiebra se resolverá cuando se haya realizado totalmente el activo y se haya practicado la distribución final.

## **7. Derecho tributario. Impuestos de la persona física y jurídica.**

La Argentina es un país federal, de modo que existe potestad tributaria nacional y provincial, así como tasas municipales, con ciertas limitaciones, que terminan siendo verdaderos tributos (pese a ser técnicamente tasas retributivas por servicios públicos).

Los impuestos que toda persona física o jurídica debe abonar son:

### **7.1 Impuesto a las ganancias**

Este impuesto grava las ganancias obtenidas por las personas argentinas de existencia física o ideal y los residentes (que tributan por sus ganancias obtenidas en el país y en el extranjero). Los no residentes tributan exclusivamente sobre las ganancias de fuente argentina.

La ley enumera algunas presunciones acerca del origen de la fuente, las cuales, en algunos casos, no admiten prueba en contrario.

Las rentas se dividen en cuatro categorías que tienen deducciones específicas y formas de cálculo

- Primera. Renta del suelo: renta obtenida por locación de inmuebles urbanos y rurales.
- Segunda. Renta de capitales: originada por acciones, intereses, transferencia de llaves de negocio y otros intangibles, dividendos y utilidades, etcétera.
- Tercera. Renta de las empresas y ciertos auxiliares del comercio: se trata de la renta obtenida por las empresas, comisionistas, rematadores, consignatarios y otros auxiliares

del comercio, ciertos fideicomisos y otras rentas que no puedan encuadrarse en las restantes.

- Cuarta. Renta del trabajo personal: obtenida por el desempeño de cargos públicos, el trabajo en relación de dependencia, seguros de retiro privado y jubilaciones, servicios personales de los socios de cooperativas, el ejercicio de profesiones liberales, la dirección y sindicatura de empresas y las actividades de viajante de comercio y despachante de aduanas.

La mecánica para la determinación del gravamen varía según se trate de una persona física o jurídica.

La alícuota del tributo es gradual para las personas físicas y del 35 % para las personas jurídicas. La liquidación del tributo es anual, aunque se pagan anticipos mensuales.

El siguiente cuadro ejemplifica la aplicación del impuesto:

| Ganancia neta imponible |             | Pagan     |          |                          |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------------|
| Más de \$               | Hasta \$    | \$        | Más el % | Sobre el excedente de \$ |
| 0                       | 10.000,00   | 0         | 9,00     | 0                        |
| 10.000,00               | 20.000,00   | 900,00    | 14,00    | 10.000,00                |
| 20.000,00               | 30.000,00   | 2.300,00  | 19,00    | 20.000,00                |
| 30.000,00               | 60.000,00   | 4.200,00  | 23,00    | 30.000,00                |
| 60.000,00               | 90.000,00   | 11.100,00 | 27,00    | 60.000,00                |
| 90.000,00               | 120.000,00  | 19.200,00 | 31,00    | 90.000,00                |
| 120.000,00              | en adelante | 28.500,00 | 35,00    | 120.000,00               |

## 7.2 Impuesto a la ganancia mínima presunta

Según se determine y según el monto a pagar del propio impuesto a las ganancias, éste puede resultar complementario o un tributo aparte. Se determina sobre la base de los activos. Se



gravan los activos de los sujetos comprendidos en la tercera categoría (simplificando la aplicación), sin considerar los pasivos por estimar que todos los activos deben generar una renta, aunque existen exenciones y bienes no computables.

La alícuota es del 1 % y su liquidación es simultánea con el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que resulte determinado para el ejercicio fiscal por el cual se liquida el gravamen en estudio, puede computarse como pago a cuenta del impuesto de esta ley, una vez deducido de éste el que sea atribuible a los inmuebles no afectados a la actividad.

### **7.3 Impuesto al valor agregado**

Grava la venta de bienes muebles situados o colocados en el país, las obras y locaciones de servicios prestados en el país (con algunas exclusiones), las importaciones definitivas de cosas muebles y las importaciones de servicios.

Quien se encuentra inscripto en el IVA y adquiere bienes y servicios por los que se le liquidará el tributo, computará por éstos un crédito fiscal.

Luego, al vender bienes o prestar servicios, facturará éstos adicionando el tributo correspondiente, es decir el débito fiscal.

Finalmente, abonará la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal.

La alícuota general es del 21 %, y existe una alícuota reducida del 10,50 % para ciertos bienes de capital y de primera necesidad, y una incrementada del 27 % para ciertos servicios públicos.

La liquidación es mensual, salvo para algunas situaciones especiales.

### **7.4 Impuesto a los bienes personales**

Se determina sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año; son sujetos pasivos del tributo las personas físicas y las sucesiones indivisas.

Los bienes deben valuarse conforme lo indica la ley, a lo que se le adiciona un rubro residual que consiste en una presunción relativa a bienes personales y del hogar, equivalente al 5 % de la totalidad de los bienes, con algunas exclusiones. La tabla de alícuotas es la siguiente:

**Valor total de los bienes gravados, alícuota aplicable**

Más de \$ 305.000 a \$ 750.000 -----0,50 %

Más de \$ 750.000 a \$ 2.000.000----- 0,75 %

Más de \$ 2.000.000 a \$ 5.000.000----- 1,00 %

Más de \$ 5.000.000 ----- 1,25 %

La liquidación es anual, con pagos de anticipos bimestrales, de corresponder.

**7.5 Monotributo**

Existe la posibilidad de empezar un emprendimiento inscribiéndose en la categoría para pequeños contribuyentes, en la que se podrá pagar un tributo integrado que comprende el impuesto a las ganancias y al valor agregado, obra social y aporte previsional, abonando un canon fijo según ciertos parámetros.

De esta forma quedan exceptuados de tributar los impuestos mencionados y exentos del impuesto a la ganancia mínima presunta.

La forma de determinar el impuesto es la siguiente: (fuente página web afip)

| Categoría | Ingresos Brutos  | Actividad                       | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado (**)                  |                        | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total                                    |                        |
|-----------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                  |                                 |                              |                   |                                        |                                           | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |                       |                            | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles |
| B         | Hasta \$ 48.000  | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 30 m2       | Hasta 3.300 KW                         | Hasta \$ 18.000                           | \$ 39 (****)                             |                        | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 519                                   | \$ 519                 |
| C         | Hasta \$ 72.000  | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 45 m2       | Hasta 5.000 KW                         | Hasta \$ 18.000                           | \$ 75                                    |                        | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 555                                   | \$ 555                 |
| D         | Hasta \$ 96.000  | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 60 m2       | Hasta 6.700 KW                         | Hasta \$ 36.000                           | \$ 128                                   | \$ 116                 | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 605                                   | \$ 588                 |
| E         | Hasta \$ 144.000 | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 85 m2       | Hasta 10.000 KW                        | Hasta \$ 36.000                           | \$ 210                                   | \$ 194                 | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 680                                   | \$ 674                 |
| F         | Hasta \$ 192.000 | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 110 m2      | Hasta 13.000 KW                        | Hasta \$ 45.000                           | \$ 400                                   | \$ 310                 | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 880                                   | \$ 790                 |
| G         | Hasta \$ 240.000 | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 150 m2      | Hasta 16.500 KW                        | Hasta \$ 45.000                           | \$ 550                                   | \$ 405                 | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 1.030                                 | \$ 885                 |
| H         | Hasta \$ 288.000 | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 200 m2      | Hasta 20.000 KW                        | Hasta \$ 64.000                           | \$ 700                                   | \$ 505                 | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 1.180                                 | \$ 985                 |
| I         | Hasta \$ 400.000 | No excluida                     | No se requiere               | Hasta 200 m2      | Hasta 20.000 KW                        | Hasta \$ 72.000                           | \$ 1.500                                 | \$ 1.240               | \$ 157                | \$ 323                     | \$ 2.080                                 | \$ 1.720               |
| J         | Hasta \$ 470.000 | Únicamente Venta de Bn. Muebles | 1                            | Hasta 200 m2      | Hasta 20.000 KW                        | Hasta \$ 72.000                           | No aplicable                             | \$ 2.000               | \$ 157                | \$ 323                     |                                          | \$ 2.480               |
| K         | Hasta \$ 540.000 | Únicamente Venta de Bn. Muebles | 2                            | Hasta 200 m2      | Hasta 20.000 KW                        | Hasta \$ 72.000                           | No aplicable                             | \$ 2.350               | \$ 157                | \$ 323                     |                                          | \$ 2.830               |
| L         | Hasta \$ 600.000 | Únicamente Venta de Bn. Muebles | 3                            | Hasta 200 m2      | Hasta 20.000 KW                        | Hasta \$ 72.000                           | No aplicable                             | \$ 2.700               | \$ 157                | \$ 323                     |                                          | \$ 3.180               |

## 7.6 Otros tributos

Existe gran variedad de otros tributos. Por citar algunos podemos indicar:

- Impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras: grava los débitos y créditos bancarios y ciertos movimientos en efectivo. La alícuota suele ser del 0,6 % por movimiento, lo que indica que para ingresar y sacar plata de una cuenta corriente con el depósito y retiro del fondo de un cheque se llega a un impuesto del 1,2 %. El 34 % de este impuesto puede computarse como pago a cuenta, vía compensación, para el impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sus respectivos anticipos.
- Impuesto a la transferencia de inmuebles: grava la transferencia de inmuebles, efectuada por personas físicas o sucesiones indivisas, que no esté gravada por el impuesto a las ganancias, con una alícuota del 1,5 %.
- Impuestos internos:
- Impuesto sobre los combustibles líquidos.
- Impuesto a los premios de sorteos y concursos deportivos.
- Cine, video, radio y TV.
- Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación, etcétera.

### 7.7 Impuestos provinciales

Las provincias conservan la facultad de aplicar determinados impuestos en su jurisdicción. Las direcciones de renta de cada una los fiscalizarán y recaudarán. Por lo general éstos son:

- -Impuesto de sellos: aplicable a los contratos.
- -Patentes: gravan los automotores.
- -Inmobiliarios: gravan los inmuebles.
- -Impuesto a los ingresos brutos: puede verse afectado por el régimen de convenio multilateral.

## Capítulo 8. Propiedad intelectual

### 1. Derechos intelectuales

Hemos visto en capítulos anteriores que la persona posee distintos tipos de derechos, entre los cuales estaban los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual nos estamos refiriendo, por un lado, a un derecho patrimonial, que nos permitirá realizar diversos contratos y obtener algún tipo de lucro o no; y, por el otro, a un derecho extrapatrimonial, que se da en lo referente a la paternidad en la creación de obras, para lo cual nos debemos referir, en primera instancia, a los derechos de autor. Estos derechos intelectuales abarcan todo lo referente a la propiedad intelectual o artística (ley 11.723), al derecho de marcas (ley 22.362) y al derecho de patentes y modelos de utilidad (ley 24.481), pudiendo también incorporarse el derecho a la información confidencial (ley 24.766) y lo referente a contratación de transferencia de tecnología.

#### 1.1 Naturaleza jurídica

El derecho intelectual es un derecho de dominio, por lo cual se podrá ejercer sobre la cosa con el derecho todos los actos que la ley no prohíba. El artículo 2.506 del Código Civil enseña: "El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona". La duración de este derecho, según se trate de obras, marcas o patentes, es distinta y se encuentra legislada en cada una de las leyes indicadas en el párrafo anterior, obedeciendo las diferencias a distintos intereses jurídicos, que se explicarán más adelante, en cada caso.

#### 1.2 Derechos de autor

Introduciéndonos en el derecho de autor, podemos definir su objeto de protección, *la obra*, como lo hace el artículo 1º de la ley 11.723: "A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales...".

Debe destacarse que la protección del derecho de autor abarca la expresión de las ideas, procedimientos, métodos de operación, conceptos matemáticos; pero no a las ideas, métodos y conceptos en sí mismos (artículo 1º de la ley 11.723 in fine). Se protege la exteriorización original de una idea que tiene una integridad individual plasmada en una obra, pero no la idea en sí misma.

Así puede entenderse la gran similitud de historial artístico, como ser cine, teatro, música, etcétera, que tratan siempre sobre la misma idea. Canciones de amor, novelas de desengaño, operas clásicas, todas girando en torno del mismo concepto; pero todas con diferencias en la *expresión* y siempre con distintos estilos, distintas palabras, distintas melodías, siendo así perfectamente legales y pasibles de protección del derecho de autor.

Entonces quien crea la exteriorización de la idea en la obra resulta ser el *autor* de ésta y, en consecuencia, es también el sujeto de la protección del derecho de autor. Pero, ¿quién es en definitiva el titular del derecho de autor? Quien crea la obra lo será, en principio; pero también podrán serlo los herederos del autor, quienes con autorización del autor traduzcan, refundan, adapten, modifiquen, editen obras anónimas o seudónimas, y, para el caso de programas de computación, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes hubiesen desarrollado estos programas en sus funciones laborales (artículos 3º, 4º y 5º de la ley 11.723). Todos estos en definitiva pueden ser también titulares del derecho de autor, sujetos de la protección de éste.

### **1.2.1 Duración de los derechos de autor**

El derecho de autor tiene una duración que varía en la ley según la obra de que se trate. En principio, para las obras intelectuales es para toda la vida del autor y hasta setenta años desde su muerte, contados desde el 1º de enero del año siguiente al de su muerte. Para el supuesto de que sean obras colectivas, dicho plazo se deberá contar desde la muerte del último colaborador de la obra.

En cambio, para obras fotográficas la duración es de veinte años a partir de la primera publicación (artículo 34, ley 11.723) y para las cinematográficas es de cincuenta años a partir del último de los que hubieran participado en su creación (artículos 16 y siguientes de la ley 11.723).

Cuando vence el plazo de protección del derecho de autor no significa que cualquier persona puede reproducir la obra sin más, sino que el derecho del autor pasa a ser de *dominio público*. Esto implica que una obra cuyo autor (entiéndase autor o titulares del derecho de autor vistos en los párrafos anteriores) tal vez no estaba interesado en su divulgación, ahora podrá ser reproducida por cualquiera; pero dicha implicancia, que ocurre por pasar a ser de dominio público, no es igual a *gratuidad*. En vida el autor podía optar por reproducirla él mismo o autorizar su difusión (entre otros derechos) a un tercero cobrándole por dicho derecho o no; o

simplemente prohibir su difusión no autorizando a nadie ni ejerciendo ese derecho por sí mismo. Pero una vez extinguido el derecho de autor es el Estado quien autoriza y regula el cobro de cánones por la difusión de dicha obra. Así, encontramos entidades como SADAIC (para piezas musicales) y Argentores (para obras dramáticas y musicales), entre otras, que se encargan de realizar, perseguir y distribuir dicho cobro.

Estas entidades también se encargan de percibir los cánones por difusión pública de obras registradas por autores inscriptos y distribuir la recaudación conforme la difusión de cada obra, para lo cual sus autores debieron realizar los trámites de registro, tanto de la obra como de la edición de ésta y la apertura de cuenta propia para el pago de los derechos que les correspondan.

### 1.2.2 Facultades del autor

Retomando lo indicado en párrafos anteriores, las facultades del titular del derecho de autor son exclusivas y oponibles contra todos. Así, tendrá *derechos patrimoniales*, que le permitirán la explotación de la obra, y *derechos personales*, que son derechos morales sobre la autoría de la obra en sí, los cuales no podrán cederse.

Como principio general, los derechos patrimoniales se pueden ceder tal y como los posee el autor o en parte, por lo que se verán limitados a un máximo de los derechos que efectivamente éste poseía. Es decir, nadie puede ceder un mejor derecho que el que tenía, caso contrario estaría creando derechos de la nada.

El autor podrá disponer de la obra, publicarla, reproducirla, transformarla, todo lo que realizará por sí mismo o contratando con un tercero al que, por ejemplo, le encargue la edición de la obra y con el que suscriba el pertinente contrato de edición, que tendrá sus cláusulas particulares de cantidad de ejemplares, duración de la edición, costos, regalías, actualizaciones de la obra, etcétera (como, por ejemplo, la edición del presente libro).

En cuanto a los *derechos extra patrimoniales*, éstos son: el de la paternidad de la obra (el reconocimiento como autor de ésta sin importar la cesión de derechos que se hubiese hecho), la integridad y la divulgación de ésta.

La condición para la protección de los derechos de autor de la Ley de Propiedad Intelectual es el registro y depósito de la obra.

## 1.3 Marcas. Ley 22.362, de marcas y designaciones

Una marca es un *signo* que es utilizado para distinguir un servicio o un producto de otros de similar o de igual naturaleza. El régimen de la ley 22.362 tiene como principio ser un sistema

de atribución de marca a quien primero la solicite y obtenga, en definitiva, su registro (artículo 4º, ley 22.362).

### **1.3.1 Régimen legal**

Son aplicables al régimen de las marcas en nuestro país las disposiciones de la ley 22.362, su decreto reglamentario 558/81, el Convenio de París (ratificado por la ley 17.011), el Acuerdo ADPIC de la OMC (aprobado por la ley 24.425), las resoluciones de trámite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y, para el caso de conflicto o de oscuridad de la norma, la jurisprudencia emanada de la justicia federal.

### **1.3.2 Derechos que otorga la Ley de Marcas**

Encontramos como finalidad de la marca la distinción del producto o el servicio de otro similar para evitar la confusión del público. Dicha distinción surge no sólo del mero registro (una marca no es conocida por el hecho de haber sido registrada), sino de un trabajo que realizó o financió el titular de la marca para que ésta sea conocida y su producto o servicio sea *reconocido* por el consumidor rápidamente y se destaque entre los demás, ya que se ha identificado dicha marca.

Así, la ley protege la inversión que efectúa el titular de la marca y lo protege de usos indebidos de ésta, otorgando un derecho exclusivo de uso. Como consecuencia de este derecho y en caso de su violación la ley faculta al titular a que en virtud de su *interés legítimo* se oponga tanto al uso de su marca por un tercero que no esté autorizado por él, como al registro de marcas similares o que puedan dar lugar a confusión dentro de una misma clase de registro.

### **1.3.3 Clase de registro**

La solicitud de una marca se circunscribe a la clase de producto o servicios de que se trate. Para ello existe la Clasificación de Niza. Ésta se divide en treinta y cuatro clases de productos y once de servicios. Si uno desea proteger una marca que cae dentro de varias clases debe proceder a su registro en todas ellas.

Como excepción a las clases de registro existen las marcas notorias, que por su importancia y conocimiento generalizado no permiten registro de otra similar en ninguna clase.

La violación a estas disposiciones da lugar en primer lugar a la oposición que puede efectuar un titular de una marca o marca notoria frente a la tentativa de registro de una marca



similar en igual clase o en cualquiera en caso de ser marca notoria. Luego también puede dar lugar a las acciones judiciales de protección marcaria.<sup>80</sup>

#### **1.3.4 Duración de la marca**

Dispone el artículo 5° de la Ley de Marcas<sup>81</sup> que la duración del registro de una marca es de diez años. En virtud de que el derecho que protege obedece al interés exclusivo de quien efectúa una estrategia de conocimiento de marca, lo que implica una inversión económica y no genera ningún tipo de perjuicio a terceros ni interés de éstos, a diferencia de los derechos de autor y de las patentes de invención, el registro de la marca es renovable en forma indefinida por iguales períodos de diez años.

#### **1.3.5 Marcas registrables**

El artículo 1° de la Ley de Marcas dispone que pueden ser registrados como marca: "... una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad".

En cambio, no se consideran marcas, y no pueden ser registradas conforme los lineamientos de los artículos 2° y 3° de la misma ley, las siguientes cosas: "Artículo 2°: No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

"Artículo 3°: No pueden ser registrados: a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para

<sup>80</sup> Artículo 13 de la ley 22.362, de acción de oposición. Artículo 24 de la ley 22.362, de acción de nulidad.

<sup>81</sup> Artículo 5° de la ley 22.362: "El término de duración de la marca registrada será de diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad".

designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos; d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir; e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive; i) las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios; j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad”.

Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, también son nulas las marcas que:

- a) Sean registradas en contravención de la ley.
- b) Sean registradas por quien conocía que ellas pertenecían o debían pertenecer a un tercero.
- c) Sean registradas con el único objeto de su comercialización (no del producto o servicio, sino de la marca en sí misma) por quien desarrolla ese modo de actividad en forma habitual, es decir, puede darse el caso de una persona que registre una marca, no la utilice y por diversas circunstancias un tercero resulte interesado en ésta y termine cediéndose el derecho de uso; esto es legal, no así quien se dedique al mero registro de potenciales o posibles marcas para dedicarse a su venta a quien esté interesado.

También puede deducirse de las posibles marcas registrables una *clasificación*. De este modo tendremos, en general, marcas de productos y de servicios.

En cuanto a su naturaleza, podemos destacar:

- 1) *Denominativas*: son marcas que se leen y se pronuncian.
- 2) *Figurativas*: son los tradicionales emblemas, escudos o logos que pueden ser la marca en sí o anexos a marcas nominativas, lo que genera una marca *mixta*.
- 3) *Notorias*: son marcas que por su conocimiento generalizado gozan de una protección en todo tipo de clases ya que, en caso contrario, se prestaría a confusión, no del producto,

pero sí de quien desarrolla el otro tipo de producto o servicio. Así, no se podría registrar como marca de jeans, por ejemplo, Coca-Cola o Mercedes Benz.

También se pueden clasificar las marcas según distingan *productos o servicios*; estén registradas o sean marcas de *hecho*; o marcas evocativas (que refieren el nombre al producto que indican), como si existiera Lechesur para marca de leche, por ejemplo.

### 1.3.6 Procedimiento

Finalmente, el procedimiento de registro de marca es sencillo; como recomendación previa suele realizarse una búsqueda de antecedente, a los efectos de determinar si la marca y el signo que se pretenden como marca son idénticos a uno ya registrado. Puede realizarse una búsqueda gratuita y simple por similitud o una arancelada que intenta encontrar coincidencias fonéticas.

Luego, se deberá presentar una solicitud de registro en el INPI, el que efectuará una publicación de ésta en el Boletín de Marcas y Patentes, para que dentro del plazo de treinta días posteriores a la publicación los terceros interesados puedan oponerse al registro. En caso de que no exista oposición y se hayan cumplido todos los requisitos el registro de marca será otorgado al peticionante con validez nacional. En caso de diferendos deberán sustanciarse éstos por ante la Justicia, conforme el procedimiento dispuesto por los artículos 14 al 19 de la Ley de Marcas.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Artículo 14: "Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante".

Artículo 15: "Se notificarán al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud".

Artículo 16: "Cumplido un (1) año a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos: a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado; b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención".

Artículo 17: "La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda, la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta. El proceso judicial respectivo transitará según normas del juicio ordinario".

Artículo 18: "El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere".

#### **1.4. Patentes. Ley 24.481, de patentes de invención y modelos de utilidad (t. o. decreto 260/96). La patentabilidad de los programas de computación**

Una patente es un derecho que otorga la ley 24.481 al inventor sobre su invento por un determinado plazo para que lo explote en forma exclusiva, pudiendo impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de venta, importación, fabricación o uso del producto o procedimiento patentado.

La ley permite al titular del derecho intelectual de patente que efectúe con él todos los actos jurídicos que por su naturaleza sea capaz de realizar, dentro de los límites del derecho (puede ceder los derechos en forma onerosa o gratuita, pueden heredarse los derechos, etcétera). Así, el inventor podrá, dentro del plazo de veinte años, ejercer estos derechos en forma exclusiva. Vencido dicho plazo, la patente pasa a ser de dominio público, por lo que cualquier persona, sin tener que abonar regalías, podrá hacer uso de la marca. De esta forma, determinando un plazo limitado de exclusividad y pasando a ser público el conocimiento que se deriva de la patente, pasados los dieciocho meses de su solicitud, los inventores contribuyen al desarrollo y perfeccionamiento del estado de la técnica. Con el avance que se desprende de las invenciones patentadas, se va enriqueciendo el conjunto de conocimiento del mundo y se promueven la creatividad y la innovación futura.

##### **1.4.1 Régimen legal**

Son aplicables al régimen de las patentes en nuestro país las disposiciones de la ley 24.481; su decreto 260/96, que marca el texto ordenado de la citada ley; el Convenio de París (ratificado por ley 17.011); el Acuerdo ADPIC de la OMC (aprobación por la ley 24.425); las resoluciones de trámite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y, para el caso de conflicto o de oscuridad de la norma, la jurisprudencia emanada de la justicia federal. Todas estas reglas regulan la norma fundamental del artículo 17 de la Constitución Nacional.

##### **1.4.2 Requisitos para patentar un invento**

El artículo 4° de la ley 24.481<sup>83</sup> dispone las condiciones que un invento debe satisfacer para alcanzar la protección legal. La primera de ellas es que debe constituir una novedad

---

Artículo 19: "Mediante oposición, el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso deberá dictarse resolución, que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable".

<sup>83</sup>Artículo 4°: "Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. a) A los efectos de esta ley se

absoluta, en el sentido de que no se encuentre ya dentro del conocimiento de su ámbito técnico, denominado *estado de la técnica*. Así, la invención no debe poder ser pasible de deducción en forma directa y evidente por una persona que posea conocimientos técnicos en el área específica. Asimismo, debe constituir un uso práctico con aplicación industrial y finalmente poder ser patentable por no violar el universo normativo de la ley 24.481.

En tal sentido, dispone el artículo 6° de la citada ley: "No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación; d) Las formas de presentación de información; e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de éstas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia; g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza".

Por su parte, el artículo 7° agrega: "No son patentables: a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente; b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza".

considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios".

### 1.4.3 Derechos del titular de la patente

Como fue ya indicado, el inventor tiene el derecho exclusivo a explotar industrial y comercialmente el objeto de la patente y a oponerse a que terceros utilicen la patente. También podrá otorgar licencias para la explotación por parte de un tercero, las que deberán estar en consonancia con lo dispuesto por los artículos 37 a 40 de la ley 24.481.

Pero, dada la materia en cuestión y el interés del Estado en que se desarrolle el conocimiento y se exploten las patentes efectivamente solicitadas para contribuir al avance tecnológico, los derechos que otorga la ley obedecen también a ciertas limitaciones y restricciones. Algunas de ellas son:

- —Plazo de otorgamiento: como fue indicado, el plazo de protección es limitado (artículo 35). La duración de la patente es de veinte (20) años, improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
- —Agotamiento del derecho (artículo 36 c): dispone el citado artículo que la patente no generará ningún derecho para el supuesto de que se trate de importación y comercialización de un producto patentado o del producido obtenido por un método patentado, para el caso de que éstos hubiesen sido puestos válidamente en el comercio de cualquier país. Se entiende que la puesta en el comercio es lícita cuando lo es de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual, vinculado con el comercio, parte III, sección IV, Acuerdo TRIP-GATT.
- —Licencias obligatorias: otro límite al derecho del inventor lo constituyen las licencias obligatorias. Éstas se darán en los supuestos en que, habiendo transcurrido tres años desde la concesión de la patente o cuatro desde su solicitud, no existiera explotación por parte del titular de la licencia, ni se encuentre en proceso de preparación efectiva y seria de la explotación. También podrá solicitarse licencia obligatoria si se interrumpe la explotación por más de un año.

Estos plazos siguen corriendo, salvo casos de fuerza mayor ya explicados en capítulos anteriores, a los que deben sumarse las dificultades técnico-legales de registro, de carácter objetivo, que no sean culpa de quien lo pretende. Por ejemplo, una de estas dificultades podría consistir en las demoras en la obtención de autorizaciones para comercializar el producto por parte del organismo correspondiente.

Así, cumplidos los requisitos indicados que surgen del artículo 43 de la ley en estudio, podrán solicitarse las licencias obligatorias conforme los lineamientos del artículo 42, que indica: "Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150)

días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular...”.

—Licencias por prácticas anticompetitivas: como límite al derecho del titular de la patente se da este supuesto cuando éste incurrió en prácticas anticompetitivas (artículo 44). Así, sin seguir el procedimiento indicado para el caso de las licencias obligatorias, en INPI podrá otorgar licencias a terceros en los supuestos en que el inventor hubiese efectuado uno de los siguientes actos que dispone el artículo 44: “... A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado, o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto; b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables; c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la ley 22.262 o la que la reemplace o sustituya”.

### 1.3.3.1 Otros supuestos de límites a la patente

Existen otros supuestos, dispuestos por los artículos 45 a 50, de límites al derecho que otorga la patente, como ser:

- —Por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional disponer la explotación de ciertas patentes por parte del Poder Ejecutivo.
- —El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a requerimiento fundado de autoridad competente, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente.
- —En los supuestos de patentes cruzadas (artículo 46).

Finalmente, debe tenerse en consideración que, dentro del plazo legal, las resoluciones que impongan límites a la patente del inventor son apelables. Así enseña el artículo 48: “En todos los casos las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la patente estarán sujetos a revisión judicial, como asimismo lo relativo a la remuneración que corresponda cuando ésta sea procedente”.

Estos recursos lo serán sin efecto suspensivo de la resolución, por lo que ésta puede ser ejecutada mientras se sustancia la apelación correspondiente, la que será por ante la justicia federal en lo civil y comercial (artículo 49).

### 1.3.4 Invencciones y relación laboral

Otro aspecto importante de la ley es lo referido a la regulación de las invencciones desarrolladas como consecuencia de una relación laboral. Así, dispone el artículo 10 de la Ley de Patentes que existen dos tipos de regímenes para este tipo de supuestos:

a) *Empleado contratado para la realización de actividad inventiva*: dispone la ley, en los incisos a) y b) del citado artículo, que las invencciones de personal contratado, con el fin de desarrollar precisamente esas invencciones, pertenecen al empleador. Aun así, si el aporte del trabajador a la invención o la importancia de ésta para la empresa y el empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de la contratación laboral, tiene derecho a una remuneración suplementaria por su realización.

b) *Empleado no contratado con fines de realizar inventos*: en contrario a lo anterior, si el empleado por casualidad o en vistas del conocimiento que adquiere en la empresa o por circunstancias que observa desarrolla un invento patentable, pertenece a éste. También aclara la ley, en sintonía con los principios del derecho laboral y lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, que son nulas las renunciaciones anticipadas de derecho por parte del trabajador. La razón de ser de dicha norma es evidente a la luz de los conocidos y reiterados incumplimientos en materia laboral que se suceden en nuestro país. Como mera ilustración, podríamos imaginarnos el caso de un trabajador incorrectamente registrado, cuyas verdaderas tareas sean las de desarrollar un invento; pero cuyo registro laboral sea por un sueldo menor y por simples tareas administrativas para justificar dicho sueldo; conforme los lineamientos de la ley, la norma estaría protegiendo al trabajador indebidamente registrado y el invento sería propiedad del trabajador.

### 1.3.5 Patentes de adición

Existe también otro supuesto de patentamiento que se da en llamar *patente de adición*, cuando se mejora un descubrimiento o invención patentada. Es por ello que siendo solamente una mejora de la patente original los requisitos son precisamente éstos, y el plazo de otorgamiento es por el período de vigencia que le resta a la patente originaria de la cual depende (artículos 51 y 52).

### 1.3.6 Modelos de utilidad

Un modelo de utilidad se registra cuando existe una nueva disposición o forma obtenida que se introduce "...en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados" (artículo 53).



Estos derechos se conceden ante la nueva forma o disposición, pero únicamente para los supuestos en que la patente original se encuentre vencida.

Dependiendo de esta especial reglamentación, los certificados de modelos de utilidad sólo tienen una vigencia de diez años improrrogables, contados desde la fecha de solicitud. Y, como todos los trámites, sujetos al pago de los aranceles correspondientes bajo pena de caducidad (artículo 54).

Para comprender mejor la diferencia que marca la ley entre modelos de utilidad y patentes de invención debemos tener en cuenta que el modelo de utilidad se otorga a una disposición o forma nueva obtenida e introducida en los objetos antes mencionados. Para su existencia deben cumplirse los requisitos de novedad y aplicación industrial; pero puede obviarse el de tener actividad inventiva. De esta manera, se evalúa la *utilidad* que podría tener la nueva disposición, por ejemplo, por la modificación en su estructura, por más de que ésta sea obvia para alguien versado en la materia.

### **1.3.7 Procedimiento**

Para obtener una patente debe seguirse el procedimiento establecido en la misma ley. Así, el inventor deberá presentar una solicitud en el Instituto de la Propiedad Industrial y abonar los aranceles de presentación y tasa de análisis de fondo que surgen del decreto 260/96, anexo III.<sup>84</sup>

La presentación debe contener la identificación del solicitante, la razón por la cual se solicita la patente, la descripción y la reivindicación (una o varias).

De esta forma, los plazos de tramitación indican que pasados los noventa días de la presentación se le hará un examen preliminar a los fines de solucionar defectos formales. En caso de no merecer objeción o subsanarse los posibles errores, aprobado el examen preliminar y dentro de los dieciocho meses de solicitado, previo pago de tasa de examen de fondo, se realiza éste a los efectos de determinar la novedad de la invención. En ese mismo momento se procede a la publicación en el boletín del INPI. La duración del trámite, más allá de los plazos indicados, lamentablemente, por las demoras administrativas, suele llevar años, no siendo extraño que demore cuatro o cinco, según el tipo de invento que se pretenda patentar.

Es por lo indicado que quien presenta la patente suele comenzar a comercializar el producto con ésta pendiente de aprobación, siendo pasible de eventuales reclamos o acciones

---

<sup>84</sup> El INPI, a la fecha de escritura de este libro, se encuentra en la avenida Paseo Colón 717 de la CABA, los aranceles ascienden a \$ 500 por presentación de solicitud y \$ 500 por examen de fondo para el caso de las patentes, reduciéndose a la mitad para el caso de modelos de utilidad, y nuevamente a la mitad para el caso de particulares o pymes registrantes.

legales de quien pudiera considerar que se ha violado el derecho a una patente que tuviera registrada. Cualquier diferencia se deberá sustanciar en instancia judicial. Como consecuencia de ello, resulta conveniente, antes de iniciar un trámite de registro de patente, realizar una búsqueda para verificar el *estado de la técnica*, a través del Departamento de Información Tecnológica. Esta búsqueda es a nivel nacional, o internacional si se solicitase, realizándose *online* y limitada a las bases de datos existentes. El resultado de la búsqueda no es vinculante ni implica que la invención sea novedosa, sino que resulta una guía y un elemento de juicio previo para el inicio de la patente por parte del solicitante.

Finalmente, cuando la patente es concedida<sup>85</sup> debe mantenerse mediante el pago de anualidades,<sup>86</sup> bajo pena de caducidad de pleno derecho de la patente.

### **1.3.8 Consideraciones finales en cuanto a marcas, patentes y su diferencia con los modelos y diseños industriales**

Un tema que genera frecuentes dudas cuando se estudia la reglamentación de las patentes es su diferenciación con respecto a los modelos y diseños industriales. Las invenciones y los modelos de utilidad tienen una disposición práctica que suele obedecer a necesidades de diseño y ergonomía. En cambio, las formas o el aspecto de los productos industriales, cuando no obedecen más que a características ornamentales, se denominan modelos y diseños industriales.

En ambos supuestos, los diseños corresponden a fines meramente estéticos y no buscan solucionar problemas técnicos. Así, un modelo industrial es un objeto en tres dimensiones y un diseño industrial, en cambio, es en dos dimensiones, pero para ser aplicados sobre un objeto tridimensional. De esta forma, por ejemplo, sería un diseño industrial el entramado de una alfombra o de un mantel.

Este tipo de registro se otorga por el plazo de cinco años renovables por dos períodos iguales y consecutivos.

---

<sup>85</sup> Las patentes se conceden a nivel nacional. La protección no es mundial. El Estado argentino, por ley 17.011, adhirió al Convenio de París, lo que le permite al solicitante en nuestro país obtener un certificado de prioridad para proceder a proteger la patente en otros países, otorgándose como fecha de registro la que surge de la petición en la Argentina, y viceversa para el caso de ser un extranjero. Quien defiende una patente debe registrarla en todos los países donde pretenda su protección, y dicha prioridad tendrá lugar siempre y cuando realice los posteriores registros dentro del año de iniciado el trámite en la Argentina.

<sup>86</sup> Al momento de la escritura de este libro, las anualidades ascienden a \$ 100 los primeros tres años, \$ 250 del cuarto al sexto año y \$ 500 del séptimo año en adelante, rigiendo la misma escala de reducción para los particulares y las pymes que ya fue indicada en notas anteriores.

## **2. Nombres de dominio. Concepto. Gobierno de Internet (ICANN). Política de asignación de ND. Conflictos y soluciones. NIC.ar. Reglamentación**

Ya hemos tratado la definición de los nombres de dominio en el capítulo referido a delitos, remitiendo allí su lectura. En cuanto a la creación de éstos, su extensión y distintos niveles dependen de lo que resuelva la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).<sup>87</sup>

Los nombres de dominio de la Argentina dependen de NIC.ar,<sup>88</sup> organismo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Como regla general, NIC Argentina no acepta solicitudes de registro de nombres de dominio que sean iguales a otras ya existentes, o que, por su parecido, puedan confundirse con instituciones del Estado u organismos internacionales o sus dependencias (salvo registro efectuado por dichas dependencias). Tampoco son pasibles de registro las denominaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres.

El punto 10 de la normativa de registro dice: "El hecho de que NIC Argentina apruebe el registro de un nombre de dominio a favor de una entidad registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso que haga del nombre de dominio la entidad registrante. En virtud de ello, no le corresponde evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. NIC Argentina no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto debido a marcas registradas o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual que el registro de un nombre de dominio pudiera originar. NIC Argentina carece de competencia respecto de los contenidos de las páginas web que puedan construirse bajo los nombres de dominio que integran su registro".

En caso de conflicto con los nombres de dominio, la normativa 11 indica el procedimiento a realizar ante NIC. Éste es: "NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero. La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia. Ante varios reclamos debidamente acreditados sobre un mismo nombre de dominio, el formalizado en primer término gozará de preferencia en el registro. NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosímil, informará respecto del mismo, vía correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará la documentación acreditante adjuntada. La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de dicha comunicación por la misma vía

<sup>87</sup> Se puede consultar todo lo referente a la normativa emanada por la ICANN en la dirección web [www.icann.org](http://www.icann.org).

<sup>88</sup> NIC Argentina, *administrador de los nombres de dominio bajo el código país (ccTLD)*. AR, [www.nic.ar](http://www.nic.ar).

y emitir su descargo en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles administrativos. En él, deberá ofrecer la prueba que estime pertinente a efectos de establecer su derecho al uso del nombre disputado. En caso que NIC Argentina no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, informará tal temperamento, vía correo electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en cuyo caso las partes deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder. A los fines de la aplicación de esta Regla en los registros de nombres de dominio con caracteres multilingües, NIC Argentina considerará los mismos según la siguiente norma de conversión:

- "—Los caracteres 'á', 'â', 'ã' o 'ä' serán considerados como letra 'a'.
- "—Los caracteres 'é', 'ê' serán considerados como letra 'e'.
- "—El carácter 'í' será considerado como letra 'i'.
- "—Los caracteres 'ó', 'ô' u 'ö' serán considerados como letra 'o'.
- "—Los caracteres 'ú' o 'ü' serán considerados como letra 'u'.
- "—El carácter 'ç' será considerado como letra 'c' o 's', según corresponda.
- "—El carácter 'ñ' será considerado diferente del carácter 'n'.
- "En el ámbito exclusivo del subdominio TUR.AR, toda designación comercial otorgada por la Secretaría de Turismo de la Nación a una empresa de viajes y turismo, agencia de turismo o agencia de pasajes, implicará su mejor derecho a la registración de dicho nombre".

Tal y como surge de la normativa transcrita, en caso de disputa no solucionada por la vía administrativa se podrá recurrir a la Justicia para dirimir el mejor derecho sobre el nombre de dominio. Sin perjuicio de ello se va adecuando la normativa argentina a reconocer el valor de los nombres de dominio como activo de la empresa, equiparable, con sus salvedades, a la marca.

## Capítulo 9. Derecho laboral

### 1. Definición de derecho laboral

El hombre puede dedicarse al comercio, a la industria, a una profesión o al arte y así utilizar libremente su energía de trabajo en beneficio propio. En sentido amplio, se puede definir el trabajo humano como la actividad física o intelectual que realiza el hombre para producir bienes y servicios. Esta energía humana tiene por objeto transformar la realidad.

La Constitución Nacional garantiza al ser humano, en sus artículos 14 y 14 bis,<sup>89</sup> este derecho a trabajar para procurar su sustento y lograr su desarrollo personal. Así puede optar por hacerlo por su cuenta o laborar poniendo su fuerza de trabajo a disposición de otra persona. Para este último supuesto, el artículo 4° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) nos indica: "Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien

---

<sup>89</sup> Artículo 14 de la Constitución Nacional: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender".

Artículo 14 bis: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

"Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

"El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna".

tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración". Cuando esto ocurre nos encontramos frente a una relación o contrato de trabajo.

Frente a esta situación, el legislador, primero mediante normas aisladas, luego mediante leyes específicas, fue haciendo nacer una rama del derecho privado que se denominó derecho del trabajo. Éste se encarga de reglar los derechos y deberes en las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores y los empleadores.

Las normas del derecho de trabajo tienen como vértice a la Constitución Nacional, luego debe estarse a lo que indique la LCT como marco mínimo de regulación y derechos, seguidas por las leyes y estatutos profesionales que amplíen esos derechos; en igual sentido, las convenciones colectivas<sup>90</sup> y los laudos con fuerza de tales, la voluntad de las partes y, finalmente, los usos y costumbres (artículo 1º de la LCT).

"Dadas las características propias de la relación laboral, la ley se propone proteger a la parte más débil (el trabajador), con el objeto de equilibrar la relación. Para ello utiliza determinados medios técnicos y principios generales de carácter especial (ver § 42). Como consecuencia de ellos, en cierta manera la protección convierte al trabajador en un 'menor de edad'; se restringe la posibilidad del ejercicio de la autonomía de su voluntad, que se ve reducida por la existencia de mínimos o máximos inderogables. De esa manera se lo pone a cubierto de la posibilidad de que venga a ser víctima de quienes, gracias a su mayor capacidad de negociación, podrían obtener ventajas, como ocurrió en las primeras épocas posteriores a la llamada revolución industrial.

"De acuerdo con su finalidad, se convierte en un derecho especial; en el que no son aplicables sin más las normas básicas de la teoría general y de otras ramas del derecho (del civil en particular). En cada caso, debe comprobarse que la aplicación de ellas al ámbito de las relaciones laborales no está en pugna con el principio primordial del derecho del trabajo, que es la protección del trabajador como parte más débil de la relación. Esta especialidad, que debe destacarse, no significa una independencia absoluta entre el derecho del trabajo y el derecho civil, como pretenden algunos. En la medida en que aquél no elabore —y quizá no haya razones para que así ocurra— una doctrina general que comprenda los actos jurídicos, obligaciones, personas, etc., no hay razón para que no se admita, con carácter subsidiario, la recepción de los principios

---

<sup>90</sup>Convenios colectivos de trabajo: son todo acuerdo escrito, relativo a las condiciones de trabajo, de empleo y a las remuneraciones, celebrado entre un empleador o grupo de empleadores y una asociación profesional de trabajadores con personería gremial, que debe ser homologado ante el Ministerio de Trabajo para tener efecto *erga omnes*, es decir, respecto de todos los que están incluidos en su ámbito de aplicación. El objeto de los convenios es fijar las normas para regir las relaciones de trabajo y las condiciones de trabajo de una determinada categoría profesional y empleadores en particular.

elaborados por el derecho civil, mientras no se opongan a la citada finalidad protectora. En todo caso, debe ir desarrollando los propios (como ocurre con el que establece el artículo 260, LCT, que difiere del efecto liberatorio total que los artículos 724 y ss., del Código Civil, asignan al pago).<sup>91</sup> Actualmente la regulación de pago mencionada en la cita que antecede comienza en el art. 865 y ss del nuevo Código Civil y Comercial.

De la definición y la estructura normativa obtenemos una división del derecho del trabajo en dos grandes ámbitos o partes: por un lado, tenemos el derecho individual, que abarca las relaciones entre cada uno de los trabajadores y su empleador teniendo en vista el contrato celebrado en cada caso, y, por el otro, el derecho colectivo, que regula las relaciones entre las asociaciones sindicales que representan a los trabajadores(sindicados) y las agrupaciones de empleadores (cámaras).<sup>92</sup>

### 1.1 Especialidad del régimen laboral

Las notas características del derecho laboral, que surgen de la naturaleza del objeto que regula, se dan en un marco normativo con significativas diferencias con el derecho civil y el comercial. Las notas características de este derecho son:

- -El derecho del trabajo regula los vínculos entre empleador y empleado. Dicho vínculo se establece en un plano de subordinación, el cual se ve reflejado en tres aspectos: el económico, el técnico y el jurídico.
- -Si bien el trabajo es libre (nadie está obligado a trabajar en relación de dependencia para otro), éste se desarrolla por cuenta ajena (el trabajador no participa ni en las ganancias ni en las pérdidas del emprendimiento de su empleador).
- -El derecho laboral presume que el trabajador dependiente se encuentra en inferioridad de condiciones en la negociación de la relación laboral, por lo que se le brinda un marco de protección frente a dicha desigualdad.

---

<sup>91</sup>Vázquez Vialard, Antonio, *Derecho del trabajo y de la seguridad social*, tomo I, ed. Astrea, 1999.

<sup>92</sup>Derecho colectivo del trabajo: se ocupa esencialmente de los conflictos colectivos y medidas de acción directa, la regulación de las asociaciones profesionales de trabajadores (sindicatos) y los convenios colectivos de trabajo.

Asociación sindical: es una entidad que tiene por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores, es decir, de todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. Para ello, negocia y firma convenios colectivos de trabajo, ejerce medidas de acción directa (por ejemplo, la huelga), crea mutuales y administra las obras sociales.

Personería gremial: es una calificación legal que el Ministerio de Trabajo concede a la asociación profesional que resulte más representativa dentro de una actividad, oficio o profesión.

- –Si bien empleado y empleador pueden pactar sus condiciones de trabajo libremente, éstos se encuentran condicionados por ciertos marcos o derechos mínimos del trabajador que surgen de las normas laborales (leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones del Ministerio de Trabajo, etcétera), y por acuerdos por actividad y por empresa que surgen de las negociaciones colectivas que resultan en convenios colectivos de trabajo (CCT).

En resumen, la ley considera que este derecho especial se aplicará cuando medie contrato de trabajo. Así, el artículo 21 de la LCT establece: “Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres”.

Incluso puede darse lo que la ley considera “relación de trabajo” cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

En el caso del “trabajo en negro”, existen relación de trabajo, pero el trabajador no ha sido registrados por el empleador.

## 1.2 Principios generales del derecho del trabajo

Se indicó más arriba que el derecho del trabajo tiene principios especiales que se deducen de su naturaleza. Estos principios son:

- –Principio protectorio: tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Se manifiesta en tres reglas:
  - –*In dubio pro operario*.
  - –De la norma más favorable.
  - –De la condición más beneficiosa.
- –Principio de irrenunciabilidad: plantea la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en beneficio propio.



- -Principio de continuidad de la relación laboral: para los supuestos de dudas de si la relación laboral debe continuar, o respecto de su duración, debe resolverse en favor de ésta, considerando entonces que nos encontramos frente a la existencia de un contrato por tiempo indeterminado.
- -Principio de primacía de la realidad: las partes pueden otorgar formas jurídicas que no se condicen con la realidad que muestran los hechos. Por aplicación de este principio se prioriza lo que efectivamente ha ocurrido sobre las formas o apariencias o lo que las partes, en apariencia, han convenido.
- -Principio de buena fe: las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.
- -Principio de no discriminación e igualdad de trato: comprende la obligación del empleador de no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales, edad, etcétera.
- -Principio de gratuidad: el derecho laboral garantiza el libre acceso gratuito de los trabajadores a la Justicia para reclamar por sus derechos.
- -Principio de razonabilidad: este principio indica que los actos de las partes deben resultar adecuados, conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y habituales. Este principio debe regir especialmente en todo lo referente a las sanciones, junto con el principio de proporcionalidad.

### 1.3 Derechos y deberes de las partes

Tanto los trabajadores como los empleadores gozan de derechos y deberes originados en su relación laboral y en las normas de la materia. Si bien en la mayoría de los casos resultan unos ser la contracara de los otros, es conveniente hacer un breve análisis.

### 1.4 Derechos del empleador

El empleador goza de los siguientes derechos, que son inherentes a su posición contractual y a las circunstancias de toda contratación laboral:

- -Facultad de organización: el empleador goza de la facultad de determinar las modalidades de la prestación laboral. Así ordenará el trabajo desde el punto de vista general y hasta el destino de cada una de las herramientas con las que cuenta la organización para realizar el trabajo, orientando todo a los objetivos de la empresa.

- -Facultad de dirección: a los fines de lograr la organización indicada y alcanzar los objetivos empresariales, el empleador goza de la facultad de emitir directivas a los trabajadores, mediante órdenes e instrucciones relativas a la forma y modalidad del trabajo.
- -Facultad de control: ambas facultades examinadas más arriba deben sumar la posibilidad de controlar la debida ejecución de las órdenes impartidas.
- -Poder reglamentario: el trabajo de organización muchas veces se plasma en reglamentos escritos del trabajo. Muchas situaciones y condiciones de funcionamiento de la empresa, desde el control de las llegadas tarde hasta el uso de los bienes informáticos, se benefician con la aplicación de reglas claras.
- -Facultad de alterar las condiciones del contrato (*iusvariandi*): el empresario puede alterar las condiciones del contrato sólo en aspectos no esenciales, que deben estar justificados en las necesidades funcionales de la empresa, y no deben causar perjuicio material o moral al trabajador; si el empleador se excede, el trabajador puede considerarse despedido sin causa.
- -Poder disciplinario: todos estos derechos deben poder ser aplicados coercitivamente, ya que, sin la posibilidad de sancionar disciplinariamente, el cumplimiento de la organización y el logro de los objetivos sólo dependerían de la buena voluntad del trabajador.

### 1.5 Deberes del empleador

Además de los derechos, el empleador debe cumplir sus obligaciones esenciales, fruto de la contratación laboral. Éstas son:

- -Pago de la remuneración.
- -Deber de seguridad y protección: protección de la salud psicofísica del trabajador y su dignidad, y a su vez, evitar que sufra daños en sus bienes.
- -Deber de ocupación: brindar trabajo adecuado a la categoría y función que cumple el trabajador.
- -Deber de diligencia: cumplimiento adecuado de todas sus obligaciones contractuales con el fin de que el trabajador pueda gozar de sus derechos.
- -Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social. Entrega del certificado de trabajo.
- -Deber de no discriminar e igualdad de trato.
- -Deber de llevar libros.
- -Deber de formación profesional: otorgar al trabajador capacitación profesional para desarrollar sus tareas en la empresa.

### 1.6 Derechos del trabajador

Por su parte, el trabajador tiene derechos que la ley misma le da en virtud de la contratación laboral:

- -Derecho a beneficiarse de sus propias invenciones o descubrimientos (conforme se estudió en el capítulo de derechos intelectuales).
- -Percepción del salario.
- -Ocupación efectiva.
- -Igualdad de trato y no discriminación.
- -Ejercicio de las facultades del empleador, respetando la dignidad, derechos patrimoniales y salud psicofísica del trabajador
- -Exigencia del cumplimiento de obligaciones previsionales y sindicales y la entrega de certificado de trabajo.

### 1.7 Deberes del trabajador

También, el trabajador posee los siguientes deberes:

- -Deber de diligencia y colaboración: prestación de las tareas con responsabilidad.
- -Deber de fidelidad: no ejecutar acto alguno que pueda perjudicar los intereses del empleador.
- -Deber de obediencia: cumplir las órdenes y directivas.
- -Custodia de los instrumentos de trabajo.
- -Responsabilidad por daños: responder frente al empleador en caso de dolo o culpa grave.
- -Deber de no concurrencia: no competencia.

## 2. Duración del contrato de trabajo. Modalidades de contratación. Modalidades promovidas

Cuando un empleador toma la decisión de incorporar personal, lo primero que debe hacer es tener en claro las tareas para las que será contratado el futuro trabajador. El contrato de trabajo, por ley, se presupone efectuado por "tiempo indeterminado".<sup>93</sup> De esta forma, si las partes nada

---

<sup>93</sup> Artículo 90 de la LCT: "Indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias: a) Que se haya fijado en forma expresa

aclaran o si no se firma contrato,<sup>94</sup> éste no tendrá fecha de finalización y durará hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y/o en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) (según artículo 91 de la LCT).

Asimismo, este contrato debe ser ejecutado dentro de los horarios laborales previstos. Éstos son:

- Jornada normal diurna (de 6 a 21): 8 horas diarias o 48 semanales.
- Jornada nocturna (de 21 a 6): 7 horas diarias o 42 semanales.
- Trabajo insalubre: 6 horas diarias y 36 semanales.
- Trabajo de menores: 6 horas diarias y 36 semanales.

## 2.1 Principio general: tiempo indeterminado

En el contrato de trabajo está ínsita la idea de estabilidad en el empleo y permanencia del trabajador.

---

y por escrito el tiempo de su duración. b) Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen. La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b) de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado”.

Artículo 91 de la LCT. Alcance. El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley.

<sup>94</sup> Como se ha visto, la relación de trabajo no requiere de contrato firmado alguno, por lo que se presupone realizada por tiempo indeterminado, siendo las modalidades de contratación una excepción a este principio general. Esto lo dispone el artículo 22 de la LCT, que regula la relación de trabajo. Su texto indica: “Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”. Esta relación se presume al punto de que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostre lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio” (artículo 23 de la LCT).

La regulación de los contratos por tiempo determinado, que son la excepción, está sujeta al cumplimiento de requisitos formales y sustanciales (deben existir circunstancias objetivas que los justifiquen); la prueba de este tipo de contratos recae sobre el empleador.

Existen también modalidades de contratación distintas del tiempo indeterminado que obedecen a las características particulares de las actividades que cada empresa efectúa o de la naturaleza del trabajo por realizar.

## 2.2 Modalidades

**a) Plazo fijo.** Indica el artículo 93 de la LCT: "El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de cinco (5) años".

### Características:

- -Duración máxima: cinco años.
- -Modalidades de la tarea o actividad que lo justifiquen. No puede utilizarse para reemplazar a un empleado permanente.
- -Debe ser realizado por escrito y tener establecido el plazo.
- -Debe preavisarse treinta días antes.
- -Abona una indemnización al 50 % de la indemnización por despido del contrato por tiempo indeterminado, que surge del artículo 245 de la LCT, si la antigüedad supera el año.
- -Despido antes de tiempo: abona el ciento por ciento (100 %) de la indemnización del artículo 245 de la LCT y los daños y perjuicios por derecho común que autoriza el artículo 95 (éste suele alcanzar el equivalente total de sueldos pendientes).

**b) Contratación eventual.** "Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración." (Artículo 99 de la LCT.)

**Características:**

- -Se realiza cuando no se determina plazo.
- -Circunstancias extraordinarias como ser:
  - ✓ Determinada obra.
  - ✓ Aumento circunstancial del trabajo.
  - ✓ Cubrir ausencia temporaria personal.
- -No paga preaviso ni integración de mes de despido.
- -No da derecho indemnizatorio.
- -No hay período de prueba. La extinción antes de tiempo obliga a indemnizar, conforme el artículo 245 de la LCT, y autoriza el reclamo de daños y perjuicios como en el contrato a plazo fijo.

**c) Contrato de temporada.**

Reza el artículo 96 de la LCT: "Habrà contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad".

Desde la regulación inicial de este contrato se generó la controversia de cómo se calculaba la antigüedad en caso de despido. Esto fue zanjado por el fallo plenario N° 50, "Bonanata, Gorizia, Emma c/Nestlé S.A.", del 13/5/1959, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), que indicó que en el trabajo de temporada, a los efectos de establecer el monto indemnizatorio en caso de despido, se debe computar como antigüedad el tiempo efectivamente trabajado durante los períodos de actividad de la explotación.

La otra cuestión que se generó en este tipo de contratación fue la de la prolongación de la temporada. Es común constatar que en algunos lugares la temporada, por cuestiones ajenas a la explotación donde trabaja el empleado, se prolonga. Por ejemplo es usual que en algunos centros de esquí, por cuestiones climáticas, la temporada se alargue o se acorte. La solución planteada fue que en los contratos típicos de temporada (actuación en establecimiento donde se realizan actividades total y exclusivamente en determinadas épocas del año) la prolongación del período real de actividad no implica una modificación en el carácter de la relación. Caso contrario se

plantea en los establecimientos cuya actividad es continua. Para estos casos conviene hacer un aviso previo a la terminación de la temporada; el hecho de que se labore con posterioridad al vencimiento del plazo establecido en el contrato, sin petición del trabajador al respecto, otorga al contrato el carácter de permanente. Esta solución fue establecida, nuevamente, por un fallo plenario de la CNAT, el N° 34, en los autos "Acuña, Alejandro c/Frigorífico La Negra", de fecha 24/7/1956.

*d) Trabajo por equipo.*

"Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo, cuando el mismo se celebre por un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquél. El empleador tendrá respecto de cada uno de los integrantes del grupo, individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo.

"Si el salario fuese pactado en forma colectiva, los componentes del grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Cuando un trabajador dejase el grupo o equipo, el delegado o representante deberá sustituirlo por otro, proponiendo el nuevo integrante a la aceptación del empleador, si ello resultare indispensable en razón de la modalidad de las tareas a efectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del grupo.

"El trabajador que se hubiese retirado, tendrá derecho a la liquidación de la participación que le corresponda en el trabajo ya realizado.

"Los trabajadores incorporados por el empleador para colaborar con el grupo o equipo no participarán del salario común y correrán por cuenta de aquél." (Artículo 101 de la LCT.)

**Caracteres:**

- -Celebrado por un empleador y un grupo representado por intermedio de un delegado.
- -El intermediario pacta condiciones y el precio del grupo.
- -El intermediario puede cambiar a los integrantes; o solicitarlo si las circunstancias lo requieren.
- -No se puede despedir a un integrante sin la anuencia del jefe del grupo.
- -El personal extra contratado tiene una vinculación aparte.
- -No es igual al trabajo por equipos, ley 11.544.

*e) Contrato a tiempo parcial.*

Indica el artículo 93 ter que en el contrato de trabajo a tiempo parcial "...el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad".

Caracteres:

- -Horas del día, semana o mes inferiores a los dos tercios de la jornada habitual.
- -Rige período de prueba.
- -No existen horas extras. Si se llega a dar el supuesto se paga como hora simple.
- -Aportes, contribuciones, indemnizaciones proporcionales al salario, con excepción de la obra social, que deberá pagarse sobre el total del sueldo de tiempo completo.<sup>95</sup>

<sup>95</sup>Ley 26.474. Artículo 1º: "Sustitúyese el artículo 92 ter de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) -Ley de Contrato de Trabajo- y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 92 ter: 1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. 2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento. 3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá. 4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador. 5. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa".



### 3. Administración de los recursos humanos.

#### 3.1 Salario. Definición

La Ley de Contrato de Trabajo define el salario en su artículo 103: "A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo..."

Las características de ese salario son:

- -No puede ser inferior al SMVyM (a partir del 1° de enero de 2016 se fijó en la suma de \$ 6.060 mensuales o \$ 30,30 por hora, para los trabajadores jornalizados).
- -Se devenga aunque no se preste servicio; con la *mera puesta a disposición de su fuerza de trabajo* se hace acreedor al trabajador de su salario aunque no se le encargue y realice, efectivamente, nada.
- -El 80 % del pago debe ser en dinero efectivo y el resto puede ser imputado a pagos en especie.
- -El trabajo se presume remunerado (artículo 115 de la LCT).
- -El SMVyM es inembargable, salvo por deuda alimentaria. Lo que supere el monto del SMV y M se embarga en un 10 %. Cuando el monto del salario supera el duplo del SMVyM se embarga el 20% de lo que exceda de dicha suma.
- -No puede sufrir retenciones que no surjan de aportes jubilatorios u obligaciones fiscales y adelantos de remuneraciones (artículo 130 de la LCT), con un tope máximo de 50 % de un salario. Existen otras excepciones que surgen del artículo 132 LCT.
- -Se debe otorgar recibo donde conste lo indicado en el artículo 140 de la LCT.

#### 3.2 Determinación

Cuando una empresa va a contratar personal sabe de antemano cuánto ofrecerá pagarle a dicho empleado. Más allá de los montos que puede indicar el mercado laboral para puestos como el que se desee incorporar, existen mínimos legales. Para determinar dichos mínimos se procede de la siguiente manera:

1. -Se observa el mínimo: SMVyM.
2. -Se analiza el CCT de empresa o de actividad que rige al empleado por contratar. Así se establecen las escalas salariales que se aplican a la actividad desarrollada por el trabajador, según surgen del mismo convenio.
3. -Se suma la antigüedad que determine el CCT.
4. -En su oportunidad, se abona el sueldo anual complementario (SAC o aguinaldo), que equivale a un sueldo anual más abonado en dos cuotas, el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año.
5. -Luego, se determina si la empresa voluntariamente puede pagar aumentos no convencionales.
6. -Finalmente, debe tenerse en cuenta que cada convenio puede establecer obligaciones particulares para la actividad o convenio de empresa.

### 3.3 Régimen de las licencias

Las licencias son períodos en que el trabajador, a pesar de que no trabaja, tiene derecho a percibir su remuneración. De allí que se suele denominar licencias pagas a las que establecen la LCT y algunos convenios colectivos, en contraposición a las licencias sin goce de haberes, que pueden ser otorgadas, inclusive, por acuerdo entre el trabajador y el empleador.

Es normal encontrar que algunos CCT modifican las licencias que surgen de la LCT, ampliándolas en plazos o determinando otras causales de licencia que sólo gozan los trabajadores amparados en el convenio particular que las establece.

La licencia ordinaria, comúnmente conocida como *vacaciones*, se encuentra normada en el artículo 150 de la LCT, que establece lo siguiente:

“El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

”a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco (5) años;

”b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de diez (10);

”c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20);

"d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) años.

"Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas".

También es requisito para el goce íntegro de la licencia haber prestado servicio como mínimo más de la mitad de los días hábiles del año. En caso contrario se establece la licencia en un día por cada veinte trabajados.

La ley establece que las vacaciones se gozan desde el 1º de octubre hasta el 30 de abril y se comunican por escrito 45 días antes del inicio.

El cálculo del salario por vacaciones es distinto, ya que el salario mensual se divide por 25 para proceder al pago de los días por vacaciones.

El objetivo de las vacaciones es la salud del trabajador, por lo que no pueden compensarse en dinero para que éste no las usufructúe. Esto es así al punto de que si no se las otorgan hasta el 30 de abril, el trabajador puede tomárselas durante mayo (hasta el 31/5).

### 3.4 Licencias especiales

A la licencia ordinaria se le agregan licencias especiales dispuestas por la LCT. Éstas surgen de los artículos 158 a 161 y de las disposiciones de protección a la maternidad.

En el siguiente cuadro se resumen las licencias indicadas y su duración.

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nacimiento de hijo: dos días.                                                                           |
| Matrimonio: diez días corridos.                                                                         |
| Fallecimiento del cónyuge o concubino, hijos o padres: tres días.                                       |
| Fallecimiento de hermano: un día.                                                                       |
| Para rendir examen de enseñanza media o universitaria: dos días corridos con un máximo de diez por año. |

### 3.4.1 *Licencia por maternidad*

La protección a la maternidad encuentra resguardo en forma directa por la ley con el régimen especial de protección contra el despido por causa de embarazo, que se verá en los puntos siguientes, y por los plazos de licencia pre y posparto con prohibición de prestar tareas. En forma indirecta cuenta con la protección contra el despido por causa de matrimonio.

El régimen es el siguiente: "Artículo 177. Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre término se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.

"La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.

"Garantizase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.

"En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley. (Artículo sustituido por el artículo 1° de la ley 21.824, B.O. 30/6/1978.)"

"Artículo 178. Despido por causa del embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo, así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley."

“Artículo 179. Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternas y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan.”

### **3.4.2 Licencias por accidentes y enfermedad inculpables**

Los accidentes o enfermedades inculpables impiden la prestación del servicio, pero no afectan el derecho de percibir remuneración. Son enfermedades o accidentes inculpables porque no guardan relación con el trabajo prestado o no ocurrieron *in itinere* (trayecto desde el trabajo al hogar y del hogar al trabajo).

- –Menos de cinco años de antigüedad: tres meses.
- –Más de cinco años de antigüedad: seis meses.
- –Los plazos se duplican si el trabajador tiene cargas de familia.
- –La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad salvo que se manifestara transcurridos los dos años.
- –Aviso: el trabajador debe darlo indicando el lugar en el que se encuentre durante el transcurso de la primera jornada. Mientras no lo haga pierde derecho a remuneración (artículo 209).
- –El empleador puede ejercer los controles médicos pertinentes.

#### **3.4.2.1 Conservación de empleo y reincorporación**

Vencidos los plazos del artículo 208 de la LCT se lo debe conservar un año desde el vencimiento y hasta que alguna de las partes decida y notifique su voluntad de rescindir la relación sin indemnización.

##### **Reincorporación:**

- –Si no puede realizar la misma tarea debe asignársele otra que pueda realizar.
- –Si no existe tal tarea (no imputable al empleador) se extingue la relación por el artículo 247 de la LCT.

- -Si se le puede asignar y no la hace se aplica el artículo 245 de la LCT.
- -Si se deriva incapacidad absoluta se aplica el artículo 245 de la LCT.
- -Si ocurre el despido durante los plazos del artículo 208 de la LCT se debe abonar el tiempo restante de la licencia o hasta la fecha de alta con más la indemnización del art. 245. de la LCT.

### 3.5 Régimen de las sanciones

Indica el artículo 67 de la LCT: "El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria".

Clases de sanciones:

1. -Amonestación.
2. -Suspensión de uno a treinta días.
3. -Despido.

En virtud de que el artículo 67 indica que la sanción debe ser proporcionada al incumplimiento, no existe regla alguna sobre cantidad de sanciones hasta llegar al despido, más que el hecho de la razonabilidad en la adecuación de la falta con la sanción, pudiendo llegar a despedirse a la primera oportunidad cuando la falta es grave y no permite la prosecución del vínculo laboral.

### 3.5 Formas de extinción del contrato o la relación laboral

#### 3.5.1 Protección contra el despido arbitrario

La LCT dispone la existencia de una indemnización tarifada. Ésta se presupone como suficiente para cubrir todos los daños que pudo generar el despido. Es independiente de los

verdaderos daños sufridos. Toda notificación, dentro del ámbito laboral, incluso la de despido, es recepticia.

Los antecedentes legislativos con relación a la indemnización por despido injustificado son:

- 1934. Reforma del Código de Comercio. Se incluyó la indemnización por preaviso y despido para empleados de comercio.
- 1945. Decreto 33.302/45. Extiende el beneficio a todos los trabajadores.
- 1974. Se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo.

En sí mismo el despido es una forma de extinción del contrato de trabajo que surge de la voluntad unilateral de alguna de las partes. Éste puede estar fundado en una justa causa o disponerse sin expresión de ella.

Los caracteres del despido son:

- -Unilateral.
- -Recepticio.
- -Extintivo e informal (para despido con justa causa es indispensable la forma escrita).

Se puede clasificar en:

- -Del empleador (despido directo).
- -Del trabajador (despido indirecto).

### **3.5.2 Indemnización**

El preaviso es una notificación de la extinción del contrato de trabajo dada con antelación.

La duración del preaviso es la siguiente:

- -Quince días de sueldo si la antigüedad es menor a tres meses.
- -Un mes de sueldo si la antigüedad es menor a cinco años.
- -Dos meses de sueldo si es mayor a cinco años.

El preaviso se prueba por escrito (artículo 235 de la LCT), mediante telegrama, carta documento o nota firmada. Si no se otorga el preaviso se debe abonar una indemnización sustitutiva (artículo 232 de la LCT).

### **3.5.3 Despido directo**

El despido directo puede ser de dos tipos, teniendo en cuenta que en cada uno de éstos las consecuencias son distintas:

A) Sin causa. No fundado. Se debe indemnizar conforme se indica a continuación y abonar u otorgar preaviso.

B) Causado. Con justa causa fundada en el incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, no se abona indemnización. El empleador debe expresar por escrito, en forma suficientemente clara, la causa que motivó su decisión rescisoria (artículo 243 de la LCT).

### **3.5.4 Despido indirecto**

Es decidido por el trabajador ante incumplimiento del empleador de suficiente gravedad que constituya una injuria que impida la continuación del vínculo. Abona indemnización si el trabajador prueba la causa (artículo 246 de la LCT).

### **3.5.5 Indemnización por antigüedad o despido**

Indica el artículo 245 de la LCT: "En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

"Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá



fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

"Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

"Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

"El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo".

Esta norma, en caso de empleados con altos puestos en empresas importantes, generaba una desproporción entre el monto de la indemnización y el salario por aplicación del tope que surge del artículo transcripto. Esta desigualdad se vio superada por la jurisprudencia en el precedente "*Vizzoti, CarlosAlberto c/AMSA S.A. s/despido*" de la CSJN, donde se habilitó, únicamente, hasta un 33 % de reducción del salario real bruto por aplicación de dicho tope.

### **3.5.6 Integración del mes de despido (artículo 233 de la LCT)**

Cuando el despido se realiza sin otorgar el plazo de preaviso y en fecha que no coincide con el fin de mes, se deben abonar como integración del mes de despido los días que faltan para completar dicho mes.

### **3.5.7 Conceptos de pago obligatorio**

Sin importar la causa por la que se extinga la relación laboral, siempre deben liquidarse los siguientes conceptos:

- -Sueldo anual complementario (SAC).
- -Vacaciones proporcionales.
- -Días trabajados hasta la ruptura.

### **3.6 Contingencias especiales que extinguen la relación laboral.**

### 3.6.1 Indemnizaciones agravadas

*Despido por maternidad:* se presume *iuris tantum* si se produce despido dentro de los siete meses y medio antes o después de la fecha de parto, si medió notificación de la trabajadora de su embarazo.

Si no se demuestra la existencia de justa causa se abona un año más de salarios (artículos 178 y 182 de la LCT).

*Despido por matrimonio:* presunción *iuris tantum* cuando el despido es en los tres meses anteriores o seis posteriores al matrimonio. La indemnización es también de un año de remuneraciones.

*Licencia por enfermedad,* artículo 208 de la LCT: deben abonarse los salarios hasta el alta médica o vencimiento de la licencia.

*Despido sindical:* debe procederse al reintegro del puesto de trabajo o abonar las sumas resultantes de los salarios caídos hasta lo que hubiese sido la finalización de su mandato.

### 3.6.2 Otras causales:

- -Jubilación del trabajador. No abona indemnización.
- -Incapacidad e inhabilidad. Abona las indemnizaciones de los artículos 212 o 247 de la LCT.
- -Quiebra. Según sea el supuesto ocasionado por la falta de trabajo no imputable al empleador, abona las indemnizaciones de los artículos 245 o 247 de la LCT.
- -Muerte del empleador. Abona la indemnización reducida del artículo 247 de la LCT.
- -Muerte del trabajador. También abona la indemnización reducida del artículo 247 de la LCT.
- -Falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Abona igual que en los supuestos anteriores.

### 3.7 Multas

Algunos incumplimientos del empleador ocasionan la aplicación de multas que guardan relación con las indemnizaciones vistas. Así, si el empleado no estaba registrado o lo estaba en forma deficiente se abonarán las indemnizaciones de la ley 24.013 o del artículo 1° de la ley 25.323.

Para el supuesto de que exista falta de depósito de aportes retenidos se abona la indemnización del artículo 132 bis y, en caso de falta de entrega de los certificados de trabajo, la del artículo 80 de la LCT.

Finalmente, de no abonarse dentro del plazo legal las indemnizaciones por despido y preaviso, habiendo sido debidamente intimado el empleador a ello, se abona la multa del artículo 2° de la ley 25.323.

### 3.8 Reglamento interno de la empresa

Los reglamentos internos facilitan a la empresa la gestión del trabajo en muchos aspectos que no se encuentran regulados en ninguna otra parte y que hacen a las facultades de dirección y organización del empleador. De este modo, sirven para diversos fines, por ejemplo:

- -Posibilidad de regular particularidades de la empresa.
- -Para fijar parámetros objetivos frente a posibles sanciones.
- -Para fijar pautas de conducta.
- -Por prohibiciones y formas de utilización de elementos y herramientas de la empresa.
- -Es especialmente útil para empresas que utilicen tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

Para tener validez, el reglamento interno debe ser notificado, capacitado el personal y debe aplicarse a todos por igual, sancionando su incumplimiento.

### 3.9 Uso de recursos informáticos de la empresa por empleados

En la exposición realizada por el autor del presente libro en el ámbito del I Congreso de Investigadores y Docentes de Derecho Informático, llevado a cabo en la Ciudad de Mar del Plata

en el mes de abril del 2012, indicaba: "Los medios informáticos y tecnológicos son provistos por el propio empleador con la finalidad de facilitar la realización de las tareas para las cuales fue contratado el empleado, lo cual les otorga la calidad de 'herramientas' (artículo 84 de la LCT), propiedad del empleador, que autoriza su uso al trabajador con un fin determinado, sin tener ningún derecho el empleado sobre éstos. Sin perjuicio de ello, resulta común que el empleado tenga expresiones del tipo 'mi computadora', 'mi impresora', 'mi correo', otorgándoles carácter propio a los elementos de trabajo y generándose así el origen de disputas al respecto".

El artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo (conocido como "poder de dirección") indica: "El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento". Por su parte, el artículo 65 reza: "Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador".

Como se ve, ambos artículos otorgan al empleador la facultad de organizar y dirigir la empresa y el uso de los elementos de ésta. Así, puede disponer cómo se utilizarán los elementos informáticos; cuándo y con qué límites, debiendo el trabajador regirse por dicha organización, respetando la funcionalidad de los elementos otorgados y buscando la prosecución de los fines de la empresa.

Es el empresario quien libremente ha decidido instalar determinado sistema y considerar que la labor debe ser desarrollada a través de éste, surgiendo dicha potestad claramente de los artículos indicados.

Sin perjuicio de ello, suele ser conveniente *recordar* estas cuestiones a través de un reglamento interno o de uso de los sistemas de la empresa, que se justifica acabadamente por las razones de *confidencialidad de la información* privada de la empresa.

También puede darse que:

-Utilizando los medios informáticos para fines distintos de aquellos para los que fueron asignados, el empleado pueda afectar el rendimiento de éstos. De hecho, y siendo de experiencia personal del autor, ocurrió que un cliente, empresa dedicada a generación de contenidos multimedia para televisión, nunca obtenía ancho de banda suficiente para las tareas que debía desarrollar (ello fue así, aun siendo su abono extremadamente oneroso); resulta que las causas del problema se debían a un desvío de recursos informáticos con fines no perseguidos por la empresa. En efecto, investigando el problema se descubrió que treinta de los cuarenta empleados

utilizaban, simultáneamente con sus tareas, el servicio de Youtube como una *radio minimizada*, lo que generaba un gran consumo en la conexión de Internet e imposibilitaba realizar las tareas específicas a las que se dedicaba la empresa. La solución radicó en la prohibición de utilización de los sistemas informáticos para distracción en tanto ello implicara bajar contenidos de la web, así como la instalación de dos computadoras en el salón de esparcimiento de la empresa destinadas a la libre navegación.

—Existe, también, con estas conductas, el grave riesgo de incorporar virus, troyanos y otros elementos informáticos dañinos. Si bien esto no es privativo del mal uso de los sistemas, la navegación por páginas de origen dudoso o pornográfico y el reenvío de mails, con adjuntos de procedencia desconocida, potencian enormemente el problema. Con los sistemas de protección adecuada el problema es evitable, pero aquéllos se vuelven muchas veces obsoletos, por los errores del usuario, como, por ejemplo, el ignorar la advertencia de *página peligrosa*, que muchos antivirus efectúan, con tal de acceder al sitio deseado, propósito que, claramente, no tiene un fin laboral.

Es consecuente con lo indicado que, más allá de las soluciones prácticas como las arriba señaladas, se reglamente el uso de los medios informáticos de la empresa con expresa indicación de su finalidad y las consecuencias claramente establecidas para el caso de su violación. Es importante también establecer que *basta el peligro* para hacer procedente la sanción, por ello la reglamentación intenta ser *preventiva* y las sanciones *graduales* para ser adecuadas a la infracción.

Siendo éstos los principios generales dentro de los que deben desarrollarse las relaciones laborales, el uso de las herramientas informáticas sólo agrega dos cuestiones puntuales:

- a) Una dificultad probatoria.
- b) Un mayor celo en la reglamentación y preaviso del trabajador por esa común, pero equivocada, consideración de que son *propios* los elementos informáticos de la empresa.

Estas herramientas informáticas (artículo 84 de la LCT) pueden ser pasibles de control (artículo 70 del mismo cuerpo normativo). Así, conforme dispone este artículo, los medios de control deberán ser automatizados, afectar a todo el personal y salvaguardar la dignidad del trabajador. En este último punto, los sistemas informáticos corren con ventaja.

De cualquier forma, es claro que el artículo 70 de la LCT fue establecido para salvaguardar *bienes físicos* de la empresa y tratar de evitar el conocido *robo hormiga*, lo que, de

cualquier forma, resulta aplicable por cuanto, dentro de los *bienes* de la empresa, está también la información confidencial. Ésta merece, hoy más que antaño, la misma o mayor protección que los bienes tangibles. En muchas empresas estos bienes intelectuales superan ampliamente en su valor a los muebles e inmuebles vinculados al activo de la empresa.

Así, es conveniente ejecutar métodos de control, tales como claves de acceso, "logueos" adecuados al sistema, control de permanencia en éste, control automatizado de correos electrónicos de la empresa, reglamentación de uso o cualquier otro medio idóneo para la protección buscada. Esto recae sobre la facultad de control que tiene el empleador y surge de los artículos antes mencionados de la LCT.

Finalmente, pesa también sobre el trabajador el deber de diligencia del artículo 84, que indica: "El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean". De esta forma, de la propia norma surge que el trabajador debe dar un uso adecuado a los elementos de trabajo, no pudiendo hacerlo para fines personales. Estas herramientas informáticas, que permiten la comunicación permanente con el ámbito extralaboral, acentúan la obligación por parte del trabajador.

#### **4. Ley de Riesgos de Trabajo. Enfermedades y accidentes de trabajo**

La Ley de Riesgos de Trabajo trata sobre los infortunios laborales. Para ellos establece indemnizaciones tarifadas y brinda dos tipos de prestaciones:

-En especie: comprende atenciones médicas, traslados, honorarios médicos, medicamentos, accesorios, etcétera.

-Dineraria: comprende pago de suma mensual igual al salario desde el 11° día, y mientras esté incapacitado temporariamente. Esto finaliza al año del evento, con posibilidad de extenderse hasta tres años.

Estas prestaciones ocurren cuando nos encontramos frente a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el *in itinere* se modifica por razones de

estudio, concurrencia a otro empleo o atención de un familiar directo enfermo y no conviviente; se deben presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.

Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3, de la LRT. El listado identificará el agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles, con la única excepción de lo que determine la comisión médica en cada caso.

Una vez determinada la *incapacidad definitiva* se paga una indemnización. Ésta se calcula sobre la siguiente fórmula:

$\text{Ingreso base} \times 53 \times \% \text{ incapacidad} \times \text{coef. edad.}$

Ingreso base: es la cantidad que resulta de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los doce (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un (1) año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado.

Coefficiente edad: igual a  $65/\text{edad}$  al momento del infortunio o primera manifestación invalidante.

Cuando la incapacidad resulta ser mayor al 50 % y menor al 66 %, se abona una renta periódica al trabajador, en virtud de que el grado de incapacidad en la práctica lo incapacita casi totalmente para el trabajo; pero no alcanza a cumplir los lineamientos de la ley 24.241 para obtener un retiro por invalidez.

Cuando el grado de incapacidad es menor al 50 % se paga al contado.

#### 4.1 Procedimiento

A los fines de obtener las prestaciones de la LRT, el procedimiento es el siguiente:

- 1) Denuncia ante la ART.
- 2) Evaluación de la comisión médica.

- 3) Evaluación de la comisión médica central, en caso de disconformidad con el porcentaje de incapacidad otorgado.
- 4) Participación de la Cámara Federal de la Seguridad Social, como alzada judicial en caso de nueva disconformidad con el porcentaje otorgado.

#### 4.2 Planteos judiciales

La LRT ha sido permanentemente atacada y considerada inconstitucional en muchos de sus artículos, sobre todo en lo referente a la prohibición de solicitar reparación integral en caso de infortunio y a los topes máximos indemnizatorios que surgen de la fórmula explicada.

Así, judicialmente, al solicitar la reparación integral (en contra de la indemnización tarifada), se requiere declarar la inconstitucionalidad de la LRT (conforme los fallos de la CSJN), especialmente del artículo 39, que prohíbe el reclamo por la vía civil, conforme los lineamientos de la responsabilidad oportunamente analizados.

A la hora de calcular las indemnizaciones, y para el supuesto de lograr la declaración de inconstitucionalidad, suelen calcularse las indemnizaciones conforme el precedente "Méndez" de la CSJN, en el que se ha efectuado una fórmula en que la idea subyacente del fallo era que el trabajador es acreedor a una suma que, puesta a un interés, se agotará al momento de llegar a los 75 años si el trabajador extrae de esa suma los fondos proporcionales a su incapacidad mes a mes. Esta fórmula, en su resultado, arroja diferencias del doble al triple del cálculo de la LRT, dependiendo de las características de cada caso en particular.



## CAPÍTULO 10. Derecho administrativo.

### 1. El Estado

Para llegar a definir el derecho administrativo hace falta avanzar sobre la concepción del Estado. Sin pretender profundizar en un estudio evolutivo del derecho político, basta recordar, como fuente del concepto de Estado, las revoluciones inglesa (1688), francesa (1789) y americana (1776), junto con las teorías políticas de Montesquieu (que hablaba del poder público dividido en tres poderes) y Rousseau (quien trataba de explicar el origen de los Estados hablando de un contrato social preexistente, y llegaba a la conclusión de que la ley es, en definitiva, una expresión popular).

El Estado es considerado la mejor organización jurídico-política que se conoce a la fecha. Como ya se dijo, para el caso de la Argentina, éste se encuentra organizado en forma representativa, republicana y federal. El *impérium* del Estado, el poder público, que en su concepción tradicional se dice dividido en tres, hoy por hoy, se concibe como un poder único, y lo que se divide son las funciones entre distintos complejos orgánicos, todos funcionando para lograr el fin del Estado. Esta última interpretación permite comprender que *no debe existir primacía de una función sobre las otras*; esto es articulado así para que el Estado, en el ejercicio de su poder, no termine violando los derechos de los individuos. Mediante el Estado se deben garantizar los fines de la unión nacional y el respeto de los derechos reconocidos por la Carta Magna, para todos los argentinos y para quienes quieran habitar el suelo de este país. Así se comprende mejor que el Estado debe permitir que los individuos actúen para satisfacer, por su iniciativa privada, sus derechos por sí mismos y, cuando ellos no lo logren, actuar subsidiariamente; hasta tanto no lo pueda hacer la misma iniciativa privada, el Estado debe garantizar los derechos constitucionales para todos. Cabe aclarar que existen también ideas políticas que comprenden este último enunciado exactamente al revés.

Los Estados pueden clasificarse en dos tipos:

1. Unitario: existe un solo ordenamiento jurídico.
2. Federal: hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos.

Dentro del Estado encontramos diversos elementos:

—Población: es el elemento humano. Al respecto, se debe distinguir entre *habitantes*, que son los residentes dentro del territorio, y *pueblo* (concepto más restringido que refiere a la parte de los habitantes que tiene el ejercicio de los derechos políticos).

—Territorio: es el elemento geográfico. En nuestro caso comprende: suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar continental, mar argentino y plataforma submarina.

—Poder o *impérium*: la finalidad del Estado es la realización de objetivos comunitarios. El ejercicio del poder será legítimo en la medida en que busque lograr el bien común.

—Gobierno: es el conjunto de órganos que ejercen el poder para el cumplimiento de las funciones del Estado.

Luego, el Estado de derecho resulta ser la forma utilizada para tutelar los derechos de los ciudadanos, mediante el sometimiento de todos, y de la propia administración pública, a la ley.

Se necesita, para el mantenimiento del referido Estado de derecho, que la administración juegue un papel *ejecutivo*, pero teniendo a la ley como fundamento y límite de su accionar. Así, las normas que dicte la administración deberán estar sometidas también al resto del ordenamiento legal visto en el primer capítulo.

### 1.1 Funciones del Estado (clasificación)

Existen diferentes formas de clasificar las funciones del Estado:

Criterio orgánico o subjetivo: divide la función que se esté cumpliendo según cuál sea el órgano de gobierno que la realiza.

Material, objetivo o funcional: para este criterio lo importante es el contenido del acto realizado, sin prestar atención al órgano que lo realiza. De esta forma, al ser aplicado vemos que el derecho administrativo se encargará de estos actos pese a que a la actividad materialmente administrativa la lleven a cabo los poderes Legislativo, Judicial y los entes públicos no estatales. Estos últimos tienen potestad política delegada por el Estado (por ejemplo, las sanciones a los profesionales por los respectivos colegios públicos o consejos profesionales, mediante procedimientos que caen dentro de la órbita del derecho administrativo).

## 2. Derecho administrativo. Concepto.

Dentro de las clasificaciones vistas en el primer capítulo, el derecho administrativo se arraiga en el derecho público. Éste se compone de normas jurídicas que regulan la actividad

administrativa del Poder Ejecutivo y la actividad materialmente administrativa del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los entes públicos no estatales.

Es objetivo del derecho administrativo el regular las vías jurídicas para garantizar el cumplimiento de los intereses de la comunidad y de los derechos colectivos, y evitar que, en el doble juego de legislador y juez, el poder administrativo soslaye derechos de los individuos. Debe tenerse en cuenta que este doble juego radica en el hecho de que los distintos órganos de la administración dictan sus normas de requisitos y procedimiento, para luego juzgarlas en cada expediente administrativo que se inicia ante ellos.

## 2.1 Características del derecho administrativo

El derecho administrativo se caracteriza por ser:

- Autónomo: tiene sus propios principios generales, es decir que es un sistema jurídico propio del derecho público.
- Común: es un derecho que se aplica a todas las actividades antes indicadas, siendo aplicables sus principios a todas ellas.
- Contralor: la función administrativa de contralor o *policía* se ha visto incrementada en la reforma de 1994 con órganos como la Auditoría General de la Nación o el Defensor del Pueblo, entre otros que se explican más adelante. La función que cumplen es la de control por delegación del Poder Ejecutivo.
- Local: la organización política del Estado argentino, según surge de nuestra Carta Magna, dispone que cada provincia dicta sus propias normas administrativas, por lo que resulta ser un derecho netamente local.

## 2.2 Soberanía. Autonomía. Autarquía. Autarcía

El alcance de los conceptos de soberanía, autonomía, autarquía y autarcía nos permite entender las funciones y atribuciones de los organismos públicos. La soberanía y la autonomía son conceptos políticos. La autarquía y autarcía son conceptos administrativos.

**Soberanía:** el Estado nacional es soberano, porque no reconoce a ningún otro poder por sobre el suyo. Ello no impide que pueda someterse, por ejemplo, a resoluciones de órganos supranacionales.

**Autonomía:** la autonomía permite a los distintos órganos administrativos dictar sus propias normas, por las cuales se regirá su accionar. Por supuesto que dichas normas deberán ser dictadas en consonancia con el resto del ordenamiento jurídico, en especial con lo indicado en la Constitución Nacional. En caso de que esto último no ocurra, o en el caso concreto de que las normas dictadas violen la Ley Fundamental, el administrado tendrá derecho a hacer revisar el acto administrativo por la Justicia.

**Autarquía:** es la capacidad de auto administrarse. Si bien la autonomía implica autarquía, no es así en sentido inverso. La entidad únicamente autárquica recibe de otros órganos sus normas sin dictarlas por sí misma. Los entes autárquicos tienen su origen en la ley o en un decreto y dependen del Estado nacional.

La autarquía puede ser:

**Territorial:** la división ocurre por el lugar geográfico que le corresponde para desarrollar su actividad (municipios).

**Funcional o por servicios:** la diferenciación está dada por la técnica desarrollada (por ejemplo el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central o la Universidad de Buenos Aires).

**Autarcía:** indica que el órgano tiene autosuficiencia económica.

### **2.2.1 Órganos de la administración pública**

Los órganos se pueden clasificar según:

**Origen:**

—Constitucional: son creados directamente por una norma de la Constitución.

—Legal: los crea una ley del Congreso.

**Estructura:**

—Unipersonal: Poder Ejecutivo nacional.

—Colegiada: compuestos por una pluralidad de individuos que sesionan cuando consiguen quórum suficiente (determinado número de miembros presentes). Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura.

**Funciones:**

—Activas: son órganos cuya función principal es la toma de decisiones. Así, el resultado típico de éstos es el dictado de actos administrativos.

—Jurisdiccionales: son órganos que actúan en la resolución de controversias de su competencia (por ejemplo, los tribunales de faltas).

—Consultivas: las de la Procuración del Tesoro Nacional, por ejemplo; tienen por objeto asesorar al Poder Ejecutivo nacional en cuestiones jurídicas. El resultado de la actividad es exponer su opinión en forma de dictámenes.

**Estructura de la administración pública centralizada:**

—Poder Ejecutivo nacional.

—Jefe de Gabinete de Ministros.

—Ministerios.

—Directores generales de distintos órganos de la administración.

Los principios de jerarquía y de competencia son los que ordenan la administración pública centralizada.

La centralización implica la existencia de una sola persona jurídica pública, el Estado nacional. La centralización trae aparejada la subordinación jerárquica entre los distintos órganos del ente.

La descentralización, en cambio, implica la existencia de diferentes personas jurídicas; cada una de ellas está dotada de personalidad jurídica en razón de la actividad que desarrolla. Aquí se encuentran los ya mencionados entes autárquicos (por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina).

Desconcentración: es una forma de acelerar la actividad de la administración pública sin dotar de personería jurídica a un órgano, aunque sí es dotado (por su especialidad) de independencia operativa y de autarcía.

### **3. Principios fundamentales de la organización administrativa**

**Jerarquía:** implica la existencia de un órgano superior que imparte órdenes para que los inferiores realicen. De esta manera, se respeta un orden para el control y ejercicio de las tareas a realizar. Se dice que los funcionarios que comparten un nivel tienen igual jerarquía.

Competencia: cuando se quiere indicar que una persona del derecho privado está facultada para realizar determinado acto o intervenir en determinada situación se dice que tiene *capacidad*. Cuando nos referimos a órganos públicos se indica que es *competente*. La norma es la incompetencia, salvo para lo que la ley expresamente la faculta (algo similar a lo que ocurre con las sociedades y su objeto social). Se trata, entonces, del grupo de atribuciones, poderes o facultades que le corresponden a un órgano en comparación con los demás. La competencia del órgano, por lo general, está establecida por la ley que lo crea.

La competencia puede ser en razón de:

- La materia: sobre qué temática el órgano se encuentra facultado para actuar, por ejemplo, en materia de gestión de las finanzas del Estado será competente el Ministerio de Economía.
- Grado: orden de prelación entre los distintos entes establecidos como superior e inferior.
- Lugar: está determinada por el ámbito territorial sobre el cual el órgano tiene competencias.

Según el artículo 3° de la ley 19.549, la competencia es de origen legal, de ejercicio obligatorio (implica que la competencia debe ser ejercida por el órgano en cuestión, que no puede guardar silencio ante el requerimiento de un administrado, a punto tal que termina considerándose la inacción de la administración como *denegatoria tácita* de lo solicitado. Esto ocurre previo al cumplimiento de determinados procedimientos e improrrogable. Esto último puede considerarse como excepción en dos circunstancias:

—Delegación: ocurre una delegación cuando las funciones que debe realizar un superior son transferidas a un inferior. La delegación debe ser expresamente autorizada, en caso contrario, no es procedente.

—Avocación: es la situación inversa a la anterior. En este caso es el superior quien resuelve directamente sin intervención del inferior, que en la generalidad de los casos es quien primero entiende en la función. La avocación es siempre procedente a menos que se encuentre expresamente prohibida.

### 3.1 Órganos de fiscalización administrativa

Son los órganos que tienen por función el contralor de determinada actividad, según la órbita del poder del Estado donde se circunscriba su acción.

Poder Ejecutivo:

—Sindicatura General de la Nación: la Sindicatura General de la Nación tiene como función realizar la auditoría contable y financiera del sector público. También cuenta entre sus funciones la de fijar las normas de la contabilidad que fiscaliza.

En su funcionamiento es una entidad autárquica que sólo depende del presidente de la Nación en forma directa.

En caso de que la Sindicatura General de la Nación detecte irregularidades que afecten los fondos públicos tiene la obligación de informar al Poder Ejecutivo, dentro de los quince días de la toma de conocimiento. Si la irregularidad recae sobre algún funcionario debe notificar a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

—Procuración del Tesoro Nacional: la totalidad del cuerpo de abogados que defienden al Estado dependen de la Procuración del Tesoro Nacional, que asesora al Poder Ejecutivo emitiendo dictámenes. Su máxima autoridad es el procurador general de la Nación.

—Entes reguladores: son órganos que tienen por función el control de cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Son entidades autárquicas que también reciben las quejas y sugerencias de los consumidores.

—Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: dependiente del Ministerio Público, lleva a cabo investigaciones mediante la sustanciación de sumarios administrativos. Se encarga también de sustanciar los procesos ante la Justicia por las denuncias que lleguen a su conocimiento por parte de la Sindicatura General de la Nación ante inconductas de funcionarios públicos.

—Auditoría General de la Nación: este órgano fue creado por el artículo 85 de la Constitución Nacional. Tiene por objeto controlar la legalidad y gestión de la administración pública, auditando su accionar. Asimismo, asiste al Congreso, siendo su titular elegido por la primera minoría de dicho cuerpo colegiado. Así, interviene en la aprobación o rechazo de las cuentas e inversión de fondos públicos, expresando su opinión mediante dictámenes no vinculantes para el Congreso Nacional.

—Comisión Bicameral Permanente: tiene entre sus funciones la de tratar sobre la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo.

—Comisión Revisora de Cuentas: tiene a su cargo el análisis de la cuenta de inversión a que se refiere la Constitución Nacional, así como el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación, el análisis de su presupuesto y el examen de los informes de auditoría del citado organismo.

—Defensoría del Pueblo: es un organismo creado directamente por la Constitución Nacional en su artículo 86. Su titular, el Defensor del Pueblo, es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes, y es reelegible una sola vez. Tiene como funciones la defensa y protección de los derechos del pueblo ante hechos, actos u omisiones de la administración

pública, así como el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, con respecto a lo cual se encuentra legitimado para iniciar acciones judiciales.

#### 4. Acto administrativo

El acto administrativo es una de las formas que tienen los órganos de la administración pública de declarar su voluntad. Éste genera efectos jurídicos sobre uno o varios administrados. Al tener dichos efectos, es el único acto de la administración atacable (del cual el administrado puede pedir su revocación o anulación por los perjuicios que le cause, si éstos resultan ser antijurídicos).

El acto jurídico, como ya hemos visto, genera la adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones. El acto administrativo es una *especie*<sup>96</sup> del acto jurídico que desarrolla sus efectos sobre el administrado.

El acto administrativo puede diferenciarse de otros actos de la administración pública, como ser los actos internos de la administración pública<sup>97</sup> o los actos civiles de la administración pública.<sup>98</sup>

##### 4.1 Clasificación de los actos administrativos

Por su alcance:

—Individual: los efectos jurídicos recaen sobre determinadas personas, (por ejemplo: el nombramiento de algún funcionario, el otorgamiento de un beneficio previsional, etcétera) y generan sus efectos a partir de la notificación, pese a que pueden ser retroactivos a algún momento anterior (v.gr. al momento de la solicitud del administrado).

La vigencia de este tipo de acto se circunscribe al caso concreto de aplicación, sin tener otros efectos y agotando su eficacia en éste. Resulta tan particular el acto que, para lograr su declaración de nulidad (pedir su extinción por resultar viciado de algún modo), la administración pública debe recurrir a la vía judicial.

---

<sup>96</sup> Cuando nos referimos a *especie* lo hacemos porque el acto administrativo es un grupo particular dentro de los actos jurídicos, que serían el *género* del instituto en cuestión.

<sup>97</sup> Carecen de efectos sobre el administrado (por ejemplo: circulares).

<sup>98</sup> Actos que efectúa la administración pública como persona de derecho privado (por ejemplo: contrato de alquiler de un edificio para poner una unidad de atención de la ANSES).



—General: es un acto jurídico que afecta a la totalidad de las personas encuadradas dentro del ámbito de injerencia del órgano. Es el *reglamento*, el más común de estos actos, ya que se dirige a un número determinado o indeterminado de personas. Por lo general tiene una vigencia indeterminada en el tiempo y comienza su obligatoriedad desde su publicación en el Boletín Oficial o diario de publicaciones que la ley indique.

Así como los reglamentos se crean cuando la administración lo considera oportuno, también puede dejarlo sin efecto con otro nuevo reglamento en el momento conveniente. Se destaca que los efectos de los reglamentos no pueden ser retroactivos y regulan únicamente a futuro desde su entrada en vigencia.

#### 4.2 Elementos del acto administrativo

Los requisitos esenciales son aquellos que de faltar o tener vicio alguno generan la nulidad absoluta del acto, ya que no es subsanable y se retrotrae todo a la situación anterior, como si no hubiera existido acto alguno. Existe un *elemento subjetivo* (voluntad, capacidad) que se da por hecho aun cuando no surja del texto de la ley 19.549. El resto de los requisitos esenciales surge del artículo 7° de la citada ley:

—Competencia: aptitud legal que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar, la materia, el tiempo y el grado.

—Causa: son los antecedentes y circunstancias de hecho y de derecho existentes al momento de emitirse el acto, considerados por la administración para el dictado del mismo. Por ejemplo, la falta de presentación de una declaración jurada (D.J.) configura una circunstancia de hecho; la presentación en tiempo y forma configura un antecedente de derecho.

—Motivación: es la justificación del acto sobre la base de las razones que han llevado a su dictado. La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y puede afectar la validez del acto, ya que la administración pública no puede obrar arbitrariamente.

—Objeto: es el efecto práctico que se pretende obtener con el acto, que debe estar acuerdo con lo establecido en el inciso c) del artículo 7° de la ley 19.549.

—Procedimientos: son los pasos que deben darse previamente a la emisión del acto.

1. Finalidad: el fin del acto administrativo consiste en la satisfacción del interés público.
2. Forma: se refiere al modo en que, posteriormente al dictado del acto, la resolución llega a conocimiento del administrado. Las formas, en derecho administrativo, cumplen una función de

garantía, tanto de los derechos de los administrados, como de la legalidad que debe existir en la actividad administrativa. En general, el acto administrativo debe ser *escrito*, fechado y firmado por la autoridad emisora. Excepcionalmente pueden admitirse otras formas: *verbal* (por ejemplo, la actividad de policía), *gráfica* (por ejemplo, los carteles de señalización de tránsito).

—Silencio administrativo: cuando la administración pública calla, vencido el plazo correspondiente (si la norma en cuestión no establece plazo, el máximo es de sesenta días) debe entenderse tal situación como una negativa a la petición del administrado. Una vez vencido dicho plazo, el interesado debe pedir un pronto despacho de las actuaciones y, pasados treinta días más, ante la falta de pronunciamiento, deberá considerar que hay silencio de la administración, lo cual habilita al administrado para recurrir a la vía judicial (artículo 10).

#### 4.3 Caracteres del acto administrativo (artículo 12 de la ley 19.549)

1. Presunción de legitimidad (*iuris tantum*): salvo prueba en contrario, se presume la legitimidad del acto administrativo, vale decir que ha sido dictado de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

2. Ejecutoriedad: es una manifestación de la auto tutela de la administración; es la posibilidad de que ella misma provea a la realización de sus propias decisiones, cuando el orden jurídico le ha concedido expresa o implícitamente tal atribución.

La executoriedad puede ser:

—Propia: cuando la ley faculta a la administración a dictar el acto y ejecutar su cumplimiento.

—Impropia: cuando la ejecución del acto de la administración depende del dictado de una sentencia judicial posterior.

#### 4.4 Nulidad del acto administrativo

Como consecuencia de algún vicio en los elementos que constituyen el acto administrativo, puede declararse su nulidad. En el derecho administrativo el particular o administrado puede peticionar la nulidad de un acto cuando tiene legitimación, es decir, solamente en los casos en que el acto afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

La nulidad puede ser de dos tipos:

Nulidad absoluta: los actos nulos de nulidad absoluta no pueden sanearse (artículo 14). Esta nulidad surge por:

—Vicios generales de los actos jurídicos:

a) Error esencial: cuando se excluye la voluntad de la administración (error en la persona, error en el objeto).

b) Dolo: como vicio del acto jurídico (tercera acepción jurídica del término dolo), es toda afirmación de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. El dolo difiere del error en que es intencional (busca engañar). Para que el dolo ocasione la invalidez del acto administrativo debe ser grave y determinante de la acción del agente. Sea que el dolo fuera propio del agente o del administrado, o de ambos, el acto administrativo resultará nulo de nulidad absoluta.

c) Violencia física o moral: la violencia ejercida sobre el funcionario que dicta el acto puede ser física o moral. La voluntad de la administración se ve frustrada por la acción sobre el funcionario.

d) Simulación absoluta: cuando ninguno de los elementos que se presentan para el dictado del acto administrativo resultan veraces.

—Vicios específicos de los actos administrativos, por incompetencia en razón de:

—Territorio: cuando el órgano actuante lo hace fuera del territorio sujeto a su jurisdicción.

—Materia: el órgano administrativo actúa fuera de la esfera de competencia con relación a los actos en los que debe entender.

—Tiempo: si el funcionario dicta el acto fuera del plazo de cumplimiento de sus funciones (antes o después del comienzo o final de sus funciones).

—Grado: el inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea de la competencia del superior, ni el superior dictar, en principio, alguno que fuera de la exclusiva competencia del inferior, sin que éste hubiese hecho lo propio oportunamente.

También existen otros vicios, como la falta de causa (acto fundado en hechos distintos o falsos), falta de motivación (acto fundado en elementos falsos), vicios en el objeto (objeto incierto o acto física o jurídicamente imposible), vicio en la finalidad (cuando el acto se ha dictado con un fin distinto del previsto por el legislador) y vicios en las formas esenciales.

—Anulabilidad: son anulables los actos administrativos regulares con vicios leves.

Un acto administrativo es saneable cuando:

- El vicio sea del objeto, por falta de resolución de todas las peticiones efectuadas.
- El vicio sea de la causa, por errónea apreciación de los hechos peticionados.
- Se tratare de un vicio leve de procedimiento.

## 5. Contratos administrativos

Siguiendo la finalidad de satisfacer el interés general, el Estado se vincula con los particulares mediante contratos de derecho público o contratos administrativos.

Las características de los contratos en cuanto a sus elementos son similares a las ya analizadas; sin embargo, tienen sus particularidades (fruto de que una de las partes contratantes es el Estado), entre las que se cuenta la necesidad de existencia de causa (artículo 7° de la ley 19.549) y de las formas (ya que es necesario el cumplimiento de éstas según el objeto a contratar).

Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar su ecuación financiera.

### 5.1 Selección del co-contratante

Etapas precontractual:

El Estado debe respetar diversas etapas o métodos para efectuar la contratación. En primer lugar, debe detectar la necesidad. Luego, debe prever la partida presupuestaria que tendrá directa relación con la preparación del proyecto (trabajo técnico).

Una vez detectada la necesidad, con precisión técnica, debe proceder a la selección del co-contratante. Para ello cuenta con diversos mecanismos, como ser: licitación pública, licitación privada, contratación directa, remate, concurso, etcétera.

El principio general es que el Estado puede elegir discrecionalmente el método a utilizar, con la limitación económica de contrataciones superiores al monto establecido en la legislación (que se va actualizando), en cuyo caso deberá a proceder a seleccionar co-contratante mediante una licitación.

Luego de efectuado el análisis seguirá la pre adjudicación y/o adjudicación. Tarea realizada por comisiones, donde se aplica el principio de adjudicar el contrato a la oferta más conveniente (la que no tiene por qué ser la más barata, ya que deben ponderarse todos los factores, incluso la solvencia o seriedad en el cumplimiento).

## 5.2 Mecanismos de selección del co-contratante

El método obligado para contrataciones donde se encuentran en juego grandes sumas de dinero es la licitación pública.

### 1. Principios de la licitación pública:

- Oposición y concurrencia de todos los oferentes.
- Publicidad del acto (lo que se logra mediante la publicación de los pliegos y sus modificaciones).
- Igualdad de todos los oferentes.

2. Pliego de condiciones: es el documento que establece las obligaciones de las partes. Es preparado en forma unilateral por la administración. Los particulares toman conocimiento de él a través de la publicación; no pueden modificarlo con posterioridad a la presentación de las propuestas, ni luego de la adjudicación. El pliego de condiciones puede ser:

- General: establece las disposiciones aplicables a todos los contratos realizados por un mismo órgano de la administración
- Particular: contiene todos los derechos y disposiciones particulares de cada contrato.

El pliego de condiciones se adquiere a costos elevados, con el objeto de resarcir a la administración por su gasto y evitar la presentación indiscriminada de oferentes sin capacidad real.

### **Procedimiento:**

1. Se abre un llamado a licitación mediante la publicación en diarios de alcance masivo y en la separata de licitaciones del Boletín Oficial, en los que se dan a conocer las características de la obra y las condiciones generales de la licitación. Para conocer los requisitos detallados de la obra debe adquirirse el pliego.

2. Luego, se inicia el período de presentación de las propuestas, las que deben ser secretas, por escrito y en sobre cerrado.

En el plazo de presentación de las propuestas se realiza la apertura de sobres y luego se produce la adjudicación a la mejor propuesta dentro de las que cumplan las condiciones exigidas. Dependiendo de la complejidad del contrato, puede haber una preadjudicación, en la que una comisión se expedirá al respecto. Si la contratación es simple, la adjudicación es directa (por ejemplo, cuando se busca simplemente precio porque los objetos son iguales). También puede darse el supuesto de que ninguna oferta cumpla los objetivos buscados por la administración. En tal caso se declarará fracasada la licitación. Si hay empate o empate técnico los empatantes deben mejorar sus ofertas.

La selección puede ser impugnada por el oferente que considere que existe alguna irregularidad.

Licitación privada: es similar a la anterior, con la salvedad de que radica en una invitación restringida a quienes la administración sabe que se encuentran en condiciones de ejecutar el contrato.

Así se procederá en los contratos que requieran una especial capacidad o competencia que no muchos poseen, en contratos que no superen determinados límites económicos o en licitación pública fracasada o desierta.

También puede ocurrir en trabajos urgentes o suplementarios que deben realizarse por circunstancias imprevistas o para la satisfacción de intereses comunitarios impostergables.

Contratación directa: finalmente, el Estado puede contratar en forma directa cuando el monto a contratar no supere los límites legales vigentes y/o cuando se trate de trabajos urgentes o suplementarios por circunstancias imprevistas o urgentes. También procede en contrataciones entre distintos organismos de la administración y para reparar vehículos o motores.

## 6. Servicio público

Las necesidades de interés general que no son satisfechas por la actividad privada, deben ser subsidiariamente realizadas por el Estado. También existe la idea de que el Estado debe garantizar y realizar en forma directa todas las actividades tendientes a satisfacer dicho interés. Así, hay épocas en que, por ejemplo, el transporte subterráneo o la producción de energía o hidrocarburos son estatales y otras en que se privatiza, dependiendo de los principios de quien gobierne el Estado. En caso de que sea la actividad privada la que efectúe la prestación, existen organismos de control denominados *entes reguladores*.

Así, podemos definir el servicio público como la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. Es una prestación de actividades o de bienes, pero no de dinero.

El servicio público tiene los siguientes caracteres:

- Continuidad: la prestación, dado que surge de una necesidad general, no puede interrumpirse ni paralizarse. El Estado tiene el deber de asegurar la continuidad. Es facultad de la administración, reservada por lo general en los contratos de concesión de servicios públicos, la posibilidad de aplicar sanciones al concesionario que interrumpe la prestación de un servicio.
- Regularidad: el servicio debe ser prestado en forma correcta y tal y como se estableció en su regulación.
- Igualdad: el servicio debe prestarse en igualdad de condiciones para todos los usuarios, pudiendo diferenciarse por categorías, pero manteniendo la igualdad dentro de la categoría.
- Generalidad: el servicio público es para todos, sin poder limitarse a nadie su gozo, siempre y cuando se encuentre dentro de la categorización efectuada.

### 6.1 Marco regulatorio

La norma jerárquicamente más importante del marco regulatorio de los servicios públicos es el artículo 42 de la Constitución Nacional.<sup>99</sup>

En cumplimiento de la manda constitucional existen leyes ordenatorias de cada servicio, a las que se suman la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia. También resultan de aplicación los reglamentos de los servicios, algunas ordenanzas municipales y la

<sup>99</sup> Artículo 42 de la Constitución Nacional: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

"Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

"La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control".

normativa particular del contrato de concesión que surge del pliego oportunamente adquirido y que fue explicado más arriba.

## **7. Entes reguladores**

Conforme lo ya explicado tenemos los siguientes entes reguladores:

- De energía eléctrica: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
- De gas: Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
- De comunicaciones: Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
- De transporte automotor y ferroviario: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
- De agua potable y saneamiento: Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS).
- De aeropuertos: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

## **8. Procedimiento administrativo**

El procedimiento administrativo es una parte del derecho administrativo que se aboca al estudio de las normas y principios que entran en acción cuando el administrado solicita o pretende intervenir en la voluntad de la administración, tanto para solicitar que se le reconozca un derecho como para contratar con ella. El procedimiento trata sobre las formas a las que deben sujetarse tanto la administración como los administrados en el desarrollo de la función administrativa. Así, el cumplimiento de las formas asegura la eficacia de la gestión de la administración y el respeto de los derechos e intereses de los administrados.

### **8.1 Recursos**

El procedimiento administrativo tiene por consecuencia el dictado de un acto administrativo. Si el administrado considera que no fue atendido su reclamo y el acto no ha sido dictado conforme los principios que rigen la materia, o que simplemente existió silencio de la administración



interpretado como denegatoria tácita, puede presentar recursos. Éstos tienen por objeto obtener la impugnación de los actos dictados u obtener resolución a los planteos que fueron objeto de silencio. De esta forma se intenta proteger y controlar la legalidad de los actos administrativos.

Recurso de reconsideración: se efectúa por ante la misma autoridad que emite el acto impugnado con el fin de que lo modifique o lo deje sin efecto. Es facultativo del administrado y procede contra cualquier tipo de acto administrativo. Debe ser interpuesto, dentro de los diez días hábiles administrativos desde la notificación del acto, ante quien lo dictó.

Recurso jerárquico: consiste en petitionar al órgano superior jerárquico que revea un acto administrativo del inferior, con el objeto de que lo revoque, suspenda o modifique. Para su interposición el administrado cuenta con treinta días hábiles desde la notificación del acto. El recurso jerárquico agota la instancia administrativa y deja expedita la vía judicial como último recurso si la resolución vuelve a ser contraria a lo peticionado.

Los plazos para la presentación de los recursos son obligatorios y perentorios.

Instancia judicial: una vez agotada la instancia administrativa, el particular tiene un plazo de noventa días para pasar a la instancia judicial. Cumplido este plazo, se produce la caducidad del derecho y quedan firmes los efectos del acto administrativo dictado.



## CAPÍTULO 11: Derecho procesal

### 1. Derecho procesal

Con la expresión derecho procesal se designa el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el proceso jurisdiccional. También comprende la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen.

Para poder efectuar reclamos ante la Justicia es necesario el dictado de normas llamadas de *forma o procedimiento*. Hasta el momento se ha visto gran cantidad de normas de *fondo* (las que regulan los derechos), pero es necesario también regular las acciones ante los tribunales y establecer los distintos procesos.

Existen distintos tipos de procedimientos, según se trate de peticiones de una naturaleza u otra. No todo reclamo necesita la misma profundidad de análisis. Así, para los procedimientos que requieren una amplitud de prueba nos encontramos con el proceso de conocimiento ordinario, que permite gran cantidad de prueba y conlleva una mayor cantidad de tiempo de tramitación. Pero también, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, normalmente indicado como CPCCN (que en la práctica resulta ser similar al resto de los códigos procesales provinciales), existen numerosos tipos de proceso, como los sumarísimos (más rápidos y de menor profundidad probatoria), los especiales, las acciones que tramitan sin forma de proceso, etcétera.

El primer concepto que surge al analizar el proceso judicial es el de *acción*, como derecho subjetivo procesal, poder jurídico o facultad que las personas tienen para promover la actividad del órgano jurisdiccional; ésta tiene por finalidad resolver una pretensión o pedido (demanda) por parte de la jurisdicción.

El segundo término en análisis es el de *proceso*, siendo éste un conjunto de actos que realizan las partes, el juzgador y demás sujetos que intervienen en una causa judicial, que tienen como finalidad lograr la solución del litigio mediante el dictado de una sentencia.

Estos procesos tienen algunas características o principios. Uno de los principios fundamentales que deben regir todo tipo de proceso es el principio de contradicción. Si existe litigio es esencial que se esté en contradicción, es decir, que lo que una parte dice sea transmitido a su tiempo a la otra para que ésta se defienda y pueda ejercer sus derechos constitucionales. El juzgador debe resolver sobre las demandas que le formule cualquiera de las partes, oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole oportunidad para que las exprese. Inclusive los procesos especiales que se tramitan sin forma de proceso, con una simple

interposición de demanda, requieren la celebración de una audiencia, donde se oirá a la parte contraria antes de resolver la petición.

Las características de cada tipo de proceso judicial exceden el alcance de la presente obra, por lo que no se tratarán en este capítulo, con excepción de los tipos o medios de prueba con los que se puede demostrar la existencia del contrato o los hechos que se pretenda acreditar frente a cualquier conflicto, que revisten un carácter eminentemente práctico.

### 1.1 Mediación y conciliación

Para llegar al proceso judicial, en la Capital Federal, es necesario someter el reclamo al procedimiento previo de mediación (para reclamos de la justicia civil y comercial) o al procedimiento de conciliación laboral obligatoria (conocido como *conciliación* o SECLO, sigla de Servicios de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo).

Ambos procesos tienen carácter administrativo, dentro de los cuales la controversia puede solucionarse logrando alcanzar un acuerdo transaccional; o puede quedar irresoluta, caso en el que se extenderá un certificado que habilita la instancia judicial.

Esto surge del artículo 1° de la ley 24.573, de mediación civil y comercial, que dispone con "carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia. Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa, existió mediación ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia". Por su parte, los artículos 2° y 3° indican: "El procedimiento de la mediación obligatoria no será de aplicación en los siguientes supuestos:

- "1. Causas penales.
- "2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.
- "3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación.
- "4. Causas en que el Estado nacional o sus entidades descentralizadas sean parte.
- "5. Amparo, hábeas corpus e interdictos.
- "6. Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite de la mediación.

"7. Diligencias preliminares y prueba anticipada.

"8. Juicios sucesorios y voluntarios.

"9. Concursos preventivos y quiebras.

"10. Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo.

"Artículo 3º: En el caso de los juicios de desalojo, el presente régimen de mediación será optativo para el reclamante, debiendo en dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia".

Por el lado de la Ley de Procedimiento Laboral, 24.635, se dispone la conciliación obligatoria previa y en forma similar a la mediación civil. Esta ley establece, en su primer artículo, que "los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la justicia nacional del trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el organismo administrativo creado por el artículo 4º de esta ley, el que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". Así, todos los reclamos de índole laboral deberán pasar por el procedimiento ante el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Como excepción, los procesos que indica el artículo 2º<sup>100</sup> del mismo cuerpo normativo no deben pasar por la conciliación previa. Todos estos procesos, para el trabajador, tienen carácter gratuito, conforme fue estudiado en los capítulos anteriores.

## **2. La prueba. Medios de prueba. Confesión. Testimonial. Pedido de informes. Instrumental. Documental. La prueba pericial. El dictamen pericial. Honorarios del perito**

---

<sup>100</sup> Artículo 2º de la ley 24.635: "Quedan exceptuadas del carácter obligatorio y previo de esta instancia:

"1. La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares.

"2. Las diligencias preliminares y prueba anticipada.

"3. Cuando el reclamo individual o plurindividual haya sido objeto de las acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis, o de conciliación obligatoria previstos en las leyes 24.013 y 14.786.

"4. Las demandas contra empleadores concursados o quebrados.

"5. Las demandas contra el Estado nacional, provincial y municipal.

"6. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público".

Cuando se lleva una controversia a entendimiento de un juez iniciando un proceso judicial, junto con la demanda o cuando se pretende contradecir los dichos de la contraparte (con la contestación de demanda) es necesario demostrar que lo que se alega (se indica como verdad) es cierto. Para que el juzgador apruebe lo que se peticiona se deben acercar elementos probatorios que generen un convencimiento de que los hechos indicados son ciertos.

Esto surge del artículo 377 del CPCCN, que indica: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiere sido probada, el juez podrá investigar su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio".

Estos elementos se enmarcan en categorías que son conocidas como medios de prueba:

## **2.1 Prueba documental**

La prueba documental se acompaña, en el proceso civil, en la demanda, la contestación y/o la reconvencción (situación que ocurre cuando alguien contrademanda al que lo demanda, en el mismo juicio). Debe acompañarse, en cada acto de los indicados, la totalidad de la documental que pretende hacerse valer en el proceso y ofrecer las restantes pruebas por aplicación del principio procesal de economía procesal y la directiva de concentración en un solo acto. Si la prueba documental no estuviera en poder de las partes, el oferente debe especificar su contenido (o acompañar copia) y lugar de archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre para remitirle un pedido de informes (prueba de informes comúnmente llamada *oficio*) a los efectos de que la poseedora la remita al juzgado.

Si lo que se debe probar es, por ejemplo, un contrato, éste se prueba por los medios y formas legales previstas, tanto en el Código Civil y Comercial, en los artículos 1.019 a 1.020, como en los previstos en el CPCCN que se están analizando en estos puntos.

Para este supuesto, los medios de prueba del Código Civil y Comercial son los enumerados a continuación.

### **2.1.1 Instrumentos públicos:**

Son los mencionados en el artículo 289 del Código Civil y Comercial. El instrumento público hace plena prueba de los hechos o actos que contiene, ya que la ley presume que tanto el

documento como su contenido son auténticos. El instrumento público hace plena fe hasta que se pruebe su falsedad por medio de un juicio de redargución de falsedad.

### **2.1.2 Instrumentos particulares firmados o no firmados:**

Los instrumentos privados no requieren formalidades en virtud del principio de libertad de formas. En el caso de los contratos, existe la exigencia de la firma de las partes y la pluralidad de ejemplares según la cantidad de personas obligadas por el contrato. Los instrumentos privados requieren de otros medios de prueba para obtener verosimilitud, a diferencia de los públicos, que hacen plena fe por sí mismos.

Así, si la contraparte desconoce la firma del contrato, se deberá hacer una pericia caligráfica. También, para que sea válido en sus efectos contra terceros debe tener fecha cierta, que se adquiere según lo dispuesto por el artículo 317 del Código Civil y Comercial.<sup>101</sup>

Respecto de los instrumentos privados no firmados, como los tickets o los registros informáticos simples, se consideran también medios de prueba o principio de prueba, por escrito, de la existencia de un contrato.

Finalmente, en cuanto a los documentos electrónicos y la firma digital, nos remitimos a lo ya indicado en los capítulos anteriores.

### **2.2 Confesión de partes:**

Es otro medio probatorio que consiste en una declaración de la parte reconociendo la verdad de un hecho personal que produce efectos desfavorables para ella y favorables para la otra parte. Es la declaración de una persona contra sí misma (es el origen de la conocida frase "A confesión de parte relevo de prueba"). La confesión puede ser:

Judicial: cuando se presenta dentro del proceso. Se desarrolla mediante la audiencia de absolución de posiciones o en cualquier presentación que efectúe la parte por escrito.

---

<sup>101</sup> Artículo 317: "La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez."

Extrajudicial: cuando se presta fuera de un proceso, no se hace ante un juez.

## 2.3 Presunciones legales o judiciales:

Las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho que se conoce o da por cierto, para afirmar un hecho desconocido. Pueden ser de dos clases:

*Legales*: son establecidas por la ley y se dividen en dos:

- *Iure et de iure*: no admiten prueba en contrario. Hacen plena prueba del supuesto que se presume.
- *Iuris tantum*: admite prueba en contrario a cargo de quien pretenda destruirla.

*Judiciales*: son las que un juez establece en el caso concreto ante el examen de los indicios que surgen de la causa y según su criterio. Para evitar la discrecionalidad judicial (que el juez decida sin ningún tipo de fundamento válido) la ley exige que, para tener fuerza probatoria, las presunciones judiciales deben fundarse en antecedentes reales, probados, debiendo ser graves, precisas y concordantes.

## 2.4 Testigos

Un testigo es una persona de existencia física, tercero extraño al juicio, que declara acerca de los hechos percibidos por sus sentidos y que tengan relevancia para el proceso (no interesa la declaración del testigo sobre hechos anecdóticos o que no tengan vinculación a la causa y los hechos dubitados). La percepción tiene que ser de hechos directos, por lo que no sirve un testigo que, por ejemplo, declara: "Me dijo el demandante que ocurrió determinada cosa". Los hechos deben haber sido percibidos por el testigo en forma directa, a través de sus sentidos, para que su declaración tenga validez. Si bien el Código Civil y Comercial como regla general prohíbe la prueba de los contratos únicamente por testigos, nada obsta a que se prueben los *efectos* de un contrato determinado. Luego, probados sus efectos, junto con la restante prueba, se logrará presumir la existencia de éste. Es el artículo 426<sup>102</sup> del CPCCN el que establece quién puede ser testigo.

---

<sup>102</sup> Artículo 426: "Toda persona mayor de catorce (14) años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley. Los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal pero dentro de un radio de setenta (70) kilómetros, están obligados a comparecer para



## 2.5 Prueba pericial

Un juez, por sus estudios jurídicos, se encuentra capacitado con un gran bagaje de conocimiento del derecho, pero cuando para interpretar hechos o actos sea necesario un conocimiento técnico especial dentro del campo de otros saberes, debe requerir el auxilio de terceros especialistas. Así, el perito será una persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de dichos conocimientos especiales, científicos o técnicos.

Para brindar su auxilio, el perito realizará un peritaje, esto es, un examen y estudio sobre el problema encomendado, que tendrá por conclusión un informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley.

Dicho examen no versará sobre lo que al perito le parezca conveniente, sino que las partes, a quienes interesa este medio de prueba, propondrán con claridad y precisión el objeto sobre el cual deba recaer el reconocimiento pericial. El juez permitirá o no dicha prueba, resolviendo sobre la necesidad o no de ésta e incluso disponiendo él mismo de interrogantes para el perito.

Los peritos son nombrados por sorteo efectuado sobre los listados de peritos que por especialidad lleva cada una de las cámaras de apelaciones. Dicho sorteo lo realiza el secretario del juzgado, con conocimiento de las partes, con el fin de que puedan ser recusados o tachados por causas anteriores o posteriores al nombramiento.

La pericia es plasmada en un documento que contiene las respuestas a los interrogantes planteados por las partes y el juez, en su caso. Éstas deben contener los fundamentos de su explicación, los métodos y medios empleados, y la lógica de sus conclusiones expuesta en forma clara. Este informe se denomina dictamen pericial.

Los elementos que debe contener un dictamen pericial son:

---

prestar declaración ante el tribunal de la causa, si lo solicitare la parte que los propone y el testigo no justificare imposibilidad de concurrir ante dicho tribunal”.

Testigos excluidos. Artículo. 427: “No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratare de reconocimiento de firmas”.

- a) La descripción de las circunstancias en que se realiza la pericia, partes presentes, el estado material en que se encuentra el sujeto u objeto de estudio.
- b) El relato de cada una de las acciones realizadas durante la pericia con descripción de sus resultados.
- c) Los elementos técnicos empleados y métodos científicos utilizados para llegar a los resultados indicados en el punto anterior y que le dan validez a su dictamen.
- d) Las conclusiones del dictamen pericial que se plasman como respuesta a los interrogantes individuales y/o como conclusión general.

El dictamen pericial será informado a las partes, las que podrán observarlo o impugnarlo por las razones que consideren de valor o por los métodos utilizados. Al término del cruce de pericia, impugnación y respuesta, las conclusiones finales serán apreciadas y valoradas, según las reglas de la sana crítica, por el juez que intervenga. Sin perjuicio de la importancia del dictamen pericial, éste no es vinculante para el juzgador, ya que puede apartarse de sus conclusiones fundadamente.

Los peritos, por la labor desarrollada, reciben un honorario que se estima, principalmente, como un porcentaje del monto de condena, acuerdo o demanda, según sea la forma en que se resuelva el proceso. Resulta así ser una posibilidad laboral para la mayoría de las profesiones colegiadas, como, por ejemplo, la mayoría de las ingenierías. Existen también leyes especiales de honorarios profesionales que son utilizadas muchas veces como parámetro, pero exceden el alcance de la presente obra. Queda a cargo de cada profesional ingeniero estar al tanto de las regulaciones específicas de su especialidad, las que generalmente pueden obtenerse en el colegio profesional que los agrupa.

## 2.6 Prueba de informes

Cuando el conocimiento de los hechos no surja de la apreciación de un testigo, sino que se encuentre registrado de algún modo en documentos o archivos de personas jurídicas o escribanos con registro, se les remitirá un pedido de informes. Así lo dispone el artículo 396 del CPCCN cuando indica: "Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio".

Muchas veces se intenta utilizar este medio de prueba para suplantar otros, como la documentación que debió estar en poder de la parte o una prueba pericial. Así, el CPCCN prohíbe dicha sustitución cuando el artículo 397 indica: "No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo podrá ser negado si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio".

## 2.7 Admisibilidad de la prueba

No todo medio probatorio se admite o resulta eficaz, pese a haber sido autorizada su producción, para demostrar la existencia de algunos contratos. Los contratos no formales, en principio, pueden ser demostrados por cualquier medio probatorio; pero los formales tienen como principio general la exigencia de que sólo se prueban presentando el instrumento indicado taxativamente por la ley. Ejemplo: contrato de renta vitalicia o, como se lo suele llamar, retiro o jubilación privada.

Dentro de los contratos formales, a su vez, se encuentran dos categorías: *ad solemnitatem*, es decir, no pueden ser probados si no es por el medio indicado en el código pertinente, y *ad probationem*, cuando dichos medios probatorios tienen validez como medio de prueba en juicio.

## 3. El arbitraje. Procedimiento. Cláusulas arbitrales

Existe la posibilidad de que las partes sometan sus diferencias, en forma voluntaria, a un juicio arbitral. En este tipo de proceso, quien resuelve la causa no es el juez natural de la causa, sino una persona o personas que las partes han designado.

Dispone el artículo 739 que el compromiso para someter las controversias a juicio arbitral debe ser formalizado "por escritura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante el juez de la causa, o ante aquel a quien hubiese correspondido su conocimiento".

Para ser válido, el compromiso arbitral (el cual puede plantearse desde el mismo momento de la contratación hasta dentro del proceso judicial en curso) debe contener los siguientes elementos que surgen del artículo 740 del CPCCN:

- 1) Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes.
- 2) Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del artículo 743.
- 3) Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias.
- 4) La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso.

También suele ser útil la concertación de cláusulas facultativas que permite el artículo 741 del mismo cuerpo normativo. Así, se podrá convenir en el compromiso:

- 1) El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si no se indicare el lugar, será el de otorgamiento del compromiso.
- 2) El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo.
- 3) La designación de un (1) secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 749.
- 4) Una multa que deberá pagar la parte que recurra el laudo a la que lo consienta, para poder ser oída, si no mediase la renuncia que se menciona en el inciso siguiente.
- 5) La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad, salvo los casos determinados en el artículo 760.

Para poder hacer efectiva la constitución del árbitro o tribunal arbitral es necesario que la parte que requiera dicha constitución presente una demanda ante el juez natural de la causa (artículo 742), la que puede ser negada únicamente mediante fundamentación válida. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el alcance de lo que deberá resolver el árbitro, lo decidirá el juez competente. La designación de árbitro sólo podrá recaer en personas mayores de edad y que estén en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

El procedimiento podrá pactarse libremente por las partes. Si nada dice el compromiso, se utilizarán las reglas de los procedimientos del CPCCN.

Por ser una decisión voluntaria de las partes y no poseer *imperium* judicial, "los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias, ni de ejecución, deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral" (artículo 753).

La resolución de la controversia la fijará el dictado del laudo arbitral. Contra éste se podrán admitir los recursos en forma idéntica al supuesto de dictado de sentencia definitiva, salvo que las partes hayan pactado renunciar a este derecho.

La ejecución forzada de lo resuelto por el laudo deberá sustanciarse ante el juez natural de la causa, el que ejecutará el laudo como si fuera una sentencia definitiva que se encuentre firme.

Claramente el procedimiento arbitral se muestra interesante y útil para controversias complicadas o cuya resolución requiera de un conocimiento técnico importante, y en el que las partes consideren oportuno que sea resuelto por alguien versado propiamente en la materia. Esto recuerda a la prueba pericial, en la cual es necesario el auxilio de un perito para cuestiones técnicas especiales. Si bien se encuentra prevista la realización de pericial en el proceso arbitral, el conocimiento del árbitro en los aspectos técnicos suele ser esencial y definitivo, o al menos así lo consideran las partes involucradas.

### Glosario de términos jurídicos:

El derecho posee términos que no son de uso común o que, siéndolos, por ser vocablos multívocos, requieren una aclaración para su uso en cuestiones jurídicas. Se agrega el presente glosario con el objeto de aclarar alguno de dichos términos, los que, en la experiencia del autor, son reiteradamente vistos a nivel del mundo jurídico empresarial y así facilitar el estudio del profesional de otras ramas del saber. No se incluyen en el presente las definiciones de términos que surgen del mismo texto del libro. Tampoco se pretende agotar la totalidad de los términos usados en el mundo jurídico. Para ello, deberá recurrirse a un diccionario de términos jurídicos. Se intenta con el presente lograr una guía de estudio y auxilio sobre algunos vocablos no vistos durante la presente obra; pero que se encontrará el profesional en su vida laboral. Finalmente, debe saberse que este glosario es en respuesta a los pedidos de los alumnos que fueron pasando por los distintos cursos, a lo largo de los años, los cuales sentían su ausencia como una dificultad. A ellos, a los actuales y a los futuros profesionales espero que les sirva y sea de utilidad este pequeño glosario.

#### A

**AB-INTESTATO:** Tipo de proceso sucesorio que se inicia cuando una persona fallece sin dejar testamento. En estos casos la sucesión debe regirse por las relaciones de parentesco conforme indica la ley. (art. 2424 y ss. del Código Civil y Comercial.)

**ABSOLUCION:** Declaración que surge de una sentencia como no punible a una persona procesada por un delito.

**ABSOLUCION DE POSICIONES:** Declaración realizada por una de las partes del proceso bajo juramento o promesa de decir verdad.

**ABSOLVER:** Declarar no punible a una persona.

**ABUSO:** Mal uso de alguna cosa o derecho por ser un uso distinto del correspondiente.

**ABUSO DEL DERECHO:** EL artículo 10 del nuevo Código Civil y Comercial dispone: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario

para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización."

**ACCESORIO:** Lo relacionado a lo principal; pero sin ser sustancial o esencial. Así podemos decir "una cláusula accesoria del contrato" o "los objetos accesorios siguen la suerte del objeto principal".

**ACCIDENTE:** Acontecimiento fortuito o hecho humano involuntario generador de un daño a las personas o cosas.

**ACCIDENTE DE TRABAJO:** Accidente ocurrido en ejercicio u ocasión del trabajo.

**ACCIDENTE "IN ITINERE":** Accidente ocurrido al trabajador en el trayecto de ida y vuelta de su trabajo, salvo que el recorrido fuera afectado o interrumpido por causas de interés del trabajador o no imputables a la empresa.

**ACCIÓN:** Facultad de solicitar la actividad estatal de jurisdicción para la declaración de algún derecho. Es distinto del *derecho* como potestad y de la *demanda* como escrito donde se insta la acción. Se puede tener derecho sin poseer acción e iniciarse una demanda que sea rechazada por falta de acción. Por ejemplo, ante la prescripción de un derecho el mismo subsiste como *obligación natural*; pero no poseo acción para reclamar ya que, de hacerlo, puede rechazarse el progreso del proceso por una defensa de excepción de falta de acción. En derecho comercial la acción es el interés o participación en algunas compañía cuyo capital social se representa en *acciones*.

**ACCIONISTA:** titular de una acción de alguna sociedad.

**ACEPTACIÓN:** Como elemento de la conformación del contrato es la admisión del encargo o de la propuesta que se le efectuara a una persona.

**A CONTRARIO SENSU:** resulta ser una locución latina que significa *en sentido contrario*.

**ACRECER:** Aumentar.

**ACREEDOR:** Persona con derecho a peticionar alguna cosa o servicio.

**ACREEDOR COMÚN O QUIROGRAFARIO:** Aquel que no tiene privilegios.

**ACREEDOR HIPOTECARIO:** Aquel que tiene sus créditos garantizados con uno o más bienes inmuebles del deudor.

**ACREEDOR PIGNORATICIO:** Aquel que tiene sus créditos garantizados por la entrega que le hiciera el deudor de uno o más bienes muebles determinados del deudor, los cuales devolverá cuando este cumpla su obligación (prenda con desplazamiento). En los casos de prenda sin

desplazamiento (por ejemplo la constituida en el registro automotor sobre un vehículo) el deudor es depositario regular de la cosa.

**ACREEDOR PRIVILEGIADO:** Es aquel en que en virtud de una disposición legal tiene derecho a hacerse pagar antes que otro.

**ACREEDOR SOLIDARIO:** Son aquellos que poseen un mismo crédito común a su favor, al punto de que cualquiera de ellos puede solicitar el cumplimiento del total de la deuda. EL pago hecho por el deudor a cualquier de ello extingue la deuda. (art. 853 y ss del Código Civil).

**ACTIVO:** Conjunto de bienes y derechos susceptibles de apreciación económica que integran el patrimonio. Es lo opuesto del *pasivo* el cual se integra por las deudas que gravan dicho patrimonio.

**ACTO ADMINISTRATIVO:** "Toda decisión, general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones y que se refiere a derechos, deberes e intereses de la administración o de los particulares respecto de ellas"(Bielsa).

**ACTOS DE ADMINISTRACIÓN:** Opuesto al acto de disposición. Es aquel cuyo objeto consiste en conservar, mantener o incrementar un patrimonio, o percibir y utilizar rentas.

**ACTOS DE DISPOSICIÓN:** Aquellos cuyo objeto es enajenar del patrimonio un bien o derecho crediticio, o gravar algún bien con derechos reales de garantía.

**ACTOS ILÍCITOS:** Según la Nota del Codificador Vélez en el título "De los actos ilícitos" del Código Civil, este es "acciones, pues que tales se consideran aún los de la expresión tácita de la voluntad. Los actos ilícitos pueden ser acciones u omisiones. Acciones, cuando se hace lo que la ley prohíbe; omisiones cuando no se hace lo que la ley manda."

**ACTOS JUDICIALES:** Los realizados por las partes por ante los tribunales o el efectuado por los auxiliares de justicia, jueces y tribunales en el ejercicios de sus funciones.

**ACTOS JURÍDICOS:** Manifestación de una o más voluntades cuyo objeto es producir efectos jurídicos. El art. 944 del Código Civil reza "los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos".

**AD EFFECTUM VIDENDI:** Expresión latina cuyo significado es "a efecto de tener a la vista".

**AD-HOC:** Expresión latina cuyo significado es "para el caso".

**AD HONOREM:** Expresión latina utilizada para referir que la acción o proceso que alguien realiza será sin ninguna retribución económica.



**AD-PROBATIONEM:** Expresión latina que se utiliza para referir que cierta formalidad es exigida por la ley para probar el acto jurídico que se pretende demostrar. (Art. 283 y s.s. del C.Civ.Com.).

**AD-SOLEMNITATEM:** Expresión latina que se utiliza para referir que cierta formalidad es exigida por la ley para la validez del acto jurídico que se pretende realizar. (art. 284 y s.s. del C. Civ. Com.).

**ALEGAR:** Es la exposición ordenada de los argumentos de hecho y derecho que pretende la parte y lo realiza ante una juez.

**ANALOGÍA:** Método por el cual al no existir una legislación específica para un caso previsto, se le aplica a su resolución la normativa existente que rige cuestiones semejantes a aquel.

**ANATOCISMO:** Acuerdo por el cual se establece la capitalización de intereses.

**APELAR:** Recurrir ante el juez superior del cual ha dictado sentencia para que modifique lo resuelto por el inferior.

**APERCIBIMIENTO:** Advertencia que hace la autoridad a alguien bajo su potestad para que realice o se abstenga de efectuar determinado acto.

**AUTENTICAR:** Dotar a alguna cosa de las formas, requisitos o solemnidades que le exige la ley para dotarla de las presunciones que le otorguen validez.

**AUTOS:** Forma de referir a las "actuaciones". También se indica con esta palabra a algunas resoluciones dentro de una proceso judicial.

**AUXILIARES DE JUSTICIA:** Persona que por la función que ocupa es llamada a colaborar con la administración de justicia.

## B

**BALANCE:** Saldos de inventario de un comerciante que demuestra el estado de sus negocios.

**BENEFICIO DE DIVISIÓN:** Para el supuesto de existir cofiadores, estos serán simplemente mancomunados con relación a la deuda, por lo que pagaran la parte que les corresponda a prorrata.

**BENEFICIO DE EXCUSIÓN:** Beneficio que tiene el fiador para que se reclame la deuda y se intente su cobro, justificando la insolvencia del deudor, antes de reclamar el pago por parte de aquel.

**BIENES MUEBLES:** Los que pueden transportarse de un lugar a otro. Contrario a Bienes Inmuebles.

**BUENA FE:** Modo sincero y leal de proceder en los negocios y contratos sin pretender engañar al otro. Forma de obrar de una persona que se cree en posesión o realiza sobre actos sobre alguna cosa, creyéndose con derecho a ello.

## C

**CADUCAR:** Efecto de perder su valor algún derecho, título o beneficio.

**CAPACIDAD:** Es la aptitud de gozar de un derecho o ejercerlo por sí mismo.

**CARTA DE PAGO:** Documento donde el acreedor reconoce haber recibido del deudor el cumplimiento de su obligación.

**CASO FORTUITO:** "Es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse"

**CAUCIÓN:** Se refiere a la seguridad que una persona otorga a otra sobre el cumplimiento de su obligación.

**CÉDULA:** Documento utilizado para notificar a las partes o peritos de una providencia, auto o sentencia de un juez o tribunal.

**CESIÓN:** Traspaso de bienes, derecho o acciones de una persona a otra.

**CITACIÓN:** Comunicación judicial por la cual se hace comparecer a una audiencia, acto o trámite a las partes, testigos o terceros.

**CLÁUSULA:** Es cada una de las disposiciones particulares de un documento.

**CLÁUSULA PENAL:** Es una disposición particular de un contrato por la cual se sujeta a una pena o multa en caso de incumplimiento total o simple retardo de una obligación.

**COMPETENCIA:** Es la aptitud de una autoridad pública para realizar actos jurídicos según la materia de que se trate.

**CONDENA:** Sentencia judicial por la cual una parte resulta obligada a satisfacer la pretensión de la otra según lo resuelto por el juzgador.

**CONDICIÓN:** Hecho futuro e incierto del que se hace depender la adquisición o resolución de algún derecho. (art. 343 y s.s. C.Civ. Com). Existen las condiciones resolutorias o suspensivas.

**CONDOMINIO:** Derecho real de propiedad que es compartido por varias personas y recae sobre partes indivisas de alguna cosa inmueble o mueble.

**CONDONACIÓN:** Renuncia o perdón que una persona hace de derechos que posee a favor de otro.

**CONFESIÓN:** Declaración de una parte donde reconoce hechos que le generan consecuencias jurídicas a su cargo.

**CONSENTIMIENTO:** Manifestación de una persona en el sentido de prestar conformidad con determinado acto que se celebrará.

**CONSIGNAR:** Depositar en forma judicial alguna cosa o su precio.

**CONTRA-DOCUMENTO:** Documento escrito en donde las partes hacen constar la verdadera naturaleza jurídica de un acto que celebraron en forma simulada.

**COSA JUZGADA:** Cuestión jurídica sobre la que ya ha recaído sentencia judicial válida y firme. Sobre ella ya no se admite nueva apelación o tratamiento judicial.

**COSTAS:** Gastos efectuados por las partes en un pleito.

**CURADOR:** persona encargada de cuidar los bienes y derechos de un incapaz.

## D

**DAÑO:** Todo menoscabo, disminución, pérdida o detrimento que sufre una persona en su físico, moral o patrimonio. Perjuicio patrimonial o moral que sufre una persona.

**DEMANDA:** Escrito con el cual se inicia un juicio o proceso judicial. En él se exponen, en general (ya que puede variar según el tipo de proceso), la individualización de las partes, exposición de los hechos antecedentes, la invocación del derecho, la prueba y la petición en concreto que se efectúa al Juez.

**DÍA:** Intervalo de tiempo que ocurre de media noche a media noche.

**DÍA HÁBIL:** Es el destinado al trabajo normal. Se opone al día feriado.

**E**

**EDICTO:** Aviso, citación o notificación que se efectúa, de una orden judicial, inserto en un elemento de publicidad oficial o privado (por ejemplo, en un diario de circulación masiva o en el Boletín Oficial).

**EMBARGO:** Es la retención de bienes del deudor o derechos crediticios dispuesta por un juez con el objeto de quitarlo de la libre disposición de aquel.

**ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA:** Es el traspaso de valores de un patrimonio a otro sin existir un antecedente que lo justifique, sea este legal o convencional.

**ESCRITURA:** Documento donde constan actos o contratos.

**ESTAR A DERECHO:** Comparecer por sí mismo o a través de representante en un juicio.

**EXHORTO:** Oficio que remite un juez a otro de idéntica categoría a los fines que mande dar cumplimiento a lo que se le solicita.

**F**

**FALSO TESTIMONIO:** Es un delito que comete un testigo, perito o intérprete que altera la verdad, la niega, la omite cuando debía saberla, en todo o en parte en su declaración, pericia o interpretación.

**FALLO:** Parte de la sentencia que dispone la resolución del conflicto.

**FECHA CIERTA:** Momento a partir del cual se tiene por cierto un documento.

**FRUTOS:** Utilidad que da alguna cosa o derecho en forma periódica sin alterar la sustancia del mismos. Si se alterare desapareciendo o disminuyendo se consideraría un "producto".

**G**

**GARANTÍA:** Es una seguridad que se ofrece sobre el cumplimiento de una obligación. El patrimonio es la garantía común de los acreedores; pero las obligaciones también se pueden garantizar por terceros u otros derechos de garantía (prenda, hipoteca, seguros, etc).

**GENERALES DE LA LEY:** Son las circunstancias relativas a las personas que se presentan en calidad de testigos con relación a su vinculación con las partes, profesión, capacidad y estado civil.

## H

**HONORARIOS:** Es aquello que se percibe como remuneración por el trabajo ejercido en las profesiones liberales.

## I

**INCIDENTES:** Son distintas controversias accesorias que se producen durante la sustanciación de un juicio.

**INSOLVENCIA:** Calidad de un deudor que se encuentra imposibilitado económicamente de afrontar sus deudas.

## J

**JURIS ET DE JURE:** Expresión latina que significa "de pleno y absoluto derecho". Esto se utiliza cuando un acto no admite prueba en contrario en un juicio.

**JURIS TANTUM:** Expresión latina que significa que se tendrá por cierta determinada situación hasta que se demuestre lo contrario.

## L

**LANZAMIENTO:** Acción de desalojar un inmueble por la fuerza pública.

**LEONINO:** Se trata de los contratos donde una parte tiene una mejoría sustancial sobre la otra. Por eso se indica como que se lleva la parte del león.

**LEX:** Ley.

**LITIGAR:** Disputar en un juicio sobre alguna cosa o derecho.

**LITIS EXPENSAS:** Gastos que se prevén llevará iniciar y continuar un juicio hasta su finalización.

## M

**MALA FE:** Es el conocimiento que una de la partes tenía o debió tener de su falta de razón o fundamento en sus pretensiones.

**MANDAMIENTO:** Oficio judicial por el cual se ordena la realización de algún acto.

**MATRIZ:** Escritura original conde consta la realización de determinado acto.

**MEJORAS NECESARIAS:** Son las que la cosa precisa para su mantenimiento mínimo.

**MEJORAS ÚTILES:** Son las que sin ser necesarias a la cosa, le aprovechan a cualquier poseedor de la misma.

**MEJORAS VOLUNTARIAS:** Son las de mero lujo de exclusiva utilidad para quien las realiza.

**MINUTA:** Resumen o borrador de lo que luego será un convenio o documento con las formalidades necesarias al acto que se prende.

**MULTA:** Pena que consiste en el pago de una suma de dinero.

## N

**NOTARIO:** Designación tradicional del escribano.

**NOTIFICACIÓN:** Acto por el cual se lleva a una persona al conocimiento de determinado acto jurídico efectuado o por efectuar.

## O

**OFICIAL DE JUSTICIA:** Auxiliar de la justicia que ejecuta las diligencias ordenadas por la justicia como ser notificaciones, embargos, lanzamientos, etc.

**O.I.T.:** Organización Internacional del Trabajo.

**P**

**PACTO:** Acuerdo entre dos o más personas en relación a determinado negocio jurídico.

**PACTO DE QUOTA LITIS.** Es mediante el cual una parte promete abonar al letrado que la patrocina o representa una parte de lo que resulte obtener del juicio o pleito.

**PENA:** Sanción jurídica por violar una norma.

**PERENCIÓN O CADUCIDAD DE INSTANCIA:** Modo anormal de finalizar el proceso por abandono o inacción de la parte que debía impulsarlo.

**PERITO:** Persona versada en alguna parte del conocimiento que es llamada a emitir un dictamen sobre algún punto a dilucidar.

**PLAZO:** Lapso de tiempo fijado para el cumplimiento de determinado hecho o acto jurídico.

**PLAZO CIERTO:** Aquel que está designado para ocurrir en determinado día, mes y año.

**PLAZO INCIERTO:** Aquel que se designa con relación a un hecho futuro que necesariamente ocurrirá; pero que se desconoce el momento.

**PLIEGO DE POSICIONES:** Documento que contiene preguntas que se realizarán a la contraparte en la audiencia de posiciones.

**PODER:** Facultad de ejercer actos en nombre de otro. Suele surgir de un mandato y por extensión se refiere a aquel documento de donde surge dicho contrato.

**PODER ESPECIAL:** El que se otorga únicamente para la realización de un negocio jurídico determinado.

**PODER GENERAL:** El que se otorga para realizar todos los negocios que se requiera dentro de determinados límites administrativos.

**PRESCRIPCIÓN:** Medio o forma de adquirir o perder derechos por el mero transcurso del tiempo.

**PRESUNCIÓN:** Es una forma de probar en juicio donde por indicios o por indicación de la ley el juez supone la existencia de un hecho o circunstancia determinada. Se utiliza en conjunción con las locuciones IURIS TANTUM y IURE ET DE IURE.

**PRIMA FACIE:** Locución Latina que significa "a primera vista".

**R**

**RECONDUCCIÓN:** Renovación de un contrato de locación.

**RECURSO:** Es un medio de impugnación de resoluciones o sentencias.

**RECUSACIÓN:** Acción o efecto de apartar a un juez o funcionario del entendimiento de una causa.

**RESOLVER:** Deshacer.

**RETROCESIÓN:** Cesión de un derecho a quien nos lo había cedido anteriormente.

**REVOCACIÓN:** Acción de anular una sentencia, orden, mandato o acto.

**S**

**SANA CRÍTICA:** Regla o método de apreciación de las prueba que debe realizar el juzgador.

**SECRETO PROFESIONAL:** Obligación impuesta a ciertas personas de no divulgar los hechos que ha tomado conocimiento en ejercicio de sus funciones.

**SENTENCIA:** Decisión judicial que pone fin al conflicto.

**T**

**TÁCITA RECONDUCCIÓN:** Es la renovación de una contrato de locación que ocurre cuando las partes siguen el contrato más allá del vencimiento. La legislación no la admite en los contratos de locación de inmuebles, entendiéndose que permanecen en dicha situación hasta que alguna de las partes resuelva en contrato.

**TEMERIDAD:** Es la sinrazón evidente de quien litiga.

**TERCEROS:** Son las personas ajenas a una relación jurídica.

**TÍTULO:** Causa por la que adquirimos o poseemos algún derecho o cosa.

**U**

**USUCAPIÓN:** Forma de adquirir el dominio por el paso del tiempo. (prescripción adquisitiva).



**USUFRUCTO:** Derecho real que permite usar y gozar de una cosa ajena.

**V**

**VICIO:** Causa por la cual un acto jurídico pierde su valor como tal.

**VICIOS OCULTOS:** Son los vicios que no están manifestados en la cosa y que al aparecer la tornar inútil para su finalidad.

**BIBLIOGRAFÍA**

- MANUEL O. COBAS y JORGE A. ZAGO. "Derecho Civil Parte General". Ed. Universidad.
- EDUARDO, A. ZANNONI- MARINA, MARIANI DE VIDAL, JORGE O.ZUNINO; FERNANDO E. SHINA Y GLORIA S. RAMOS. "Código Civil y Comercial. Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN"...- Ed. Astrea, Abril 2015.-
- ALBERTO J. BUERES (director). Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado. Edición de dos tomos de editorial Hammurabi SRL. José Luis Depalma Editor.-2015.
- ALTERINI, ATILIO ANIBAL. "Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales". Ed. AbeledoPerrot.
- DIRECTORES: GHERSI Y WEINGARTEN. "Código de Comercio y normas complementarias" Tomos I a V. Editorial Nova Tesis.
- DIRECTORES: GHERSI Y WEINGARTEN. "Código Civil y normas complementarias" Tomos I a IV. Editorial Nova Tesis
- BORDA, GUILLERMO. "Manual de Contratos". Editorial Perrot.
- JUAN M. FARINA. "Contratos Comerciales Modernos". Ed. Astrea. Segunda Edición actualizada 1999.
- ISAAC ALPERIN, "Curso de derecho comercial". Vol. 1. Editorial Depalma.1994.
- ANTONIO VAZQUEZ VIALARD. "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social". Tomo I y II. Editorial Astrea. Octava Edición Actualizada. 1999.
- ALTMARK, DANIEL RICARDO Y MOLINA QUIROGA, EDUARDO. "Tratado de Derecho Informático". Tomo II, Ed. La ley 2012.
- FERNANDEZ DELPECH, HORACIO; Internet: su problemática jurídica, Editorial Abeledo-Perrot, 2001.
- LUZ CLARA, BIBIANA BATRIZ; Manual de Derecho Informático, Editorial Jurídica Nova Tesis, 2001, Argentina.
- PALAZZI, PABLO A.; Delitos informáticos, Ediciones Ad-Hoc, 2000. Argentina.
- ALTMARK, DANIEL RICARDO. "Informática y derecho". Vol. 1. Ed. Depalma, 1987.
- Ponencia de LUZ CLARA, BIBIANA BEATRIZ. "Derecho de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios Informáticos". Puede consultarse online en [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx).
- RÍOFRIO MARTÍNEZ-VILLALBA. "La pretendida Autonomía del Derecho Informático". Publicado en la Revista ALFA-REDI del N°50 de Septiembre de 2002.-

- MOLINA QUIROGA, EDUARDO. "Prueba en la locación de servicios de obra. Honorarios profesionales y presunción de onerosidad.". Biblioteca digital de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. <http://www.aaba.org.ar/bi07002.htm>.
- STO. TOMAS DE AQUINO, "Suma Teológica". Ed. BAC. Tomo VI.

Sitios Web consultados:

- Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional. [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)
- [www.pki.gov.ar](http://www.pki.gov.ar)
- Network Information Center Argentina. [www.nic.ar](http://www.nic.ar)
- Asociación Argentina de Informática Jurídica. [www.aaij.com.ar](http://www.aaij.com.ar)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. <http://www.icann.org/>
- INPI Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. <http://www.inpi.gov.ar>
- Dirección Nacional de protección de Datos Personales. [www.jus.gov.ar/datos-personales.aspx](http://www.jus.gov.ar/datos-personales.aspx)
- World Intellectual Property Organization. <http://www.wipo.int/>
- United States Department of Justice - Computer Crime & Intellectual Property Section. <http://www.cybercrime.gov/>
- FBI - Computer Crime Squad. <http://www.fbi.gov/cyberinvest/cyberhome.htm>
- Diccionario de la Real Academia Española on line. [www.rae.es](http://www.rae.es)
- Administración Federal de Ingresos Públicos. [www.afip.gov.ar](http://www.afip.gov.ar)

